

CAPÍTULO 1 LAS PERSONAS

§ 159 bis. *Hombre y persona*. En el Derecho moderno, el vocablo central básico es el de *persona*, entendido como "sujeto de derecho", es decir, como el ente capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. Este concepto es para el Derecho actual uno de los centrales, puesto que todo gira jurídicamente en torno del "sujeto de derecho".

Este "sujeto de derechos" puede ser la *persona física*, esto es, el hombre, pero también determinados entes o corporaciones, a las cuales se les atribuye la capacidad jurídica, y son denominadas *personas jurídicas*. Respecto de ambas rige, en general, el doble principio de que: a) todo hombre es persona, es decir, "sujeto de derecho" por el hecho de ser hombre; y b) todas las personas son iguales, por lo menos ante la ley. Estas ideas simplificadoras es lo que permitirá hablar de una "teoría general de la persona".

En el Derecho Romano el panorama es distinto. En principio no existe una "teoría general de la persona". Se habla de los hombres, es decir, los entes biológicos que consisten en la unidad psicofísica humana. A veces en forma genérica, como p.ej. en el paso célebre del Digesto donde Hermogeniano dice que "todo el *ius* ha sido constituido por causa de los hombres" (D.1.5.2). Pero lo que interesa de los hombres es su situación jurídica (*status*), es decir, la posición o situación jurídica que ocupa en la sociedad, esto es, en la *civitas* y en la *familia*. Conforme a este *status*, el hombre podrá ser libre o esclavo; ciudadano romano, latino o extranjero; *sui iuris* o *alieni iuris*. El vocablo *persona* hace referencia jurídica al *homo* en relación con su *status*.

A su vez, el concepto de "persona jurídica" es prácticamente desconocido entre los clásicos y es solamente en el derecho posclásico y sobre todo con Justiniano que se podrán delinear ciertos esbozos que darán luego pie al desarrollo de esta personalidad por parte de los autores modernos.

1. La palabra "sujeto" (*subiectus*) sólo existe en Roma como participio pasado del verbo *subicio* (en infinitivo *subicere*), es decir, para designar que algo está colocado bajo o cerca de otro ente, como lo que

se pone bajo nuestros ojos (*subiectio sub oculis*), o cuando se queda sujeto a los enemigos (*subiectio hostium suorum*), o para referirse al tema a que se sujeta un pensamiento o una conversación (*subicio aliquid cogitatione sua*); este último permanecerá empleado en francés (*sujet*) o en inglés (*subject*), precisamente para referirse al tema que estamos tratando: *Quel est le sujet?*, o *What's the subject?* La utilización moderna parte de la filosofía cartesiana, que será desarrollada por Kant y por Hegel, y trasladada al lenguaje jurídico por Savigny y los demás juristas del siglo XIX.

El párrafo citado de Hermogeniano "todo el *ius* ha sido constituido por causa del hombre" (D.1.5.2), significa el carácter humano del *ius*, al cual son ajenos, por lo menos activamente, los animales (*simples res*). Pero de él no se puede deducir el concepto modernista de "sujeto del Derecho".

2. El primero de los principios asignados por el derecho moderno y actual, según el cual "hombre" = "persona" (como "sujeto de derecho"), no se da exactamente así en Roma. Por "hombre" (*homo*) se entiende de la unidad biológica psicofísica: una mente racional contenida en un cuerpo; y es vocablo comprensivo tanto del varón como de la mujer (Gayo, D.50.16.152). En cambio, "persona" hace referencia a la máscara de teatro (= *prosopon*; *prosopon*, entre los griegos), que solía usar el actor para significar el personaje que representaba, y para amplificar su voz. Esta máscara es usada en forma análoga para figurar el "rol atribuido a esa máscara, carácter, personaje", y también de "persona". Según ello, la "persona" es la consideración cualitativa de algo del "hombre". Esa *qualitas* desde la cual el *ius* considera al *homo* es su *status*. De ahí que podemos decir, con Heineccio, que "*persona est homo consideratus cum suo statu*" (La persona es el hombre considerado con su *status*). Así, el capítulo pertinente del Digesto lleva por título *De statu hominum* (Del *status* de los hombres).

3. Ciertamente es que en el derecho clásico todos los hombres son llamados personas. Así, Gayo (1.9) cuando habla de la división más amplia de las personas, nos dice que es ésta: todos los hombres o son libres o esclavos (= D.1.5.3; Inst. I.3 pr.), y nos habla de *persona servilis* (1.121) y de *persona servi* (2.187; 3.189). Pero si bien es una denominación que nominalmente nos hablaría de una sinonimia entre hombre y persona, lo cierto es que, en su funcionamiento

jurídico, el esclavo es meramente un *homo* (es la designación empleada en el lenguaje coloquial para el esclavo). Hay que tener en cuenta que mirado con ojos modernos, el esclavo no podría ser considerado "sujeto de derechos", lo cual si ocurriría con el resto de las personas, si bien, como hemos visto, este concepto no es romano. En otras palabras, el esclavo que es mero *homo* carece de *status*. Si hablamos de su capacidad jurídica propia, ella es nula: *Servile caput nullum ius habet* (Paulo, D. 4.5.3.1); Ulpiano (D. 50.17.209) lo compara con un muerto, puesto que "en lo que atañe al *ius civile* los esclavos son considerados como si no fueran nadie —*pro nullis habentur*—" (D. 50.17.32), si bien cabe aclarar que incapaces de derecho, tienen capacidad de obrar, lo que será importante cuando hagan actos en nombre de su *dominus*, e igualmente pueden poseer ciertos bienes (*peculios*), así como también se los tiene en cuenta respecto del *ius naturale* (Ulp., D. 50.17.32); y en las prácticas religiosas.

Ya en el derecho posclásico, la palabra persona se emplea preferentemente respecto de los libres. Los comentaristas, así Donello (1517-1591), profundizarán la diferencia: "el esclavo es *homo* según la naturaleza; en cambio, persona es un vocablo del *ius civile*".

4. En cuanto al segundo principio moderno (todos los hombres son iguales, por lo menos ante el Derecho), tampoco se aplica en Roma, puesto que cada persona, en lo relativo al Derecho público, y al Derecho privado (*ius civile*, *ius praetorium*), dependen del *status* que tengan. Sólo en lo que atañe al *ius naturale*, como hemos visto, "todos los hombres son iguales" (Ulp., *ibid.*).

Desde este punto de vista, el *status* más elevado es el del *paterfamilias* (que es libre, ciudadano romano y *sui iuris*). Los demás *status* son situaciones intermedias. El *status* es, pues, una *qualitas* que acompaña al hombre-persona, pero es como si esas cualidades van aumentando o disminuyendo, como la importancia de los papeles de las máscaras teatrales.

5. También se emplea la palabra *caput* (cabeza), pero *capax* no significa "capacidad" en el sentido moderno (la persona es capaz), sino en un tono más simple, o sea, la posibilidad concreta de entrar en determinadas relaciones jurídicas (así, *doli o culpa capax*; Ulp., D. 47.2.23; o *iniuriarum capax*; Ulp., D. 9.2.5.2); o la posibilidad de hacer testamento (Gayo, 1.25), o poder adquirir por testamento (Gayo, 1.25).

I. Comienzo y fin de la persona.

§ 160. Se suele afirmar que la persona comienza a partir de su nacimiento. Pero la noción estrictamente romana toma en consideración, para considerar el comienzo de la persona, al concebido (*qui in utero est*; más tarde llamado vulgarmente *nasciturus*), si bien para efecti-

vizar determinados derechos hay que esperar que nazca con vida.

Por eso, al hijo concebido se lo considera entre los herederos (Gayo, 1.147; 2.242; Sabino-Ulp., D.38.16.3.9) y se le concede la *bonorum possessio**, considerándolo entre los *sui heredes**, siempre que no hubiere sido desheredado (Ulp., D.37.9.1 pr. y 1; EP, § 147); igualmente, se lo protege con un *curator ventris* (Modest., D.26.5.20; EP, *id.*). Si la mujer abortara, por lo menos a partir de la *lex Cornelia de sicariis et veneficiis*, se lo considera un crimen, debiendo sufrir la pena de destierro (*exilium*); Ulp., D.48.8.8.

1. Encontramos textos del Digesto en los cuales se habla del *qui in utero est*, como estando en paridad de situación con el nacido, puesto que se lo comprende como siendo en la realidad (*in rerum natura esse*; así, Paulo, D.1.5.26; D.1.5.7: *in rebus humanis esse*; D.50.16.231; se lo tiene por sobreviviente: *pro superstitis esse*; Juliano, D.1.5.26; Celso, D.38.16.7; etc.

Esto se enuncia con la regla, enunciada como *nasciturus pro iam nato habetur* (al concebido se lo tiene por ya nacido); así, Gayo, 1.147. Esto no es una ficción, sino que expresa una realidad: que el *nasciturus* realmente existe y como tal goza de los beneficios que pueda recibir. Muy claramente lo dice Terencio Clemente (D.50.16.153): "Se ha de entender que existió al tiempo de la muerte el que fue dejado en el claustro materno".

2. Certos párrafos utilizan una expresión aparentemente contraria: *in rerum natura non est* (Gayo, 2.203; Pomp., D.30.24 pr.; etc.). Pero hay que comprenderlos como refiriéndose al hecho de que aún no han nacido efectivamente. Así, en estos dos pasajes citados se habla de que se puede dejar por legado al "hijo concebido por una esclava", cuya efectividad final está supeditada al nacimiento real. Pero ya, desde el momento que puede ser capaz de recibir un legado; se está reconociendo su existencia.

3. En cuanto a la expresión de que el concebido es meramente "parte de la mujer o de sus vísceras" (*mulieris portio est vel viscerum*; Ulp., D.25.4.1), hay que entenderla no como una regla genérica, sino que la expresión se explica en el caso muy particular allí planteado. Se trataba del derecho de inspección del vientre de una madre divorciada pedido por su anterior marido. Se llega a la conclusión de que los *ss.cc.* sobre reconocimiento de hijos no resultaban aplicables "si la mujer disimulase que estaba embarazada, o aun si lo negase", dando como razón el derecho de la madre sobre su vientre. Como se ve, se trata de un problema jurídico atinente a la madre, pero de acá no se puede deducir una regla sobre la condición jurídica del concebido.

Al contrario, en el caso presentado por Scévola (D.38.9.10) se habla de si la madre embarazada que ha repudiado la herencia puede pedir la *bonorum possessio* por el hijo concebido, optando el jurista

que corresponde. Esto resultaría contradictorio con el principio de que el *nasciturus* es "parte del vientre de la madre", puesto que si ella repudió la herencia, sus vísceras no podrían pedir la posesión hereditaria.

Igualmente, la madre embarazada no podía ser sometida a tormento, y si fuera condenada a muerte, la ejecución se difería hasta el parto (Ulp., D.48.9.19.3).

4. Un problema lateral está planteado por la regla clásica según la cual el *status* del hijo habido en *iustae nuptiae** está determinado por el momento de la concepción, mientras que el hijo habido de otras uniones ilegítimas (caso del hijo de la esclava) se determina a partir del nacimiento (Gayo, 1.89-92; Ulp., 5.10). Pero esta regla no se refiere a la existencia del *nasciturus*, sino al diferente *status* (ya sea el *libertatis*, el *civilitatis* o el *familiae*) que podían tener. Esto se explica porque la paternidad cierta es presumida siempre al *pater* que hubo al hijo en *iustae nuptiae*; en las demás uniones se atiende siempre a la madre que *semper certa est*, por el nacimiento.

Lo mismo ocurre a propósito del nacimiento de los póstumos. A los póstumos del *pater* (*postumi sui*) se los puede instituir herederos o hacerles legados o fideicomisos, mientras que a los *postumi alieni* (es decir, los que nazcan de un extraño), no se los puede instituir herederos (Gayo, 2.242), ni dejarles legados (Gayo, 2.240-1), ni fideicomisos (Gayo, 2.287). Ello se debe a que son consideradas *incertae personae*. Pero esto no afecta a la existencia de los concebidos, sino a su capacidad hereditaria.

5. Estos aspectos de diferente tratamiento para *qui in utero sunt*, serán luego modificados en la época posclásica. Se fue aceptando el criterio del *commodum*, es decir, de aceptar la existencia para las situaciones jurídicas que favorezcan al concebido (Paulo, 2.24.1-3; D.1.5.7).

Así, respecto del *status libertatis* se sigue el criterio de que no importa si la madre fuera esclava en el momento de la concepción o del nacimiento, sino que bastaba que hubiera sido libre en cualquier momento intermedio durante el embarazo (Marciano, D.1.5.5.2-3; Paulo, 2.24.1-3; Inst., 1.5.4). Lo mismo se permite a todos los póstumos, sin hacer diferencias, ser herederos, recibir legados o fideicomisos (Inst., 2.20.26-27). Tampoco quedan dudas acerca de que se pueda, en su nombre, pedir la *bonorum possessio* o un *curator ventris* (Ulp., D.37.9.1 ss.). Justiniano termina decidiendo que para establecer el *status* hay que atender al momento del parto, "exceptuándose solamente los casos en que la conveniencia (el *commodum*) de la condición de los hijos requiere que se atienda preferentemente a la concepción (C.5.27.4; año 530).

II. Requisitos para considerar nacida la persona.

§ 161. A los efectos de considerar nacida una persona era ante todo necesario:

a) la separación del claustro materno, es decir, el parto (Pap., D.35.2.9.1). Pero

b) podía suceder que se tuviera alguna duda acerca de si el niño (o niña) nació efectivamente con vida o, al contrario, nació muerto.

El caso tenía interés jurídico, puesto que si se hubiese preterido al *suus* concebido y éste nacía sin vida, ello no rompía el testamento; en cambio, este efecto se producía si nacía con vida. En general el nacimiento con vida puede alterar el orden sucesorio.

Los proculeyanos seguían el criterio tradicionalista de que se tenía que haber escuchado la voz, es decir, el clásico lloro del recién nacido; en cambio, los sabinianos, más amplios, admitían cualquier signo vital. Justiniano terminará esta discusión inclinándose por esta última posición (C.6.29.3; año 530).

c) Un requisito que resulta elemental es que el nacido tenga figura humana, es decir, que la mujer no haya procreado un monstruo o un prodigio de la naturaleza, pues ello no podría ser considerado hijo suyo (Paulo, 4.9.3 = D.1.5.14, C.6.29.3, *in fine*).

III. Extinción de la persona.

§ 162. Ocurre con la muerte, la cual es un hecho que debe ser probado por parte de aquel que pretenda gozar de alguna situación jurídica (p.ej., ser heredero) del fallecido.

1. Se podía plantear un problema cuando varias personas morían en un mismo accidente (p.ej., en un naufragio, un incendio, una batalla, etc.). A este caso se lo suele denominar como el de los "conmorientes". Tenía importancia para decidir los efectos hereditarios que se pudieran haber producido.

En la época clásica se seguía el criterio de que si no se probaba que uno de los conmorientes hubiera muerto primero, no se consideraba que el uno sobreviviera al otro, es decir, que todos murieron en forma coetánea (Marciano, D.34.5.18(19) pr.).

Justiniano establecerá una presunción de premoriencia para el caso de que en un mismo hecho hubieran muerto el padre y el hijo. Si el hijo era púber, se entiende que sobrevivió al padre, si no se pudiera probar lo contrario, y si existiera testamento y en él el hijo hubiera sido instituido heredero, la herencia pasará a los herederos de dicho hijo. Pero si se trataba de un hijo impúber que pereció con su padre, se presume que primero murió el hijo y luego el padre, salvo prueba en contrario (Trifonino, D.34.5.9.4 itp.). Lo mismo se aplica en caso de conmorencia de madre e hijo (Javoleno, D.34.5.22 itp.; Gayo, D.12.23 itp.; Papin., D.23.4.26 pr., itp.). Esta presunción se basa en el criterio abstracto de la mayor o menor resistencia física.

Además, si en un fideicomiso, existe la condición de prelación de un hijo del fideicomisario, se presume que ha muerto, antes del padre conmoriente (D.36.1.18(17).7), para salvar la donación, se presume muerto al cónyuge donante (D.34.5.8(9)), y si las donaciones fueron recíprocas, se presume que nadie ha sobrevivido al otro (D.39.6.26).

2. En cuanto al "ausente" de quien no se tienen noticias, ignorándose dónde está, los magistrados y los jueces apreciaban la situación.

Pero, en general, no hay ningún procedimiento de "declaración de presunción de fallecimiento". Serán los juristas medievales los que establecerán que luego de haber vivido 100 años el ausente, se lo considera muerto; luego se redujo el plazo a 70 años, apoyándose en el v. 10 del salmo 89, que habla de dicha edad como la normal de un hombre: "Los días de nuestra edad son 70 años".

IV. Status y capitis deminutio.

§ 163. La *capitis deminutio* es un cambio (*permutatio*) del *status* que tiene alguien (Gayo, 1.163; D.4.5.1). Puede ser de tres modos: "máxima" (cuando se pierde al mismo tiempo la ciudadanía y la libertad; Gayo, 1.160); "media" (cuando se pierde la ciudadanía conservando la libertad; Gayo, 1.161) y "mínima" (cuando conservando la libertad y la ciudadanía, se modifica su situación en la familia; Gayo, 1.162; Paulo, D.4.5.11).

1. La expresión comenzó a ser usada hacia fines de la República, posiblemente empleada por Quinto Mucio Escévola. El sentido originario estaba referido no al individuo, sino al grupo. Así, si un ciudadano pierde la ciudadanía, se decía que se producía una *capitis deminutio* (disminución de cabeza) por cuanto el grupo, esto es, el *populus*, experimenta la pérdida de uno de sus miembros. Así, p.ej., por sufrir la pena de la *interdictio aquae et ignis* —forma de destierro— o por haber emigrado a una colonia, etc. Igualmente, cuando un *pater* da a su *filius* en adopción, la familia sufre también la pérdida de uno de sus miembros.

2. Pero el término se aplicó también respecto de la propia persona implicada y gradualmente fue teniendo el sentido de empeoramiento del *status* de la persona considerada en sí. Ello resulta cierto en el caso de la *c.d. maxima* y *media*, pero no ocurre lo mismo con la *c.d. minima*. Así, en el caso de un *filius* que está en una familia y es adoptado por otro *pater*, su situación cambia, pero no sufre ningún deterioro (era *alieni iuris* y continúa siendo tal una vez adoptado). Acá hay, simplemente, un cambio (*permutatio*). Menos aún para el caso de que el *pater* emancipe a uno de sus *filiifamilias*. El hijo emancipado no sufre ningún empeoramiento jurídico; al contrario, era *alie-*

ni iuris y se transforma en *sui iuris* (hay más bien un mejoramiento de su *status*); por ello resulta paradójico que se diga de él que ha sufrido una *capitis deminutio*. Esto tiene sentido si recordamos el significado originario: se trata de una *capitis deminutio*, puesto que la familia *capite deminuta* est.

Sobre la base de esta división de la *capitis deminutio*, se ha construido una clasificación de los *status*; respecto de la cual hay que señalar que no es romana, y que es la contrafigura de la tricotomía de la *c.d.* De este modo, se habla de *status libertatis* cuando se configura a los hombres según la "libertad"; de *status civitatis* cuando se los considera conforme a su ubicación respecto de la *civitas*; y de *status familiae* cuando se los analiza en su posición dentro de la familia.

1. El texto básico que da motivo a esta tripartición de los *status* es el de Paulo (D.4.5.11). Habla acá de la *c.d.* diciendo que son tres (las cosas) que tenemos: la libertad, la *civitas* y la familia. De allí se continúa el razonamiento poniendo en positivo los bienes señalados.

2. El inconveniente principal es que se considera a los hombres como individualidades, desdibujándose la función "organicista" de los grupos de los cuales forman parte: la *civitas* y la familia. Además, respecto a la libertad, nótese que en Gayo (1.160) va unida a la *civitas* (la *c.d.* es máxima cuando se pierde al mismo tiempo la ciudadanía y la libertad), ésta se conforma como una unidad por lo menos para el ciudadano romano (*libertas civitasque* = la libertad y la ciudadanía). Así, Cicerón (*pro Caec.*, 33.96): "¿quien puede ser libre conforme al *ius Quiritium*, si no está en el número de los Quirites?".

Previendo sobre estos riesgos, para no producir un mayor desconcierto en el estudio, adoptaremos esta manera de explicación, no romana, de los tres *status*.

STATUS LIBERTATIS

§ 164. La máxima distinción de los hombres es la que nos dice que unos son "libres" y otros "esclavos". A su vez, los libres son "ingenuos" o son "libertos" (Gayo, 1.9; Inst., 1.3 pr.).

1. Lo que se considera aquí es el bien de la libertad. Algunos la tienen desde su nacimiento. Estos son los "ingenuos" (Gayo, 1.11 = D.1.5.6; Inst., 1.4 pr.); el nombre viene de *gigno* = engendrar, puesto que en ellos la libertad se considera engendrada desde el nacimiento. Otros no la tienen y son los "esclavos", pero si alcanzan la libertad, al ser manumitidos, se convierten en "libertos".

2. La libertad es considerada como una cosa inestimable (Paulo, D.50.17.106: *Libertas inaeestimabilis*

res est). En la época de Justiniano se subraya al aspecto público de la libertad: *non privata sed publica est* (Marciano, D.40.5.53 pr.).

§ 165. Los esclavos. El esclavo (*servus*, o simplemente *homo*) es aquel hombre que por una justa causa (*iusta causa servitutis*) no tiene libertad y pertenece a otro a quien sirve (Gayo, 1.11 = D.1.5.6; Inst., 1.4 pr.).

1. Florentino (D.1.5.4 pr.) define la libertad al gusto helenístico como "la facultad natural (*naturalis facultas*) que tiene cada uno de hacer lo que le plazca, a no ser que la fuerza o la ley se lo prohíban". Y a la esclavitud (D.1.5.4.1) como "una institución del *ius gentium*, por la cual uno se encuentra sujeto contra la naturaleza, al dominio de otro". En las expresiones *naturalis* y *contra naturam* se puede ver la neta influencia estoica, luego afirmada por el Cristianismo.

2. Para ser esclavo es necesario que medie una *iusta causa servitutis*; de lo contrario el hombre continúa siendo libre.

Interesante es el caso de quien, de buena fe, siendo libre se cree esclavo de otro; o también, siendo esclavo de A se cree esclavo de B (*homo bona fide serviens*). Mientras dure el error, su situación se rige por las reglas de la esclavitud. Cuando advierte el error y recobra la libertad, o sea reclamado por el verdadero dueño, se plantea el problema acerca de a quién corresponden los bienes obtenidos. Así, lo logrado por su trabajo o mediante el empleo del supuesto *dominus*, le pertenece a éste y le deberán ser devueltos. En cambio, si es algo logrado a otro título (p.ej., una herencia o un legado) le queda al *homo liber bona fide serviens*, si es "libre"; y si es esclavo de otro, a su verdadero *dominus* (Gayo, 2.92; 3.164; Inst., 2.9.4). Gayo explica que es la misma solución que se da para el esclavo que se tiene en usufructo (2.91).

I. Condición jurídica del esclavo.

§ 166. El esclavo es al mismo tiempo un *homo* y una *res mancipi*, por cuanto pertenece a su dueño (*dominus*), quien tiene sobre él una potestad absoluta (*potestas vitae necisque* = potestad de vida y muerte; Gayo, 1.52 = D.1.6.1 pr.; Inst., 1.8.1).

Como *homo* tendrá, pese a su incapacidad, cierta actuación en la vida negocial para obrar actos por cuenta de su dueño, y si pertenecen al *populus* o a una *civitas* podrán desarrollar cierta actividad como agentes públicos (*servi publici*). Esto no se contraponen con que son considerados *res*. Por ello es que pueden ser vendidos y comprados, y puedan ser causa de reivindicación. Pero los juristas romanos nunca lo consi-

deran igual que a un animal, que es un simple ente inanimado.

1. La esclavitud es una institución del *ius gentium*, es decir, que era aplicada por todos los pueblos. Incluso, es elocuente la epístola de San Pablo a Filemón, para apreciar que el Cristianismo, no obstante sus ideas igualitarias de los hombres frente a Dios, no se siente llamado a provocar un cambio social que significara la abolición de esta institución. Se trata en ella del consejo que el Apóstol da a Filemón, a quien regresa su esclavo fugitivo, no para que lo libere, sino para que lo trate "como un hermano amado".

2. La situación social de los esclavos fue muy variable en Roma. En la época primera, éstos colaboraban en la explotación agrícola y trabajos domésticos. El trato era muy bueno, se sentaban en la misma mesa y compartían las comidas, como también participaban del culto familiar (*sacra privata*).

Con el éxito de las grandes guerras, el número de esclavos aumentó; no hay que olvidar que el ser prisionero bélico era la principal causa de esclavitud. Las formas económicas variaron y los nuevos romanos no se dedicaban a la agricultura como forma de trabajo personal. Aparecen los grandes latifundios, en los cuales se pone a trabajar a los esclavos adquiridos, así como en otras empresas artesanales e industriales, etc. El dueño se desprecupaba de ellos, entregándolos a un mayordomo (*villicus*) que, constreñido por la eficacia de los resultados, los trataba de manera muy inhumana. Fue quizá la peor época de la esclavitud.

Sin embargo, había esclavos que eran especialmente considerados; así los griegos, que solían servir en la enseñanza de los hijos, y que por sus dotes intelectuales escalaban posiciones. Además, para comprender la complejidad de la esclavitud, tal como lo veremos, los esclavos podían servir como operadores económicos de su *dominus*. Para los que estaban en la propia casa del amo, el trato dispensado continuaba siendo en general bueno. Así lo demuestran las comedias de Plauto y de Terencio. Eran el personal doméstico, que muchas veces se aprovechaban de las situaciones en su beneficio personal, pese a lo vigoroso que podía lucir el *ius vitae necisque*.

3. Frente a los abusos, existieron leyes humanitarias que morigeraron la situación de los esclavos, sobre todo en los dos primeros siglos d.C. A comienzos del Imperio, una *lex Petronia* —completada bajo Adriano por un s.c.— prohibió a los *domini* destinar los esclavos a combatir con las bestias del Circo, a menos que fuera a título de pena y con autorización del magistrado (Modestino, D.48.8.11.2). También un edicto de Claudio ordena la libertad del esclavo enfermo abandonado por su dueño (Modest., D.40.8.2; C.7.6.3). Quien mataba injustamente a un esclavo caía bajo la *lex Cornelia de sicariis* (de la época de Silya; Marciano, D.48.8.1.2) con la pena de deporta-

ción, y más tarde, hasta la de muerte (Marciano, D.1.3.5). Según una constitución de Antonino Pio, tratar a su esclavo es lo mismo que hacerlo con uno ajeno; además, un trato abusivo ocasionaba la venta forzada de sus esclavos (Gayo, 1.53; Inst., 1.8.2; Ulp., D.1.6.2). Un s.c. del año 83 d.C. castigó con la multa de la mitad de los bienes a quien castrara a un esclavo (Venuleyo Saturnino, D.48.8.6).

§ 167. *Capacidad jurídica*: a) Si bien el esclavo carece de capacidad jurídica propia, sin embargo puede actuar como instrumento de adquisición de su *dominus*. Así, podía realizar todos los actos que procuraran bienes a su *dominus*: p.ej., adquirir por ocupación, por tradición o recibir un bien por la *mancipatio**; igualmente, celebrar una *stipulatio**, por la cual alguien queda deudor del *dominus*; o con autorización de éste, aceptar una herencia o adquirir un legado. En todos estos casos, si bien los actos son realizados por el esclavo, el que se convierte en propietario o acreedor es el *dominus* (Gayo, 2.87; Inst., 2.9.3). Solamente no pueden celebrar una *in iure cessio**, ya que se trata de una *legis actio**, en la que se reclama algo como propio (Gayo, 2.91).

b) En cambio, el esclavo no se puede obligar por negocio jurídico para sí, por el *ius civile*; más tarde, a partir de Juliano, se entenderá que la obligación contraída por el esclavo es una "obligación natural" (Ulp., D.47.7.14).

Sin embargo, en la época clásica, el *dominus* podrá servirse del esclavo como un operador comercial, de tal modo que respondía por las obligaciones contraídas por éste. Así, se lo autorizaba directamente a celebrar determinados negocios, o más aún asumiendo la responsabilidad por los negocios contraídos por el esclavo puesto al frente de una nave (*magister navis*), o de una tienda (*institor*). En estos casos el pretor concedía a los terceros acreedores acciones especiales (*adiecticiae qualitatis**) contra el *dominus*.

1. Estas posibilidades nos permiten visualizar cierta interdependencia operacional de los esclavos, si bien con el conocimiento y la responsabilidad del *dominus*. En germen, está acá la idea de una empresa, establecida a partir del dueño, pero ejecutada por esclavos (también podía ser por los *filifamiliae*). Así, el caso del esclavo puesto en Arles, al frente de un comercio de aceite, y realizando también negocios bancarios, del cual nos habla Ulpiano (D.14.3.13 pr.).

c) Igualmente se le podía constituir al esclavo un peculio, es decir, ciertos bienes entregados por el *dominus*, quien le dejaba la administración y el goce de las rentas producidas, aun cuando conservaba la propiedad (Ulp., D.15.1.5.4).

1. Si bien se describe al peculio como de monto reducido (Ulp., D.15.3.3), hay ejemplos de esclavos que lo habían administrado en forma tan beneficiosa, que se compraron su libertad (Séneca, Ep.80.4; Plinio, H.N. 7.39; Petronio, 57). Incluso, dentro de su peculio el esclavo podía tener esclavos que recibían el nombre de *servi vicarii*.

2. El *dominus* era el propietario del peculio, pero como lo explica Tubero (Ulp., D.15.1.5.4), no figuraba en la contabilidad del *dominus*, sino que estaba separado de ella. Esto le daba cierta libertad al esclavo, de tal modo que el *dominus* sólo se lo retiraba en casos de mala gestión o de falta grave.

El pretor, al conceder a los acreedores del esclavo la *actio de peculio* (*et de in rem verso*)*, ha interpretado que el esclavo podía obligarse con terceros; éstos, por medio de dicha acción, podían responsabilizar al *dominus* hasta la concurrencia del monto del peculio (o de lo enriquecido sin causa por el *dominus*).

d) Si el esclavo cometía un delito, el *dominus* responde con la *actio noxalis**. En este caso, el dueño puede optar entre pagar la pena, como si él mismo hubiera cometido el delito, o entregar el esclavo a quien había sufrido el delito (*noxae deditio*; Gayo, 4. 75 ss.).

e) Desde el punto de vista procesal, los esclavos no podían ni por sí, ni como representantes (*cognitor*, *procurator*), actuar en juicio. Sin embargo, en el derecho posclásico se admiten algunas pocas excepciones en el procedimiento de la *cognitio*.

1. Las cuestiones jurídicas que podían afectar a los esclavos eran las siguientes:

(1) que se discutiera la propiedad de un esclavo por parte de alguien que se dice el dueño respecto de otro que lo está poseyendo (*rei vindicatio*);

(2) que se discutiera si un hombre es libre o es esclavo; lo que conllevaba un procedimiento de libertad (*liberalis causa*). Aquí, como el esclavo no podía actuar, debía hacerlo en favor suyo un hombre libre que afirmase su libertad (*adsertor libertatis*). Por tanto, si el actor decía que el hombre era libre, el juicio era una *vindicatio in libertatem* (EP, § 178) y si en cambio el actor decía que era esclavo, ocurría una *vindicatio in servitutem* (EP, § 179).

2. En el derecho posclásico se permitía actuar directamente al esclavo en contados casos. Hermogeniano (D.5.1.53) menciona: cuando se habría hecho desaparecer el testamento en el cual se le habría manumitido; cuando se discutía la libertad dejada por fideicomiso; cuando reclamaba por haberse comprado la libertad y no haberse respetado el trato; para acusar al *dominus* por encarecimiento de los viveres públicos; etc.

f) Al esclavo se le reconoce capacidad en el *ius naturale*. La unión entre esclavos era cono-

cida como *contubernium*; y a diferencia de las *iustae nuptiae**, era un simple hecho no reconocido. El hijo nacido de una esclava (*partus ancillae*) pertenece al *dominus* de la madre. A su vez, se respetan los vínculos de sangre (*servilis cognatio*); a los efectos de los impedimentos y la sucesión intestada del libertio.

1. Atendiendo a la *servilis cognatio*, se prohibió en ciertos casos separar las familias de los esclavos (C.Th., 2.25.1) y se consideró inapto separar los hijos de los padres (Nov.Valentiniano, 31.2; año 451).

g) En el orden religioso, al esclavo se lo hace participe en el culto público y en los *sacra privata*. Tiene capacidad para jurar (Ulp., D.12.2.23; Venuleyo, D.40.12.44 pr.); su sepulcro es *res religiosa* (Ulp., D.11.7.2 pr.), mereciendo las honras fúnebres (Ulp., D.19.1.13.22; Paulo, 21.10).

II. Causas de esclavitud.

§ 168. *Por nacimiento*. Los esclavos nacen o se hacen. Nacen esclavos los hijos de una madre esclava. No importa que el padre sea libre o esclavo, pues fuera del matrimonio legítimo (*iustae nuptiae*), único supuesto en el cual se presume que el *pater* es *certus*, la regla es que el hijo sigue la condición de la madre (regla: *mater semper certa est*). Como los esclavos no pueden celebrar *iustae nuptiae*, se explica la solución dada (Inst., 1.4 pr.).

1. ¿Cuándo se toma en cuenta la situación de la madre? Podía suceder que ésta fuera libre en el momento de la concepción y esclava en el momento del parto, o viceversa. Los romanos tuvieron sus dudas, pero luego, por aplicación del principio del *favor libertatis*, se entendió que en ambas situaciones el hijo nacía libre, lo mismo que si la madre hubiera sido libre en algún momento del embarazo (Paulo, 2.24.1-3; Marciano, D.1.5.5.3, Inst., 1.4 pr.).

2. Gayo (1.85) nos habla de una ley (desconocida) según la cual si alguno se uniese con una esclava creyéndola libre, los varones nacidos serían libres, no así las mujeres. Pero Vespasiano, considerando "inelegante" la solución, determinó que en todos los casos, sean varones o mujeres, eran esclavos del *dominus* de la madre esclava.

§ 169. *Causa de esclavitud del "ius gentium"*. Se hacen esclavos por el *ius gentium* quienes caen en cautividad en una guerra formalmente declarada (*iustum bellum*); Inst., 1.3.4.

1. La declaración de guerra a un pueblo enemigo (*hostes*), importaba, aparte de la decisión política, la

realización de un rito en el cual intervenía el *pater patratus* (jefe del colegio de los *fetiales*). El efecto de la esclavitud podía ocurrir lo mismo tratándose de pueblos con los cuales Roma no tenía ni amistad ni pactos, y sucediera una guerra (Pomp., D.49.15.5.2). En cambio, no caían en esclavitud los prisioneros en una guerra civil (Ulp., D.49.15.21.1), ni tampoco los cautivos por los piratas o los ladrones (Paulo, D.49.15.19.2).

2. En principio, los cautivos extranjeros pasan a ser "esclavos del *populus*", al cual puede utilizarlos para trabajos públicos; o también subastarlos a los particulares en venta pública (*sub hasta; emptio sub corona*). Raramente eran cedidos a los jefes y a los soldados.

§ 170. *Postliminium (ius postliminii)*. Siendo una causa del *ius gentium*, la esclavitud por ser prisionero de guerra era recíproca respecto de todas las naciones. Por ello podía ocurrir que un ciudadano romano cayera prisionero del enemigo. Mientras esté en tal situación de dependencia será esclavo de quien lo tenga. Pero si llegara a escapar o regresar de su cautiverio, alcanzando suelo romano, gozaba del *ius postliminii* o *postliminium* (*post* = después de; *limites* = límites). Se consideraba que recobraba toda su situación jurídica, fingiendo que no cayó en esclavitud. Así, seguía siendo ingenuo (no libertio), *paterfamilias*, propietario, etc. (Tryfonio, D.49.15.12.6).

1. Pero esta ficción se operaba sólo para los supuestos "de derecho", no para las situaciones "de hecho", como, p.ej., la posesión*, que se consideraba interrumpida durante la ausencia (Tryfonio, D.49.15.12.2), y también el matrimonio, que por ser una *res facti*, exige la continuidad de la convivencia. Debido a ello, por la cautividad de uno de los cónyuges cesan las *iustae nuptiae*, aunque la mujer las quiera mantener y viva en la casa marital (Tryf., D.49.15.12.4). Al regresar y reanudar la convivencia, se considera un matrimonio nuevo y no continuación del anterior (Pomponio, D.49.15.14.1).

2. En el derecho clásico, la regla es que el matrimonio del cautivo cesaba, sin estar protegido por el *postliminium* (Ulp., D. 49.15.14.1). En el derecho posclásico, si luego de cuatro años de espera no se tenían noticias ciertas del cautivo, la mujer podía volver a casarse (Constant., C.5.17.7 pr.). El plazo se extendía a 5 años en caso de incertidumbre sobre el cautivo. Así lo determinó Justiniano (Juliano, D.24.2.6 itp.; Nov.22.7, año 536). Si durante ese lapso la mujer faltaba al deber de fidelidad era considerada adúltera (Ulp., D.48.5.14.7 itp.). También, después de la muerte declarada del cautivo, había que esperar un año para que la mujer contrajera nuevas nupcias (Nov 117.11).

§ 171. *Fictio legis Corneliae*. Si el romano moría cautivo del enemigo, lo hace en esclavitud, extinguiéndose sus derechos desde el momento en que fue apresado. El testamento hecho antes era inválido, puesto que la capacidad de hacer testamento (*testamenti factio activa*) debía estar presente tanto en el momento de hacerlo, como en el de la muerte. Para beneficiar al ciudadano que había peleado por la patria, una *lex Cornelia* (alrededor del 80 a.C., de la época de Sula) fingía que en este caso la muerte había ocurrido en el mismo momento en que es tomado prisionero, es decir, siendo libre (Paulo, 3.4.8; D.35.2.18 pr.; Juliano, D.28.1.12). De este modo, mediante esta *fictio legis Corneliae*, el testamento resultaba válido aunque realmente muriera siendo prisionero del enemigo.

§ 172. *Causas de esclavitud del "ius civile"*. La causa principalísima de esclavitud es la del cautiverio por causa de guerra. Pero también por el *ius civile* si se cometen determinadas acciones que son castigadas con la esclavitud. Estos casos, que son raros y limitados, son los siguientes:

a) En el derecho antiguo se volvía esclavo quien no se había anotado en el censo (*incensus*); el desertor y, además, el que sufría la *manus iniectio*, podía ser vendido como esclavo llevándolo al otro lado del río Tiber (*trans Tiberim*).

b) En el derecho clásico caían en esclavitud los condenados a ciertas penas graves (*servi poenae*). Así, los estigmatizados con la marca de hierro, los sometidos a tormentos y encontrados culpables, los entregados para combatir en el Circo (Gayo, 1.13); o a trabajar en las minas (Ulp., D.48.19.3.4.12; Gayo, D.28.1.8.4).

1. Constantino suprimió la condena a combatir con las fieras (C.11.43.1) y Justiniano decidió que la condena a las minas no arrastraba la esclavitud (Nov.22.8).

c) Según un s.c. Claudiano (año 54 d.C.) se castigó con la esclavitud a la mujer libre que mantenía relaciones sexuales con el esclavo de otro, pese a una triple advertencia del *dominus* de éste, pasando a ser esclava de dicho *dominus* (Paulo, 2.21 a.1 y 17).

1. Según Gayo (1.84), el s.c. Claudiano permitía un pacto entre el *dominus* y la mujer para que ésta permaneciera libre, pero el hijo habido era esclavo. Hadriano estableció que, mediando el pacto, no sólo la mujer sino también el hijo eran libres. Justiniano abrogó los efectos de esclavitud de este s.c. (Inst., 3.12.1).

2. Esta dura disposición estuvo vigente hasta que

fue derogada por Justiniano (C.7.24.1 pr.), pero para evitar que proliferaran estas uniones, por las cuales un esclavo podía imaginarse haber contraído matrimonio con una mujer libre, se le concede al *dominus* potestad sancionatoria para corregir con el castigo convenientes tales actos (C.7.24.1.1).

d) Podía ocurrir que un hombre libre se hiciera vender como esclavo por un cómplice suyo; con él compartía luego el precio y luego reclamaba su libertad, puesto que no era esclavo. Ya desde Q.M.Scévola (Paulo, D.40.12.23 pr.), el pretor, luego confirmado por ss.cc. (Pomponio, D.40.13.3), determinó que le sería negada la libertad y quedaría como esclavo, siempre y cuando, sea hombre o mujer, tuviera 20 años, hubiera actuado con dolo y participado del precio y el comprador fuera de buena fe (Ulp., D.40.12.7.1.3; Paulo, D.id. 23 pr.).

1. En el caso de que, aun con dolo, el hombre o la mujer que se vendieron logran obtener la libertad por reclamo judicial (p.ej., si no participaron del precio; Ulp., D.40.12.13.1 pr.), el pretor le concede al comprador de buena fe una *actio in factum*, de carácter penal (Ulp., 40.12.14 pr.; D.id.22 pr. y 6) por el *duplum* del precio contra el vendedor y el vendido (Ulp., D.id.18; 20.2; EP, §182).

e) Por una constitución del emperador Cómodo, y probablemente antes, si un libertus se había mostrado ingrato con su patrono (injurándolo, golpeándolo o abandonándolo, etc.), se producía una revocación de la manumisión (*revocatio ad servitutem*), volviendo a ser esclavo (Constantino, C.6.7.2 pr.; Modestino, D.25.3.6.1).

Para la época de Justiniano, aparte del nacimiento y de la cautividad por guerra, sólo quedaron vigentes las dos últimas causales expuestas (Inst., 1.3.4).

III. Fin de la esclavitud.

§ 173. Excepcionalmente la esclavitud puede terminar por concesión especial de los emperadores, pero la forma normal por la cual se libera al esclavo es la manumisión.

1. Así, entre los esclavos que dejan de ser tales sin manumisión (D.40.8), podemos citar los siguientes casos:

a) Por un s.c. *Silanianum* (de Augusto, año 10 d.C.) se otorga la libertad al esclavo que haya probado quiénes fueron los asesinos de su *dominus* (C.7.13.1); y también, con posterioridad, por constituciones de Constantino, el esclavo que denuncie a un falsificador de moneda (C.7.13.2; año 321), o el rapto de una virgen (C.id.3; año 320) y por otra de Gracia-

no, Valentiniano y Teodosio; el esclavo que presente un desertor del ejército (C.id. 4; año 380).

b) Un edicto de Claudio da la libertad al esclavo abandonado por su amo (Modestino, D.40.8.2).

c) Por una disposición de Marco Aurelio se da la libertad a la esclava expuesta a la prostitución en contra de lo dispuesto en la venta de ella (Marciano, D.40.8.6.1; C.7.6.1.4; año 531).

d) También por el mismo emperador, el esclavo que había sido vendido pero con la condición de ser manumitido dentro de cierto término, y no se hizo así (Calistr., D.40.8.3, Marciano, D.id.6 pr.).

e) En la época posclásica, por una constitución de León, los esclavos afectados al servicio del emperador; y por influencia cristiana, los esclavos que entraban como monjes (Nov. 5.2.1), o eran designados obispos (Nov.123.4.17).

2. Diocleciano (C.7.22.1 ss.) admite la posibilidad de que un esclavo que de buena fe, sin haberse, p.ej., fugado, ha vivido 20 años como libre, puede alcanzar una prescripción adquisitiva de la libertad (*longi temporis praescriptio*).

§ 174. *Manumisión*. Es el acto por el cual el *dominus* le otorga la libertad a su esclavo (*manus* = poder; *mittere* = abandonar, enviar). Generalmente es un acto de reconocimiento por el cual se premian los servicios del esclavo. Los viejos modos solemnes de manumisión son la *vindicta*, el censo y el testamento (Ulp., 1.6).

A) Se manumite *per vindictam* en un acto que sucede ante el magistrado (cónsul, pretor, gobernador de provincia; Ulp., id.). Presente el esclavo, así como el *dominus*, un tercero (*adsertor libertatis*, generalmente un licitor de la guardia del magistrado) afirmaba su libertad, tocando al esclavo con una varita (*vestuca*). El dueño consentía guardando silencio, ante lo cual el magistrado confirmaba la libertad por una *adictio* (Ulp., 1.9; Inst., 1.5.2).

1. Tiene la forma de una *in iure cessio*, siendo la afirmación solemne del *adsertor libertatis* una forma imitativa de la *vindicatio in libertatem*: "Afirmo que este hombre es libre".

2. Hacia fines de la época clásica, se permitió que fuera el propio dueño el que dijera la fórmula, así como que hiciera el gesto de la varita, en presencia del magistrado. Y así se siguió usando hasta Justiniano (Hermogeniano, D.40.2.23).

B) Se manumite *per censum* cuando el dueño autorizaba al esclavo a inscribirse en la lista del censo de los ciudadanos (Ulp., 1.8), lo cual ocurría cada cinco años. A comienzos del Imperio esta forma cayó en desuso, por la desaparición del censo.

1. El último censo se realizó el año 74 d.C., si bien se hicieron censos municipales o provinciales.

Los juristas clásicos, retóricamente, siguen hablando de este modo de manumisión (Ulp., id.; Gayo, 1.17; 138; 140).

C) Se manumite *per testamentum* cuando el dueño ordena en su testamento la libertad de su esclavo. Se puede efectuar "directamente"; ya sea en forma expresa: "Que Stichus sea libre", ya en forma tácita: "Que Stichus sea heredero" (Inst., 1.6.2). Pero también en forma "indirecta", ya sea por un legado* o por un fideicomiso*, mandando al legatario o al heredero fiduciario* que manumita al esclavo, que se convierte de este modo en libertus del legatario o del heredero fiduciario, que serán sus patronos.

1. A los esclavos manumitidos por testamento se los llamaba "libertos orcinos", porque su patrono yace en el Orco —mundo inferior donde van las almas—.

2. La libertad se alcanza a partir de que el testamento surta efectos (Gayo, 2.267; se requiere —época clásica— que esté en el dominio quirritario* del testador, tanto en el momento de la facción del testamento como en el momento del deceso).

3. La cláusula de manumisión se podía sujetar a plazo o a condición. Mientras el plazo no se haya cumplido o esté pendiente la condición, el esclavo es un *statuliber* (D.40.7). Los sabiananos opinaban que era del heredero; los proculeyanos, que era *sine domino*; es decir, *nullus*, lo cual no significaba que fuera susceptible de ocupación (como ocurre con las *res nullius*) por un tercero (Gayo, 2.200).

D) Constantino reconoce una nueva forma de manumisión: la *manumissio in ecclesia*, *in sacrosanctis ecclesiis* (C.1.13.1-2). Se realizaba en las iglesias, en presencia de los prelados y de la grey cristiana allí reunida; generalmente se hacía el día de Pascua, y luego de la declaración de libertad se redactaba un libelo solemne.

§ 175. *Formas no solemnes de manumisión*. Podía ocurrir que el *dominus* le otorgara la libertad de un modo informal: así, haciéndole saber que desde ese momento era libre (*inter amicos*); o enviándole una carta anunciándole la libertad (*per epistulam*); o por el hecho de sentar a la mesa al esclavo (*per mensam*).

Estas formas "no solemnes" tornaban al esclavo "libre de hecho" (*in libertate esse*), pero no "de derecho", por cuanto estrictamente continuaban perteneciendo a su dueño. Sin embargo, el pretor los protegió contra un eventual reclamo del *dominus* que intentara una *vindicatio in servitutem* (Gayo, 3.56; Ulp., 1.10; Fragn. Disitheo, 8).

1. La expresión *inter amicos* no significaba necesariamente que debían estar presentes los amigos del

dominus, sino más bien que ocurría entre éste y el esclavo como si fueran amigos (*inter dominum et servum ut inter amicos*); es decir, de manera informal. Justiniano es quien exigirá la presencia de cinco testigos (C.7.6.2; año 531).

2. También la forma *per epistulam*, en la época clásica, era el mero envío de una carta (Juliano, D.41.2.38 pr.). Justiniano exigió además cinco testigos que firmaran o dieran fe del contenido de la carta (C.7.6.1; año 531).

3. La forma *per mensam*, aparecida a comienzos del siglo III, procede del derecho helenístico, pero fue suprimida por Justiniano en Oriente (C.7.6.12), mientras que en Occidente queda confundida con la de *inter amicos* (*Lex Rom. Burgund.*, 44.3).

4. Además Justiniano, siguiendo a Catón, dispuso que fuera libre el esclavo a quien su dueño daba "nombre de hijo" en forma pública, aun cuando por esto no alcanzaba la situación legal (C.7.6.10; Inst., 1.11.12). También a los esclavos que acompañaban el funeral del *dominus* adornados con su *pileus* (bonete de fieltro que se daba al esclavo el día de la manumisión, C.7.6.5).

§ 176. *Leyes restrictivas de las manumisiones*. El esclavo que era manumitido por alguna de las formas solemnes (vindicta, censo, testamento), hacía fines del período republicano, se transformaba en liberto ciudadano romano. Los abusos que se cometieron, provocaron que Augusto, celoso de la ciudadanía romana, estableciera, mediante dos leyes, restricciones a las manumisiones:

A) La ley *Aelia Sentia* (4 d.C.) estableció que:

(i) el dueño que quería manumitir debía tener 20 años cumplidos, mientras que el esclavo no debía ser menor de 30 años; salvo que existiera una justa causa aprobada por un *consilium*, en cuyo caso había que realizarla por una vindicta (Gayo, 1.18 ss.; Ulp., 1.12);

(ii) se consideraban nulas las manumisiones hechas en fraude de los acreedores (Gayo, 1.37; Ulp., 1.15);

(iii) los esclavos por penas infamantes (*servi poenae*) que fueran manumitidos no adquirirían la ciudadanía romana, sino que estaban asimilados a los *peregrini dediticii* (Gayo, 1.13).

1. El *consilium* que debía aprobar la justa causa de manumisión estaba formado en Roma por 5 senadores y 5 caballeros (*equites*), y en las provincias por 20 *recuperatores*, todos ellos ciudadanos romanos (Gayo, 1.20). Las causas aceptables respondían a razones humanitarias: así, la manumisión de un hijo o hija naturales, la de una esclava con la que se quiere cesar el *dominus*, etc.

2. Si el dueño no tenía 20 años, la manumisión era nula. Se daba la particularidad de que el púber

de 14 años podía hacer testamento, pero no manumitir por tal acto (Gayo, 1.40). En el fondo no había incongruencia, porque una cosa es disponer del esclavo (acto de interés privado; p.ej., legarlo), y otra manumitirlo y hacerlo ciudadano romano (acto de interés público). Justiniano tomará una solución intermedia, permitiendo la manumisión testamentaria a los 18 años (Inst., 1.6.7). Luego derogó la disposición (Nov.119.11), de tal modo que el púber podía manumitir desde los 14 años, quedando el requisito de la edad para los actos *inter vivos* (vindicta, manumisión en la iglesia).

3. El fraude a los acreedores era el perjuicio que sufrían por la merma del patrimonio, tornándolo insolvente o aumentando la insolvencia (Inst., 1.6.3). Justiniano, siguiendo un criterio anterior, exige para sancionar la nulidad por fraude un doble requisito: no sólo el estado de insolvencia, sino también la intención por parte del dueño de haber querido cometer fraude y perjudicar a los acreedores (Inst., *id.*).

Había un caso de excepción: el del "heredero necesario" cuando se instituía heredero a un esclavo, en una sucesión insolvente, para evitar la caída del testamento; esto estaba permitido por la propia ley *Aelia Sentia* (Paulo, D.28.5.57(55)).

4. De este modo, para la época de Justiniano, sólo quedó el requisito de la edad del *dominus* para manumitir por actos *inter vivos*, con la posibilidad de la justificación de una justa causa (Inst., 1.6.7; Nov.119.2) y la nulidad de la manumisión en fraude a los acreedores, en la forma ya expresada. La categoría de liberto dediticio quedó abolida (C.7.5).

B) La ley *Fufia Caninia* (2 d.C.) limitó las manumisiones por testamento. Éstas se habían hecho excesivas, manumitiendo sin discriminación, aun a los indignos, por simple acto de ostentación del testador, con lo que aparte del problema de la ciudadanía, se perjudicaba a los herederos. Esta ley estableció cupos máximos, atendiendo al número de esclavos del *dominus*, estableciendo una tabla permisiva, pero de tal modo que no se podía manumitir en un número superior a 100.

1. Gayo (1.43) nos dice que, según la ley *Fufia Caninia*, quien tuviera entre 3 y 10 esclavos, podía manumitir hasta la mitad; quien tuviera entre 10 y 30, hasta la tercera parte; quien tuviera entre 30 y 100, hasta la cuarta parte; quien tuviera entre 100 y 500, hasta la quinta parte. No decía nada respecto de más de 500; aquí regía la prohibición de no más de 100. Y en cuanto a quien tuviera tres o menos, era libre de manumitirlos a todos ellos.

Justiniano derogó la *lex Fufia Caninia* (Inst., 1.7; C.7.3).

IV. Los libertos: clases.

§ 177. Se puede distinguir tres clases de libertos: los libertos ciudadanos romanos, los libertos latinos junianos y los libertos dediticios (Gayo, 1.12; Ulp., 1.5).

A) *Libertos ciudadanos romanos*. Eran aquellos que: (i) eran manumitidos en forma solemne, (ii) por el *dominus* que los tenía en su propiedad quiritaria* (no bonitaria*), y (iii) que, desde Augusto, cumplimentaran los requisitos de la ley *Aelia Sentia* (ser mayor de 30 años); Gayo, 1.17 ss.; Ulp., 1.6 ss.

Son los más favorecidos. Su situación se acercaba a la de los ciudadanos romanos ingenuos. Sin embargo, había algunas diferencias. En cuanto al *ius publicum*, carecían del *ius honorum*, y si bien tenían el *ius suffragii*, sólo les era permitido intervenir en los comicios tribados, donde se les solía ubicar en alguna de las cuatro tribus urbanas, por lo que su peso político era menguado. En cuanto al *ius privatum*, tenían capacidad para efectuar los actos del *ius civile* (*ius commercii*), y también el *ius conubii*. Sobre ellos pesaba la relación del patronato.

1. Sin embargo, a pesar de ser válido jurídicamente, el matrimonio entre ingenuos y libertas era mal visto socialmente (los libertos eran llamados también "libertinos" —*libertini*—). En la época de Augusto, la ley *Iulia et Papia Poppaea* prohibió el matrimonio entre senadores y descendientes con libertas (Paulo, D.23.44 pr.). Y un s.c. debido a Marco Aurelio, consideró inexistentes las nupcias habidas entre una mujer senatorial y un liberto (Paulo, D.23.2.16).

2. En el Imperio, los libertos ciudadanos romanos podían adquirir individualmente, por concesión del Príncipe, una condición que los acercaba a los "ingenuos". Había dos grados: el *ius aureorum anulorum* (derecho de los anillos de oro) que usaban los caballeros (*equites*) (D.40.10; C.6.8); el que gozaba de esta concesión seguía manteniendo la relación del patronato; por lo menos en cuanto a los derechos sucesorios del patrono (Paulo, D.11.5). En cambio, por la concesión de la *restitutio natalium*, se lograba la igualdad total con los ingenuos (D.40.11; C.6.8). En ambos casos se necesitaba el consentimiento del patrono (Marciano, D.40.10.3; D.40.11.2).

B) *Libertos latinos junianos* (*Liberti Latini Iuniani*). Cuando un esclavo es manumitido por una forma no solemne (p.ej., *inter amicos*), o no se cumplimentaban los otros requisitos del *ius civile*, era libre de hecho, pero quedaba indefinido su *status*. Por ello es que se dio la ley *Iunia Norbana* (19 d.C.).

Son denominados "libertos latinos junianos" porque están asimilados a los latinos (colonias

rios) y porque reciben su libertad por la ley *Iunia* (Gayo, 1.22; Ulp., 1.10).

Carecen de los derechos políticos, y en principio se les permite el *commercium*, pero limitado a los actos *inter vivos*. Por ello no pueden ni hacer testamento, ni recibir nada a título de herencia o de legado en forma directa (Gayo, 1.23-24; Ulp., 20.14).

1. Su situación puede resumirse así: "Viven como libres, pero mueren como esclavos" (Salviano, *adv.avar.* 3.7). Una vez que fallecen, los bienes regresan a su antiguo *dominus*, pero no a título hereditario, sino a título de peculio (*iure peculio*; Gayo, 3.56).

2. Sin embargo, mediante algunas concesiones especiales podían alcanzar la ciudadanía romana. Así:

a) Por la propia ley *Iunia Norbana*, quien era latino juniano por no tener los 30 años de edad requeridos por la ley *Aelia Sentia*, si tomaba por mujer —no *iustae nuptiae*— a una ciudadana o latina, y tenía con ella un hijo que alcanzaba un año de edad, se podía presentar ante el pretor y tanto él como su mujer —si no lo era ya— obtenían la ciudadanía (Gayo, 1.29; Ulp., 3.3).

b) También podían adquirir la ciudadanía por haber prestado determinados servicios a Roma: así, haber militado durante 6 años en la guardia (*vigiles*) de Roma (ley *Vissellia*); un s.c. posterior redujo el cómputo a 3 años (Gayo, 1.32b; Ulp., 3.5); o si había construido una nave con capacidad para 10.000 medidas de trigo y había estado llevando dicho cereal durante 6 años a Roma (edicto de Claudio, Gayo, 1.32c; Ulp., 3.6); También Nerón le da la ciudadanía al latino que tuviera un patrimonio de más de 200.000 sesterces y edificara una casa en Roma, invirtiendo la mitad de dicho monto (Gayo, 1.33). Y Trajano, al latino que trabajó como molinero en Roma durante 3 años, habiendo molido no menos de 100 medidas de trigo diarias (Gayo, 1.34).

Como es fácil advertir, todas estas disposiciones están vinculadas con distintas necesidades públicas de la vida romana.

3. Además, siendo mayor de 30 años, si se corregía la manumisión informal anterior, realizando una solemne (por vindicta, censo o testamento), el latino adquiere la ciudadanía romana (*iteratione*, Gayo, 1.35; Ulp., 3.4).

C) *Libertos que se cuentan en el número de los dediticios*. Son aquellos que eran esclavos por penas infamantes (*servi poenae*). Al ser manumitidos obtenían la libertad; pero, debido a su conducta anterior, se los trataba con rigor jurídico, asimilándolos a los extranjeros dediticios.

1. No tenían ni derechos políticos ni tampoco participaban del *ius civile*. Lo único que podían hacer eran actos del *ius gentium* (Ulp., 20.14). Pero por la ley *Aelia Sentia* no podían habitar en Roma, ni en un

radio de 100 millas a su alrededor, y si contravenían esta disposición, se los vendía públicamente, pero de tal modo que el comprador no los podía tener como esclavos ni en Roma ni a 100 millas de ella, ya que de lo contrario se convertían en esclavos públicos (*servi populi Romani*), Gayo, 1.27.

2. Gayo denomina su situación como *pessima libertas*, no pudiendo lograr el acceso a la ciudadanía romana por ninguna ley, o s.c., o constitución imperial (Gayo, 1.26).

Justiniano abolió la condición de los *dediticios* (C.7.5.1; año 530), e igualmente la de los *libertos junianos* (C.7.6; año 531), quedando todos los *libertos* como ciudadanos romanos (Inst., 1.5.3).

V. El patronato.

§ 178. El *liberto*, pese a ser libre, se halla sometido a una situación jurídica especial con su antiguo *dominus*. Este pasa ahora a ser su *patronus*. De ahí el nombre de este vínculo que es el *patronato*.

1. Ya desde antiguo, el *liberto* quedaba unido al patrono por un vínculo análogo al de la clientela. El *liberto* quedaba amparado por su patrono, quien debía protegerlo. Si no lo hacía, según la ley de las XII Tablas (8.21), el patrono caía en *exsacratio*, siendo considerado *homo sacer* y expuesto a la venganza divina.

El contenido del patronato abarcaba:

a) El deber del *obsequium* (*o reverentia, honor*), en virtud del cual el *liberto* debía respetar siempre al patrono como un hijo a su padre (Ulp., D.37.15.9). El cumplimiento de este deber abarcaba muchas situaciones. Así, prestarle alimentos en caso de necesidad del patrono (Paulo, 2.32); o la de no poder iniciar una acción contra él, sin autorización del pretor (Ulp., D.2.4.4.1). En caso de contravenir este deber, se lo podía considerar como *liberto ingrato*, permitiéndose en la época imperial una *revocatio in servitutem*, por lo que volvía a caer en esclavitud (v. *supra*, § 172.e).

b) El *liberto* debe prestar al patrono determinados servicios (*operae*). Algunos de ellos, elementales, se consideraban un cumplimiento del *obsequium* —*operae officiales*— (p.ej.: guardarle la casa, acompañarlo en un viaje; ayudarlo en los negocios; Calistrato, D.38.1.38.1). En cambio, para otras, obras —*operae fabriles*— el *liberto* la debía prometer por un juramento (*iururandum liberti**) antes de la manumisión, renovada luego de ella (p.ej., por una *stipulatio*). En caso de incumplimiento, el patrono ta-

nía una *actio operarum* (Ulp., D.38.1.2.1), o en su caso la *actio ex stipulatu*.

c) El tercer aspecto era de carácter patrimonial (*bona*). El patrono (y en su caso sus herederos) es llamado a la sucesión intestada cuando el *liberto* muere careciendo de herederos suyos (*heredes sui*). Igualmente, el patrono como sus descendientes agnados más cercanos son llamados a la tutela legítima de los hijos del *liberto*.

§ 179. A su vez, el patrono debe prestar su *fides* a sus *libertos*; por ello le incumbe el deber de alimentos al *liberto* que se los pida (Modestino, D.25.3.6 pr.), asistirlo y defenderlo en juicio, no acusarlo por delito que traiga la pena capital ni ejercer injustamente la *actio ingrati* (Ulp., D.38.2.14; id., 16).

La relación de patronato pasa a los descendientes del patrono; en cambio, cesa con la persona del *liberto*, y no se extiende a su descendencia, siendo los hijos de éste considerados *ingenuos*.

VI. Situaciones similares a la esclavitud.

§ 180. Aunque no son propiamente esclavos, había ciertas situaciones que resultaban similares:

A) Los hijos dados "*in mancipio*". El *pater* podía "vender" a los hijos a un tercero —p.ej., entregándolo por una *mancipatio* para reparación de un daño ocasionado por el hijo (*noxae deditio**). En este caso, el tercero tenía el *mancipium* sobre dicha persona, que quedaba sujeta a él —*in causa mancipii*—. Mientras lo sirviera, continuaba siendo libre y en su caso ciudadano, pero para las relaciones patrimoniales estaba como si fuera un esclavo (*in loco servi*; Gayo, 1.123; 3.114). Se salía de esta situación por la manumisión, regresando *in potestate* de su *pater*.

B) Los *addicti* eran aquellos que en el derecho antiguo no habían pagado la obligación contraída por el *nexum**, o habían sufrido la *manus iniectio**. No eran exactamente esclavos, pero patrimonialmente estaban sujetos al acreedor, de quien dependían hasta que éste los liberara, luego de haber satisfecho la obligación.

C) El *redemptus ab hostibus* (rescatado de los enemigos) es aquel que fue rescatado de la esclavitud por causa de guerra, mediante un rescate en dinero. Quedaba retenido por el que había pagado, hasta recobrar el precio.

1. Por una constitución de Arcadio y Honorio se favoreció su situación señalando un plazo máximo de 5 años, entendiendo que los trabajos y servicios prestados durante ese lapso valían como compensación de la suma del rescate (CTh. 5.7.2; C.8.50.20).

D) El *auctoratus* es aquel que arrienda sus servicios a un empresario (*lanista*) para ser gladiador en los juegos del Circo, obligándose bajo juramento a dejarse quemar, sujetar y morir con el hielro (Séneca, Ep.37.1; Apocol. 9.8). Es libre y en su caso ciudadano, pero su situación es equivalente a la del esclavo.

E) En el derecho posclásico se conoció el "*colonato*". Los colonos (*coloni*) eran hombres libres, pero que por condición estaban adscritos de manera permanente, al igual que sus familiares, a una tierra determinada, y en consecuencia al dueño de ésta. Se los consideraba *servi terrae* (esclavos de la tierra) o *glebae adscripti* (adscritos a la gleba).

1. El *colonato* no tiene un origen propiamente romano, sino que surge de ciertas costumbres usuales en el Oriente (Egipto, Asia Menor, etc.). A partir del siglo III, debido a las circunstancias agro-económicas, y a los impuestos, muchas familias vendían sus tierras quedando en esta situación. Formaron una parte importante de la masa de población agrícola. Son considerados como parte integrante de la tierra (C.11.48 (47).23 pr.). Debían pagar al dueño de la tierra un canon, ya en especie —lo más usual—, ya en dinero. Si bien son libres, su atadura a la tierra hacía que cuando se vendía ésta, los colonos también lo eran como accesorios de ella; tampoco se los podía vender sin la tierra (C.11.47.7). Esta situación tendrá luego cierta vida en el Occidente; así, los "siervos de la gleba" en el Medioevo.

Resultaba muy raro que se pudiera hacer cesar la situación del colono, lo cual llama la atención dada la vigencia del Cristianismo. Antes de Justiniano, se permitía una prescripción de tal situación por el transcurso de 30 años para el hombre y 20 para la mujer, cuando éstos habían cambiado por ese lapso de domicilio (CTh.12.19.2; 5.10.1.1 y 3), pero Justiniano la abolió (C.11.47.23). En cambio, un modo aceptado era que el colono fuera nombrado obispo, pero no el simple ingreso al estado eclesiástico (C.1.3.16; 27 pr.1; Nov.123.4; 27).

STATUS CIVITATIS

§ 181. Si se observa la posición jurídica que un hombre libre ocupa dentro de la *civitas*, podemos distinguir entre: a) los ciudadanos romanos; b) los latinos; y c) los peregrinos (extranjeros).

1. Roma fue siempre muy celosa en lo referente a la concesión de prerrogativas o ventajas en la *civitas*. El criterio rector sería el de la *romanitas*, conforme al cual, cuanto mayor fuera el grado de "romanización", es decir, la adaptación al modo de ser romano, mejor sería la situación del individuo o del grupo en su ubicación jurídica (política y privada) dentro de la *civitas*.

2. Este criterio fue aplicado muy liberalmente respecto de los esclavos (generalmente extranjeros), ya que por su manumisión regular se hacían ciudadanos romanos. Al respecto, Schulz (DRG, § 141) cita una carta del rey Filipo V de Macedonia, aliado de Aníbal, en la cual respecto de esta actitud jurídica romana, la considera como fuente importante de la fuerza y del poderío de Roma. Con sus esclavos, dice el rey macedonio, Roma no solamente acrecienta el número de sus ciudadanos, sino que puede con ellos fundar numerosas colonias.

A) Los ciudadanos romanos.

§ 182. Aquellos que tienen la ciudadanía plena (*cives optimo iure*) son los que gozan de la totalidad de los derechos, tanto en el *ius publicum* como en el *ius privatum*. Respecto al primero, tienen los derechos políticos fundamentales: (1) el de poder participar en los comicios, votando las decisiones (*ius suffragii*), así como (2) poder acceder a las magistraturas (*ius honorum*). En cuanto al *ius privatum*: (1) el poder realizar todos los actos y los negocios propios del *ius civile* (*ius commercii*), así como también (2) el *ius conubii*, o sea el poder contraer nupcias legítimas (*iustae nuptiae*).

1. Resulta difícil enumerar detalladamente la totalidad de los derechos que pueden ejercer los ciudadanos romanos. Preferimos por ello centrarlos en estos fundamentales, viéndose luego en cada una de las instituciones posibilidades de actuación más precisas.

Así, podemos mencionar que en el *ius publicum*, por su participación en los comicios, gozan de la *provocatio ad populum* (forma de apelación extrema al *populus* en los juicios criminales), así como el *ius sacrorum* (posibilidad de acceder a los colegios sacerdotales). Y en el *ius privatum*, la posibilidad de hacer testamento (*testamenti factio activa**), así como la de ser heredero o legatario en un testamento romano (*testamenti factio passiva**). Además, como consecuencia del *ius conubii*, el parentesco de la *agnatio**, la *patria potestas**, la *manus**, etc. Igualmente, el poder presentarse con una *actio** en el procedimiento romano (*ius actionis*).

2. También sobre los ciudadanos pesan ciertas cargas (*munera*), tales como anotarse en el censo, servir en las legiones, pagar los impuestos, ejercer la tutela, etc.

3. Los ciudadanos romanos se distinguen fácilmente por cuanto, en general, llevan tres nombres (*tria nomina*): el *praenomen* (nombre individual), el *nomen* (nombre de la gens a qué pertenecen) y el *cognomen* (nombre familiar). Así, Marco Tulio Cicerón. A veces se agrega un sobrenombre (*agnomen*): Publio Cornelio Escipión el Africano (esto en honor por la victoria obtenida sobre Aníbal en Zama, África).

Los *libertos* ciudadanos romanos tienen su nombre particular precedido por el de su antiguo *domi-*

rus. Así, el esclavo Stichus, manumitido por Cicerón, se denominaba *Marcius Tullius (Marci libertus) Stichus*.

§ 183. *Adquisición y pérdida de la ciudadanía romana*. I. Por lo general, la ciudadanía se tiene por haber sido concebido por padres romanos unidos en *iustae nuptiae*. Fuera de esta unión, había que considerar la situación de la madre, sin importar la del padre, por lo que era ciudadano el hijo de una madre romana desde el momento del parto (Gayo, 1.89; Ulp., 5.10; Inst., 1.4 pr.).

1. Hacia fines de la República (alrededor de comienzos del siglo I a.C.) se sancionó una *lex Minicia* según la cual el hijo habido de la unión de una ciudadana romana y un latino, o un extranjero, seguía la condición del padre, con lo cual se le rechazaba la ciudadanía romana, en contra de la regla general que se venía aplicando (fuera de las *iustae nuptiae*, seguir la condición de la madre). Esta ley fue derogada por un s.c. de la época de Adriano (Gayo, 1.77-78; Ulp., 5.8).

II. Pero también se podía obtener la ciudadanía romana por hechos posteriores: así, por la manumisión de un esclavo, por medios solemnes y cumplimiento de los requisitos de la ley *Aelia Sentia* (liberto ciudadano romano); por concesión especial expresada por el *populus* en los comicios —época republicana— o por un senado-consulta o una constitución del Príncipe —época imperial—. Podía comprender a un solo individuo, o a un grupo, o un pueblo entero, y podía ser la concesión plena o limitarse a alguna prerrogativa —*ius suffragii*, o *ius conubii* o *ius commercii*—. En el año 212 d.C., Caracalla dictó la *constitutio Antoniniana*, en virtud de la cual se declaró ciudadanos a todos los habitantes del Imperio, con la excepción, quizá, de los *dediticii** (Ulp., D.1.5.17).

III. La ciudadanía romana se pierde: a) por haberse incurrido en *capitis deminutio maxima*, es decir, si el ciudadano cae en esclavitud, salvo el caso del *postliminium** para el prisionero de guerra (Gayo, 1.160; Ulp., 11.11; Inst., 1.16.1); b) por la *capitis deminutio media*, cuando se convierte en latino coloniarior*, o cuando se sufre la pena del destierro (Gayo, 1.161; Ulp., 11.12; Inst., 1.16.2).

1. Por razones políticas, un ciudadano podía ser condenado a sufrir la *interdictio aquae et ignis* (prohibición del agua y del fuego), con lo que se significaba simbólicamente que se lo ponía al margen de la *civitas*; ello significaba la pérdida de la ciudadanía (Gayo, 1.55; 90; 128; 161; Ulp., 10.3; Inst., 1.12.1; 1.16.2).

2. Ya desde la época del Principado se habla de la deportación *in insulam*, que era la pérdida de la ciudadanía a un romano a quien se lo confinaba en una isla (Inst., 1.12.1; Ulp., D.32.1.3). Por favor imperial, se podía perdonar al deportado y volverlo a su situación anterior (a veces, con limitaciones respecto a la *patria potestas* que se perdía; Gordiano, C.9.51.6). Justiniano determinó que en ese caso se recobraba el *pristinus status*, es decir, la posición de la cual se gozaba anteriormente.

3. Existía también la *relegatio in insulam* (Inst., 1.12.2). Era una pena menor que no provocaba la pérdida de la ciudadanía, reteniéndose la *patria potestas* (Marciano, D.48.22.4). Tal fue la situación sufrida por el poeta Ovidio, confinado al Ponto.

§ 184. *Los latinos*. Estos estaban en una situación intermedia entre los ciudadanos romanos y los extranjeros (*peregrini*). Los había propiamente de dos clases: *Latini veteres* y *Latini coloniarii*; debiendo agregarse los *Latini Iuniani** (libertos manumitidos en forma irregular, y asimilados a los latinos por la *lex Iunia Norbana*).

(A) *Latini veteres*. Fueron los antiguos habitantes del *Latium*; luego, se agregaron los miembros de las colonias fundadas por la Liga Latina hasta su disolución en el 338 a.C.

1. Se trataba de los ex aliados de Roma, sobre los cuales ésta había triunfado disolviendo la Liga Latina. Según la política romana, se los admitió por la similitud de costumbres y religión en una categoría muy cercana a la de los ciudadanos romanos.

2. Conservaban los *iura privata* —*conubium*; *commercium*— e incluso el *ius suffragii*, siempre y cuando estuvieran en Roma en oportunidad de las reuniones de los *comitia*, en tiempos de Cicerón, se sacaba a la suerte la tribu donde votarían. Carecían, en cambio, del *ius honorum*.

(B) *Latini coloniarii*. Uno de los procedimientos arbitrados por los romanos para mantener el espíritu de la *romanitas* sobre las regiones conquistadas en Italia fue el de las colonias, que servían como centro de irradiación de ese espíritu. Unas eran propiamente romanas y sus habitantes eran ciudadanos romanos, pero a partir del año 268 a.C. se crearon doce nuevas colonias, que eran latinas —formadas por latinos o por ciudadanos romanos que al irse de Roma perdían su categoría—. A éstos se les concedió un *status* particular llamándoselos *Latini coloniarii*.

1. Tenían el *suffragium* siempre que estuvieran en Roma en oportunidad de reunirse los *comitia*, pero no el *ius honorum*. Ejercían también el *ius commercii*, pero necesitaban una concesión especial expresa

para tener el *conubium* con los ciudadanos romanos (Ulp., 5.4; 19.4).

2. Este *status* fue concedido también a los habitantes de otras comunidades fuera de Italia. Así, en España, donde conocemos las leyes que ordenaban la administración de Salpensa y Malaca.

3. Los *Latini veteres* podían alcanzar con cierta facilidad la ciudadanía romana, siempre que cambiaran su domicilio a la ciudad de Roma, y a fin de evitar la despoblación de las ciudades latinas, debían dejar por lo menos un hijo varón afincado en ellas (Tit. Liv., 41.8 y 9). Este beneficio también lo tenían los *Latini coloniarii* que hubieran sido magistrados en su ciudad antes de trasladarse a Roma. Pero fue suprimido para todos por la ley *Lotina Mucia* (95 a.C.), lo cual provocó la guerra social, tras la cual todos los latinos de Italia adquirieron la ciudadanía romana (leyes *Iulia*; 90 a.C.; *Plautia Papiria*, 89 a.C.).

4. Quedaron solamente los latinos colonarios de ciudades extranjeras, pero podían acceder a la ciudadanía romana ocupando una magistratura municipal (*ius minus Latium*), o habiendo sido decuriones (*ius maius Latium*); Gayo, 1.96.

Igualmente, haciendo condenar por concusión (peculado) a un magistrado romano (ley *Servilia*, año 111 a.C.; Cicer., *pro Balbo*, 8.21; Aul. Gell., 4.4) y también por los modos por los cuales se admitía la ciudadanía a los latinos junianos.

§ 185. *Los peregrinos*. Los *peregrini* (viene de *per agros*, es decir, los que se acercaban a Roma caminando por los campos) son los extranjeros, o sea, aquellos pertenecientes a otras comunidades que se habían integrado a Roma, asegurándole ésta ciertos derechos y garantías. Generalmente se firmaba un pacto (*foedus*) donde se establecía el *status* de la *civitas*, así como de sus habitantes. Desde este punto de vista se diferencian de los "bárbaros" que vivían fuera del Imperio y con los cuales no había habido relaciones.

1. Los peregrinos, en general, no quedan sujetos al *ius civile*. Perteneciendo a una *civitas* libre, es decir, a la que se le reconocía cierta autonomía, podía llevar sus litigios ante sus propios tribunales que decidían por su propio derecho civil. Si recurrían ante un magistrado romano (el gobernador o en Roma el *praetor peregrinus*), la causa se resolvía mediante creaciones basadas en el *ius gentium*.

2. De este modo, su ámbito jurídico se mueve en torno de este *ius gentium*. De allí surgen la compra-venta, la sociedad, el mandato y la locación. Pero había instituciones típicamente romanas que eran usadas por los peregrinos (así, la *stipulatio**, pero no la *sponsio**); también, por razones de equidad se extienden ficticiamente en favor y en contra de ellos la *actio furti** y la *actio legis Aquiliae**.

3. Una categoría especial entre los peregrinos era

la de los *peregrini dediticii*. Estos eran aquellos que se habían alzado en armas contra Roma y se rindieron a discreción, es decir, sin gozar de ninguna prerrogativa (Gayo, 1.14). Tal era, p.ej., la situación de ciertos nativos de Egipto, excluyendo algunas ciudades griegas (así, Alejandría); también los judíos, aunque al parecer reducidos a los habitantes de Jerusalén, luego de su destrucción por Tito. También los que sufrían la *interdictio aquae et ignis*, y luego la *deportatio in insulam*, caían en esta condición. No tenían derechos políticos, no sólo en Roma, sino tampoco en sus ciudades, salvo permisión especial de los gobernadores.

No podían hacer testamento, no sólo por el *ius civile*, sino tampoco como peregrinos (*ius gentium*), "porque al no ser ciudadanos de ninguna ciudad no pueden testar de acuerdo a su *ius civile*" (Ulp., 20.14). Se podían casar según el *ius gentium*, pero sin poder ejercer ninguna *potestas* sobre sus hijos.

También les estaba prohibido vivir en Roma y en un radio de 100 millas de Roma. Además, debían pagar un impuesto especial (*tributum capitis*), si bien está discutido si esta carga era genérica o no para todos los *dediticii*.

Los *peregrini dediticii* no pueden adquirir directamente la ciudadanía romana, pero sí indirectamente, tomando antes una ciudadanía extranjera. Así se deduce de una correspondencia habida entre Plinio el Joven y el emperador Trajano (Ep. 6). Plinio deseaba lograr la ciudadanía para su médico *barbaricus*, manumitido por una egipcia. El procedimiento consistió en hacerlo primero ciudadano de Alejandría.

La *Constitutio Antoniniana* (año 212 d.C.) parece haber excluido de los beneficios de la ciudadanía romana a los *dediticii*, si bien para esta época, su número había disminuido mucho, debido a la nueva reestructuración municipal de muchas partes del Imperio. No hay que olvidar que en esta categoría estaban también los *servi poenae* manumitidos, que por la ley *Aelia Sentia* se cuentan en el número de los *dediticii*. Todavía existían peregrinos *dediticii* en el siglo IV d.C. (CTh.4.6.3). Justiniano hizo finalmente desaparecer esta categoría en el año 530 (C.8.5.1).

STATUS FAMILIAE

§ 186. Es la situación en que se hallan los hombres libres y ciudadanos dentro de una determinada familia. La plena capacidad la tiene sólo el *paterfamilias*, quien es el único que es *sui iuris*. Los demás integrantes de la familia son todos *alieni iuris*; así, los *fili* sometidos a la *patria potestas*, la mujer (*uxor*) sujeta a la *manus*, lo mismo que el tercero recibido por ej. en *noxam**, tras haber cometido un delito, y que está sometido al *mancipium* (in *causa mancipii*). Todas estas situaciones las estudiaremos con la familia romana.

CAUSAS MODIFICATIVAS DEL STATUS

§ 187. Una persona que tenga un *status* determinado puede ver variada su situación, especialmente el ejercicio de él, por determinadas causas. En el derecho moderno se habla de "capacidad jurídica" y de "capacidad de hecho". Así, un demente podrá ser "capez de derecho" (p.ej., para ser propietario), pero dada la alteración de sus facultades mentales, carecerá de "capacidad de hecho" para actuar jurídicamente. En este caso necesitará de la asistencia jurídica de un curador.

Fuera de otras situaciones que son tratadas en el lugar pertinente, analizaremos algunos de esos factores que modifican el *status*, en lo relativo a la posibilidad jurídica de obrar.

A) *Edad*. Dejando a un lado la situación del *nasciturus**, una vez nacida la persona, su posibilidad depende de la edad que se tenga:

a) *Infantes*. Son los niños que no pueden pronunciar las palabras (*qui fari non possunt*) en los actos jurídicos, en el sentido de que carecen totalmente de la comprensión de ellas. Por tanto, carecen de posibilidad de obrar en los actos jurídicos y tampoco son responsables por la comisión de delito.

1. Durante los primeros siglos, la duración de la *infancia* debió ser variable. Pero luego se determinó que duraba hasta la edad de 7 años (CTh. 8.18.8 pr.; año 407; C.6.30.18, año 426), la cual debió haber sido la edad normal en la época clásica (Ulp., D.26.7.1.2; Juvenal, *Sat.*, 14.10 ss.; Quint., 1.1.4).

b) *Impúberes* son aquellos que aún no han alcanzado la capacidad de procrear (*qui generare non possunt*). Sobre la pubertad, las niñas la alcanzan a los 12 años, mientras que respecto de los varones existió una discrepancia en las Escuelas. Los sabinianos la dejaban como una cuestión de hecho, de tal modo que el *pater* era el que determinaba cuándo el varón manifestaba por signos corporales (*habitus corporis*) que era capaz de procrear. Si lo reconocía como púber, el varón pasaba a vestir la toga viril (blanca; abandonando la toga *praetexta*, orlada con una banda púrpura). En cambio, los proculeyanos determinaban que la pubertad se alcanzaba para los varones siempre a los 14 años. Este último criterio prevaleció en la decisión de Justiniano (C.5.60.3; Inst., 1.22-pr.).

1. En la época clásica este problema quedó indeciso. Así, Scévola habla de 16 años (D.40.5.10 y 13). Javoleno Prisco se inclinaba por una solución intermedia, hablando de la edad y del desarrollo físico. Es curioso señalar que San Pablo, en la epístola a los Galatas (4.2), habla de que los padres eran los que

señalaban la edad de sus hijos, por lo que cabe suponer que para esa época (siglo I d.C.) esa era el criterio ordinariamente seguido. Llama la atención que una cuestión tan importante como la fijación de la edad por la que se adquiere la "capacidad de hecho" haya permanecido fluctuante hasta la decisión final de Justiniano. Éste da en favor de la tesis proculeyana razones de castidad para suprimir la *inspectio habitus corporis* a los varones, que propiciaban los sabinianos (Inst., 1.22 pr.).

La denominación de *impuberes* abarca en general a los *infantes* (a los cuales se los llama directamente por este último nombre) como para quienes han pasado la infancia. Los textos emplean a veces la terminología de *infantiae proximi* (próximos a la infancia) y *pubertati proximi* (próximos a la pubertad). Estos últimos serían responsables por los delitos que cometieran (*capaces doli*), mientras que los primeros estarían más asimilados a los *infantes*.

1. Los textos hablan de que el *pubertati proximus* resulta obligado por el *furtum*, puesto que se da cuenta de que comete el delito (Gayo, 3.208, Inst., 4.1.18), cosa que no ocurre con el *infantiae proximus*. Además, si son pupilos, los primeros podrían actuar por sí, pero con la *auctoritas* del tutor, si bien este criterio se extendió en algunos casos también a los segundos (Gayo, 3.109; Inst., 3.19.10).

c) *Puberes y menores*. La pubertad confiere la plena capacidad, ya negocial, ya la responsabilidad delictiva. La circunstancia de haber identificado la capacidad de engendrar con la jurídica trajo muchos problemas debido a que los púberes, por su falta de experiencia negocial incurrieron en actos que les eran perjudiciales. Por ello, a partir de la *lex Laetoria* se habla de una nueva edad, llamándose a los púberes menores de 25 años con la denominación de "menores" (*minores viginti quinque annis*). Respecto de ellos se dieron protecciones especiales que culminaron con su curatela.

B) *Sexo*. Las mujeres no estuvieron equiparadas a los varones. Si era una *filia* que estaba *in potestate* de su *pater*, quedaba sometida, al igual que sus hermanos varones, a la *patria potestas*. Si salía de ella, se volvía *sui iuris*. Podía ocurrir que se casara, en cuyo caso, si el matrimonio era *cum manu*, quedaba sujeta a la *manus* de su marido, o del *pater* de quien éste dependiera. Si el matrimonio celebrado era *sine manu*, continuaba siendo *sui iuris*. Pero aun así, durante mucho tiempo, quedaba sometida a una tutela perpetua (*tutela mulierum*), la cual era una institución tutitiva, es decir, de protección para que no realizaran actos perjudiciales para ellas, debidos a su *infirmis sexus* (in-

constancia del sexo) o *levitas animi* (ligereza de espíritu; Gayo 1.145). Esta tutela tuvo una historia muy matizada por ciertos aspectos que estudiaremos. Todavía se halla vigente en tiempos de Diocleciano, pero ya no aparece en el Código Theodosiano ni tampoco en parte alguna de la compilación justiniana.

1. No podían actuar en la vida política ocupando magistraturas. Tampoco ejercer la *patria potestas*. Ración en la época posclásica, la madre o en su defecto la abuela podían ser tutoras. Además no se podían ofrecer afianzando obligaciones de terceros (*s.c. Velleianum**). Todos estos aspectos serán estudiados en cada una de las instituciones pertinentes.

d) *Enfermedad mental*. El demente (*furiosus*) es aquel que tiene alteradas las facultades mentales, por lo que carece de "capacidad de obrar" (Gayo, 3.106). Por ello es que desde antiguo se lo puso en la curatela de alguien (*curator*) que administrará sus bienes.

1. Se suele hacer una diferencia con el *mente captus*, es decir, con el débil mental. Éste padece una enfermedad permanente, mientras que el *furiosus* puede recobrar su salud mental, o realizar actos en intervalos lúcidos (Macer, D.1.18.14).

B) *La infamia*. Consistía en la pérdida del "honor civil", es decir, de la *existimatio*, que era la designación de la posición de "dignidad" (*dignitatis status*; Calistrato, D.50.13.5.1).

1. Existía la *infamia censoria*, por la cual el censor como guardián de las costumbres (*curator morum*) tachaba de infamia al ciudadano indigno; sus efectos principales eran la pérdida de sus posibilidades de actuación política (*suffragium, honores*).

2. También existía una *infamia consular*, por la cual el magistrado, generalmente el cónsul, veta que alguien sea candidato en los comicios.

3. Y también estaba la *infamia pretoriana*, por la cual se les prohibe a determinadas personas la representación judicial (*cognitor**, *procurator**). Sufrían esta *ignominia* los condenados en acciones penales (salvo el caso de la *actio legis Aquiliae**, donde la condena podía ser por mera culpa), así como los condenados en acciones donde intervenía la *fides* (*actio pro socio**, *actio mandati**, *actio fidei**, *actio tutelae**); Gayo, 4.182; EP, § 16.

4. También otras personas, fuera de la actuación judicial (*infamia immediata*); así, la mujer sorprendida en flagrante adulterio (Ulp., D.23.2.43.12; id., 13); el tutor o curador, o su hijo, que se casara con la pupila antes de que ésta alcanzara los 28 años de edad, salvo que hubiera sido prometida en matrimonio por el *pater*, ya en vida, ya por testamento (Paulo, D.23.2.66 pr.).

5. Justiniano, continuando una tendencia del Bajo Imperio, nos da una lista de *infames*; excluidos de postular por otros en los juicios y de otras actividades administrativas (Juliano, D.3.2.1 ito.). Figuran: a) el militar que ha sido dado de baja por causa ignominiosa; b) los actores y gladiadores; c) quien hubiera hecho *lenocinio*; d) quien hubiera casado a su hija viuda sin respetar el plazo de luto; lo mismo que quien se casa con ella, si sabía esa circunstancia, y el *pater* de quien se casa; e) quien se compromete por dos esponsales* al mismo tiempo, o se casa estando casado. También figuran los casos mencionados por Gayo, aclarándose que no se comprende a quienes fueron condenados en una *actio contraria** (caso de la tutela del mandato, etc.); D.3.2.1; Inst., 4.16.2.

6. Juntamente con la "infamia" (*infamia turis*) estaba la *turpitud* (*infamia facti*); Juliano, D.37.15.2 pr., quien establece la diferencia aunque no las denominaciones. Era una descalificación de hecho, en virtud de la cual, sin llegar a ser *infames*, se los excluía para algunos actos, tales como el testimonio, la tutela, etc. (cfr. XII Tablas, 8.22; Aul. Gell., 5.13.11).

PERSONAS JURÍDICAS
(Corporaciones y fundaciones)

§ 188. A) En el derecho moderno se admite la existencia de determinadas asociaciones y corporaciones que tienen por sí una personalidad jurídica independiente de la de los miembros que la conforman. Se las llama "personas jurídicas".

En su vida interna tienen su regulación particular, poseen un patrimonio propio, cuyo propietario es la misma persona jurídica, y no las personas particulares que la integran. Igualmente, en las relaciones negocials, es también la "persona jurídica" la que resultará acreedora o deudora de los actos realizados por sus miembros para ella. Finalmente, desde el punto de vista procesal es la persona jurídica la que podrá demandar y ser demandada.

1. Así, tomemos una sociedad anónima X*. Ésta es, según el derecho actual, una persona jurídica. Ello significa que ella misma, con la intervención de sus miembros ejecutivos, podrá realizar actos y negocios jurídicos *per se*. Los bienes que tenga no son de los miembros sino que les pertenecen a ella. Si hay un crédito, ella, y no los miembros, es la acreedora. Si hay una deuda, es ella, y no los miembros, la deudora.

2. La construcción jurídica de este tipo de "personalidad jurídica" es propiamente modernista. No le es ajena la aparición del concepto de "sujeto de derecho", de tal modo que éste podrá ser determinado como "persona física" y como "persona jurídica". También se las llama "personas de existencia ideal", y primeramente "personas morales" o "personas ficti-

cias", pero la teoría de la ficción (como si fueran personas) fue lentamente abandonada en favor de reconocer la realidad de su personería.

B) En el Derecho Romano antiguo, y también en el clásico, falta el concepto de "persona jurídica". Hay que recordar el principio liminar de que "todo el *ius* está constituido por causa de los hombres" (*hominum causa omne ius constitutum est*; Hermog., D.1.5.2). Sin embargo, como buenos realistas que eran, admitieron la necesidad del agrupamiento de personas para determinados fines asociativos, y ello fuera del caso del contrato de sociedad. Pero, a diferencia del derecho actual, no vieron en ellas un ente distinto de sus miembros. Mediante un proceso lento y esforzado, tuvieron que ir determinando el régimen jurídico de estas asociaciones. Recién en la época posclásica, y principalmente con los bizantinos, se admitirán ciertos principios sobre los cuales los modernos construirán el concepto de "persona jurídica".

Es necesario considerar por separado las distintas situaciones:

I. Populus.

§ 189. Es indudablemente la primera asociación. Es la totalidad de los ciudadanos. El *populus* puede adquirir bienes, tanto muebles como inmuebles. Serán consideradas *res publicae* (= cosas del *populus*). Están consideradas como no pertenecientes a un ciudadano en particular, sino que son de todos los participantes del *populus*, como si estuvieran en una suerte de condominio ciudadano (Gayo, 2.11; D.1.8.1 pr.; Inst., 2.1.6; Ulp., D.50.16.15). El tesoro del *populus* es denominado *aerarium populi Romani* o, más brevemente, *aerarium*.

Puede celebrar negocios, de los cuales resultará acreedor y deudor el mismo *populus*, pero considerado no como un ente distinto, sino como la "colectividad de ciudadanos". Podrá igualmente ser instituido heredero en un testamento, y hasta ser nombrado tutor. Pero siendo el *populus* "todos los ciudadanos", no se da la característica esencial de la persona jurídica moderna, y según la cual el *populus* hubiera debido ser un ente distinto de los ciudadanos. Esto no se dio en Roma.

El *populus*, además, se rige siempre por el *ius publicum*, no por el *ius privatum*. Por ello, el *populus* no puede ser citado para comparecer ante el pretor, ni tampoco puede demandar por esta vía a sus deudores. Las cuestiones suscitadas entre el *populus* y un particular serán resueltas políticamente en un proceso en el cual el magistrado estará actuando a la vez como juez y como parte.

1. El *populus* es definido por Cicerón como *coetus multitudinis iuris consensu et utilitate communione sociatus* (unión asociada de la multitud por la comunión del *ius* y de la utilidad; de *re publ.* 1.15.39). Se hace referencia a que no se trata del mero agrupamiento de la multitud, sino que se trata siempre de la "comunidad organizada" que para su tiempo se reúne por el *ius* en los comicios. Ulpiano (D.50.17.160.1) habla de la "mayoría": "Lo que se refiere a todos, es lo que en forma pública hace la mayor parte".

2. Por no ser "persona jurídica" resulta totalmente desacertado concebir al *populus* como Estado. Ésta es una expresión absolutamente modernista. En la expresión *res publica* (forma normal de nombrar la organización del *populus*) se denota el "grado de concernimiento" de los ciudadanos en dicha *res publica*, es decir, la cosa que les compete. En cambio, en el Estado, los modernos ven a un ente distinto de los ciudadanos; un *obiectum* (lo que está ahí delante y se opone). De este pensamiento aparecerá la idea decimonónica de poder demandar al Estado, que es una persona jurídica. Esto, de esta forma, es inconcebible para el Derecho Romano.

3. La expresión de Ulpiano al definir al *ius publicum* como aquel que está referido al *status rei publicae* (D.1.1.1.2), no debe ser entendido como lo referido al "estado de la República", sino como la situación o posición de la *res publica*, del mismo modo como se emplea la expresión *status* en *status hominum* (situación o posición en que se hallan los hombres).

II. Fisco.

§ 190. En la época primera del Imperio, la figura del *princeps* goza de un determinado patrimonio denominado *fiscus Caesaris* o más simplemente *fiscus* (= "cesta de dinero"), producido fundamentalmente por el tributo que le es debido en las provincias a su cargo (*provinciae Caesaris*). En principio, este patrimonio debe ser distinguido del *aerarium*, que es el patrimonio del *populus*.

1. Se da acá la situación especial de que mientras el *aerarium* corresponde al patrimonio de una "colectividad", el fisco es patrimonio público de una sola persona, el *Princeps*.

Sobre el *fiscus*, el *Princeps* tiene potestad especial para administrarlo y disponer de él sin dar cuentas ni al *populus* ni al Senado. Luego de su muerte, no va a parar a sus herederos familiares, sino a su sucesor político, es decir, el nuevo emperador. Se rige, más por el *ius publicum* que por las reglas del derecho privado.

2. No hay que olvidar que el *Princeps* tiene también su propio patrimonio (*res familiares*), distinto

del fisco, y que se rige solamente por el *ius privatum*. A su muerte va a parar a sus herederos, ya por testamento o *ab intestato*.

3. Ya desde la época de Claudio comienza una lenta aproximación entre el *fiscus* y el *aerarium*, de tal modo que a fines del Principado el *aerarium* es absorbido por el fisco, el cual pasa a constituir el único patrimonio público (Ulp., D.43.2.2.4). Todas las cuestiones que se pudieran presentar promovidas por o contra el fisco son motivo de un procedimiento administrativo especial. Tampoco hay que olvidar que el fisco gozaba de una serie de privilegios que no son propios del derecho privado.

En la última época estas ideas se consolidan, de tal modo que el fisco (lo mismo que las *res familiares* del Emperador) son reguladas en parte por el derecho privado.

4. Conforme a este cuadro, no se puede decir que el fisco sea una persona jurídica. Ciertas expresiones que encontramos en los textos, como *debitores fisci* o *ius fisci*, las debemos entender como una terminología que resultaba cómoda para el tratamiento de los problemas que se suscitaban, pero no se puede pensar que por ello el fisco gozara de personalidad.

III. Municipia. Civitates.

§ 191. Semejantes al *populus Romanus*, existirán en el resto del Imperio los *municipia* (llamados también *civitates*). Cada uno de ellos será regido por un ordenamiento especial; a veces, por determinadas *leges datae* (así, la *lex municipalis Malacitana*, la *lex municipalis Salpensana*, etc.). En parte se regirán por el derecho público en cuanto a su vida política (magistrados locales, decuriones, etc.). Pero también por el derecho privado. Al igual que para el caso del *populus* (*ad exemplum Reipublicae*; Gayo, D.43.1.1.), podrán tener bienes comunes (*arca communis*), que estarán a cargo de un *actor* o *syndicus*. Durante la época clásica predominará el criterio de asemejarlas al *populus*, de tal modo que no se puede hablar de que eran "personas jurídicas". Solamente en los tiempos posclásicos los bizantinos, y principalmente bajo Justiniano, se las dotará de cierta personalidad.

1. La cuestión de la personalidad de los *municipia* en la época clásica, aparece complicada por las interpolaciones realizadas por los bizantinos. Pese a ello, se puede descubrir ciertos rastros que hacen pensar en la respuesta negativa para los juristas de esta época.

En el vocablo *municipium* (lo mismo que respecto de *civitas*) se puede ver un aspecto de "unidad jurídica" (*municipium*) y un aspecto de "colectividad" (la de los *municipes*, es decir, los habitantes municipa-

les). Los clásicos preferirán hablar precisamente de este último aspecto, tal como se ve por su gusto de hablar de los *municipes*, en lugar de *municipium* (o de *cives*, en lugar de *civitas*), por lo menos en cuanto a los aspectos privados (Ulp., D.3.4.2; D.3.4.7 pr.; D.4.3.15.1; D.10.4.7.3). De este modo, el aspecto de "colectividad" predominará sobre el de la "unidad".

2. Así, los bienes existentes en el *municipium* no pertenecen a éste, sino que son consideradas *res communes* (Gayo, 2.11; D.3.4.1.1). Eran, p.ej., los teatros, estadios y otras cosas (Inst., 2.1.6). A veces eran llamadas *res publicae*, lo cual es excesivo (*abusivus*, según Ulpiano, D.50.16.15); ya que esta última denominación es para las cosas del *populus*, mientras que acá son las de los *municipes* (Gayo, D.50.16.16). Son los magistrados los que adquieren dichos bienes, que serán de los *municipes*, por lo que no rige el principio clásico de que "no podemos adquirir por personas libres" (no sujetas a nuestra potestas; Gayo, 2.95).

Respecto de estas cosas, los *municipes* no pueden poseer nada por sí, ya que todos ellos no pueden consentir la posesión (Paulo, D.41.2.1.22). Tampoco pueden heredar, puesto que al no ser el *municipium* persona jurídica, la institución hereditaria recaería en un número indeterminado y variable de personas (*incertae personae*; Ulp., 22.5). En cambio, el *populus* puede ser heredero, por cuanto se rige por el *ius publicum*, y no por el derecho privado.

Por razones políticas, un s.c. mencionado por Ulpiano facultó al liberto de un *municipium*, poder instituir herederos a los *municipes* (Ulp., D.38.3.1 pr.). Y otro s.c. *Aproniano* (año 117 o 123 d.C.) permitió que se dejara a los *municipes* un fideicomiso universal (Paulo, D.36.1.26, it. al comienzo, donde se habla de *municipium*).

3. En cuanto a las obligaciones, figura el famoso paso de Ulpiano (D.3.4.7.1.), que está interpolado: "Si algo es debido a la *universitas*, no le es debido a los particulares, ni aquello que deba la *universitas* lo deben los particulares". Por la sucesión de los textos anteriores, debió haberse referido al *municipium* o a la *civitas* (*universitas municipium* o *civium*), de tal modo que originariamente debió haber dicho: "Si algo le es debido a la *universitas municipium* (entendida como la "colectividad" de los *municipes*), no le es debido a éstos en forma particular; ni si la *universitas municipium* debe, lo deben los *municipes* (en forma particular)". De lo que se trata es de que las obligaciones contraídas por los magistrados del *municipium* debe siempre responder o demandar la "colectividad", no las personas en forma particular.

Una prueba más que demuestra la carencia de personalidad de estos *municipia*, figura en las dos rúbricas del Edicto, que explican el sentido dado: "De aquellos a quienes es lícito accionar en nombre de los *municipes* (no del *municipium*); EP, § 31; y "Cuando se acciona contra los *municipes*" (no contra el *municipium*), EP, § 33.

4. Luego, en el derecho posclásico y justiniano,

a diferencia de lo que ocurría en el derecho clásico, se hace prevalecer el aspecto de la "unidad" del *municipium* sobre el de la "colectividad" de los *municipes*, es, admitirá hablar directamente del *municipium* y de la *civitas* (así como de los *collegia*, de los *corpora*, y en general de las *universitates*), como presuponiendo capacidad para adquirir bienes por sí. Por una constitución de León (C.6.24.12.-C.11.32.3) se admite la plena capacidad para adquirir bienes *mortis causa*.

Los bizantinos, de manera escrupulosa y esforzada —dejaron algunos restos anteriores—, hablarán de estos entes en términos que servirán de antecedente a la doctrina de la persona jurídica. Así, las dos rubricas del Edicto serán referidas en D.3.4 como: "De cuando se demande en nombre de una *universitas* o contra ella".

IV. Collegia.

§ 192. Ya desde tiempos muy antiguos (Gayo, D.47.22.4), los romanos admitieron la existencia de numerosas corporaciones, denominadas algunas veces *sodalitates*, y otras *collegia*, así como también —más tardíamente— *corpora* y *universitates*.

1. Así, en la época antigua figuraban los cuatro grandes colegios sacerdotales (*pontificum*, *augurum*, *VII virum epulorum*, *XV virum sacris faciendis*), así como otros muchos cuyo origen se atribuye al rey Numa Pompilio.

2. Otros estaban dedicados a fines profesionales, como la de los publicanos, que cobraban los *vectigalia* sobre los terrenos públicos, o la explotación de las minas de oro, plata, salinas, etc.

3. Y también existían asociaciones con fines de mutualidad, como los *collegia tenuiorum* (Marciano, D.47.22.1 pr.), que agrupaba a gente pobre, sobre todo para prestar un servicio funerario decoroso.

Permitidas ya desde la ley de las XII Tabas (8.27), todas estas asociaciones estarán más vinculadas con el *ius publicum*, y ésta es la razón por la cual los juristas clásicos prestaron poca atención a lo relacionado con ellas. Podían tener bienes comunes (*arca communis*) y las rubricas del Edicto referidas a la posibilidad de accionar o ser demandados, si bien referidas a los *municipia*, les fue también aplicable. Tal como lo dice Gayo (D.3.4.1.1), su régimen está establecido *ad exemplum Rei publicae*, con lo cual se está denotando la poca importancia que se les dio en el *ius privatum*, terminándose por darle las mismas reglas que hemos ya analizado respecto de los *municipia*.

Funcionando como apéndices del *populus*, en una labor subsidiaria, se las miró siempre con

desconfianza. Ya en la ley de las XII Tabas había libertad para crearlas, siempre que sus fines no fueran contrarios al *ius*: Gayo (D.3.4.1 pr.) nos dice que no se las permitía fácilmente "porque esto está restringido por leyes, senadoconsultos y constituciones de los Principes", habiéndoselas reconocido "en pocos casos".

Precisamente un ordenamiento especial le fue dado por una *lex Julia de collegiis* (de Julio César o de Augusto), la cual no nos ha llegado, como tampoco las otras disposiciones reglamentarias mencionadas por Gayo. Seguramente los datos que conservamos, se exigía un permiso del Senado para que se pudieran reunir en asambleas. El propósito principal era la preocupación política, puesto que estas asociaciones podían servir para encubrir actividades políticas y partidarias a veces consideradas peligrosas.

1. Se exigía, por lo menos, un número de tres asociados (*tres faciant collegium*; Neracio Prisco-Marciano, D.50.16.85), pero más tarde se determinó que si luego de la constitución del *collegium* quedaba un solo, la asociación continuaba subsistiendo (Ulp., D.3.4.7.2).

En cuanto a la vida interna, debía existir una reglamentación propia (*lex collegii*). Debían tener una caja común —*arca communis*—.

2. La política seguida por Roma fue en principio muy restrictiva. Así, se puede mencionar el caso del pedido de Plinio el Joven a su amigo Trajano, de conceder la autorización a un cuerpo de bomberos voluntarios de Nicomedia, donde había sucedido un serio incendio. Le fue denegada, dándose como razón que podía degenerar en un comité político. En cambio, se admitió la asociación de gente humilde (*collegia tenuiorum*), quizá porque no se veía en esa mutualidad ninguna fuente de preocupaciones políticas. Existieron *collegia* especiales de mujeres.

3. El *collegium* debe ser distinguido de la *societas*. Acá se ve claramente como el primero, dedicado a tareas *ad extra*, formaba más bien parte del *ius publicum*, mientras que la segunda era una asociación para el solo interés de los socios. Además, en el *collegium*, los asociados pueden ir y viniendo, saliendo o entrando; en cambio, en la sociedad, el apartamiento o muerte de uno de los socios, disolvía el contrato.

En cuanto al problema de la personalidad, se plantea un problema similar al de los *municipia*, cuyo régimen será aplicado finalmente por Justiniano a las *universitates* y *corpora*. Tampoco se alcanzó una construcción jurídica clara acerca de la personalidad jurídica.

1. El corto título "De los colegios y corporaciones" (D.47.22) sólo demuestra las prevenciones para su admisión. En cuanto al régimen jurídico: a) los bienes comunes terminan considerándose propios de la uni-

versitas, y no de sus miembros (Marciano, D.1.8.6.1 itp.; Gayo, D.3.4.1.2, parece más bien referir el estado comunitario, como condominio de los socios, propio de la época clásica); b) los créditos y las deudas corresponden a la *universitas*, y no a los miembros (Ulp., D.3.4.7.1 itp.), a diferencia de la mera sociedad, en la cual hay que demandar a todos los socios; c) el representante de la *universitas* actúa más en nombre de ésta que de sus integrantes (Ulp., D.3.4.2). Vemos, pues, los mismos problemas que respecto de los *municipia*. El título "De cuando se demande en nombre de una *universitas* o contra ella", se refiere tanto al caso de la *universitas*, como del *municipium*. El predominio en Justiniano del aspecto "unidad" sobre el de "colectividad", que se dio en los *municipia*, se dará también en estas *universitates*.

V. Fundaciones.

§ 193. En el derecho actual, una fundación es un capital o un patrimonio destinado a cierto fin, generalmente a perpetuidad o por una duración indeterminada. Lo importante es que se la considera como "persona jurídica", es decir, como dotando al patrimonio afectado de una personalidad independiente. Así, p.ej., donar un capital o realizar un fideicomiso, pero de tal modo que quede exclusivamente afectado a la construcción de un hospital o de un asilo.

En Roma existieron casos análogos, aunque se dieron soluciones distintas de la moderna de la persona jurídica.

1. En la época clásica se solía afectar terrenos alejados a un sepulcro, de cuyo cultivo surgían fondos que debían quedar afectados al cuidado de la sepultura. O dedicar un capital para la distribución de alimentos, o la atención de los pobres, o la cura de enfermos, etc.

2. Jurídicamente se recurría al procedimiento de imponer al donatario o legatario o fideicomisario la obligación de cumplir con el fin fiduciario a que estaba destinado el capital y su rendimiento. Se trata, pues, no de un caso de personería jurídica, sino de la aceptación por parte de alguien de cumplimentar la idea del fundador (fundación fiduciaria). Si no se cumplía, podía estar prevista una estipulación penal, o en su caso el reemplazo del fiduciario.

3. Este tipo de fundaciones tendrá especial desarrollo en la Roma cristiana, ya que muchas personas se desprendían de sus bienes para afectarlos a obras de caridad (*piae causae*). El camino seguido era entregar el patrimonio a la Iglesia de tal modo que sus autoridades asumían la obligación de administrar el capital afectándolo a los fines indicados. No se podía decir que perteneciera a la Iglesia, ni tampoco que fuera una entidad separada e independiente, es decir, una persona jurídica, como se dice en los tiempos modernos.

4. Justiniano permitirá otorgar legados a "personas inciertas", tales como los cautivos, o los pobres (en caso de duda al hospicio más pobre que exista, a juicio del prelado de la ciudad), encargando la administración al Obispo y el ecónomo del lugar, autorizándolos para cobrar los créditos y pagar las deudas (C.1.3.49(46).1-5).

PARTe TERCERA
DERECHO DE LAS COSAS

CAPÍTULO 1 LAS COSAS

§ 194. *Concepto de cosa.* La palabra *res* (cosa; o cosas —es igual en plural—) sirve, ante todo, para designar los entes materiales (una mesa, una casa), así como los naturales, sean animados (un esclavo, un buey) como los inanimados (el oro, la plata)

1. En latín, *res* excede el mero concepto vulgar de cosa y sirve para designar todo aquello que de algún modo concierne al hombre. Así se explica la denominación genérica de *res secundae* (todo aquello que acaece según nuestras expectativas, los asuntos favorables) y de *res adversae* (todo lo desfavorable, lo que debemos superar). Por ello, *res* designa también los negocios o los asuntos que interesan al hombre. Así, lo relacionado con la agricultura son *res rusticae*; con el ejército, *res militares* o *castrenses*; con los buques y la navegación, *res nauticae*; con la historia, *res gestae* (hechos realizados).

2. En cuanto al *ius*, se considerará en principio un sentido más restringido, tal como lo expresamos al comienzo. Sin embargo, Gayo, que divide el *ius* en tres partes: el de las personas, el de las cosas y el de las acciones, tratará del primero en el libro I. Y luego, en los libros II y III, tratará no sólo de las cosas, sino también de las herencias, de las obligaciones tanto las nacidas de los negocios, como de los delitos. Si bien él abarca estos temas para saber cómo se obtienen las cosas, guarda relación con ese sentido amplio de *res*:

3. En las lenguas romances, "cosa" nace de *causa*. Si bien en principio tiene su sentido filosófico, prontamente se aplicará en el lenguaje judicial romano para designar "el procedimiento que se debate ante la justicia". El litigio (la *lis*) es la "causa que motiva el asunto", así, Cicerón, *pro Cluentio*, 139, *quae ex re ipsa causaque dicuntur* (lo que sugieren por sí el asunto y la causa que lo motiva). Esta aproximación conduce a que la "causa" es el "caso". De aquí que tiene el mismo sentido de *res*; por ello se habla de *res iudiciaria* (en el sentido de lo que sería la *res litigiosa*). De allí se formará la palabra "cosa" (en italiano, en portugués; en francés *chose*; un sentido análogo tendrá en alemán *Ding* y en inglés *thing*). La identificación de la "causa" con el "proceso" es usual en la jerga forense actual.

4. Se puede establecer una distancia entre *res* = "lo que concierne al hombre" y *objectum* = "lo que

está ahí delante (*iectum* = yecto) y se opone al hombre (ob). Que las cosas fueran vividas por el romano como *res*, y no como *objecta*, es algo esencial para comprender su espíritu, vivenciado en la *humanitas*. Así, como ya lo dijimos, cuando en sentido político se habla de *res publica* (lo que concierne a todos los ciudadanos), esta expresión no se compadece con el concepto, ya modernista y no romano, de Estado (concebido como *objectum*, con la tensión entre el poder estatal y la libertad de los ciudadanos).

§ 195. *Res corporales et incorporeales.* Gayo (2 12-14) incorporará la clasificación, proveniente de la retórica y de la filosofía, de *res corporales* y *res incorporeales*. Las primeras son las materiales, las que se pueden tocar (*quae tangi possunt*), como, p.ej., un fundo, un esclavo, un vestido, el oro y la plata. En cambio, las segundas son las inmateriales, que no se pueden tocar (*quae tangi non possunt*). Son las que se inteligen y consisten en algo jurídico (*quae in iure consistunt*), como, p.ej., la herencia, el usufructo, el uso, las obligaciones, las servidumbres... Hoy día se las conoce como "derechos".

1. Cicerón (*Top.*, 5.26 ss.) habla de las cosas que realmente son (*quae sunt*), diferenciándolas de las "inteligidas". La expresión no es muy feliz, por cuanto ambas "son", las primeras materiales; las segundas, inmateriales.

También Séneca (*Epist.*, 58.6.11) distingue entre *corporalia* e *incorporalia*: *quod et nec visu, nec tactu, nec nullo sensu comprehenditur: cogitabile est* (id. 16 = aquello que no es visto, ni cae bajo el tacto, ni es aprehendido por ningún sentido: es lo pensable). Ver también Diog. Laert., 7.140-141; Quintiliano, *Insts.* 5.10.116.

A pesar de que algunos ven sólo una clasificación teórica, se desprenden algunas consecuencias jurídicas prácticas. Así, la *possessio** se aplica sólo a las *res corporales*. Sólo más tarde y a propósito de ciertas situaciones especiales de *res incorporeales*, se podrá hablar de *quasi possessio**. También la *traditio** y la *usucapio** sólo se emplean, en principio respecto de las *res corporales*; en cambio, la *usucapio hereditaria**, rigó respecto de la *hereditas*, que es una cosa incorporal, distinguiéndosela de las cosas individuales de la herencia.

§ 196. *Patrimonio*: El conjunto de cosas que pertenecen a una persona, capaz de tenerlas, constituye su patrimonio. Este está conformado no sólo por las *res corporales*, sino también por las *res incorporeales*.

El derecho moderno mantiene como punto relevante su concepción del patrimonio como una "universalidad de derecho" (*universitas iuris*), comprendiendo el conjunto de los derechos subjetivos (reales y creditivos, ambos llamados precisamente "patrimoniales"), así como, también las deudas. Igualmente, para el derecho moderno, el patrimonio es considerado como un "atributo de la personalidad", de tal modo que toda persona tiene un patrimonio, aunque su pasivo sea mayor que el activo, y no hay patrimonio que no tenga un titular.

En Roma la idea de patrimonio no está concebido como un "atributo de la personalidad". Sólo los *sui iuris* (también las mujeres que están en esa situación) pueden poseer un patrimonio. En cambio, los *alieni iuris* no lo tienen. Se ve, pues, que hay personas que siendo tales carecen de patrimonio, aunque puedan tener (los *filiifamiliae* y los esclavos) un *peculio** (*peculium*), lo cual es algo distinto.

1. La palabra *patrimonium* (que a veces se confunde con *bona*) tiene en Roma, a veces un significado jurídico, a veces un significado económico. En su significación jurídica abarca tanto el activo como el pasivo. Su denominación proviene de lo recibido por herencia del *pater*. En la *hereditas*, lo que se transmite por el causante no son sólo los bienes, sino también las deudas. Lo mismo ocurre con la *bonorum possessio** (posesión hereditaria de los bienes —*bona*—), ya que quien la pide se hace cargo del activo y del pasivo. Lo mismo ocurre en la *venditio bonorum**, cuyo adquirente no sólo se apropia de los bienes del deudor insolvente, sino que además se hace cargo de las deudas.

2. En cambio, otras veces la palabra *bona* (bienes) es computada como una expresión económica. Así, Paulo (D.50.16.39.1) nos dice que "por *bona* se entienden los bienes que quedan una vez deducido el dinero ajeno —es decir, las deudas—"; id., Javoleno, D.49.14.11. Aquí, el significado es meramente económico, tal como hoy día, cuando hacemos una "declaración de bienes", y deducimos las deudas.

En los casos especiales de la *adrogatio** y de la *conventio in manu**, no podemos ver una aplicación de esto, a pesar de que el que se ha dado en *adrogatio* o la mujer *sui iuris* que ha celebrado la *manus*, lo único que hace ingresar en el patrimonio del adrogante o del marido (en su caso su *pater*) que adquiere la *manus*, es el activo, y no las deudas. Pero esto no hace al sentido jurídico de patrimonio, puesto que si es así, es porque las deudas se extinguen por *capitis deminutio**, si bien el pre-

tor protege a los acreedores por medio de *actiones ficticiae**.

3. También se emplea la palabra *pecunia*. Esta deriva de *pecus* = cabeza de ganado, y en la época primitiva servía para designar el patrimonio mobiliario. Así como también *familia* (así se denomina a la *hereditas*, y en una acepción especial, sirve para designar el conjunto de esclavos que pertenecen a una familia). En los tiempos clásicos, *pecunia* sirve propiamente para designar el dinero (*pecunia numerata* = dinero amonedado). Y en general, en un sentido muy amplio, para denominar no sólo el dinero, sino todas las cosas "que hay en el patrimonio" (Ulp., D.50.16.5 pr.; Herrenogeniano, D.50.16.222).

§ 197. *Clasificación general de las cosas*. Gayo (2.1) y también Justiniano (Inst., 2.1) habían de una primera gran clasificación de las cosas, distinguiendo entre aquellas que están in *nostro patrimonium* y las que están *extra nostrum patrimonium*. La idea es deslindar las cosas que pertenecen, o pueden pertenecer al patrimonio de una persona, de aquellas que, por determinadas razones, nunca pueden integrar un patrimonio.

Pero generalmente se prefiere clasificarlas, según un criterio muy parecido, que hace referencia a las cosas mismas, en *res in commercio* y *res extra commercium*. Estar en una u otra clase depende de la capacidad de cada cosa de poder ser admitida como objeto de actos o negocios jurídicos. Este criterio no figura explícitamente en las fuentes, si bien en forma aislada se habla de algunas cosas diciendo de ellas que no están en el *commercium* (tráfico jurídico patrimonial; Inst., 2.20.1.4; Pomponio, D.18.1.6 pr.; D.18.1.34.1).

1. Este último criterio permite ubicar mejor ciertas cosas como las *res nullius* (cosas de nadie; así, un animal salvaje que puede ser cazado). De hecho no está in *nostro patrimonium*, si bien puede estarlo. En cambio, no cabe duda de que es una *res in commercio*. Lo mismo ocurre con las *res derelictae*, es decir, las abandonadas por su dueño y de las cuales se puede apropiarse el que les interese.

2. También pueden existir cosas que temporáneamente están sin propietario actual. Son las *res (in commercio) sine domino*. Así, el caso de la *hereditas yacens** (herencia yacente), el *statuliber**, los *servi poenae**, etc.

§ 198. I. *Res extra commercium*. La regla es que las cosas estén in *commercium*. Veamos por ello primero las que constituyen la excepción, es decir, las que no pueden ser objeto de actos o negocios jurídicos patrimoniales (*res quarum commercium non est*).

Las cosas que están fuera del comercio son

tales por "derecho divino" (*res divini iuris*); así las *res sacrae*, las *res religiosas* y las *res sanctae*. O por "derecho humano" (*res humani iuris*), como lo son las *res communes*, las *res publicae* y las *res universitatis*.

§ 199. Ante todo, están las *res divini iuris* (cosas del *ius divinum*). En primer lugar figuran:

A) las *res sacrae*. Son las cosas consagradas a los dioses superiores (Gayo, 2.4; Inst., 2.1.8); así, los templos, terrenos, edificios, altares y cosas culturales dedicados a las divinidades. Para que se tenga por sacro un lugar debe mediar:

a) la intervención autorizante del *populus*, cristalizada en una *lex*, o en un *s.c.* o una constitución imperial (Gayo, 2.5, Inst., 2.1.8);

b) una ceremonia religiosa (*dedicatio* o *consecratio*) en la cual tomaban parte los Pontífices (Cicer., *de domo sua*, 177 ss.), como también magistrados especiales (*duoviri aedi dedicandae*). En la época imperial intervenía el César, en su carácter de *Pontifex Maximus*, o un delegado suyo (Ulp., D.1.9.9.1).

1. En todos los casos se pronunciaba la fórmula sacramental (*lex dedicationis*), la cual contenía las indicaciones del terreno, límites, etc. (ver Bruns, *Fontes*, I p. 263). Lo que se consagraba era el suelo (*locus*), el edificio (*aedes, templum*) y los utensilios rituales (aras, vasos, etc.). Pero si se derruía el *aedes*, no por ello deja de ser sacro el lugar (Papin., Inst., 2.18; Marciano, D.1.5.6.3).

2. Para que una *res* deje de ser *sacra* es necesario una ceremonia inversa (*exaugurio* o *profanatio*), la cual tiene efectos permanentes: la cosa se convertía definitivamente en profana. Pero si llegaba a caer en poder del enemigo, cesaba provisoriamente de ser sagrada, ya que por efecto del ejercicio del *postliminium*, si se recuperaba por los romanos, retornaba al estado primitivo (Pomp., D.11.7.36).

En cuanto a los efectos, la calificación de sacra la tornaba *extra commercium* (Marciano, D.1.5.6.2; Ulp., D.1.8.9.5. "La cosa sagrada no admite estimación (pecuniaria)". La violación de una *res sacra* podía importarle al sacrilego fuera declarado *sacer*, pudiéndose matar impunemente sin que ello fuera crimen. La *lex Julia peculatus* matizó las penas, que podían variar "de acuerdo con la condición, el tiempo, la edad y el sexo" (Ulp., D.48.13.6 pr.). Iban desde la *uqae* et *ignis interdictio* (Ulp., id.3), hasta la pena capital (Paulo, D.48.13.9 pr.). Para proteger las *res sacrae*, el pretor concedió un interdicto prohibitorio (Ulp., D.43.6.1; EP, § 235: "Vado que se haga o se introduzca cosa alguna en lugar sagrado").

Con el advenimiento del Cristianismo, al abandonarse los ritos antiguos, la calificación "pasa" a los edificios y cosas aplicadas a la Iglesia (Inst., 2.1.8). Como novedad jurídica importante, se permitirá la venta de algunas cosas muebles, p.ej., los vasos sa-

grados, por causas muy especiales, tales como redimir esclavos (C.1.2.21: "porque no es absurdo que sean preferidas las almas de los hombres a cualesquiera vasos u ornamentos"), o para pagar las deudas de una iglesia (Nov. 120.10).

B) También entre las cosas que están fuera del *commercium*, por ser *res divini iuris*, están las *res religiosas*. Son los sepulcros, englobando tanto el lugar como las construcciones y demás enseres de las sepulturas (Gayo, 2.6; Inst., 2.1.9).

1. Es interesante señalar que para Gayo (2.4), mientras las *res sacrae* son "consagradas" (*consacratae sunt*), las *res religiosas* son aquellas "dejadas" (*relictae sunt*) a los dioses Manes (*Dii Manes*), es decir, los antepasados familiares, a los cuales se debían los *sacra privata*. En la época cristiana, obviamente no rige este culto familiar pagano, pero el respeto a los muertos (tema de la resurrección de la carne) mantendrá esta calificación de cosas religiosas referidas a las sepulturas (Inst., 2.1.9).

Son requisitos para que una cosa sea religiosa:

a) La inhumación efectiva de un cadáver, o el resguardo de sus cenizas. Por ello, un cenotafio, es decir, un mero monumento funerario, sin contener el cuerpo o sus cenizas, no es *res religiosa* (D.1.8.6.5). Si las partes del cadáver hubiesen sido enterradas en partes distintas, sólo se considera sepulcro el lugar donde estuvieran las partes principales; p.ej.: la cabeza (Paulo, D.11.7.44). El sepulcro donde está enterrado un esclavo es *res religiosa* (Aristón-Ulp., D.11.7.2).

b) Que el entierro lo realice aquel a quien le corresponda rendir las honras fúnebres, en terreno propio. Si el lugar es ajeno, se debía contar con el permiso del dueño (Marciano, D.1.8.6.4).

1. Si hay condominio, para enterrar el condómio debe contar con la autorización del otro u otros condóminos; si existe usufructo, el usufructuario necesitará el permiso del nudo propietario, y si fuera éste el enterrador, el del usufructuario (Inst., 2.1.9; Ulp., D.11.7.2.7).

El motivo es obvio: al enterrar un cadáver, el sitio se hace religioso, perdiéndose la parcela ocupada por el sepulcro, por ser *res extra commercium*. Por ello, quien enterraba en terreno ajeno sin autorización del dueño, podía ser obligado por una *actio in factum*, o a retirar el cadáver o a pagar el precio del lugar ocupado (Gayo, D.11.7.7 pr.).

2. En el caso del suelo provincial, nos indica Gayo (2.7) que la mayoría opinaba que allí el sepulcro no puede convertirse al lugar en religioso. En efecto, el suelo provincial era, en la época del Principado,

ya del César o del Senado, por lo que los habitantes sólo tenían la posesión o el usufructo; sin embargo, dice el mismo Gayo que, aun cuando no sea religioso, es tenido por tal (*pro religioso habetur*). Lo mismo ocurre con las cosas consagradas en terreno provincial (*pro sacrae*; Gayo, 2.3). Al modificarse la propiedad, en la época posclásica, obviamente este problema desaparece.

3. Gayo (D.11.7.5) distingue entre los *sepulchra familiaria* (los constituidos para sí y para su familia) y los *sepulchra hereditaria* (de aparición más tardía; son los constituidos para sí y para sus herederos). Al principio todos eran *familiaria*, para reservarlos para los familiares. De ahí que llevaban la fórmula epigráfica H.M.H.N.S = *Hoc monumentum heredem non sequitur* (este monumento no le corresponde al heredero). Luego se irá implantando la costumbre de ampliarla a los herederos que no sean familiares.

En cuanto a sus efectos, el sepulcro por ser *res extra commercium* no es susceptible de dominio (Ulp., D.8.5.1). Sin embargo, quien lo había constituido tenía un particularísimo *ius sepulchri*.

Por él se permitía el paso por el terreno vecino para visitar el sepulcro (*iter ad sepulchrum*), defendido por un interdicto (Gayo, D.11.7.1 pr.; Ulp., D.id. 8.1.3); la utilización del sepulcro (Ulp., D.11.7.6); la edificación de un monumento (Ulp., D.11.8.15); el poder repararlo (Ulp., D.id. 5 pr.); e incluso la posibilidad de conceder a un tercero la permisión de ser inhumado en él (*ius sepeliendi*), o la de enterrar un muerto (*ius mortuum inferendi*; Ulp., D.11.8.1 pr. y ss.).

1. Este *ius sepulchri* no significaba una excepción al principio de que el *sepulchrum* está fuera del *commercium*. Lo que otorga es una serie de permisiones, pero no el *sepulchrum* en sí, lo que estaba prohibido (Ulp., D.11.7.12.1). En cambio, el *ius sepulchri* es comerciable y se transmite a los herederos, aun a los indignos (Ulp., D.11.7.33), pero no es patrimonial. Así, en el caso de la herencia, queda vinculado a la persona del heredero, quien no lo pierde ni aun en el caso de que tenga que restituir la herencia (Ulp., D.11.7.33).

Quien violaba un sepulcro podía ser perseguido por la *actio sepulchri violati* (D.47.12; C.9.19; EP, § 93), que era una *actio in factum*, de carácter popular y que arrastraba la infamia.

C) Finalmente están las *res sanctae* (de *sancio* = sanción), que se llaman así porque los atentados contra ellas se castigan con una *sancio*. Se las considera protegidas "de la injuria de los hombres" (Marciano, D.1.8.8 pr.). Son, p.ej.: los muros y las puertas de las ciudades. Gayo (2.8) las considera "en cierto modo de derecho divino", aunque no estén consagradas a los di-

ses" (cfr. Ulp., D.1.8.9.3). Justiniano directamente las involucra entre las *res divini iuris*, haciendo la tripartición de *res sacrae*, *res religiosas* y *res sanctae* (Inst., 2.1.7).

1. La *sancio* que protege a los muros (y puertas) es la pena capital (Inst., 2.1.10; Pomp., D.1.8.11). Se recuerda el caso de Rómulo, que mató a su hermano Remo por haber violado el surco donde estaba delimitado el término de la recién fundada Roma (Tit.Liv., 1.7), y una ley atribuida a Numa Pompilio, según la cual, quien con sus bueyes pasare los términos del fundo vecino, violándolos, debía morir juntamente con las bestias, sancionándolo como *caper* (Dion.Halic., 2.74).

2. Por otra parte, las leyes que prevén penas contra sus violadores —es decir, contienen una *sancio*—, son por ello denominadas *sanctae* (Inst., 2.1.10; Ulp., D.1.8.9.3).

§ 200. Pero aparte de las *res divini iuris*, hay además otras cosas que están fuera del *commercium*, es decir, excluidas de la apropiación privada por alguna razón del *ius humani iuris*, ya porque pertenecen a todos los hombres en general (*res communes*); o al *populus* (*res publicae*) o a una *civitas* o a una corporación (*res universitatis*).

A) *Res communes*. Son aquellas cosas que por el *ius naturale* son comunes a todos los hombres: el aire, el agua corriente, el mar y sus costas (Inst., 2.1.1).

1. El agregado de estas *res communes omnium* puede ser de origen posclásico. Ni Gayo ni Ulpiano (D.43.1.1 pr.) las mencionan; aunque sí Marciano (D.1.8.2). Hay una especie de concordancia, muy del gusto de los estoicos, para quienes existe una *res publica* de todo el género humano; otra, más propia de cada nación; y finalmente, otra más reducida formada por los *municipia* o *civitates*, o *universitates*.

2. El mar, en sí mismo, fue siempre considerado por los romanos como cosa común (cfr. Plauto, *Rud.*, 4.3.36; Cic., *pro Rosc.*, 26; Séneca, *de benef.*, 4.28; Ovidio, *Metam.*, 6.349). De ello resulta que la navegación es libre, lo mismo que la pesca.

3. En cuanto a las costas del mar (*littora maris*) se consideran tales hasta donde se extienden las aguas en las mareas más altas, es decir, las de invierno (Inst., 2.1.3). Curiosamente, Celso (D.43.3.3 pr.) establece que las costas marítimas sobre las cuales Roma ejercía *imperium* hay que considerarlas *res publicae*. Pero en Inst., 2.1.1 y 5, se afirma que "la propiedad de dichas costas (las del mar) no es de nadie, sino del mismo de quien es el mar, y la tierra o arena que está debajo".

De todos modos, el uso de dichas costas es público y de las *res gentium*. Es lícito acercarse a las costas del mar, pescar desde ellas, y también elevar una

construcción (p.ej., una choza) para habitarla, secar las redes y sacarlas del mar (Inst., *ibid.*). Pomponio (D.41.1.50) establece que para hacer una construcción había que pedir autorización al pretor. El uso de tales bienes, lo mismo que el uso genérico de las costas marítimas, está protegido por la *actio iniuriarum*, respecto de aquel que impidiera tales usos (Ulp., D.43.8.2.9).

B) *Res publicae*. Son aquellas cosas que son del *populus Romanus* (Ulp., D.50.16.15; Gayo, 2.11 = D.1.8.1 pr.; Inst., 2.16), siendo su uso público para los particulares, como las calles (*viae publicae*; Ulp., D.43.8.2.22), plazas, foros, teatros, puentes, ríos perennes (*flumina perennia*), etc.

1. Estas *res publicae* están destinadas al uso público, el cual está protegido por la *actio iniuriarum* y por interdictos (D.43.7.15). Pomponio, apoyándose en Celso (D.18.1.6 pr.), distingue entre las "cosas que se tienen en uso público" (*res publico usu habentur*) y las que están en el patrimonio del *populus* (*in pecunia populi*), careciendo de uso público —p.ej., los esclavos públicos, campos, etc.—, las cuales pueden entrar en el tráfico jurídico, pudiendo adquirirlas los particulares por venta del *populus*.

2. Los *flumina perennia* son aquellos ríos de caudal perenne. Se oponen a los torrentes (torrentes), que se secan en verano (Ulp., D.43.12.1.1-3); estos últimos son del dominio de los particulares.

Lo que es *res publica* es el "río" en sí, considerado como una unidad. Pero sus elementos constitutivos, por separado, son de naturaleza distinta: el agua corriente (*acqua profluens*) es una *res communis*; las riberas son de propiedad de los ribereños, si bien los particulares las pueden recorrer, pescar, etc.; en cuanto al lecho (*alveus*), mientras esté ocupado por el agua, carece de interés, pero si el río se secaa, o cambiara su curso, el lecho queda al descubierto, y por ser una extensión de las riberas correspondería a los propietarios ribereños (caso del *alveus derelictus*).

3. En cuanto a la posibilidad del aprovechamiento del agua para regadíos, el tema es muy confuso en Roma. Acá interviene el principio de la permisibilidad de los ribereños, siempre y cuando no se perjudique a los demás. En la práctica, debieron mediar acuerdos privados y hasta concesiones públicas.

C) *Res universitatis*. Son las propias de los habitantes de un *municipium* o *civitas*; así, el campo municipal, los teatros o estadios, etc. (Inst., 2.1.6); se las considera como que son de toda la comunidad de los *municipes* o *cives*.

§ 201. II. *Res in commercio*. Fuera del caso de las ya examinadas *res extra commercium*, el resto de todas las cosas son *res privatae*.

La clasificación más antigua es la que dis-

tingue entre las *res Mancipi* y las *res nec Mancipi* (Gayo, 2.14a-17; Ulp., 19.1). En general, las primeras son las cosas más valiosas para la mentalidad primitiva romana, que es rústicamente agrícola y rural. Gayo (1.192) se refiere a las *res Mancipi* como las "más preciosas" (*res pretiosiores*).

Ulpiano (19.1; Gayo, 2.14a) nos ofrece una lista de las *res Mancipi*: a) los fundos y las construcciones itálicas (las ubicadas en Italia y que gozan del *ius Italicum*); b) las servidumbres rústicas (las de "paso" —*iter**, *actus**, *vía**—) y la de *aguae ductus**; los esclavos; los animales "que se suelen domar por el cuello o por el lomo", es decir, los bueyes, los caballos, las mulas y los asnos.

1. Esta clasificación, netamente romana, es muy antigua. La propia denominación así lo denota. *Mancipi* es un genitivo arcaico de *mancipium* (quedó con la terminación en una sola "i", y no como sería en la época posterior: *mancipii*, tal como se ve en *causa Mancipii*, o en *lex Mancipii*). También el *nec* es una negación antigua (más actualizada hubiera debido ser *non*).

2. Los fundos provinciales son *nec Mancipi* (Gayo, 2.14a). Igualmente, los que componen el ganado menor (ovejas, cabras, etc.). Tampoco son *res Mancipi* las bestias feroces (osos, leones), ni los elefantes y los camellos, que aun pudiéndose domar por el cuello y por el lomo, eran desconocidos por los primitivos romanos (Gayo, 2.16).

3. Sobre el sentido de esta clasificación se ha discutido. Por un lado aparecen como las cosas más preciosas en una economía agrícola-ganadera (así Bonfante). Así, el *fundus* y los *instrumenta fundi* (esclavos, animales como bueyes, caballos, etc.) y las servidumbres rústicas (se excluyen las servidumbres urbanas). Igualmente, el dinero —típico bien de una sociedad comercialista— es *res nec Mancipi*.

Por el otro (De Visscher), se ha sostenido que la división no se hacía a partir del criterio económico-rural, sino a partir de la noción jurídica del *mancipium*, como representativo de la *potestas* que ejercía el *paterfamilias*. Por ello, lo adquirido por la *mancipatio* hace nacer el *mancipium*, y de ahí la denominación de *res Mancipi*. Quizá ambos aspectos de las dos posiciones —y esto sin caer en un eclecticismo— no parecerían excluirse (Arangio-Ruiz).

También se quiere (A. d'Ors) ver una aproximación entre *familia* (entendida como *hereditas*) como designando las *res Mancipi* (es decir, "la riqueza permanente") y *pecunia* las *res nec Mancipi* (los bienes de "ganancia").

El efecto principal es que mientras el dominio de las *res nec Mancipi* se adquiere por la simple *traditio**, para poder tener el *dominium ex iure Quiritium* de una *res Mancipi*, es nece-

sario el empleo de un rito especial, la *mancipatio**, de donde toma su nombre. Ambas clases de cosas eran susceptibles de ser adquiridas por medio de la *in iure cessio**.

De gran importancia en el derecho antiguo, y también en el clásico, fue poco a poco perdiendo vigencia: Justiniano suprimió esta clasificación (C.7.31.1); incluso, se borrará toda referencia a esta división; los bizantinos interpolarán todos los textos clásicos donde figuraba *mancipatio*, reemplazándola por *traditio*.

4. Para ver su vigencia en la época clásica, Gayo la toma en sus Institutas como algo que se aplicaba. Incluso, habla de una controversia en las Escuelas sobre los animales que deben ser domados. Para los sabinianos, los animales *mancipi* lo eran desde el nacimiento. En cambio, para los proculeyanos, sólo desde que habían sido domados (Gayo, 2.15).

Otras clasificaciones de las *res in commercio*.

§ 202. *Cosas inmuebles y muebles*. Las cosas inmuebles (fundos) son las que no pueden ser trasladadas de un lugar a otro. En cambio, las cosas muebles son las trasladables; entre ellas hay que distinguir los seres vivos que se mueven por sí solos (semovientes; p.ej., un esclavo, un animal).

1. En la época antigua y clásica, esta división resulta secundaria. Tiene importancia en temas como la *usuceptio**; para la ley de las XII Ts. el plazo para *usufructu* las *res fundi* era de dos años, mientras que para las otras cosas (*ceteras res*), sólo de un año; igualmente, el *furtum** sólo puede ocurrir respecto de una cosa mueble, no respecto de un inmueble; para los interdictos posesorios, está el *uti possidetis** que protege al poseedor de inmuebles, mientras que el *utrubi** lo es para el de una cosa mueble, etc.

2. Los suelos y terrenos son denominados "fundos" (*fundi*). Había que distinguir entre los "fundos itálicos" (de Italia, gozando, a partir de Augusto del *ius italicum*) y los "fundos provinciales", sometidos al gobierno del César o del Senado (quienes los poseen no son propiamente propietarios; son llamados *poseedores*, o *fructuarii*).

También hay "fundos urbanos" (los de la ciudad) y "fundos rústicos" (los del campo); esto está vinculado, aunque no decisivamente, con las "servidumbres rústicas y urbanas"; dentro de los campos se diferencian los *agri arcifini* (cuyos límites son los naturales; así, hasta un río) de los *agri limitati* (cuyos límites han sido fijados por los agrimensores). Esto tendrá importancia en el tema de la "acción" de inmuebles.

3. Precisando la terminología, aparte de la expresión genérica de *fundi*, están las de "predio" (*praedium*) para designar un espacio esté o no edificado; la de "lugar" (*locus*) para señalar una parte del predio; en los fundos rústicos, la parte edificada es llamada *villa* y *ager* la no edificada. En los fundos urbanos, la casa recibe el nombre de *aedes* y la parte sin edificar es llamada *area*. Los edificios de una o más pisos son llamados *insulae* (islas), por no tener apoyo en otros edificios.

4. En la época posclásica, tendrá mayor importancia esta división, sobre todo respecto a la compra-venta de inmuebles, que requerirá ciertos requisitos nuevos (v. *infra* §§ 238,4,3; 413,4).

§ 203. *Cosas simples y compuestas*. Una cosa simple es aquella que consiste en algo unitario (p.ej., un esclavo, una mesa). Una cosa compuesta es aquella que consiste en el agrupamiento de cosas simples componentes de una unidad (p.ej., un edificio, un buque). A su vez, una "universalidad de cosas" (*universitas rerum*), es el agrupamiento de cosas, que consideradas individualmente son simples, pero consideradas en su conjunto, asumen el rol de una unidad, a pesar de no estar conectadas materialmente entre sí (p.ej., una biblioteca, un rebaño y también una herencia).

1. Esta distinción está en un texto de Pomponio (D.41.3.30 pr.) y es de origen filosófico estoico (Séneca, Ep. 102.6). Habla de tres clases de *corpora*: a) el que está contenido en un solo espíritu (*quod continetur uno spiritu*), como el esclavo, el madero, la piedra; b) otro, que consta de componentes (*quod ex contingentibus*), como un edificio, una nave, etc.; y c) el que consta de partes distantes (*quae ex distantibus*), que son llamadas por un solo nombre, como un pueblo, una legión o un rebaño.

2. Si se trata de una cosa compuesta, en la cual se cambian las partes, no se hace otra cosa, sino que continúa siendo la misma (Alfeno, D.5.1.76, caso de la nave reparada). También, el que posee un edificio, lo posee independientemente de las partes componentes (así, los materiales; Paulo, D.41.2.30 pr.). Por ello, si dichos materiales fueran ajenos y luego se desagregan del edificio, el propietario de ellos puede reivindicarlos (Paulo, D.6.1.23.7; Labeo-Pomponio, D.41.3.30.1; Gayo, D.41.1.7.11).

3. En el caso del rebaño, éste no es susceptible de posesión ni *usufructu* unitarias, sino que se posee y se *usufructu* cada animal en forma particular (Pomp., D.41.3.30.2). Pero se admite que se pueda vender todo un rebaño por un precio único (Gayo, D.18.13.5.5). Respecto de la *rei vindicatio*, se la permite respecto de todo el rebaño (Gayo, 4.17; Ulp., Pomp., D.6.1.1.3), sin perjuicio de que si animales propios están mezclados con los ajenos, el propietario de aquéllos los pueda reivindicar (Paulo, D.6.1.2). Quizá, estas últi-

mas reglas hayan sido de origen bizantino, ya que antes de Justiniano el rebaño sólo es una unidad desde el punto de vista económico.

4. Los glosadores, y luego el derecho moderno, denominaron a las "universalidades" como "de hecho" (*universitas facti*) y "de derecho" (*universitas iuris*). Esta última categoría no es romana. Pese a ello, la *hereditas*, lo mismo que el *peculio* y la *dote*, son consideradas una unidad.

§ 204. *Cosas fungibles y no fungibles*. Las cosas fungibles son aquellas que se consideran, no por su especificidad, sino por pertenecer a determinado género (p.ej.: el dinero, el vino, el aceite, etc.), de tal modo que en las obligaciones de género, se pueden dar las unas por las otras. En cambio, las no fungibles son aquellas que consideramos jurídicamente por su individualidad (p.ej.: esta botella de vino que he diferenciado de las otras, este caballo que está en mi establo y tiene este nombre; etc.).

1. Los romanos, para referirse a las cosas fungibles, hablan de las que "se pesan, cuentan o miden" (*quae pondere numero mensurae sunt*) o simplemente de las que "se cuentan" (*quae numero sunt*). El vocablo *res fungibles* no es romano. Fue utilizado por primera vez por el jurista humanista U. Zazius (1461-1535) en su *inst. de actionibus* (1536), § 30, n.17-18, como neologismo derivado del texto de Paulo (D.12.1.2.1, cfr. A. d'Ors, DRP, § 132.1).

2. La más fungible de todas las cosas es el dinero corriente (*pecunia numerata*); pero si se trata de monedas de colección o de joyas, serían no fungibles. La voluntad de las partes puede transformar una cosa fungible en no fungible (así, el dinero que está en una bolsa cerrada, o un animal marcado dentro de un rebaño).

§ 205. *Cosas consumibles y no consumibles*. Las cosas consumibles son aquellas que se pierden con el primer uso que se haga de ellas. La pérdida puede ser física (p.ej., los alimentos), pero también jurídica (p.ej., el dinero, porque con el primer uso sale de nuestro patrimonio).

Justiniano alterará este sentido primero, al asimilar aquellas que se agotan con el primer uso con las que se "gastan" sensiblemente por el uso reiterado (p.ej., la ropa; cfr. Tit. D.7.5: "Sobre el usufructo de las cosas que se consumen (*quae usu consumuntur*) y que se gastan (*vel minuuntur*)").

§ 206. *Cosas divisibles e indivisibles*. Son divisibles las que se pueden fraccionar sin perjudicar su naturaleza y función económica propia: así, una suma de dinero, una cantidad de aceite o de vino, aun cuando divididas disminuyan, por supuesto, su valor. En cambio, son indivisibles aquellas que no se pueden dividir

sin alterar su naturaleza o función propia; así, una estatua, un navío, etc. (Gayo, D.6.1.35.3). Esta división tiene importancia para las obligaciones divisibles e indivisibles.

§ 207. *Partes, accesorios, pertenencias y frutos*.

a) La expresión *pars* (parte) hace referencia, no sólo a un elemento que integre la cosa (así, la vela de un barco, la teja de un edificio, etc.), sino que como *pars pro divisa* es la separación que se hace de una cosa: así, la división de un fundo en porciones o dividir, cuando se pueda, una casa poniendo un muro medianero (Ulp., D.8.4.6.1).

1. En el caso del condominio (*communio pro indiviso*), cada uno de los copropietarios no tiene una *pars* *divisa* de la cosa en común, sino una parte cuantificada en cuotas ideales: la mitad, un tercio, etc.).

b) Respecto de las cosas muebles (no de las inmuebles) se dice que son "accesorios" respecto de otras que son "principales", y a las cuales están subordinadas. Esto puede ocurrir cuando se agrega un adorno a un vestido, o una piedra a un anillo (se habla de *accessio**), o sin estar unidas, guardan una relación de dependencia funcional; así, las llaves respecto de las cosas que tienen cerradura. La regla general es que lo accesorio sigue la suerte de lo principal (*accessorium sequitur principale*).

c) Distinta de la *pars* es la "pertenencia" (*instrumentum fundi*), como ocurre con los útiles de labranza respecto de un campo (Ulp., D.33.7.8 pr.), lo mismo que el *instrumentum domus* (lo que sirve para proteger la casa: así las vidrieras, cortinas, etc., que no sean de simple ornato; Ulp., D.33.7.12.16). Si bien son cosas muebles separables de la cosa principal a la cual están destinadas, la interpretación comercial puede considerarlas integrando una unidad (así, si se trata de un legado o de la venta de una casa; Ulp., D.19.1.13.31; D.14 ss.).

En los muebles que introduce el arrendatario rústico en la finca, se distinguen los *invecta* (aperos de labranza y ajuar doméstico) de los *illata* (esclavos y semovientes); ambos, quedaban como garantía del pago de las rentas.

d) Los frutos son los rendimientos que produce de manera periódica una cosa, sin alterar la sustancia de ella. Así, están ante todo los "frutos naturales" (cosechas, y respecto de los animales, la leche, la lana, las crías). Igualmente, los denominados "frutos civiles" (así, los rendimientos pecuniarios que se producen por arrendamiento —alquileres—, o por dineros que aporta un esclavo arrendado por sus trabajos —jornales—, etc.; Ulp., D.22.1.36; D.5.3.29).

1. Sin embargo, los intereses del capital prestado no son considerados propiamente como frutos, ya que representan el "precio por el uso" del capital prestado (Pomp., D.50.16.121). Pero en ciertos textos, utilizando el sentido griego de que los intereses son como "partos" (*tokoi*) del capital, se dice que el dinero "para" intereses (Ulp., D.22.1.33 pr.; *pariet usuras*), y por ello, se comportan como haciendo las veces de frutos (Ulp., D.43.34: *Usurae vicem fructuum obtinent*); incluso, cuando el capital no produce intereses se habla de "dinero estéril"; Papiniano, D.43.7; aunque en otras se contraponen "intereses" a "frutos" (Paulo, D.43.16.1).

2. Lo típico del fruto es la periodicidad; por ello, el aprovechamiento que se hace al separar una parte de la cosa que no tenga renovación, será considerado "producto". Así, respecto de los árboles, el corte de ramas es considerado fruto cuando por las características de ellos pueden ser objeto de podas regulares (*silvae caeduae*), pero no si no lo son (*silvae non caeduae*; Ulp., D.24.3.7.12). Igualmente los clásicos veían como frutos las extracciones de las minas y canteras (Paulo, D.50.16.77), pero Justiniano varió el criterio respecto de las canteras de mármol (Ulp., D.24.3.7.13 itp.). Para los recopiladores, el mármol no es considerado un fruto, "si no fuera tal que allí renaciera la piedra, como las canteras que hay en la Galia y en Asia".

3. Respecto de los hijos de una esclava, pertenecen al propietario, pero no son considerados frutos. Hubo una discusión en la época republicana, ya para Q.M.Scávola y Manilio eran frutos, pero terminó triunfando la opinión de Junio Bruto (Cic., *de finib.*, 14.12; Ulp., D.7.1.68). Se considera que la función propia de la esclava no es tener hijos (Ulp., D.5.3.27 pr.), a lo que se agrega un argumento humanista que impide llamar fruto a un ser humano (Gayo, D.22.1.28.1; Inst., 2.1.37). El problema tenía importancia jurídica respecto del usufructuario de una esclava; al no ser frutos, los hijos habidos (*partus ancillae*) serán del propietario.

4. Mientras los frutos estén todavía adheridos a la cosa fructífera (*fructus pendentes*), son accesorios de ésta; por tanto, como parte del fundo, son del propietario de ella (Gayo, D.6.1.44; D.19.1.40).

A su vez, los *fructus separati* (frutos separados) son aquellos que han sido separados de la cosa fructífera, sobre todo por la acción natural que los corta y hace caer (el poseedor de buena fe que se cree propietario, los hace suyos desde la *separatio*, por lo menos si no fueron sembrados por un poseedor anterior) (Gayo, D.22.1.45).

Finalmente, se habla de *fructus percepti* (frutos percibidos) cuando se ha realizado la acción humana de recogerlos (*perceptio*); así los adquiere, por lo general, el usufructuario (Ulp., D.7.1.12. 5; D., id., 27 pr.).

CAPÍTULO 2

LA POSESIÓN

§ 208. *Conceptos generales.* La palabra "posesión" (*possessio*) designa el poder de hecho que alguien tiene sobre una cosa corporal, con ánimo de tenerla para sí. Podemos decir que se trata siempre de un "señorío de hecho", en el que interesa esa relación real efectiva con la cosa, con independencia de su "derecho a poseer". Así, el dueño de una cosa, por regla general, es al mismo tiempo el poseedor de ella, pero si la pierde o se la sustraen, dejará de ser el poseedor, aunque siga siendo el dueño.

En otras palabras, al hablar de posesión, estamos siempre tratando una "cuestión de hecho", y no una "cuestión de derecho". Esto es lo que la diferencia de la propiedad o dominio, que es siempre un "señorío de derecho", en virtud del cual el dueño es el titular jurídico de la cosa.

1. El vocablo *possessio* deriva del verbo *possidere*, en el cual está presente el *sedere* (sentarse en una cosa). De ahí que en su acepción prístina, *possessio* equivale a "asentamiento", y el *possessor* es la "persona asentada en una cosa". Por eso consiste en este "señorío de hecho". El poseedor es el que fácticamente tiene el control físico de la cosa, con ánimo de tenerla para sí, situación que es reconocida y protegida por el *ius civile* o por el *ius praetorium*.

2. Los juristas romanos nunca hicieron una "teoría general de la posesión", como la harán luego los modernos (así, en la célebre controversia entre Savigny e Ihering). Ellos simplemente detectaron la necesidad de proteger en determinadas circunstancias el hecho de la posesión, ya por el *ius civile* y también por el *ius honorarium*, respecto de ciertos poseedores a los cuales se conceden las vías procesales adecuadas.

3. Lo que sí resulta el principio liminar de este tema, es que al hablar de posesión lo hacemos de manera independiente de la propiedad. Los textos son en este aspecto bien claros: "La posesión debe estar separada de la propiedad" (*separata debet esse possessio a proprietate*; Ulp., D.43.17.1.2); "Nada de común tiene la propiedad con la posesión" (*nil commune habet proprietatis cum possessione*; Ulp., D.41.2.12.1); "La propiedad y la posesión no deben mezclarse" (*nec possessio et proprietatis misceri debent*; Venuleyo, D.41.2.52 pr.). Esto vale principalmente

cuando nos referimos a la "posesión interdictal" (*ad interdicta*), ya que en cuanto a la *possessio civilis*, ella será un requisito precisamente para adquirir la propiedad.

§ 209. *Efectos de la posesión.* Sus efectos principales, que explican su razón de ser, son los siguientes:

a) *Por medio de la posesión se puede llegar a ser propietario.*

(i) Así, para adquirir el dominio de una *res nec mancipi**, se realizaba una *traditio ex iusta causa** (es decir, el adquirente es propietario desde que accede a la posesión de la cosa).

(ii) Por medio de la posesión continuada (y de otros requisitos) se puede usucapir una cosa.

(iii) El entrar en posesión de una *res nullius** (cosa de nadie), por medio de la *occupatio**, lo hace propietario de ella.

(iv) El poseedor de buena fe de una cosa adquiere los frutos de ella.

b) *La posesión juega un papel importante en el proceso reivindicatorio.* Quien reivindica, por carecer de la posesión, está obligado a suministrar toda la carga de la prueba (*onus probandi*), mientras que el poseedor demandado está en mejor situación procesal, ya que en principio no debe probar nada.

c) *El poseedor—independientemente de que tenga o no derecho a poseer—resultará protegido contra los ataques de hecho de terceros* que pretendan turbarle su posesión, o despojarlo de ella. El principio general es que si alguien se cree con derecho a la cosa, debe demandarlo por las vías jurisdiccionales idóneas, pero no hacerse justicia por mano propia.

§ 210. *Adquisición de la posesión.* Son necesarios dos elementos: uno físico, denominado *corpus*, que consiste en el efectivo apoderamiento y control de la cosa, y otro intencional, denominado *animus*, que consiste en la voluntad de tener la cosa para sí (*animus rem sibi habendi, animus possidendi*). La presencia de ambos elementos es esencial para la adquisición posesoria: "Adquirimos la posesión por el *corpus* y el *animus*, no sólo por el *corpus* o sólo por el *animus*" (Paulo, D.41.2.3.1; Paulo, 5.2.1).

1. Respecto del *corpus*, si se trata de cosas muebles, hay que tomarlas así, la pieza cobrada en la caza, pero también si cae en la trampa que he puesto en mi fundo y no puede escaparse (Próculo, D.41.1.55). Pero en otros casos basta que estén en presencia y ante la vista del adquirente (Paulo, D.41.2.1.21), o si el vendedor me las ha dejado en mi casa (Celso, D.41.2.18.2), o puestas bajo la custodia de un guarda que yo puse (Javoleno, D.41.2.51), o con la entrega de las llaves del almacén o bodega donde están las cosas (Paulo, D.41.2.1.21; *traditio symbolica*).

Respecto de un inmueble, no es menester recorrerlo, como se hacía antiguamente (*circumambulatorio*), bastando con pisarlo (Paulo, D.41.2.3.1), o también mostrándolo desde lo alto de una torre y viendo que está libre de ocupantes (*vacua possessio*); Celso, D.41.2.18.2, D.41.15 (14); D. id. 16 (15); *traditio longa manu*.

2. Respecto del *animus* los juristas hablan en términos muy generales. La expresión más propia es *animus rem sibi habendi* (ánimo de tener la cosa para sí), o también, más general, *animus possidendi*. En cambio, la expresión *animus domini*, que será la predilecta de Savigny, no se la encuentra en ninguna parte ni de los autores clásicos ni en la compilación justiniana, al parecer, surge de dos textos ambiguos de Teófilo (2.9.4.1; 3.28.2.1: *psyché despozonos*, más *animus dominantis* que *animus domini*). A pesar del favor de que gozará para los modernos, — pese al ataque de Ihering — no refleja tampoco todas las posibilidades posesorias, que no quedan reducidas al "ánimo de ser propietario".

3. Por la presencia del *animus rem sibi habendi*, se diferencia la "posesión" de la "tenencia" (caso, p.ej., del locatario o del comodatario; es llamada *possessio naturalis, possidere corpore, esse in fundo*). El mero tenedor tiene una *affectio tenendi*, pero no tiene la cosa para sí, sino que está reconociendo que le pertenece a otro como poseedor.

4. El tenedor no puede cambiar por su propia voluntad la causa de su situación (regla: *nemine sibi ipso causam possessionis mutare potest*; Paulo, D.41.2.3.19). Para que ello ocurra debe mediar un acto de violencia o una causa negocial (así, si el propietario, que es el poseedor, se la vende; entonces, sin tradición efectiva, por cuanto ya tiene el *corpus*, el tenedor comienza a poseer; este caso es la *traditio brevi manu*; Gayo, D.41.1.9.5, Ulp., D.12.1.9.9). El caso opuesto es si un poseedor se convierte en tenedor; así, si vendo mi casa, pero me quedo en ella como inquilino (Celso, D.41.2.18 pr.). En la terminología medieval se lo llamó *constitutum possessorium*.

5. La posesión la podemos adquirir directamente nosotros mismos, pero también por medio de nuestros *alieni iuris* (Gayo, 2.89.80), puesto que si ellos adquirieron, lo hacen para nosotros. Esto se extendió para el caso de los *procuratores* (administradores generales; Paulo, 5.2.2, D.41.3.41). Con Justiniano, la regla se generalizó para los mandatarios y gestores

de negocios (Ulp., D.41.1.20.2 *in fine*; Modestino, D. id. 55, *in fine*, ambos itps.).

Dada la exigencia del *animus* no pueden adquirir por sí ni los infantes, ni los dementes (Paulo, D.41.2.3). Se discutió si los impúberes necesitaban la *auctoritas* del tutor, opinando Oñilio y Nerva hijo, que por ser una cuestión de hecho, y no de derecho, el pupilo podía adquirir sin ella, siempre que tuvieran entendimiento (Paulo, D.41.2.1.3).

§ 211. *Conservación de la posesión*. Para retener la posesión, en principio, lo debemos hacer con el *corpus* y con el *animus*. Pero se admitió que la podemos mantener *animus nostro, corpore alieno* (con nuestro *animus* y teniendo otro el *corpus*). Así, las poseemos para nosotros, por medio de nuestros comodatarios o inquilinos (Gayo, 4.153, D.41.2.9). Somos los poseedores, mientras que ellos gozan de una mera tenencia (*possessio naturalis*).

1. También, la retenemos *nudo animo*, aun cuando no la tengamos a nuestro alcance inmediato, pero podemos acceder a su control. Sería el caso de los *saltus hiberni vel aestivi*, es decir, de terrenos para pasar el invierno o el verano, y por ello no visitados una parte del año (Paulo, D.41.2.3.11; Papin., D.41.2.44.2; Paulo, 5.2.1).

Lo mismo ocurría cuando alguien poseía un campo que lo usaba como agricultor, pero en el cual no estaba permanentemente; lo poseía él, al igual que los *saltus hiberni vel aestivi* (Ulp., D.43.16.1.25).

2. Igualmente, si tenemos la posesión por medio de un esclavo o un arrendador, y éste fallece o se vuelve demente, seguimos manteniendo la posesión sólo por el *animus* (Pomp., D.41.2.25.1; Afric., D.41.40.1, inicio).

3. Otro caso es el del "esclavo fugitivo". Los proculyanos afirmaban que se perdía la posesión. Pero se admitió que mientras está fugitivo y no sea poseído por otro, *utilitatis causa*, se lo continuaba reteniendo (Paulo, D.41.2.1.14). Justiniano dirá que se lo conserva *nudo animo*, pudiendo adquirir por medio de él (C.7.32.12).

§ 212. *Pérdida de la posesión*. A su vez, se pierde la posesión si perdemos el *corpus* de la cosa o dejamos de mantener el *animus* o por la pérdida de ambos elementos:

1. Para los clásicos, la posesión se podía perder *aut corpore aut animo*. Los bizantinos establecen el principio de que son necesarios los dos elementos (Paulo, D.41.2.8 itp.).

a) *Pérdida corpore*: Así, si tenía unas piedras y éstas se cayeron al río (Ulp., D.41.2.13), o si tenía un fundo y éste es ocupado permanentemente por un río o el mar (Paulo, D.41.3.17);

o si nos sustraen la cosa o nos la arrebatan (Gayo, D.41.15).

1. También perdemos la posesión de las cosas que perdemos ignorando dónde están (Pomp., D.41.2.25 pr.). Igualmente, si enterramos una cosa o la escondemos, olvidando el lugar; y esto aun cuando nadie la haya tomado (Papin., D.41.2.47). Los bizantinos interpretarán que si escondo en la tierra un tesoro, y volviendo de un viaje no recuerdo el lugar, "la debilidad de la memoria" no perjudicará la posesión, a menos que otro lo tome (Papin., D.41.44 itp.).

2. Igualmente se pierde respecto de los animales salvajes que apresados recuperan la libertad natural o respecto de los domesticados (palomas, abejas, etc.) que pierdan la costumbre de volver (*animus revertendi*); Paulo, D.41.2.3.14 y 16.

3. Si alguien se ha alejado de su inmueble (p.ej., para ir al mercado), y en el ínterin un tercero entra clandestinamente al inmueble, el primero al regresar podía expulsarlo empleando la fuerza (Gayo, 4.154, *in fine*), pero si el intruso lo repele y se queda con la cosa, entonces el despojado pierde la posesión *corpore*.

Para los juristas clásicos, la posesión se pierde desde el momento que el otro adquiere la posesión. Los bizantinos, interpolando los textos primitivos, dicen que en el caso planteado el primer poseedor, por ignorar la invasión del intruso y ante el fracaso de su restitución, sigue siendo tal *solo animo* (v. Laben Ulp., D.41.2.6.1 itp.; Pomp., D.41.25.2 itp.; Papin., D. id.46, totalmente espurio).

b) *Pérdida animo*: ocurriría cuando el poseedor, aun reteniendo la cosa, determina su voluntad de no querer seguir poseyéndola. Así, A vende a B una casa, pero llegan a un acuerdo, de tal modo que A continuaba reteniendo dicho bien a título de inquilino. Es decir, de poseedor que era, se transforma ahora en mero tenedor (es el caso llamado por los medievales *constitutum possessorium*). Y esto ocurría por la voluntad del poseedor, es decir, sólo por el *animus*, ya que seguía manteniendo el *corpus*.

1. Se podía dar también el caso de que A, que estaba poseyendo un fundo de buena fe, acordara con el dueño de ella, ser su inquilino. Perdía la posesión, pasando a ser un mero tenedor (cf. Marcelo, D.41.2.19 pr.). Y esto también ocurría sólo por el *animus*, pues seguía reteniendo el *corpus*.

2. Estos casos están vinculados con la retención de la posesión *solo animo* (caso de los predios de verano o de invernación). Para los clásicos, la posesión de ellos se perdía desde el momento en que alguien entraba y adquiría su posesión; en cambio, para los bizantinos, bastaba que sospecháramos que podíamos ser repelidos por quien ha entrado en la posesión; por lo que la pérdida sería sólo por el *animus* (Pomp., D.41.2.25.2, itp.).

3. Para los bizantinos, el elemento del *animus* tendrá especial importancia.

Así, en algunos casos se pueda mantener solamente por el *animus* la posesión aunque se haya perdido el *corpus*. P.ej., si alguien posee un campo por medio de un esclavo o arrendatarios y éste se va sin voluntad de volver, en la época clásica se perdía la posesión (Pomp., D.41.2.31), mientras que para Justiniano, el propietario la sigue poseyendo *solo animo*, hasta que un tercero entre en el campo y comienza a poseer (Afric., D.41.2.40.1 itp.).

Por el otro lado, aunque subsista la relación posesoria, basta la voluntad negativa de poseer, para hacer cesar la posesión. Así, la regla general está en el texto interpolado de Paulo (D.41.2.3.5): "Para que se pierda la posesión se ha de atender al *animus* del que posee. Y así, si tuvieras un fundo, y sin embargo, no quisieras poseerlo, perderás inmediatamente la posesión" (cf. Ulp., D.41.17.1 itp.).

c) *Pérdida corpore et animo*: ocurre cuando el poseedor cede la cosa a otro (p.ej., se la vende), o la abandona (*derelictio*) y también cuando el poseedor muere (Javoleno, D.41.2.23).

1. Cuando el heredero adquiere la herencia, se vuelve propietario de los bienes, pero no poseedor. No existe en el Derecho Romano la adquisición del hecho de la posesión *ipso iure*; había que entrar a poseer las cosas *corpore et animo*; esto se aplica a toda clase de herederos, incluso los *sui heredes*, aunque este tema está discutido. Pero de haber existido para ellos, habrían quedado importantes rastros en los textos, los cuales no existen.

§ 213. *Clases de posesión*. I. *Posección civil* (*possessio civilis*). Es la que está protegida por el *ius civile* y por medio de ella se puede acceder a la propiedad. Aparte de tratarse de una verdadera *possessio* (es decir, que se tenga la cosa *corpore et animo*; no una mera tenencia), requiere una "justa causa de posesión" (*iusta causa possessionis*). Esto significa que la posesión de la cosa tenga un título jurídico que la justifique. Así, haberla adquirido por causa de compraventa (*pro emptore*), por causa de donación (*pro donato*), por causa de legado (*pro legato*), etc. (Paulo, D.41.2.3.21). Siendo de buena fe, y cumpliendo los demás requisitos de la *usucapio*, permite que el poseedor civil se transforme en propietario quiratario de la cosa. Cuenta con la protección de los interdictos, así como de la *actio Publiciana in rem*.

II. *Posección pretoriana*. Es la posesión protegida por el pretor, por medio de los interdictos (por ello es denominada por los modernos *possessio ad interdicta*). Con estos procedimientos especiales, el poseedor puede defenderse contra toda usurpación o perturbación.

Los poseedores que pueden acudir a la defensa interdicial son los siguientes:

A) Todo poseedor que acredite poseer, o haber poseído la cosa con voluntad de tenerla para sí (*corpore et animo*). En tal situación se pueden hallar:

(i) el poseedor que es propietario, aunque acá interese como poseedor, y no como propietario;

(ii) el poseedor de buena fe (*possessor bonae fidei*) que creyera erróneamente que es propietario;

(iii) incluso el ladrón, quien puede interponer los interdictos, si bien no contra la persona que había sufrido el hurto.

1. Así, supongamos que A ha hurtado una cosa a B. Si un tercero C le toma dicha cosa a A, éste tiene contra dicho C el interdicto *utrubi*. Esto puede parecer raro, pero se trata de preservar la "paz posesoria", de tal modo que nadie puede hacerse justicia por mano propia. En cambio, si quien le tomó la cosa es B, el ladrón no puede intentar con éxito el interdicto, puesto que ha sido él quien la ha hurtado.

B) El pretor protege también a otros poseedores de cosas, a los cuales, por razones de *aequitas*, considera que hay que proteger. De este modo, la protección interdicial se amplía a ciertas personas, a las cuales denomina *possesores*, a pesar de que están reteniendo la cosa en lugar de otro, es decir que reconocen y aceptan su deber de entregar la cosa a otra persona. Esto sucede en los siguientes casos:

(i) Aquellos que han recibido la concesión del *ager publicus* y pagan por ello al *populus un vectigal* (*vectigalistae*); y más tarde el *enfiteuta** (Macer, D.2.8.15.1). Igualmente, el titular de una "superficie" (Ulp., D.43.18.1 pr.; EP, § 249).

(ii) El acreedor pignoraticio que retiene como garantía la cosa de otro, se considera que es el poseedor pretoriano, resultando protegido por los interdictos. Quien se la entregó en *pignus* (generalmente el deudor, ya que puede también ser un tercero) continúa siendo el poseedor civil (*ad usucapionem*; Javoleno, D.41.3.16, Juliano-Paulo, D.41.2.1.15).

(iii) El "precarista" (figura distinta del comodatario), es decir, aquel que ha rogado a otro que le conceda la posesión de una cosa mueble o inmueble (*precarium* = préstamo suplicado; de *preces*, ruego; Ulp., D.43.26.1 pr.-3). Su posición es muy débil respecto de quien le concedió la posesión (*precario dans*), pero, en cambio, está protegido por interdictos contra terceros (Ulp., D.43.16.2; EP, § 258).

(iv) El "secuestratario" (*sequester*), es decir, aquel que retiene las cosas discutidas por los litigantes en una apuesta o en un proceso. Siendo incierto el resultado, es de interés del secue-

trario el contar con los interdictos posesorios. (Florent., D.16.3.17 pr.1).

1. Estos casos resultan muy problemáticos para construir una "teoría general de la posesión", pues escapan de algún modo al concepto mismo de la *possessio*, que exige el *corpus* y el *animus*. Savigny hablará acá de que se trata de una "posesión derivada", es decir que el poseedor originario la ha derivado en otro.

Ello presenta dificultades, ya que en la mayoría de los casos, este *possessor* anómalo entiende más bien poseer la cosa en su interés que en nombre de quien sería verdadero poseedor.

Lo que ocurre es que los romanos no trataron nunca de construir una teoría general, sino que más bien la posesión fue siempre un recurso técnico para proteger por equidad —además del poseedor típico, es decir, de quien posee a nombre propio— ciertas situaciones especiales.

2. Fuera de estos casos señalados —muy excepcionales— el mero poseedor (*possessor naturalis*) no tiene protección posesoria. Es el caso del arrendatario, comodatario, depositario, etc. Si son perturbados por un tercero, deben acudir al arrendador, al comodante y al depositante, etc., quienes son los verdaderos poseedores, ejerciendo la posesión precisamente por estos tenedores. Tampoco éstos, como meros tenedores, tienen la vía interdicial contra aquellos por los cuales están teniendo la cosa. En caso de turbación, tendrían las acciones negociales nacidas del arriendo, el comodato, el depósito, etc.

3. El usufructuario, que no es poseedor, está sin embargo protegido, no por los interdictos comunes, sino por uno especial: el *uti frui prohibitus esse dicitur* (EP, § 245). Además, tenía el *interdictum uti possidetis utilis* (EP, § 247), sólo para el caso de que dos personas se reclamaran recíprocamente el mismo usufructo.

Protección de la posesión.

§ 214. *Interdictos*. La posesión, tanto civil como pretoriana, está defendida por los interdictos. Mediante ellos, se protege a quienes están poseyendo frente a sustracciones o perturbaciones injustas por parte de otro. Pero tienen también otra función. Así, cuando se discute acerca de la propiedad de una cosa, antes de iniciar la *rei vindicatio*, hay que aclarar cuál de los eventuales litigantes es el poseedor que será el demandado en la reivindicación (Gayo, 4.148; Inst., 4.15.4).

1. Cuando se piensa en intentar la *rei vindicatio*, según nos dice Ulpiano (D.47.1.3), se puede convenir o no quién es el actual poseedor y quién no. Si se conviene, la cuestión previa está resuelta: el posee-

dor, aparte de gozar de la posesión, como demandado en la reivindicación gozará de la ventaja procesal de su situación cómoda en el juicio, puesto que la carga de la prueba (*ei onus probandi*) le corresponderá al actor (Marciano, D.22.3.21; Gayo, D.6.1.24). Además, si el actor no prueba que es propietario, el demandado poseedor se queda con la cosa (Paulo, D.50.17.128 pr.). En caso de duda era preferida la posición del poseedor (Paulo, D.50.17.128 pr.; Inst., 4.15.4: "cuando sea oscuros los derechos de uno y otro, suele fallarse contra el actor").

Pero si no se conviniera acerca de quién es el actual poseedor, habrá que recurrir a los interdictos (*uti possidetis*, si se trata de un inmueble, o *utrubi*, si es una cosa mueble). También, si alguien ha sido desposeído violentamente de su fundo, le podrá interesar plantear primero el interdicto *unde vi* para recobrar la posesión y estar por ello en mejor situación en el juicio, amén de la ventaja de estar poseyendo la cosa.

2. Esto significa que la vía interdicial —que goza de un procedimiento más simplificado (ver *supra*, § 138)— es, como decía Ihering, el combate inicial en torno de la cosa. Éste no es definitivo, por cuanto el perdedor en dicho combate por la posesión, podrá luego intentar la batalla definitiva por la propiedad.

Es lo que en terminología moderna se suele mencionar como la correlación entre el "posesorio" y el "petitorio". En el "posesorio" se resolverá la cuestión de la posesión, sin poder invocarse el título de propiedad, sino las circunstancias fácticas relativas a la posesión (principio: la propiedad y la posesión no deben mezclarse; Venuleyo, D.41.2.52 pr.).

En el "petitorio", en cambio, la discusión es sobre la propiedad (caso de la *rei vindicatio*). La regla general es que si se plantea primero el "posesorio" y se resulta vencido, se podrá luego intentar el "petitorio". Pero, si de entrada resulta convenido quién es el poseedor y se va por ello directamente al "petitorio" (es decir, se promueve la *rei vindicatio*), quien resulta vencido no puede luego litigar con la misma persona y por la misma cosa, por la vía del "posesorio" (Paulo, D.44.2.14.3).

§ 215. *Clases de interdictos posesorios*. La clasificación de los interdictos (prohibitorios y restitutorios; simples y dobles), ya ha sido vista anteriormente (v. *supra*, § 139). Digamos acá que respecto de la posesión, los interdictos suelen estar clasificados en interdictos que tienen a adquirir, a retener y a recuperar la posesión (Gayo, 4.143).

Los primeros (*adipiscendae possessionis causa*) están dados a aquel que quiere entrar en la posesión de cosas que no ha tenido; así, el interdicto *quorum bonorum**, para el heredero o el *bonorum possessor** que quiere ser poseedor de los bienes hereditarios (Gayo, 4.144; Inst., 4.15.3). También el *interdictum Salvianum**, en

favor del propietario de un fundo respecto de los bienes del colono establecidos como garantía (*in vecta et illatae*) de los alquileres a pagar (Gayo, 4.147; Inst., 4.15.3, *in fine*; EP, § 266).

Por causa de retención de la posesión (*retinendae possessionis causa*), se protege a aquel que discute con otro su posición de poseedor, para saber quién lo es y quién no, a los efectos de la *rei vindicatio* posterior (Gayo, 4.148; Inst., 4.15.4). Son dos: el *uti possidetis* para la posesión de inmuebles, y el *utrubi*, para los muebles.

Finalmente, los interdictos de recuperación de la posesión (*recuperandae possessionis causa*) para proteger a aquel que ha sido desposeído de la cosa que poseía; así, el *unde vi* (Gayo, 4.154; Inst., 4.15.6).

En realidad, los interdictos que propiamente defienden la posesión son los de "recuperar" y los de "retener". Los de "adquirir" más que proteger la posesión cuestionada, sirven para adquirirla.

§ 216. I. *Interdictos posesorios "retinendae possessionis causa"*.

1. Los dos interdictos que analizamos, si bien están clasificados para "retener la posesión", cumplen igualmente una función restitutoria, puesto que quien pierde debe reintegrar al otro en la posesión.

2. Ambos son "dobles" (*interdicta duplicata*), porque a pesar de que sea uno quien lo pide, la situación de los litigantes es semejante, pudiéndose desempeñar como actor o como demandado. Igualmente, son "prohibitorios", porque lo que hace el pretor es prohibir el uso de la fuerza u otros vicios, dirigiéndose a ambos con el mismo lenguaje, a fin de mantener la posesión que esté libre de dichos vicios posesorios (Gayo, 4.160; Inst., 4.15.7).

3. Sobre el procedimiento, muy complicado en la época clásica, ver *supra*, § 140.3. Había que interponerlos dentro del año (Ulp., D. 43.17.1 pr.).

§ 217. *Uti possidetis*. Mediante este interdicto —referido a los inmuebles— el pretor ordena que sea preferido aquel que en el momento en que otorgue el interdicto posea sin "violencia", sin "clandestinidad" y sin "precariedad" (*nec vi nec clam nec precario*) respecto de su adversario (Gayo, 4.150; Inst., 4.15.4a).

1. La fórmula edictal era la siguiente; "Prohibeo que se haga violencia para que poseáis, tal como los poseáis, los edificios de que se trata, y que no poseáis, el uno respecto del otro con violencia, clandestinidad ni en precario (Ulp.; D.43.47.1 pr., EP, § 247.1).

2. Conforme a ello triunfará quien tiene la *possessio iusta* de la cosa. El concepto de *possessio iusta*

está dado por la locución *nec vi nec clam nec precario*. Acá están señalados los tres vicios: *vi*, es decir, haberla obtenido con violencia; *clam*, el haberla obtenido clandestinamente; ya por un procedimiento oculto o tomando precauciones para que no se entere quien estaba poseyendo (p.ej., entrando al inmueble cuando el otro está ausente); y *precario*, cuando alguien se la pidió al poseedor como "precarista". Si está presente alguno de estos vicios, es llamada *possessio vitiosa*, o *iniusta* o *improba* (Gayo, 4.151, *in fine*; Venuleyo, D.41.2.53; Paulo, D.43.17(16).2).

3. Pero hay que señalar que estos vicios funcionan en forma "relativa" (por eso en la fórmula el pretor hablaba de "respecto de su adversario"). Ello significa que pueden ser opuestos al otro litigante por vicios cometidos por éste, pero no respecto de vicios de terceros.

Así, p.ej., A interpone el *uti possidetis* a B; pero B ha adquirido la posesión por un acto clandestino respecto de A. Cuando B alegue ser el actual poseedor, A le opondrá la *exceptio vitiosae possessionis*, y será el vencedor.

En cambio, si, p.ej., A demanda por el *uti possidetis* a B, quien obtuvo la posesión mediante un acto clandestino realizado a C, A no le podrá oponer la excepción, por cuanto el vicio no lo afecta a él, sino que ha sido perpetrado contra otro, es decir, no contra el adversario (*ab-altero*). Como lo dice Paulo (D.43.17(16).2): "nada importa, en este interdicto, que respecto de los demás, la *possessio* sea *iusta* y *iniusta*, porque cualquier poseedor, por el hecho de ser poseedor, está en mejor situación que el que no posee"; y también Venuleyo (D.41.2.53): "Respecto de los extraños suele aprovechar la *vitiosa possessio*".

§ 218. *Utrubi*. Es un interdicto similar al anterior, pero protegiendo la posesión de cosas muebles. El pretor ordena que sea preferido aquel que durante la mayor parte de aquel año haya poseído la cosa *nec vi nec clam nec precario* respecto de su adversario (Gayo, 4.150).

1. La fórmula interdictal estaba redactada así: "Prohibo que por medio de la fuerza, a aquel de entre vosotros dos que tuvo a este esclavo durante la mayor parte de este año, que se le irapida que se lo lleve" (Ulp., D.43.31(30) pr.; EP, § 264). Si bien se habla sólo del vicio de *vi*, hay que agregar los otros integrando la redacción con la *exceptio vitiosae possessionis*, tal como lo indica Gayo (4.150) y lo hace Lenel. Respecto de los vicios rige la misma regla de la "relatividad" que en el *uti possidetis*. Sobre el procedimiento, v. *supra*, § 140.3.

2. A diferencia del *uti possidetis*, acá se requiere la posesión de la cosa mueble durante el mayor período de tiempo del último año anterior al interdicto. Así, si tú, p.ej., hubieras poseído la cosa 6 meses, y yo luego en los 7 posteriores, yo seré el preferido, ya que a los efectos de este interdicto, sólo te vale la

posesión de 6 meses, sin importar los 3 anteriores (están más allá del año) (Gayo, 4.152).

A los efectos del cómputo, se puede adicionar la posesión del poseedor anterior (p.ej., la de aquel de quien se es el heredero, o la del vendedor a quien se la compró). Rigen reglas distintas de las relativas a la *usucapio*. Acá sólo interesa, en cualesquiera de los casos, que ninguna de las posesiones que se acceden fuera viciosa respecto del adversario (Gayo, 4.151).

3. Se trata también de un interdicto "prohibitorio", que funciona generalmente como *retinendae possessionis causa* (cuando el vencedor es el poseedor actual que la tuvo durante la mayor parte del año anterior), pero a veces puede ser restitutorio (cuando, p.ej., yo la poseí 8 meses y tú, que la estás poseyendo, sólo 4).

§ 219. II. Interdictos "recuperandae possessionis causa".

A) *Unde vi*. Se concede este interdicto a aquel (A) que estaba poseyendo un inmueble y alguien (B) lo ha despojado empleando la violencia, a los efectos de que se le restituya la posesión, siempre y cuando que ésta no sea viciosa (*nec vi nec clam nec precario*) respecto del adversario. Debe ser intentado dentro del año a partir de la "expulsión" (*deiectio*). Luego del año, el pretor daba una *actio in factum* (Ulp., D.43.16.1 pr.).

1. La fórmula era así: "Por aquel fundo del cual, en este año, has expulsado por la fuerza, o lo expulsó tu familia, a aquel que lo poseía respecto a ti ni por violencia, ni por clandestinidad, ni en forma precaria, restitúyesele, así como las cosas que entonces allí había" (EP, § 245; Ulp., D.43.16.1 pr.; Cicer., *pro Caec.*, 19.55 ss.; *pro Tullio*, 19.44-45).

2. El interdicto estaba limitado a los inmuebles (fundos o edificios). Respecto de las cosas muebles, su poseedor quedaba amparado por la *actio furti* (caso de hurto) o la *actio vi bonorum raptorum* (caso de robo). Es necesario que se lo haya expulsado por medio de la fuerza de otro (o de su "familia": "el conjunto de sus esclavos" (Ulp., D.43.16.1.18). Se considera tal no solamente el haber ejercido violencia personal sobre el poseedor, expulsándolo de su fundo, sino también cuando el poseedor se ve obligado a huir, aterrado ante la presencia de una turba que luego ocupa el fundo (Labeón-Ulp., D.id.1.29).

3. La fórmula contiene la llamada *exceptio vitiosae possessionis*, la cual funciona en forma relativa, al igual que en el *uti possidetis* y en el *utrubi*.

Así, si A despojó a B por la fuerza, y éste promueve el interdicto, triunfará, puesto que a su respecto la posesión de A es viciosa. También el despojado puede proceder a expulsar impunemente al despojante (Gayo, 4.154, *in fine*). Éste no podría en este caso intentar con éxito el *unde vi*, dado el vicio inicial en que incurrió.

Pero si A despojó a B y más tarde fuera expulsado por otro C, y A intentara el *unde vi*, C no le podría oponer la *exceptio*, puesto que siendo relativa, A no actuó con violencia respecto de C.

4. A quien le quitara un fundo por violencia, podía optar entre el *uti possidetis* y el *unde vi*. El segundo tiene la ventaja de que aparte del fundo o edificio, comprende también las cosas muebles que estaban en ellos (Ulp., D.43.16.1 pr.; D., id. 1.33) y los frutos, contados desde la expulsión, y no como en el *uti possidetis* desde la interposición del interdicto (Ulp., D., id. 1.44). En cambio, aunque está discutido, no está claro si se recupera la posesión anterior o se comienza una nueva, lo que podría ser desventajoso para quien esté usucapiendo la cosa.

Incluso, para poder evitar el *uti possidetis* y acudir al *unde vi*, para el caso de que no hubiera habido una expulsión violenta, se convenía una "expulsión simbólica" (*vis ex conventu*), con lo que se abría la posibilidad de poder actuar por el *unde vi* (cfr. Cicer., *pro Caec.*, cit.).

B) *Unde vi armata*. Es un caso agravado del anterior. Protege a aquel que es despojado del inmueble, por medio de violencia ejercida por una banda armada, o simplemente con armas. A diferencia del anterior, aquí no rige la *exceptio vitiosae possessionis*, ya que "a causa de la atrocidad del delito", en todos los casos, incluido el del poseedor que había perdido la posesión por violencia, clandestinidad o precariedad, y procediera a expulsar con el empleo de armas a quien se la había arrebatado, debiendo restituirla (Gayo, 4.155; EP, § 245.2).

1. La fórmula era así: "De donde tú, por medio de la violencia, has expulsado, o tu familia lo ha hecho, por la coacción de hombres armados o de armas, y también todo cuanto entonces tuviera allí el despojado, que se lo restituyas" (EP, § 245.2).

2. Por "armas" se entiende, en sentido amplio, no sólo los escudos, las espadas y los cascos, sino también los palos y las piedras (Gayo, 4.155; Ulp., D.43.16.3.2-4).

3. También, a diferencia del anterior (*unde vi non armata*; la expresión *vis cotidiana* no es romana), en este caso del *unde vi armata*, el interdicto no es dado en el año, sino que es "perpetuo" (Cicer., *ad fam.*, 15.16).

C) Interdicto "de precario". Es para conseguir la restitución de la posesión de la cosa cedida al "precarista" (es decir, que la hubo por *precarium* = ruego, preces; EP, § 258), y también para obtener la indemnización de aquello que en forma dolosa se dejó de poseer (Ulp., D.43.26.2 pr.).

1. La fórmula era así: "Restituye a aquel de quien tienes en precario la cosa de que aquí se trata,

o que has dejado de poseer por dolo malo" (Ulp., D.43.26.2 pr.; EP, § 258). Es interdicto restitutorio (Ulp., D.id. 2.1).

2. La caracterización de este interdicto de *precario*, como posesorio, está discutida por cuanto estaría más basado en la relación de concesión precaria (el *precarium*) que en la misma posesión. Incluso, su carácter restitutorio. Lo sería según la tesis proculiana, según la cual el precarista es el poseedor que la ha recibido del concedente. En cambio, para la posición sabiniiana, ambos (concedente y precarista) están poseyendo en común la cosa, por lo que más que la restitución, lo que se busca por este interdicto es la reintegración plena de la posesión por parte del concedente (v. Paulo, D.41.2.3.5).

D) Interdicto "de clandestina possessione". La mención de este interdicto no aparece en el Edicto Perpetuo, aunque sí en un texto de Ulpiano (D.10.3.7.5). Estaría referido al caso ya visto (*supra*, § 212.a.3): Si alguien deja su casa para ir al mercado y en el ínterin otro entra en posesión, cuando aquél regresaba podía expulsar al intruso (aunque no por medio de *vi armata*; Gayo, 4.154-155). En el texto de Ulpiano se menciona la opinión del mismo Juliano, pero éste no la incorpora al Edicto Perpetuo, por considerar, ya para su época, que si fracasaba el primitivo poseedor en lograr la restitución de la cosa, perdía la posesión, "más por violencia que clandestinamente" (Ulp., D.41.2.3.1), pudiendo plantear el *unde vi* y luego el *uti possidetis* (Ulp., D.43. 17.1.4). De este modo, no era necesario este interdicto.

§ 220. Los interdictos en la época posclásica y justinianeas.

Con la desaparición del sistema formulario, en su forma clásica, los interdictos desaparecen, borrándose la distinción con las *actiones* (Diolec., C.8.1.3; Inst., 4.15.8). Con Justiniano, el interdicto tramita como una *actio* (como dándose una *actio utilis* en lugar del interdicto; Inst., id.). Tiene, sin embargo un trámite más rápido. Así, las instrucciones dadas en el Código (8.1.4; 8.2.3; 8.4.8; 11.47.14) de acelerar el procedimiento, y para el caso del *unde vi* (que podría ser tomado en forma análoga respecto del resto), la sentencia no se suspende por apelación (C.7.69).

1. Justiniano equiparará el *utrubi* con el *uti possidetis*, eliminando el requisito de la posesión durante la mayor parte del año anterior. De este modo, se trate de una cosa mueble o inmueble, lo que se tiene en cuenta es la *possessio iusta*, es decir, *nec vi nec clam nec precario* respecto al adversario, no al tiempo de interposición del interdicto, sino al tiempo de la *litis contestatio* (Inst., 4.15.4; Ulp., D.43.31(30).1 itp.).

2. Respecto del *unde vi non armata*, ya en la época posclásica, quizá por una constitución de Valentiniano (C.8.4.7) desaparece la *exceptio vitiosae possessionis*. De este modo sólo existirá un interdicto *unde vi*, asimilándose los casos clásicos de *vi non armata* y de *vi armata*. Debe ser planteado dentro del año, y pasado éste, bajo la forma de *actio in factum*, por todo aquello que hubiere logrado el despojante (Ulp., D.43.16.1 pr.).

3. Ya en el Bajo Imperio, dentro de un cuadro de desórdenes sociales, los conflictos posesorios aumentaron y las vías interdictales ordinarias se mostraron insuficientes. De ahí la aparición de medidas nuevas (Inst., 4.15.6):

c) Cuando se utilizó violencia respecto del poseedor, expulsándolo antes de terminado el juicio, si quien lo hizo era el propietario, debía devolver la cosa y perdía el dominio; si en cambio era un tercero, además de restituir la cosa, debe pagar al *dictus* una suma indemnizatoria igual al valor de las cosas despojadas (Valent.-Theod.; CTh.4.22.3; C.8.4.7; año 389).

b) Conforme a una constitución de Zenón (C.8.4.9; año 477), el despojado podía bajo juramento fijar el valor de todas las cosas que les han sido quitadas por la fuerza.

c) Además, quien ha expulsado a otro por la fuerza, queda sujeto a la ley *Iulia de vi privata out de vi publica*, entendiéndose por *vi privata* la mera violencia y por *vi publica* si se empleó armas (Inst., 4.15.6; Diodlec., C.8.4.4).

d) Cuando se hubiera desposeído sin violencia (p.ej., a los ausentes), y para remediar la falta de protección interdictal (el *unde vi* no era aplicable, quedándole sólo la *rei vindicatio*), los emperadores bizantinos crearon un interdicto recuperatorio nuevo (que algunos confunden con una ampliación del *unde vi*). Recibió el nombre de interdicto (o *actio*) *momentariae possessionis* (C.8.4.6; C.8.6.3). Tiende a procurar la restitución inmediata (*beneficium momenti*). Era popular, es decir, lo podía intentar cualquiera (C.8.6.3); el magistrado debe atenderla inmediatamente, incluso en forma oral, sin escrito (C.8.4.8), y sólo tiene que comprobar si existió o no la desposesión. Este interdicto sólo prescribe a los 30 años de ocurrido el despojo.

Lo que no contemplaron fue un interdicto para recuperar las cosas muebles, las que tenían menos importancia que los inmuebles. Quizá no advirtieron que al cambiarse las reglas del *utrobi*, dejó de tener la función recuperatoria de la época clásica, ya que

se exigió la posesión actual, al momento de la *litis contestatio*, por lo que era sólo para retener. Esta laguna recién será cubierta, dentro del Derecho Canónico, con la *actio spoli*.

§ 221. *Quasi-posesión (Quasi possessio)*. La *possessio* se refiere siempre, en la época clásica, al poder de hecho que se tiene sobre las cosas corporales. No podía existir respecto de las *res incorporales*, como los *iura* (Gayo, 2.14).

Cierto es que el pretor, en la época clásica, extendió la protección interdictal utilizando la vía de figuras "útiles" a quienes tenían un *ius in re aliena** (caso del usufructuario, usuario, habitador y algunas servidumbres prediales), pero sin emplear la palabra *possessio*. Ello significaba una protección de hecho de los *iura*, empleando la *aequitas* pretoriana.

Pero, con Justiniano, se habla directamente de *quasi possessio*, entendiendo que quien gozaba de uno de los *iura in re aliena* tenía directamente la posesión de dichos *iura*, lo cual significaba una *possessio iuris* (es decir, sobre una *res incorporalis*). Por ello, en los textos bizantinos se habla de *quasi possessio* del *ius iuris quasi possessio*; Ulp.; D.8.5.10 itp.) y de que la *possessio* podía versar sobre un *corpus* o un *ius* (*possessio vel corporis vel iuris*; Ulp., D.43.26.2.3 itp.).

1. En Gayo, 4.140, se habla de *quasi possessio*. Para algunos es un glosema añadido posteriormente. Para otros la expresión es auténtica, en el sentido de, p.ej., un usufructuario, pese a no ser poseedor, implicaba el uso y goce de la cosa en forma semejante a la posesión, sin avanzar más, es decir, sin que implicara una *possessio iuris*.

2. En los Fragmenta Vaticana, citando a Ulpiano, se habla de que al usufructuario se le concedía la protección interdictal en forma "útil" (*utile datur*, FV. 90), ya que se lo consideraba poseer (la cosa en usufructo), y a semejanza del interdicto *Quem fundum (ad exemplum interdicti Quem fundum)*, se le propone el *interdictum Quem usufructum iudicare velit* (FV.92).

3. Luego, con Justiniano, quedaría explicitada, no ya bajo la forma analógica de la *quasi possessio*, sino directamente de la *possessio iuris* (figura equiparable a la *possessio corporis*). Así, aparte del usufructo y del uso, también respecto del superficiario (D.48.15), de quien goza de un *iter* o de un *actus* (D.48.19), etc. (cfr. hasta D.48. 23).

CAPÍTULO 3 LA PROPIEDAD

§ 222. *Noción de la propiedad*. La propiedad (o dominio) consiste en el señorío jurídico más amplio que se tiene sobre una cosa. El propietario (*dominus; proprietarius*) puede libremente usar la cosa, disfrutarla y disponer de ella como mejor le plazca, y aunque existan diversas limitaciones y restricciones, el dueño es considerado como ejercitando un poder pleno sobre la cosa. Por ello, para los romanos, que no la definieron, era la *plena in re potestas*.

Frente a la propiedad están los denominados *iura in re aliena* (servidumbres, usufructo, uso, habitación y garantías reales, como la prenda y la hipoteca), que configuran siempre potestades no plenas sino "limitadas" sobre la cosa. Y también está la posesión (*possessio*), que no es un "señorío jurídico" como la propiedad, en virtud del cual se puede decir que la cosa es de alguien (= *esse alicuius*; o *meum est* = "es mío" o "soy el dueño"), sino un mero "señorío de hecho", por el cual tengo una cosa bajo mi poder con ánimo de tenerla para mí, aunque no sea el dueño.

1. En los tiempos antiguos no existe una denominación específica para la propiedad. Todo lo que integra la familia romana (tanto las personas como las cosas) está sometido al *mancipium* del *paterfamilias*. Para referirse a la propiedad de una cosa, se dice de ella *meum esse ex iure Quiritium* (es la fórmula empleada en la *vindicatio*). Ya a fines de la República aparecen las palabras *proprietat* (que tiende a señalar lo que es *proprium* de alguien) y *dominium* (vinculado a *domus*, y a *dominus* = "señor"; de donde *dominium* es el "señorío jurídico"). En la época clásica estos vocablos lucen como sinónimos.

2. Tal como dijimos, la propiedad es ilimitada en principio. Las limitaciones surgen ya por el *ius*, o ya por la propia decisión del propietario, que puede conferir ciertas ventajas sobre su dominio en favor de un tercero. Así, cederle el *uti frui* (usufructo) o constituir una servidumbre (p.ej., la de paso, por la cual debe permitir que otro pase por su fundo). Ello no obstante, continúa siendo el propietario; así, en el caso del usufructo, se emplea la expresión "nudo propietario", es decir, es el titular jurídico de la cosa, pero habiendo cedido todas sus ventajas de uso y disfrute, es como si estuviera "desnudo". Pero, para el caso de que estos *iura* de los terceros se extingan,

entonces el propietario recobra la plenitud de su dominio (los modernos hablan acá de "elasticidad de la propiedad").

§ 223. La noción del *dominium* romano se refiere propiamente a la cosa misma, de la cual se afirma una cualidad (*qualitas*), cual es la de pertenecer a una determinada persona. Así, cuando se reclama en juicio la cosa, él afirma "ser suya la cosa" (*rem suam esse*; Gayo, 4.92). Ello supone que, dadas las características de la cosa, el propietario tendrá su aprovechamiento en forma plena (*plena in re potestas*).

1. En la doctrina moderna, el dominio es el principal de los "derechos reales" de goce de una cosa. Se lo define, en forma general, como "la relación directa e inmediata que una persona tiene sobre una cosa". Pero no es exactamente así como lo entendían los romanos: a) el dominio no es, curiosamente, un *ius in re*; b) tampoco se habla de una relación con la cosa, puesto que las únicas relaciones jurídicas son posibles entre personas, como p.ej., en una obligación; c) al contrario, se parte de la situación en que se halla la cosa de la cual se afirma una cualidad, la de pertenecer a alguien. Por eso la propiedad son las cosas mismas; d) ello engendra una *potestas* por parte del dueño, que se manifiesta en la denominación de *dominium* = "señorío" (*dominus* = "señor").

2. El sentido modernista se mueve dentro de otra frecuencia de onda. Se trata siempre, en los denominados "derechos subjetivos patrimoniales" de la relación "sujeto-objeto". Por ello el dominio es el derecho subjetivo que el sujeto tiene de manera inmediata sobre un objeto, así como en el "derecho subjetivo de crédito", está presente la idea de que "el acreedor tiene una relación con el deudor, en virtud de la cual éste le tiene que entregar un objeto". A diferencia del derecho real, acá la relación con el objeto no es inmediata, sino mediata, ya que en el medio está el deudor, quien tiene que cumplir la obligación de entregar el objeto.

I. Caracteres y contenido del dominio.

§ 224. A) El dominio es *absoluto*: Aparece como la posibilidad más amplia de aprovechamiento de las cosas (*plena in re potestas*). El

dueño tiene el *uti frui habere possidere*. El *uti* se refiere al uso de la cosa; el *frui*, a poder disfrutar de ella, aprovechándose económicamente de la cosa (así, sembrando un campo y cosechando los frutos, o locando la cosa y percibiendo los alquileres); el *habere*, o sea, el poder, decir que la cosa la pertenace y en consecuencia disponer de ella, ya vendiéndola o gravándola con un *pignus*; finalmente el *possidere*, que se refiere al poder tenerla como suya, gozando de la defensa pretoriana de los interdictos.

1. El carácter "absoluto" hace referencia a que el propietario tiene jurídicamente todas las posibilidades de aprovechamiento de la cosa (*plena in re potestas*). En tal sentido sólo el *dominium* es absoluto. Los *iura in re aliena* presentan siempre limitaciones. Pero también, en un segundo sentido, se suele por algunos tomar la palabra "absoluto" en el sentido de "facultad irrefrenada" que no admite cortapisas.

Se habla de la regla: "Quien usa de su propio derecho no daña a nadie" (*qui iure suo utitur neminem laedit*); sobre la base de Paulo, D.50.17.151; Gayo, en D.50.17.55: "se considera que no hace ningún dolo quien usa de su derecho". Pero una cosa es "usar del derecho propio" y otra ocasionar con ese uso un daño a un tercero, puesto que estaría involucrado el principio del *alterum non laedere* (Ulp., D.1.1.10.1).

Se acostumbra hablar acá de "abuso de derecho", aunque los romanos hablan de "mal uso del ius". Así, Gayo (1.53 = D.1.6.1.2) nos habla del esclavo maltratado por su dueño y que por ello busca asilo en un templo o en la estatua del emperador. Por un rescripto de Antonino Pio, se obliga al dueño a vender el esclavo. Gayo nos dice acá que "en efecto, no debemos usar mal de nuestro derecho" (*nostro iure*). Justiniano le dará un fundamento público: "Pues aun la *res publica* tiene interés en que nadie use mal de su cosa" (*Expediit enim Reipublicae, ne sua re quis male utatur*; Inst., 1.8.2).

Si bien en los tiempos primitivos la *potestas* del propietario luce como soberana, comenzaron a aparecer restricciones cuando ese ejercicio traía perjuicios a otro o a la generalidad, a las cuales luego nos referiremos. Tampoco hay que olvidar que la conciencia social jugaba un papel importante. Aquí era de importancia el rol de los censores que tenían a su cargo el cuidado de las costumbres (*cura morum*). Intervinieron en los casos de gastos irracionales o realizados por lujos. Incluso respecto de los fundos deficientemente trabajados. El campesino está obligado a trabajar bien su campo, y no descuidarlo, ya que de lo contrario se lo sanciona con pena censoria (Aulo Gell., 1.4.2). También, el pater pródigo, que despilfarraba su fortuna, cae en interdicción y se le designa un curador (*ecce, ei interdicta es familiar*).

2. Vinculado con esto, surge en textos posclásicos la prohibición de los "actos de emulación" (*ad aemulacionem*). Se entiende por tales los actos realizados

por un propietario, no con miras a la utilidad propia, sino con la intención de perjudicar al vecino. El vocablo *aemulatio* está en Macer (D.50.10.3 pr.) con el sentido de "hacer competencia (injusta)"; así construir *in privato* una obra para competir con un monumento público. Los bizantinos, alterando los textos, plantean varios casos, a propósito de la *actio aquae pluviae arcendae* (D.39.3). El principio general, a propósito del aprovechamiento de las aguas es que "no se prohíbe que cada cual se aproveche mientras no perjudique a otro" (Ulp., D.1.1.1).

3. En lo que se refiere al *abusu* (algunos hablan de *ius abutendi* = derecho de abusar, lo que sería una contradicción) no es lo que se piensa. Para los juristas romanos, *abusus* significa el hecho de consumir una cosa al usarla (Ulp., D.7.5.5.1: si le ha sido hecho un legado de usufructo de dinero o de otras cosas *quae in abusu consistunt*).

§ 225 b) El dominio es *exclusivo*. Esto debe ser entendido como que en un *dominium* sólo puede haber un propietario, y éste excluye a cualquier otro en tal situación jurídica. El caso del "condominio", donde deben existir dos o más personas respecto de una misma cosa, no es una excepción a este carácter, puesto que en realidad se trata de un derecho distinto con particularidades propias.

§ 226. c) El dominio es *perpetuo*. No se puede constituir un dominio *ad tempus*. Así, que alguien sea propietario por un cierto tiempo, y que pasado un plazo determinado, retorne *ipso iure* al enajenante.

1. Los casos de modalidades en la compraventa, tales como la *lex commissoria* (el vendedor se queda con la posibilidad de resolver el contrato en caso de que el comprador no pague en cierto plazo), el *pactum displicentiae* (compra a prueba), o el de *retroemendo** (el vendedor puede recuperar la cosa devolviendo el precio que cobró), no alteran este carácter de perpetuo e irrevocable del dominio, puesto que no se trata de una revocación *ipso iure*, sino que los efectos son puramente personales, dando ocasión a la *actio venditi** o a la *actio empti**.

2. En cambio, en el derecho posclásico vulgar, al ampliarse la noción de dominio incluyendo en él a los enfiteutas y superficarios, es posible un dominio temporalmente limitado. Justiniano aceptó una propiedad limitada en el tiempo. Así, una donación con la condición de que muerto el donatario regresara la propiedad al donante (Diocl., C.8.55(54).2, año 286 it.).

II. Clases de dominio.

§ 227. *Dominium ex iure Quiritium*. Es la propiedad del *ius civile* (vulgarmente llamada

"propiedad Quiritaria"). Sólo la pueden tener los ciudadanos romanos, o al menos aquellos que, sin serlo, tengan el *commercium*. Puede recaer sobre las cosas muebles, y también sobre los inmuebles siempre que se hallen en suelo itálico. Si se trata de una *res Mancipi*, se adquiere por la *mancipatio*, o por la *in iure cessio*. Si se trata de *res nec Mancipi*, por la *traditio* o también por la *in iure cessio*. También se llega a esta propiedad por la *usucapio*. Está protegida por la *rei vindicatio*.

§ 228. *In bonis habere*. Es la "propiedad" del derecho pretorio (vulgarmente llamada "propiedad bonitaria"). En ciertas circunstancias, alguien podía haber adquirido la cosa pero faltando algún requisito para que se convirtiera en "propietario quiritario". Esto podía ocurrir: a) si alguien p.e.j., compraba una *res Mancipi*, pero el vendedor le hacía simplemente *traditio* de la cosa, es decir no el modo solemne eficaz (*mancipatio* o *in iure cessio*) para adquirir el *dominium ex iure Quiritium*; y b) si alguien compraba de buena fe a alguien que no era el verdadero propietario. En ambos casos, podía *usucapir* la cosa y transformarse en propietario quiritario, pero mientras transcurrieran los plazos, por el *ius civile* estaba en una situación de indefensión. Por ello; en el lapso intermedio, el pretor, para protegerlo lo considerará como "teniendo la cosa entre sus bienes" (*in bonis esse* o *in bonis habere*; respecto de este v. *infra*, § 255).

1. Sólo la pueden tener los ciudadanos romanos o quienes detentan el *commercium*. Se trata estrictamente de una situación especial, que es distinta del *dominium*, a pesar que Gayo (1.54; 2.40) la denomina *dominium in bonis*.

2. En la época posclásica, desaparecidas las viejas formas solemnes de la *mancipatio* e *in iure cessio*, se fue unificando la noción de propiedad. Justiniano admitió una sola clase de dominio, aboliendo la denominación del *dominium ex iure Quiritium* (considerando que se trataba de una antigua sutileza basada en una palabra vacía y superflua; C.7.23.1).

§ 229. *Propiedad provincial*. Los fundos situados en suelo provincial (en tanto que no gocen del *ius Italicum*) no pueden ser del dominio privado. Son atribuidos al dominio eminente ya del Emperador, ya del *Populus Romanus* (Gayo, 2.7). Por ello es que deben pagar ya un *stipendium* (al *Populus*; provincias "estipendiarias"), ya un *tributum* (al César; provincias "tributarias"). De ahí la expresión, respecto de los fundos de *agri stipendiarii* y *agri tributarii* (Gayo, 2.21).

Quienes están ocupando dichos fundos, al no poder ser denominados *domini*, serán llamados

fructuarii o *possessores* (Gayo, 2.7). Cuentan con la protección jurisdiccional de los gobernadores de provincia, que actúan por las vías pretorianas:

1. La protección jurisdiccional figuraría en el Edicto Provincial, estableciendo acciones "útiles"; así, en lugar de la *rei vindicatio*, la rúbrica *si cger stipendiarius petatur*.

2. Diocleciano extiende el pago del *tributum* a los fundos del suelo itálico, por lo que esta península pasa a ser una "provincia" más.

§ 230. *Propiedad peregrina*. Los extranjeros (*peregrini*) por carecer del *commercium* no pueden ser propietarios *ex iure Quiritium*. Pero ello no les impide ser propietarios según el *ius gentium*. El pretor los debió proteger mediante acciones ficticias, en las cuales se fingía la ciudadanía romana.

1. Este tipo de acciones debían ser de la misma clase que menciona Gayo (4.37). Si bien allí sólo se menciona la aplicación de una ficción por la *actio furti** y la *actio legis Aquiliae**, ellas están dadas como ejemplos, no existiendo razón para no extenderla a otras acciones.

§ 231. En el derecho vulgar posclásico, asistimos a un desdibujamiento de la propiedad. En los tiempos clásicos, los conceptos de *dominium*, *possessio* e *iura in re aliena*, aparecían claramente señalados. Con el vulgarismo, estas nociones se muestran mezcladas. Así, la denominación de *dominium* y *proprietat*, abarca también situaciones que constituirían claros casos de posesión (así, el enfiteuta y el superficario).

Justiniano restableció el concepto clásico de propiedad, distinguiéndola de la posesión y de los *iura in re aliena*. Existe, a su vez, un sólo concepto de propiedad, a la que pueden llegar todos sobre las cosas patrimoniales. Ha desaparecido la diferencia entre *dominium ex iure Quiritium* y el *habere in bonis*, así como también la situación jurídica especial de los fundos provinciales.

III. Limitaciones del dominio.

§ 232. Si bien el dominio es la *plena in re potestas*, su ejercicio no puede perjudicar a los terceros, ya sean los vecinos, ya la generalidad. Estas limitaciones o restricciones son impuestas directamente por el *ius*, y por ello deben ser respetadas por los propietarios. Por ello son distintas de aquellas otras que voluntariamente se imponga el propietario (p.e.j., una servidumbre), ya que aquí debe haber mediado un acuerdo entre el propietario y el beneficiario.

§ 233. A) Limitaciones por interés público.

La razón de estas limitaciones está en la primacía del bien general sobre el privado.

1. Para preservar las urbes, el propietario no puede demoler el edificio para vender los materiales (s.c. *Hosidianum*, año 44 d.C.; s.c. *Volusianum*, año 56 d.C.; *lex Tarentina*, 32; *lex Malacitana*, 52; *lex Ursonsis*, 75).

Igualmente, la ley de las XII Tablas prohíbe enterrar en la urbe, cremar los cadáveres cerca de los edificios; debía ser a una distancia superior a 60 pies (Cicer., *de leg.*, 2.24.61). También por la ley decenviral se limitó la cuantía de los gastos funerarios (10.1 ss.; 7.6 ss.).

2. En Roma no se puede hablar técnicamente de "expropiación", no estando regulada como institución jurídica. Cuando era necesaria la incorporación pública de un inmueble, se prefiere seguir la vía jurídica adecuada. Así, Augusto, no obstante su poder, recurrió a la compraventa para adquirir el terreno necesario para construir el Foro (Suet., *Aug.*, 56.2). A veces se apelaba a la coacción política, pero no a la jurídica.

Frontino (*de aquis urbis Romae*, c.125; 128) nos habla del s.c. *de aqueductibus* (siglo II a.C.), por el cual *sine iniuria privatorum*, se podía forzar al dueño de los materiales (tierra, arena, piedras, etc.) a venderlos para construir un acueducto. Pero no estaba referido a los inmuebles. Si el propietario de un fundo se oponía, no se podía realizar la obra (Tit. Liv., 40.51). Igualmente Augusto, respetuoso de la propiedad privada, por el *edictum de aqueductu Venafrano* (últ. década a.C.), renuncia a expropiar los terrenos necesarios para dicho acueducto.

La tradición jurídica romana se muestra renuente a entrometerse en la propiedad más allá de lo necesario. Ya desde la época bizantina, debido al absolutismo político, se pierde este respeto y se acude a la incautación de fondos para construcciones públicas, o también de viveres en caso de necesidad. Aunque había que pagar una indemnización en especie o en dinero, de hecho se trataba de ventas forzosas.

3. Los propietarios de fundos linderos a una vía pública, están obligados a mantenerla en buen estado. Si se hace intransitable por el descuido en la manutención, los propietarios negligentes deben soportar el paso de los jumentos por sus fundos (XII Ts., 7.7). En la época clásica, si la vía o el río se ha deteriorado o perdido, el vecino inmediato debe permitir el paso (Javol., D.8.6.14.1).

4. Los dueños de fundos ribereños quedan obligados a permitir el uso de las riberas, ya para pescar o navegar (Gayo, D.1.8.5 pr.; Inst., 2.1.4).

§ 234. B) Restricciones por relaciones de vecindad. En estos casos, más que el interés general, de lo que se trata es de regular las relaciones entre los propietarios de fundos vecinos.

1. *Frutos u otras cosas caídas en el fundo vecino.* La ley de las XII Tablas (7.10) establece que el dueño de un fundo puede entrar al fundo del vecino, día por medio, para recoger las bellotas del árbol propio caídas en éste. El pretor establecerá el *interdictum de glande legende*, prohibiendo el uso de la violencia para que no se recoja, dentro de tercero día, la bellota propia caída en suelo del vecino (Ulp., D.43.28.1 pr.). Se extiende, no sólo a la bellota, sino a cualquier otro fruto (Ulp., D.id.1.1); y también a cualquier cosa caída en el fundo vecino (Ulp., D.39.2.7. 2; D. id.9.1; D., 10.4.5.3-5).

2. *Árboles y ramas en los límites.* Cuando las ramas de un árbol invaden el fundo vecino, el dueño de este último puede pedir que el vecino lo "aclare" hasta la altura de 15 pies. Si no lo hacía, el requirente puede él mismo podar las ramas hasta dicha altura y llevárselas como leña (XII Ts., 7.9; *interd. de arboribus caedendis*: Ulp., D.43.17.1.7; Pomp., D.id.2).

En cambio, si las ramas invaden un edificio, el vecino puede hasta pedir la tala de todo el árbol, y si no lo hace el vecino hacerla él mismo y llevarse lo producido como leña (mismo interdicto; Ulp., D.43.27.1 pr. ss.; Pomp., D.id.2).

Lo mismo puede ocurrir con las raíces, dependiendo de las circunstancias la cantidad de ellas que deben ser eliminadas (C.8.1.1).

3. *Límites entre fundos vecinos.* Desde los tiempos antiguos, el fundo debía estar "limitado", mediante la ceremonia religiosa de la *limitatio*. Entre fundo y fundo había que dejar un espacio libre de 5 pies, denominado *ambitus* en la ciudad e *iter limitatum* en el campo. A ello se debe que ciertas casas romanas (para viviendas de locatarios) eran "islas" (*insulae*). Los que no eran limitados (*agri limitati*), eran denominados *agri arcifinii* y pertenecían al *ager publicus*.

En caso de que los límites se hayan confundido, cada uno de los propietarios linderos tiene la *actio finium regundarum*, que en principio se aplicó a la confusión del límite de cinco pies, y luego a los fundos rústicos (Ulp., D.10.1.2). Es una de las tres acciones divisorias (al igual que la *a. communi dividundo*, que pone fin al condominio y la *a. familiae erciscundae*, que pone fin a la indivisión hereditaria). La fórmula contiene una *adiudicatio*, por la cual el juez adjudica a cada uno la parte que le corresponde.

En la época posclásica se establecen disposiciones referidas a las construcciones, según criterios urbanísticos. Así, que no se oscurezca totalmente la casa del vecino (Paulo, D.7.1.30 it.; Marcelo, D.8.2.10 it.; Ulp., D.id.11 pr.). También se prohíbe construir a menos de 12 pies de distancia respecto de otro, o de 15 pies si es un edificio público (C.8.10.11.2; id., 13; Zenón). No se podía construir a menos de 100 pies de distancia de los ya existentes que tienen vista sobre el mar (C.8.10.12.4; 13; Nov. 63 y 165). La altura de los edificios no debe ser superior a 100 pies (C.8.10.12.4; 13).

4. *Inmisión de humo y otras emanaciones.* Diver-

sas disposiciones establecen que el propietario de un fundo debe permitir la invasión (*immissio*) de humo y otras emanaciones, dentro de los límites normales, por parte del fundo vecino. En caso de sobrepasar el límite (sería normal el de un hogar, pero no el de una fábrica de queso; Ulp., D.8.5.8.5-6), el afectado tiene el interdicto *ut possidetis*; y si el productor de la *immissio* pretende tener derecho a producirla, cuenta con la *actio negatoria* (Ulp., 8.3.8.5-7, ambos parcialmente it.).

5. *Aguas de lluvia.* En principio, el agua producida por las lluvias debe correr naturalmente del fundo superior al inferior (Ulp., D.39.3.1.13-15). Pero si como consecuencia de obras del hombre, así diques o zanjas, el agua es repelida al fundo superior o derivada al fundo inferior, entonces se concede la *actio aquae pluviae arcendae* (acción para que se contengan las aguas de lluvia; Ulp., D.39.3.1.10). El vecino que hizo las instalaciones y transformaciones responde por la completa restitución al estado primitivo. Así, quien hace una excavación que desvía la fuente del vecino, salvo que lo hiciera sin ánimo de perjudicar a éste (Ulp., D.39.3.1.12; Paulo, D. id. 2.9); o si alguien constituyó un dique, y éste se rompió produciendo una invasión de agua, puede ser obligado a repararlo (Paulo, D.39.3.2.5) o a si se obstruyese el cauce del agua con estiércol, también se tiene la acción para que lo limpie (Paulo, D.id. 2.6). La acción existía en la época clásica (EP, § 117); algunos de los textos de D.39.3, están alterados por los bizantinos.

6. *Edificio que amenaza ruina.* Si un edificio amenaza ruina y producir daños por derrumbes sobre el vecino, antes de que el daño se produzca, éste puede exigir al dueño de dicho edificio que preste la *cautio damni infecti* (caución de daño temido; ya existía un precedente en las *legis actiones*; Gayo, 4.19). Si el dueño del edificio que amenaza ruina no quiere dar la caución, el pretor le otorga al actor la posesión del inmueble (*missio in possessionem ex primo decreto*), y si persiste en la negativa, le será atribuida la "propiedad bonitaria" del inmueble (*missio ex secundo decreto*). En caso de oponerse a la *missio in possessionem*, el vecino tendrá acción para que el dueño del edificio que amenaza ruina pague el monto de los perjuicios temidos (Ulp., D.39.2.7 pr.; EP, § 175).

Si el muro del vecino no presenta una verticalidad perfecta, sino que tiene abultamientos, el propietario del fundo vecino deberá soportar esa circunstancia, si bien luego se habría fijado que ello era así siempre que dicho abultamiento no exceda de medio pie (Alfeno, D.8.5.17 pr., it.).

7. *Obras o construcciones realizadas en terreno ajeno.* Cuando alguien efectúa en un fundo ajeno obras o construcciones que perjudican al vecino, éste puede denunciar la obra nueva que se ha comenzado, a los efectos de impedir su continuación. Este procedimiento se denominaba *operis novi nuntiatio* (D.,

39.1; EP, § 291). En principio la denuncia (*nuntiatio*) se hace a quien está construyendo o modificando lo construido, sin recurrir al magistrado. Si pretende continuarla, el pretor decidirá si resulta fundada la oposición. El constructor sólo puede continuar si el pretor lo autoriza, o presta caución. Pero si la decisión del magistrado es negativa y no habiéndose dado caución se continúa la obra, el denunciante puede pedir al pretor el *interdictum ex operis novi nuntiatione* (llamado por la Romanística *interdictum demolitorium*), por el cual puede demoler la mencionada obra (Ulp., D.39.1.20 pr.).

8. *Obras realizadas en el fundo sin autorización en forma violenta o clandestina.* Si alguien realizara, ya en forma violenta o clandestina obras o trabajos en el inmueble ajeno sin autorización, el poseedor o el que tenga interés legítimo en que cesen los perjuicios, cuenta con el interdicto *quod vi aut clam*, para que se restablezca la cosa a su primitivo estado (Ulp., D.43.24.1 pr.; EP, § 256). Es restitutorio y provisto parcialmente de efectos penales (Ulp., D.id.1.1).

IV. Adquisición de la propiedad: modos.

§ 235. La propiedad civil (*ex iure Quiritium*) sobre las cosas se adquiere:

A) como consecuencia de una sucesión universal del titular de un patrimonio que pasa a su sucesor (así, en el caso de la *hereditas**, en la *adrogatio**, o en la *conventio in manu** de una mujer *sui iuris*); y

B) cuando existen actos especiales de adquisición, los cuales son generalmente llamados "modos" de adquirir la propiedad.

Estos modos de adquisición fueron clasificados por los romanos, según fueran del *ius civile* (así, la *mancipatio*, la *in iure cessio* y la *usucapio*) o del *ius gentium* (la ocupación, la tradición, la accesión, la especificación). Éste es el criterio seguido por Gayo (2.65), para quien el *ius gentium* está basado en la *naturalis ratio* (1.1). Justiniano habla directamente de modos del *ius civile* y modos del *ius naturale* (Inst., 2.1.11).

Otra clasificación, que pueda estar en los bizantinos, y que es plenamente aceptada por los modernos, es la de distinguir los modos "originales" y los modos "derivativos". Los primeros son aquellos que consisten en actos permitidos por el *ius*, en virtud de los cuales alguien se hace propietario sin reconocer un enajenante (así, p.ej., en la *occupatio*, cuando uno se apodera de cosas que no tienen dueño —*res nullius*—). Los modos "derivativos" son aquellos supuestos en los que alguien adquiere la propiedad de una cosa que pierde el enajenante (así, p.ej., en la *traditio*, cuando alguien toma la cosa que le deja el anterior poseedor).

1. Esta clasificación moderna, si bien se ve clara en los ejemplos dados, aparece más difícil de delinear en el Derecho Romano. Así, la apropiación de frutos puede ser tanto derivativa (caso de la *perceptio*) como originaria (caso de la *accessio*). Igualmente, es difícil de establecer a qué clase pertenece la *usucapio*. Por un lado, tiene algo de "originario", ya que es necesaria la adquisición de la posesión de la cosa, y mantenerla por un lapso, pero el otro tiene algo de "derivativo", sobre todo por la necesidad del "justo título" antecedente.

2. Lo que ocurre, además, es que para los juristas clásicos, resulta un tanto extraña la idea de "transmisión de un derecho", así como la sucesión a título singular o particular. Prefieren hablar de *translatio rei* (así, Gayo 3.85). Sin embargo, expresiones como *dominium transferre*, *translatio dominii*, etc., aparecen más tardíamente en los textos (Pap., FV., 263; Dioclec., FV. 283; Gayo, D.7.5.7; y si bien estos textos pudieron ser alterados por los posclásicos, en Gayo, 2.22, tenemos *Rem per mancipationem transferre*).

3. Es curioso que la formación de muchos de los vocablos haga referencia al que pasa a apoderarse de la cosa (*capere rem*); así, *manus capere* (en la *mancipatio*), *usu capere* (en la *usucapio*); *per capere* (en la *perceptio* de los frutos); *pro capere* (en el legado *per proactionem*); A.d'Ors. (DRP., § 157).

Así, en la *mancipatio* y en la *in iure cessio*, lo decisivo es la afirmación unilateral del adquirente, frente al silencio del anterior dueño, que renuncia a su situación de propietario.

Igualmente, en la *traditio* lo que interesa es el *capere* de quien recibe más que la actividad de quien entrega (como ocurre en la "traición" (*traditio*) que puede consistir en un dejar hacer; así, dejar que el enemigo entre en la ciudad y tome posesión de ella; A.d'Ors. DRP., § 169.2). Parece entonces como si el derecho del adquirente nace *ex nova*, ante el papel del trasmite que pierde su situación de propietario.

A) *Modos "inter vivos" derivativos*. En la época clásica existen tres modos privados de adquirir la propiedad: la *mancipatio*, la *in iure cessio* (si bien la propiedad es dada por una *addictio* del magistrado), y la *traditio*.

1. Si bien estos tres modos mencionados son los más importantes, además de ser privados, existen también otros modos derivativos, pero otorgados por el magistrado ya en un juicio, o por razones vinculadas más bien a lo publicístico. Así,

a) la *adiudicatio** como parte de la fórmula autorizada por el pretor en los juicios divisorios;

b) las *adsignaciones* de tierras públicas por parte de la autoridad a los particulares; igualmente la distribución del botín de guerra;

c) la atribución en propiedad por parte del magistrado a quien ganó la licitación en una subasta pública.

§ 236. I. *Mancipatio* (*mancipium*). a) Es un acto solemne, pero privado. En presencia de no menos de cinco testigos ciudadanos romanos púberes y de un otro de la misma condición que debe sostener una balanza de bronce (*libripens*), el adquirente, teniendo la cosa en una mano, dice: "Afirmo que este esclavo es mío *ex iure Quiritium* y que me lo he comprado con este cobre (por la moneda de as que tiene en la otra) y esta balanza de bronce". Luego, golpea con el cobre la balanza y se lo da a aquel de quien recibe en *mancipio* como si fuera el precio (Gayo, 1.119; Ulp., 19.4). Por la intervención del cobre y la balanza de bronce, es un acto *per aes et libram* (= por el cobre y la balanza).

1. En su forma originaria antigua, este ritual era de una época en la cual el dinero romano no consistía en monedas, sino en lingotes en bruto de cobre (*aes rudum*, *raudusculum*), cuyo valor venía dado por su peso. De ahí la necesidad de la balanza; no tiene nada que ver con la balanza como símbolo de la Justicia.

2. Pero, en una época posterior, se sigue manteniendo el rito, empleando sólo una pequeña moneda de cobre (*aes nummus unius*), razón por la cual no se la pesa, sino que se golpeaba la balanza. Por ello, Gayo (1.119) habla de que para su época, pero venía desde antes, la *mancipatio* era una "venta imaginaria" (*venditio imaginaria*). Sin embargo, la venta como negocio contractual consensual ya había sido realizada con anterioridad, siendo la *mancipatio* el modo de adquirir la propiedad. Por ello es que, a los efectos rituales, no se da todo el precio, sino una sola moneda. El precio o había sido pagado antes o era satisfecho luego de la ceremonia.

Por la *mancipatio* se puede adquirir la propiedad quiritaria de las *res mancipi*, así como también una *potestas* sobre los hombres y mujeres libres, denominada *mancipium* (Gayo, 1.120; 1.132).

3. La *mancipatio* puede tener muchas posibilidades de aplicación, ya que en general es un rito de adquisición de *potestas* ya sobre una persona o una *res mancipi*.

Así: a) *mancipando* al hijo o a la hija de familia se los puede dar en adopción, o emancipar; b) igualmente celebrar la *conventio in manu* respecto de una mujer; c) adquirir la propiedad de las *res mancipi* por causa de compra, donación, de dote, o por causa de *fiducia*. También, para posibilitar el acto de adquisición civil *per aes et libram**. Incluso, en la época primitiva, para obligarse por el *nexum** se empleaban las mismas formalidades *per aes et libram*, y para declarar pagado lo debido por este negocio (*solutio per aes et libram*).

Es, pues, el acto por excelencia de adquisición del

ius civile, así como la *stipulatio** será la forma normal para obligarse negocialmente.

4. Como acto del *ius civile*, los participantes deben ser ciudadanos romanos, o al menos contar con el *commercium*. Sin embargo, el esclavo puede por este modo adquirir para su dueño o el *filius* para su *pater*; aunque no pueden adquirir para sí (Gayo, 3.167).

5. La *mancipatio* debe ser siempre pura y simple; no tolera la existencia de una condición o de un plazo. En el caso especial del testamento *per aes et libram*, más que someterlo a una condición suspensiva, se trata de un acto *mortis causa*, es decir, para que valga después de la muerte del testador.

En cambio, el *mancipante* podía efectuar alguna declaración solemne tendiente a producir un efecto especial del acto (*nuncupatio*). Esto le estaba permitido por la ley de las XII Ts.: *cum nexum faciet mancipiumque, uti lingua nuncupassit, ita ius esto* (lo que se *nuncupa* por la lengua, en el *nexum* y en el *mancipium*, que eso sea *ius*"); 6.1). Así, para reservarse algún derecho sobre la cosa enajenada (*deductio*), como p.ej., el usufructo, o una servidumbre.

c) El efecto principal de la *mancipatio* de una cosa es obtener el dominio *ex iure Quiritium* (Gayo, 1.120; 2.22; 2.41). Pero esa adquisición está subordinada a que quien transmite la cosa fuera el verdadero propietario. Si no lo era, simplemente adquiere el *usus* o la *possessio*, de tal modo que para ser propietario quiritario la deberá *usucapir*, es decir, poseerla por los plazos legales. Si en el lapso intermedio, un tercero le inicia una *rei vindicatio*, el adquirente puede hacer una *denuntiatio* al enajenante, quien está obligado a prestarle su ayuda en el juicio (*auctoritatem prestare*). Ya si se niega a ello o si se pierde el juicio reivindicatorio no obstante su intervención, el adquirente puede reclamarle, por la *actio auctoritatis*, el doble del valor de la cosa (Paulo, 2.17.1-3).

1. La *actio auctoritatis* puede servir también para el caso de haber declarado el enajenante la inexistencia de una servidumbre, y ésta es luego reivindicada por su titular. En este caso, el enajenante debe pagar el doble del valor que importe la disminución.

2. También, si el enajenante no hubiera declarado la verdadera extensión del fundo, queda obligado al comprador a pagar el doble del valor del terreno faltante (*actio de modo agri*; Paulo, 2.17.4).

d) La *mancipatio* se siguió usando en la época clásica, no sólo en la de Gayo, sino también en la de Paulo y Ulpiano (19.4). Aparece usada en la época posclásica (siglo IV; CTh., 8.12.7). Formalmente es abolida por Justiniano, siendo reemplazada por la *traditio* (C.1.2.4.3).

1. En el Digesto no aparece mencionada. Expresiones como *mancipatio*, *mancipationem dare*, *mancipationem accipere*, son reemplazadas en todos los casos por *traditio*, *tradere*, *per traditionem accipere*. A su vez, *auctoritas* por *evictio**. Sólo excepcionalmente quedó en D.28.3.8.1, en relación con la emancipación. Por ello, hay que tomar la precaución de que cuando en el *Corpus Iuris* se habla de *traditio* de un fundo itálico o de un esclavo (que eran *res mancipi*), por lo común el texto primigenio decía *mancipatio* en lugar de *traditio*.

§ 237. II. *In iure cessio*. a) Este modo de adquisición, posiblemente posterior respecto de la *mancipatio*, figuraba ya en la ley de las XII Tablas (Paulo, FV. 50). Consistía en un procedimiento que había que realizar ante el magistrado (en las provincias ante el gobernador). El adquirente, teniendo la cosa en la mano, afirmaba: "Digo que este esclavo es mío *ex iure Quiritium*". Hecha esta *vindicatio*, el pretor se dirigía al cedente que estaba también presente. Si éste niega ser el propietario, o se calla, entonces el pretor atribuye el dominio (*addictio*) al que ha afirmado serlo (Gayo, 2.24).

1. Si bien la opinión prevaleciente es que estamos en presencia de un acto aparente —una *rei vindicatio* simulada—, en realidad se trata de un acto formal real, es decir una "cesión ante el magistrado", con la finalidad de adquirir el dominio quiritario. Si se tratara de un juicio aparente, la sentencia valdría *inter partes*. En cambio, acá la adquisición del dominio se realiza respecto de todos. Curiosamente, Gayo (2.24) dice que es una *legis actio*, aparentemente distinta del *sacramentum*.

2. Se la empleó —respecto de las *res mancipi*— en forma supletoria respecto de la *mancipatio*, que no exigía la presencia ante el magistrado; servía para el caso de que p.ej., no se podían lograr los testigos (Gayo, 2.25). A su vez, respecto de las *res nec mancipi*, resultaba más simple realizar una *traditio*.

b) La *in iure cessio* servía para adquirir el dominio tanto respecto de las *res mancipi* como de las *res nec mancipi* (Ulp., 19.10). Pero también se la utilizaba para ceder una tutela (Gayo, 1.168-172), una *hereditas* (Gayo, 2.34-36; 3.85-87) o una adopción (Gayo, 1.134).

Desaparece en la época posclásica. En la compilación justiniana, los bizantinos la abolieron, reemplazando su mención en los textos por la simple palabra *cessio*, que valía como "cesión".

§ 238. III. *Traditio*. a) Consiste en el acto que el enajenante (*tradens*) entregue o permita que otro (*accipiens*) tome posesión de una cosa, por lo que el papel del *tradens* puede ser total-

mente pasivo. Lo que importa es que el accipiens adquiriera el control posesorio de la cosa tradida. Por eso se debe tratar de *res corporales* (Gayo, 2.28).

Es el procedimiento usual para adquirir la propiedad quirritaria de las *res nec mancipi*. Si se realizaba respecto de una *res mancipi*, quien la recibe la tiene *in bonis* (propiedad bonitaria).

Las formas de realizar la tradición son varias:

1. Si se trata de un inmueble, en un principio se realizaba un paseo ritual alrededor del fundo (*circumambulatio glebarum*), pero luego bastaba que el tradens lo dejara libre, de tal modo que el adquirente lo encontrara desocupado. Incluso, bastaba con que el tradens lo señalara desde lo alto de una torre o a distancia, viéndose que la posesión de él estaba libre (*vacua possessio*; Celso, D.41.2.18.2). Los medievales dirán que se trata de una *traditio longa manu* (el término aparece, sin embargo, en Javoleno, D.46.3.79).

2. Si se trata de muebles, lo normal es la entrega en la mano. Así, si se hace la tradición de dinero, se realiza la cuenta de las monedas (*numeratim*, de donde *pecunia numerata*). Pero puede hacerse sin traslado del dinero, así, p.ej., conviniendo que la suma que te di en depósito, la puedes usar como si fuera un mutuo (Ulp., D.12.1.9.9).

También en otros casos no interesa el tomar directamente con las manos la cosa. Ello ocurre en distintos supuestos llamados luego por los medievales *traditio ficta*. Así, en los casos siguientes:

(i) La llamada *traditio symbolica*, que tampoco es una designación romana. Así, si te entrego las llaves de la bodega para hacerte la tradición del vino (Paulo, D.41.2.1.21), o las llaves del almacén donde están las mercaderías (Gayo, D.41.1.9.6 = Inst., 2.1.45). O marcando las cosas con señales especiales: así, poniendo una señal en una tinaja que está entre otras (Trebacio-Ulp., D.18.6.1.2). O sin tomar la cosa, p.ej., un montón de leña, pongo un guarda que la custodie (Javol., D.41.2.51).

(ii) También señalándola desde cierta distancia (p.ej., si se trata de una cosa pesada; Paulo, D.41.2.1.21: *oculis et affectu* (con los ojos y la intención)).

(iii) La llamada *traditio brevi manu*: si te hallas detentando la cosa como tenedor (así, como locatario, comodatario, etc.) y te la vendo. Para evitar que me la tengas que devolver y luego yo te la vuelvo a entregar, directamente te la quedas como poseedor de ella (Gayo, D.41.1.9.5 itp.; Inst., 2.1.44; Ulp., D.23.3.43.1, habla de *brevi manu*). Es el mismo caso dado anteriormente a propósito del dinero.

(iv) El caso del *constitutio possessorium*. Es la hipótesis inversa de la anterior. Poseo una cosa como dueño, p.ej., un fundo, y te la enajeno, pero la sigo conservando como mero tenedor, p.ej., como usufruc-

uario. En los tiempos clásicos, aunque sin llamarse así, podía haber sucesión en el caso de la *mancipatio* de un fundo haciendo reserva de que el mancipante se quedaba con el usufructo. Los pocos textos que hablan de supuestos de "constitutio possessoria" están interpolados (Ulp., D.8.1.77; Celso, D.41.2.18 pr.) y puestos al servicio de la idea bizantina de que por el mero *animus* alguien determina que no quiere seguir poseyendo (*constitutio nolle possidere*; Ulp., D.41.2.17.1).

b) El tradens debe ser propietario de la cosa respecto de la cual se hace la *traditio* y tener derecho de enajenarla. Pero no es necesario que sea hecha por el propietario, ya que también lo puede hacer un tercero autorizado por él (Inst., 2.1.42).

1. Se suele hablar de la regla *nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse haberet* (nadie puede transmitir a otro más derecho que aquel que tendría; Ulp., D.50.17.54). O en forma más simple *nemo dat quod non habet* (nadie da lo que no tiene). Este párrafo de Ulpiano corresponde a su comentario al Edicto. Probablemente se debió haber referido a la *in iure cessio hereditatis* realizada por un heredero legítimo. Éste podía ceder la herencia antes de haber hecho la aceptación de la herencia (*aditio hereditatis*). De este modo, lo que debió haber dicho, referido a este caso es que "el heredero no puede transmitir a otro más derecho que el que tendría si hubiese aceptado la herencia". Los bizantinos elevaron este caso, a regla general (cfr. Schulz, DRC, § 620).

2. Al contrario, Gayo, reflejando el pensamiento clásico, si bien en 2.20 dice que la cosa tradida "es inmediatamente tuya, siempre y cuando yo sea el dueño de ella", luego en 2.62 establece que "se puede enajenar sin ser propietario". Y da ej. en 2.64: Así, (a) el agnado curador de un demente puede enajenar la cosa de éste, según la ley de las XII Ts.; (b) el procurador respecto de la cosa del ausente, siempre que le esté permitido (Gayo, D.41.1.9.4); y (c) el acreedor pignoraticio puede vender la cosa prendada aunque no sea el propietario (Gayo, D.41.1.46: "No es nuevo que quien no tiene el dominio de otro el dominio; porque el acreedor, al vender la prenda da una causa de dominio, que él mismo no tuvo"). Por ello, la mencionada regla, que parece desconocida para los clásicos, no es absoluta.

3. A su vez, alguien puede ser propietario, pero no puede hacer la *traditio* para transmitir el dominio. Así, el marido puede ser titular de un fundo dotal, pero la *lex Julia (de fundo dotali)* le prohíbe cederlo sin el consentimiento de su mujer (Gayo, 2.63).

c) El acto de la *traditio*, dada su simplicidad, no involucra de por sí la adquisición del dominio. Para que ello ocurra es necesario que exista una "justa causa", que le sirva de fundamento para poder ser propietario. Como p.ej., te

hago la *traditio* de una cosa porque te la he vendido. También son *iustae causae* para adquirir el dominio por la *traditio*: el dar la cosa en donación, en dote o en mutuo.

1. Como mero acto la tradición puede tener un significado polivalente. Por ello, si te entrego o permito que tomes una cosa, hay que apreciar cuál es la causa (como antecedente) de por qué la tienes ahora. Así, puede haber tradición de una cosa que te he dado en comodato, en cuyo caso no será tuya. Pero si, si te la he vendido. Por ello, cuando aquí hablamos de "justa causa", ello significa que debe haber un antecedente jurídico válido para que se pueda adquirir el dominio.

2. Pueden, en cambio, existir *iniustae causae traditionis*, como, p.ej., las donaciones prohibidas entre marido y mujer.

Si falla la causa —así, p.ej., si se ha dado por causa de dote, pensando en el matrimonio futuro y éste no ocurre—, la *datio* realmente se ha operado. Quien recibió la dote es realmente propietario de ella, pero su adquisición se ha quedado "sin causa". Por ello es que no corresponde reclamarla por la *rei vindictio*, teniéndose que recurrir a la *condictio ex causa finita*.

d) A medida que se fue dejando de usar la *mancipatio* y la *in iure cessio*, la *traditio* fue, en principio, el modo normal de transmisión de la propiedad. Pero, en el derecho vulgar fue desapareciendo la distinción clásica entre el "título" (*iusta causa*) y el "modo" (ahora, la *traditio*). Como consecuencia de ello se atribuyeron efectos constitutivos directos de la propiedad a la compraventa y a la donación, aun sin haberse efectuado la tradición. Con Justiniano se retomó la regla clásica, considerando en general que "la propiedad se adquiere por la *traditio* y la *usucapio*, y no por simple pacto"; de este modo se diferencia el "título" del "modo" (C.2.3.20).

1. La diferenciación entre "título" (*iusta causa*) y "modo" (*traditio*) resulta esencial para lograr claridad y seguridad en los negocios. Así, una cosa es la compraventa, contrato del cual nacen obligaciones y otra es la tradición por la cual se transmite el dominio. Esta técnica jurídica es la que empleó Vélez Sarsfield en el Código Civil argentino. Si directamente por la compraventa se transmite el dominio, aparte de sucesivas ventas realizadas por el mismo vendedor, el comprador nunca podría estar seguro de ser realmente el propietario.

2. En el derecho vulgar, la situación aparece complicada. La práctica común era realizar un documento escrito, en el cual se solía insertar una cláusula de estilo por la cual se decía que la *traditio* había tenido lugar, lo cual podría haber ocurrido, pero que generalmente no era real. Incluso, se llega

a considerar que efectuada una donación por escrito, donde se diga que fue tradida la cosa, forma propiedad a la donataria (Diolec., FV.297). Esto luego será admitido por Justiniano (C.8.54(53).1 itp.).

3. Una reacción contra este estado de cosas se producirá con Constantino. Por una constitución del año 337, luego de denunciar el grave estado de cosas en torno de la propiedad de inmuebles (unos pagaban los impuestos, mientras que otros eran los que poseían), requiere para la venta de un inmueble una *traditio corporalis* (calificativo que hubiere sido sorprendente para un clásico), realizada en presencia de testigos (FV, 35; CTh., 3.1.2); lo mismo, en caso de donación de muebles, se requiere la tradición efectiva de la cosa (FV, 249; CTh., 2.29.1.2).

Pero los donantes, a fin de dispensarse de la tradición, efectuaban la donación pero reservándose el usufructo (caso de *constitutio possessorium*). Prohibida en el § 415 (CTh., 8.12.8) fue reconocida como permitida en el § 417 (CTh., 8.12.9; C.8.53(54).28).

4. Justiniano quiso, por un lado, volver a los clásicos y por el otro admitir ciertas prácticas usuales en el ámbito oriental. Por ello, si bien admite la necesidad de la *iusta causa* y de la *traditio* (C.2.3.20), multiplicó los casos de tradiciones fictas. Así, en el caso citado de donación, o de dote, con reserva de usufructo, la entrega de las llaves del negocio donde están las mercaderías vendidas (Inst., 2.1.45; D.41.1.9.6 itp.) o la entrega del documento de la donación (C.8.53.1 itp.).

Existieron dos casos en los cuales Justiniano admite la transmisión por mero consentimiento: a) la donación a las iglesias, obras pías y *civitates* (C.1.2.23 pr.), y b) el de la sociedad *omnium bonorum* (de todos los bienes), donde la simple convención basta para tornar a los socios condóminos (D.17.2.1.1; D.1.2 itps.).

La idea de la transmisión por la propiedad directamente por el contrato recién aparece en los escoliastas de las Basílicas, en el siglo XI.

B) Adquisición de la propiedad por la "usucapio".

§ 239. La *usucapio* es la adquisición de la propiedad quirritaria de una cosa corporal (*res mancipi* o *res nec mancipi*) mediante la posesión continuada durante un período de tiempo.

El propósito de este modo es solucionar ciertas situaciones en las cuales no era posible la adquisición de la propiedad quirritaria:

a) Primer caso: Como sabemos, para adquirir el dominio quirritario de una *res mancipi* es necesario que el vendedor haya efectuado la *mancipatio* o la *in iure cessio*. Ahora bien, si un propietario quirritario enajenaba a otro una *res mancipi*, pero le hacía simplemente la *traditio* de la cosa, el comprador, no obstante poseer la cosa, no era propietario *ex iure Quiritium* (a fines de la República se decía que la tenía in

bonis). Esto significaba una cierta situación de incertidumbre para el adquirente. Pero el *ius*, ya desde las XII Tablas, le permite pasar automáticamente a ser propietario quirritario si posee la cosa durante dos años (si se trata de un inmueble, o de un año, si la cosa era mueble (Ley XII Ts. 6.3; Gayo, 2.41; 2.44).

b) Segundo caso: A) no es el dueño de la cosa, pero se la vende a B), creyendo ser propietario, y B) la recibe también de buena fe. En realidad la venta ha sido realizada por un "no dueño" de la cosa (*a non domino*). Aquí también, si el comprador alcanza a cumplir los plazos legales, puede usucapir la cosa y transformarse en propietario quirritario, sin interesar si se trata de una *res mancipi* o *nec mancipi* (Gayo, 2.43; Inst., 2.6 pr.).

1. Gayo (2.60) nos da el siguiente caso: el depositario de una cosa muere, y su heredero sin saber que la cosa era ajena, sino que pensaba que formaba parte del acervo hereditario, la vende a otro. Aunque se haya realizado la *mancipatio* y tenga buena fe, el adquirente no adquiere la propiedad (regla: *Nemo plus iuris...*), pero puede adquirirla por *usucapio*, ya que el heredero que se la vendió no cometió *furtum** al enajenarla de buena fe.

Desaparecida la diferencia entre modos formales (*mancipatio* o *in iure cessio*) y no formales (*traditio*), así como la diferencia entre propiedad quirritaria y bonitaria, la *usucapio* tendrá la única función de hacer adquirir la propiedad del adquirente de buena fe que la compró a un no propietario (venta *a non domino* = por quien no es dueño); Inst., 2.6 pr.

§ 240. *Requisitos para usucapir*. Los requisitos se fueron formando gradualmente en el derecho romano, y quedaron expresados por los juristas medievales —considerando la situación vigente en la época justiniana— en la expresión *res habilis - titulus - fides - possessio - tempus*.

A) *Res habilis*. No resultan susceptibles de usucapición:

(i) Las *res extra commercium*, tales como las *res sacrae*, las *res religiosas*, las *res publicae*, ni tampoco los hombres libres (Gayo, 2.48; D.41.3.9; Inst., 2.6.1);

(ii) Las cosas robadas (*res furtivae*) o poseídas por la violencia (*vi possessae*); Gayo 2.45; Inst., 2.6.1.

1. El principio estaba en la ley de las XII Ts. (3.17), si bien no conservamos el texto literal. Por una *lex Atinia* (siglo III a.C.) se reafirmó la inhabilidad de las cosas adquiridas por robo. En esta ley se

establecía que el vicio desaparecía si la cosa regresaba al propietario, pudiendo entonces ser usucapida (Paulo, D.41.3.4.6). Gayo (2.45) menciona la ley *Iulia et Plautia*, que son en realidad dos leyes: la ley *Plautia* (primera mitad del siglo I a.C.; época de Sylla) que fue confirmada por la ley *Iulia de vi* (época de César o Augusto). Se refería a las cosas adquiridas con violencia. La segunda de ellas extendió, al parecer, la prohibición a los inmuebles poseídos por violencia (Juliano, D.41.3.3.2).

2. Cuando se dice que son inhábiles de usucapición las *res furtivae* y las *res vi possessae*, esto debe ser entendido no solamente respecto del ladrón o de quien ejerció violencia (no serían tampoco de buena fe), sino que es un vicio que sigue acompañando a la cosa, de tal modo que tampoco puede usucapirlas un tercero que las haya adquirido de buena fe (Gayo, 2.49; Inst., 2.6.3).

(iii) Mientras duró la vigencia de la tutela legítima de las mujeres, las *res mancipi* enajenadas por una mujer sometida a dicha tutela sin la *auctoritas* del tutor (Gayo, 2.47).

1. La prohibición se refería sólo a las *res mancipi*. Esto figuraba según dice Gayo en la ley de las XII Ts., aunque carecemos del texto. En FV.1, Paulo nos hace conocer que los sabinienses fundaban la prohibición en la falta de buena fe, mientras que los proculeyanos hablaban de falta de la causa *pro emptore*. Juliano, sobre la base de una *constitutio Rutiliana* (fines siglo II a.C.) atemperó la rigidez de la prohibición al admitir la posibilidad de usucapir la *res mancipi* vendida y traidida por la mujer, aún sin la *auctoritas* del tutor, si el comprador pagó el precio y no hubiese ofrecido la resolución de la venta antes del plazo de usucapición (FV.1).

(iv) Ya en el derecho posclásico y justinianeo, serán inhábiles de ser usucapidas: las cosas del Príncipe (C.7.38); las cosas del Fisco (Inst., 2.6.14, *in fine*); las de las iglesias y obras pías (Nov.111.1; 131.6); las cosas del ausente (C.7.33; Nov. 119. 7); y en general, las cosas cuya enajenación estaba prohibida (Paulo, D.50.16.28 pr.).

B) *Titulus*. La *usucapio* debe contar con una *iusta causa* (o como lo dicen los posclásicos, de un *titulus*, en el sentido de *iustus titulus*). Se trata del antecedente jurídico que habría perfectamente justificado la adquisición de la propiedad, de no haber mediado un vicio de forma (caso de la falta de la *mancipatio* o de la *in iure cessio* respecto de una *res mancipi*), o un vicio de fondo (caso de venta *a non domino*). De no haber existido estos vicios, hubiera sido un título perfecto. De todos modos, si bien no vale como tal, legítima la *causa possessionis*.

1. Los juristas más que elaborar una teoría de estas causas, se limitaron a señalar casos concretos de *iustae causae*: así, *pro emptore*, para el supuesto de haberla comprado (Gayo, 2.43); *pro donato*, en caso de donación por un no dueño (Ulp., D.6.2.7.3; Paulo, D.41.6.1 pr.); *pro soluto*, si se la recibió como pago (Hermog., D.41.3.46; Paulo, D.41.3.48); *pro legato*, si se la recibió como legado (Ulp., D.41.8(9).1; C.7.23); etc.

2. El problema se presenta cuando el "título" no era real, pero quien pretendía usucapir creía que había existido (título putativo). La cuestión no aparece como simple. Si bien la regla general está en Inst., 2.6.11: "El error que se apoya en una causa falsa no produce la *usucapio*, como, p.ej., si alguno creyendo que ha comprado o ha recibido en donación, pero sucede que realmente no ha habido ni compra ni donación", en el Digesto se encuentran citas favorables al acogimiento del título putativo.

Así, si ha mediado un error excusable (*tolerabilis error, iusta erroris causa*), como p.ej., en el supuesto de la cosa legada (Pomp., D.41.10.4); caso de la cosa comprada por un esclavo mandado que ha persuadido a su *dominus* que la cosa era de él (Afric. D.41.4.11); casos de cosas en general, a fin de que "tuviesen algún término los litigios" (Neracio, D.41.10.5).

Pero hay textos negativos de Paulo (D.41.3.48; D.41.4.2 pr.; D.41.4.6.1 pr.; D.41.8.2); de Papiniano (D.41.8.3); de Celso (D.41.3.27); y de Ulpiano (D.41.9.1 4; D.41.8.1). En general, los textos que admiten el *titulus putativus* están sospechados de interpolación, como admitiendo excepciones al principio general citado.

C) *Fides*. La *bona fides* (o simplemente *fides*) consiste en que el poseedor ignora que la cosa es ajena, o cree equivocadamente que aquel que se la transmitió era el dueño de ella (Modest., D.50.16.109). Siendo un estado de conciencia subjetivo, la *fides* queda presumida una vez probada la *iusta causa*. Es suficiente tenerla en el momento de comenzar la posesión, puesto que la mala fe sobreviniente no perjudica al usucapiente (principio: *mala fides superveniens non nocet*, Paulo, D.41.1.48.1; Pomp., D.41.10.4).

1 Esta regla no se aplica a los frutos, ya que la buena fe se debe tener en cada acto de apropiación (Ulp., D.41.1.23.1: caso del esclavo y de las adquisiciones que realice; la *bona fides* debe estar presente en cada uno de los momentos).

2. No se exige la buena fe en ciertos casos especiales:

a) en la *usucapio pro herede** (Gayo, 2.52);

b) cuando una *res mancipi* hubiera sido cedida por causa de fiducia (*fiduciae causa*), si el transmitente la vuelve a poseer por un año, aunque se trate del suelo, aun sabiendo que era de otro, podía recuperar

la propiedad usucapiéndola. Esta forma era llamada *usureceptio* (recobrar por la posesión); Gayo, 2.59-60;

c) también se la aplica como *usureceptio* si el *Populus* hubiera recibido una cosa en garantía de una obligación y luego vendió la cosa. Si ella ha sido poseída por su dueño puede usucapirla; Gayo, 2.61 *usureceptio ex praedictura* (quien adquiere del *Populus* es llamado *praedictor*).

d) igualmente se podía sin buena fe recuperar la integridad del fundo por desuso de una servidumbre: *usureceptio servitutis**.

D) *Possessio*. Se debe tratar de la *possessio civilis** (más propiamente *possessio ad usucapionem*). Por tanto, debe tener la cosa bajo su poder con ánimo de señorío (*animus rem sibi habendi; animus possidendi*), y no la mera "tenencia" (*possessio naturalis*), detentándolo a nombre de otro (Licinio Rufino, D.41.3.25; Paulo, D.41.2.3.1). La posesión debe ser ininterrumpida; si se la interrumpe no se continúa la anterior, sino que se inicia una nueva.

1. La interrupción de la usucapición es denominada *usurpatio* (Paulo, D.41.3.2). El propietario no puede recurrir a la violencia. El usucapiente tiene el interdicto *Unde vi**, entendiéndose que de triunfar en él no hay interrupción (Cassio-Paulo, D.41. 3. 4. 26). Pero si le es arrebatada con violencia por el propietario o un tercero, y el usucapiente no usa el interdicto o pierde el proceso, se habla de "interrupción natural" (Gayo, D.41.3.5).

2. Si alguien inicia una *rei vindicatio* contra el usucapiente, la *litis contestatio** no interrumpe la usucapición. Si el actor prueba que para ese momento procesal era el propietario, ganará el juicio, aunque el demandado alcance a cumplir el plazo de usucapición antes de la sentencia. Pero si el actor pierde el juicio, la usucapición continúa en vigor y podrá culminar eficazmente.

En el derecho justinianeo, la usucapición se interrumpe por la demanda judicial (C.7.40.2).

3. La posesión como situación de hecho no resulta comprendida en los efectos del *postliminium**, de tal modo que el prisionero de guerra que regresa debe iniciarla nuevamente, aunque nadie hubiere poseído la cosa (Javol., D.41.2.23.1).

E) *Tempus*. Según la ley de las XII Tablas (6.4), el plazo para usucapir es de dos años si la cosa es inmueble, y de un año si es mueble.

1. En realidad el texto decenviral decía: *usus auctoritas fundi biennium, ceterarum rerum annus esto*. La jurisprudencia posterior en lugar de la vieja mención de *usus auctoritas* empleará *possessio*. De este modo, lo que se dice en la ley de las XII Ts. es que la posesión para usucapir debe ser "para los fundos dos años, para las otras cosas (*ceterarum re-*

rum) que sea de un año. Si bien parecería que esa referencia es sólo respecto de los muebles, en realidad tiene un sentido más amplio. Así, se la aplicará respecto de la hereditas, que es una universalidad distinta de las cosas que la componen. La interpretación jurídica la hace entrar, al no ser un fundo, entre "las otras cosas", por lo que el plazo de la *usucapio hereditatis* será de un año (Gayo, 2.53-54).

Justiniano, considerando "que no se debe despojar con demasiada prontitud a los propietarios", establece que el plazo para usucapir las cosas muebles será de tres años, y las inmuebles (siguiendo la *praescriptio longi temporis*) debía durar diez años entre presentes y veinte entre ausentes, y se aplicaba a todas las tierras del Imperio (Inst., 2.6 pr.; C.7.31.1).

2. Se puede producir, para el cómputo la "sucesión de posesiones" (*successio possessionis*). Así, el heredero, como sucesor universal puede continuar la posesión del causante. En este caso, se tiene en cuenta la calidad de la posesión del causante, sin importar la del heredero. De este modo, si el causante poseía de buena fe, el heredero lo continúa aunque fuera de mala fe. Y si el causante poseía de mala fe, el heredero, aunque fuera de buena fe, no podrá continuarla, si bien puede comenzar una posesión nueva. Todo esto es una aplicación del principio *mala fides superveniens non nocet* (Paulo, D.41.4.2.19; Neracio, D.41.3.40; Inst., 2.6.12).

3. En cuanto al "sucesor particular" (comprador, legatario, etc.), como en el derecho clásico no se conoce la sucesión a título particular, no se puede sumar el tiempo de la posesión del causante. En cambio, Justiniano permitirá la *accessio possessionis*; esto ya había sido admitido respecto del uso del *interdicto utrubi* (Gayo, 4.151) y aplicado por Severo y Caracalla a la *longi temporis praescriptio* en el caso de la compraventa (Inst., 2.6.13; C.7.31.1.3; Paulo, D.41.4.2.20 it.).

Era necesario que tanto el causante (vendedor, donante, etc.) como el sucesor debían haber comenzado a poseer de buena fe (Ulp., D.41.2.13.13; Paulo, D.41.4.2.17). Si el causante era de mala fe, no se produce la accesión, sino que se considera que el sucesor inicia la usucapción *ex novo* (Ulp., D.44.3.5 pr.).

§ 241. La "longi temporis praescriptio".

A) Los fundos provinciales no podían ser usucapidos ni siquiera por un ciudadano romano, dado que se trataba de una propiedad especial (*supra*, § 229). Sin embargo, a partir de un rescripto de Septimio Severo y Caracalla (año 199 d.C.), se admite una protección especial para quien hubiere poseído sin perturbación un fundo provincial durante 10 años entre presentes (si el propietario vive en la misma *ciuitas*;

para Justiniano en la misma provincia) o 20 años entre ausentes (si el propietario vive en otra *ciuitas*; luego provincia); Girard, Textes, ps.201-3; Bruns, Fontes, 87 y 192.

No era, en su comienzo, una forma de adquirir la propiedad de los fundos provinciales. La protección consistía en una defensa otorgada al poseedor para resistir la acción petitoria del titular. Pensándose más en el proceso *extra ordinem*, se la denominó *praescriptio* (quizá tomando una defensa griega *apographé*, traducida por *praescriptio*; en el procedimiento formulario hubiera sido una *exceptio*). De allí es que recibe el nombre de *longi temporis praescriptio*. De este modo, el poseedor vino, de hecho, a ser considerado propietario, no quirritario, sino adecuado a la propiedad provincial.

En un principio rigió sólo para los inmuebles, pero luego se extendió a las cosas muebles (Paulo, D.18.1.76.1; Modest., D.44.3.3; Marciano, D.44.3.9). Por aproximación con la *usucapio*, se piden tanto la *fides* como el *titulus*. La reunión de los requisitos queda englobada en la expresión *iustum initium possessionis* (Paulo, 5.2.4).

B) En el Bajo Imperio, para remediar el estado de incertidumbre en que podían quedar los *possessores* de fundos provinciales que no podían usucapir ni prescribir por faltarles alguno de los requisitos, Constantino admitió que la acción reivindicatoria del propietario quedaba extinguida después de 40 años sin ejercerla (C.7.39.2). Theodosio (C.7.39.3, año 424) redujo el plazo a 30 años (*triginta annorum praescriptio* o *longissimi temporis praescriptio*).

C) Justiniano procedió a una fusión de las instituciones, tratando de volver a los principios clásicos. a) Empleará el término *usucapio* para la adquisición de cosas muebles, con los requisitos sabidos, pero estableciendo el plazo en 3 años. b) En cambio, para los inmuebles la denominación es *longi temporis praescriptio*, la cual era algo más que una *exceptio* para defenderse de la pretensión del propietario, otorgándole acciones al prescribiente (C.7.39.8 pr.). Por la constitución del C.7.33.12 establece que la l.t.p. es la denominación genérica para adquirir el dominio pleno de cualquier inmueble, exigiendo los requisitos de la *fides* y del *titulus* para la posesión durante 10 años (*inter praesentes*) y 20 años (*inter absentes*); C.7.33.12.1.; c) continúa manteniendo la *longissimi temporis praescriptio*, que será de 30 años (C.7.39.8); y para algunos casos especiales, de 40 años (bienes fiscales, del emperador, iglesias y obras pías).

1. Según la nueva terminología, *usucapio* es denominación de la adquisición de cosas muebles. Y a su vez, respecto de inmuebles será la de p.l.t. Por

ello, se interpolan los textos (así, *usucapio fundi* será reemplazada por *longa possessione capio*; Inst., 2.6.7).

2. La *longissimi temporis praescriptio* hace ahora adquirir al poseedor de buena fe el dominio, aun de las cosas furtivas, pero no de las adquiridas con violencia, otorgando al prescribiente una acción (C.7.39.8.2). La idea era que no se podía proteger el silencio del propietario que durante tan largo tiempo ha mostrado negligencia. El plazo aumenta a 40 años si se trata de bienes del fisco o privados del emperador, o de las iglesias y de las obras pías (C.11.61.14; Nov.111 y 151.6; anteriormente, las iglesias y obras pías tenían una prescripción de 100 años; C.1.2.23).

Para la *longissimi temporis praescriptio* no se exige título, sino únicamente la *fides* inicial (C.7.39.8.1). Teniendo *fides*, al igual que ocurre en la *longi temporis praescriptio*, no importa si la cosa era una *res furtiva*, pero si se trataba de cosa en principio arrebatada con violencia al propietario, nunca se podía usucapir (C.1.8.2).

B) Modos de adquisición originaria de la propiedad.

I. Ocupación (*Occupatio*).—§ 242. La ocupación es la apropiación de una cosa que no tiene dueño (*res nullius*), con ánimo de adquirirla para tenerla para sí. Así, p.ej., si cazamos una bestia feroz, o un ave o pescamos un pez (Gayo, 2.66-67).

Viene a corresponder a un principio de derecho natural, ya que la cosa que no es de nadie, es del primero que se la apropia (Gayo, 2.66; D.41.1.3 pr.; Inst., 2.1.12).

Se pueden dar varios casos de *res nullius* susceptibles de ocupatio:

I. Animales que pueden ser cazados (o pescados):

1. Hay tres clases de animales: las bestias "salvajes" (*ferae bestiae*); los animales "domesticados" (p.ej.: palomas, abejas, etc.), es decir, aquellos que pueden ser adiestrados; y los "domésticos", como las gallinas, los patos, etc. (Gayo, D.41.1.5.6).

Los primeros pueden ser ocupados por la caza; los segundos no, mientras permanezcan obedeciendo a sus hábitos de regresar (*animus revertendi*), pero si los han perdido se vuelven silvestres y pueden ser ocupados por el primero que los capture (Gayo, 2.68; D.41.1.5.5; Inst., 2.1.15). En cambio, los meramente domésticos no pueden ser apropiados por la caza; quien se apodere de ellos comete *furtum* (Inst., 2.1.16).

2. Los animales pueden ser cazados en cualquier lugar, propio o ajeno, puesto que no se los considera un accesorio del dominio. Pero no se puede cazar en terreno ajeno si el propietario se opone (Gayo, D.41.1.3.1). Si se ocasionan daños en el fundo ajeno, se deberá indemnizar al dueño por los daños y perjuicios, en virtud de la *lex Aquilia*.

3. Para ser considerado cazado, es necesario retener la pieza bajo nuestro control. Si escapa de nuestra custodia (así, si se evade o resulta difícil perseguirlo) vuelve a convertirse en *res nullius* (Gayo, 2.67; D.41.1.3.2 y 5 pr.; Inst., 2.1.12).

Se discutió sobre lo que ocurría con el animal herido y era perseguido por el cazador. Para Trebacio, el animal era suyo y otra persona no se lo podía tomar. En cambio, para otros no bastaba con la persecución, sino que era necesaria la aprehensión. Esta es la solución que preponderó: el animal es de quien efectivamente lo tome (Gayo, D.41.1.5.1; Inst., 2.1.13).

4. Respecto de las abejas, se indica en Inst., 2.1.14, que si están encerradas en tu colmena son tuyas; pero si están en forma silvestre en tu árbol, yo me puedo apoderar de ellas, como de los pájaros que han hecho un nido en tu árbol. Pero si el enjambre escapa, se da la solución de que continúa siendo del dueño mientras éste no lo pierda de vista y no sea difícil perseguirlo, y de no ser así, se hacen del primer ocupante.

5. Respecto de la pesca, rigen principios análogos (Inst., 2.1.12), teniendo en cuenta las particularidades de ésta (Paulo, D.41.2.3.14; Ulp., D.47.10.13.7; Novs. 56, 57, 102 y 104 de León el Sabio).

II. *Occupatio bellica*. Las cosas que aprehendemos a los enemigos son nuestras por el derecho natural (*naturalis ratio*); Gayo, 2.69; D.41.1.5.7; Inst., 2.1.17.

1. Son consideradas *res nullius* (Paulo, D.41.2.1.1). Los inmuebles pasan a pertenecer al *populus* (Pomp., D.49.15.20.1). Las cosas muebles que forman el botín deben ser entregadas por los soldados; de lo contrario cometen *peculatus* y son penados a restituir el *quadruplum* (Modest., D.48.13.14). Podrán ser de los soldados las cosas conseguidas en una escaramuza informal (Celso, D.41.1.51.1), o las logradas con permiso del emperador (C.8.54.1).

2. Es necesario que se trate de una guerra justa (*iustum bellum*), es decir, respecto del enemigo (*hostes*); no se aplica respecto de las cosas logradas en las guerras civiles (Ulp., D.49.15.21.1).

3. No se consideran nuestras hasta tanto las llevemos a un lugar seguro (Pomp., D.49.15.21.1), ya que si en el trayecto el enemigo las recobra, perdemos la propiedad, ya que no es que el enemigo cometa un hurto, sino que está usando correctamente el derecho (Pomp., D. *ibid.*).

4. Las cosas de los romanos tomadas por el enemigo pueden gozar del *postliminium*, de tal modo que recuperadas por los romanos vuelven a tener la situación jurídica anterior (Marcelo, D.49.15.2 pr. y 1; Pomp., D. *ibid.* 5 pr. y 2).

III. Cosas encontradas en el litoral del mar. Las cosas encontradas en el litoral del mar (*res inventae in litore mari*), como p.ej.: perlas, piedras preciosas y demás cosas que sean encontradas o mejor descubier-

tas en las costas del mar (Inst., 2.1.13; Paulo, D.42.12.1.1); son de quien las tome, siempre que sea con ánimo de apropiación.

IV. *Isla nacida en el mar (insula in mari nata)*, "lo cual raramente ocurre" (Gayo, D.41.1.7.3), puede ser apropiada por cualquiera; en cuanto a la nacida en un río (*insula in flumine nata*), en la época clásica, siendo el *ager limitatus*, podía también ser ocupada por quien la posea; pero si era *ager arcifinitus*, se consideraba que era una prolongación de la propiedad de los ribereños. Al desaparecer el rito de la *limitatio* esta última será la solución (Gayo, 2.72; D.41.1.7.3).

V. *Tesoro (thesaurus)*. El tesoro fue definido por Paulo como "un viejo depósito de dinero de cuyo dueño no exista memoria, por lo que no tiene ya propietario" (Paulo, D.41.1.31.1). Es un tanto inexacta, por cuanto además del dinero (propio de una época en que era una forma de guardarlo ante la inexistencia de bancos) puede consistir en otras cosas muebles (así, joyas). En C.10.15.1, el concepto de tesoro queda limitado a dichas cosas muebles.

1. En un comienzo, la posesión del fundo abarca el tesoro escondido en él (Bruto-Manilio-Paulo, D.41.2.3.3); de allí que quien usucapiere un fundo, posee el tesoro que hay en él (Paulo, D. cit.). Pero, a partir de una constitución de Adriano (Inst., 2.1.39), la mitad del tesoro pertenece al descubridor y la otra al propietario del fundo donde fuera hallado; si ocurre en terreno público, la mitad es del *populus* (luego, del fisco) o de la *civitas* (Inst., *ibid.*).

2. El tesoro debe ser descubierto en forma casual, o hallado con búsqueda autorizada del dueño del fundo. Se trataba de proteger a los propietarios respecto de terceros dedicados a estas búsquedas, con los daños consiguientes. De ocurrir la búsqueda contra la voluntad o ignorancia del dueño del fundo, el tesoro le corresponde a éste. En cambio, si era hallado en forma casual (p.ej., si arando lo halla), entonces al descubridor le corresponde la mitad (León, C.15.15).

VI. *Cosas abandonadas (res derelictae)*. Las cosas de alguien pueden convertirse en *res nullius* cuando éste las abandone.

1. Si se trató de *res Mancipi*, la propiedad no se pierde por la mera *derelictio*, sino que el adquirente debía usucapirla. Ello conforme a la regla de que dichas cosas no pueden transmitir la propiedad quirritaria por mera *traditio*.

Si se trata de una *res nec Mancipi*, los proculeyanos sostenían que el propietario perdía la cosa cuando alguien la ocupaba (Próculo-Juliano-Paulo, D.41.7.2.1). Por ello, para ellos es un caso de *occupatio*. Tal debió de haber sido el criterio predominante en la época clásica.

Los sabinianos entendían que la propiedad se pierde desde que el propietario se desprende de la cosa (Sabino-Cassio-Ulp., D.47.2.43.5).

Justiniano trata el tema en Inst., 2.1.46-47. En el primer párrafo trata un caso especial de *derelictio*: cuando un magistrado, p.ej., arroja monedas (*missilia*) a la muchedumbre para que las recoja el primero que pueda hacerlo (de allí que se hable de *traditio in incertam personam*). En el párrafo 47, saca la conclusión general de que quien abandona deja de ser; por la intención, dueño de la cosa desde ese momento, con lo que sigue la tesis sabiniana.

2. Las cosas perdidas continúan siendo de propiedad de su dueño, y cabe la obligación de devolverlas, sin hablarse de recompensa. Igualmente, no cabe apropiarse de las cosas que en una tempestad se arrojan al mar para aligerar la nave; continúan siendo de su dueño, y quien las ocupa comete *furtum*. La pérdida de ellas deben ser soportadas proporcionalmente (*lex Rhodia de iactu*); Inst., 2.2.48.

II. *Accesión (Accessio)*. § 243: La accesión se da respecto de una cosa accesoria ajena que se agrega a una cosa principal propia formando un solo cuerpo. La regla principal es que "la cosa accesoria accede a la principal" (*accessio cedit principali*; Ulp., D.34.2.19.13). Además, se considera que la tierra es siempre considerada una cosa principal y, por tanto, todas las cosas acceden a ella (*omne quod inaedificatur solo cedit* = todo aquello que se edifique accede al suelo; Gayo, D.41.1.7.10). El dueño de la cosa principal adquiere la propiedad de toda la cosa.

Se pueden producir los casos siguientes:

I. *Accesión de un inmueble a otro inmueble*. § 244. Son denominados "incrementos fluviales", porque ocurren como consecuencia del comportamiento de un río:

A) *Aluvión (alluvio)*. Consiste en el incremento paulatino e imperceptible de tierra, limo o arena, producido por la fuerza del río que traslada dicha materia del fundo superior al fundo inferior (Gayo, 2.70; D.41.1.7.1).

1. Se debe tratar siempre de la fuerza de la corriente de un río. Por eso no se produce el aluvión en el caso del estanque o de un lago, ya que son "aguas dormidas" y no "aguas corrientes" (Calístrato, D.41.1.12 pr.).

2. Los fundos sobre los cuales se deposita el sedimento deben ser *agri arcifinitii*, es decir, aquellos que no tienen otros límites que los naturales, y no *agri limitati*, es decir, aquellos cuyos límites han sido trazados con el rito de la *limitatio* por los agrimensores (Florentino, D.41.1.16).

En estos últimos, dada la limitación, el agregado queda fuera, pero pueden ser motivo de la *occupatio* (no propiamente *accessio*) por parte de los ribereños o de un tercero (Ulp., D.43.12.1.6). En el derecho justinianeo desaparece esta distinción de fundos.

3. Los sedimentos deben ser dejados de manera insensible y paulatina ("nuestros ojos no han podido percibirlo"; Gayo, 2.70; Inst., 2.1.20) y se deben fijar de manera efectiva en el fundo, es decir, hay que esperar que el aluvión "madure", pasando de su estado "esponjoso" a una total fijación.

B) *Avulsión (avulsio)*. Ocurre cuando por la fuerza del río éste arrastra violentamente un fragmento de tierra y árboles de un fundo superior y los agrega al fundo inferior (Inst., 2.1.21). Se diferencia del *aluvio* en que las características de éste es la "insensibilidad" y la "paulatinidad", mientras que la de la *avulsio* es la "violencia".

1. La regla general es que cualquier cosa arrastrada por la fuerza del río (*vis fluminis*) sigue perteneciendo a su propietario, quien la puede reclamar como suya por la *rei vindicatio* (Gayo, 2.71). Pero si deja pasar el tiempo y el fragmento de tierra ha "madurado" uniéndose al fundo inferior, y los árboles han echado raíces, entonces pertenecen al propietario del fundo que los recibió (Inst., 2.1.21; Gayo, D.41.1.7.2).

3. *Lecho abandonado (alveus derelictus)*. Cuando un río público se desvía, abandonando el lecho primitivo para seguir otro curso, el lecho ahora seco es apropiado por *accessio* por los propietarios ribereños, por formar parte de la continuación de sus terrenos (Inst., 2.1.23).

1. Esto, al igual que en el caso de aluvión, ocurre en la época clásica si los fundos son *agri arcifinitii*; si son *agri limitati*, son susceptibles de *occupatio*.

2. Los propietarios ribereños se lo deben dividir trazando una línea longitudinal por el medio del curso que tenía el río, y luego trazando líneas perpendiculares respecto de dicho eje, a partir de los límites de cada propiedad, con lo cual quedarán determinadas las partes (Inst., 2.1.23; Gayo, D.41.1.7.5).

3. En cambio, los terrenos por donde pase el nuevo curso se pierden para sus propietarios, ya que se hacen "públicos" (Inst., 2.1.23; Gayo, D.41.1.7.3). El caso es diferente si la ocupación de las aguas es transitoria (p.ej., una inundación), porque entonces no varía la naturaleza del fundo, ya que dado el carácter transitorio, vueltas las aguas a la normalidad, el propietario recupera la tierra (Inst., 2.1.24; Gayo, D.41.1.7.6).

4. *Isla nacida en el río (insula in flumine nata)*. Es el caso en que en un río, los sedimentos arrastrados forman una isla, de tal modo que pertenecerá proporcionalmente a los propietarios ribereños. (Gayo, 2.72; D.41.1.7.3; Inst., 2.1.22).

1. Se aplican acá lo ya dicho acerca de los *agri arcifinitii* y *agri limitati*. Mientras que para el caso de

la isla nacida en el mar, Gayo dice "raramente ocurre", respecto de la nacida en un río, habla de que "acontece con frecuencia" (D.41.1.7.3).

2. Para repartir la isla hay que proceder así:
a) Debemos traer una línea longitudinal por el medio del río, siguiendo su curso; si la isla permanece por entero entre dicho eje y una de las riveras, entonces sólo se la apropiarán los propietarios de esa ribera, quienes deberán señalar líneas perpendiculares a la longitudinal, a partir del confluente de sus propiedades.

b) Pero si la línea longitudinal pasa por medio de la isla, la repartición debe ser hecha entre los propietarios de ambas riveras, conforme al procedimiento ya señalado (Inst., 2.1.22; Gayo, D.41.1.7.3; Paulo D.41.1.29).

II. *Accesión de un mueble a un inmueble*. § 245. Sucede cuando se agrega alguna cosa mueble (semillas, plantas, edificaciones) a un inmueble ajeno, o en inmueble propio agrego dichas cosas muebles. Éstas pasan a integrar dicho inmueble. Por el principio de que lo que está en la superficie accede al suelo (*superficies solo cedit*; Gayo, 2.73), el dueño del fundo se hace propietario de la cosa agregada.

A) *Caso de la siembra (satio) y de la plantación (plantatio)*.

En el primer caso, alguien ha sembrado semillas y éstas han germinado en terreno ajeno, o viceversa, en mi campo he sembrado semillas ajenas. El propietario del fundo será dueño de lo sembrado (Gayo, 2.75; D.41.1.9 pr.; Inst., 2.1.32). En el segundo caso, ocurre lo mismo con un árbol, que desde que ha echado raíces es apropiado por el dueño del inmueble (Gayo, 2.74; D.41.1.7.13; Inst., 2.1.31). Si el árbol plantado en el límite de dos fundos ha echado raíces en ambos, pertenece en condominio a ambos vecinos (Inst., 2.1.31, *in fine*).

1. Supongamos que A es dueño de un fundo. Planta allí un árbol que es de B. Desde el momento que arraiga, el árbol, independientemente de su buena o mala fe, es de A, dueño del fundo. Si A es de buena fe, B no tiene ninguna acción para pedir la separación del árbol, ni tampoco para reclamar por enriquecimiento. En forma curiosa los clásicos entendieron que si por cualquier causa hubiera sido arrancado, no volvía a ser de su anterior propietario, "porque se convirtió en otro árbol que se alimentó de otra tierra", es decir que se había nutrido con el suelo del fundo (Paulo, D.41.1.26.2). A sólo es responsable por *furtum*, si había actuado de mala fe y hurtado el árbol.

2. Supongamos ahora que A no es el propietario del fundo, sino su poseedor de buena fe. En dicho

fundo ha plantado un árbol suyo, o sembrado con sus semillas. El árbol ha arraigado o las semillas han germinado. Si B, que es el propietario reclamara la devolución del fundo por la *rei vindictio*, A le puede oponer la *exceptio doli* alegando que se le pagan los gastos y perjuicios, lo cual puede nacer porque es poseedor de buena fe (Gayo, 2.76; D. 41.1.9; Inst., 2.1.30; 32).

B) Caso de la edificación (inaedificatio). Acá se pueden presentar dos hipótesis:

a) Cuando se edifica en terreno propio con materiales ajenos. Supongamos A es dueño de un fundo y edifica con materiales que son total o parcialmente de B. Por el principio general de la accesión, A es propietario del edificio. El problema es: el dueño de los materiales ¿tiene alguna acción?

Se podría pensar en la *rei vindictio*, puesto que continúa siendo el dueño de los materiales. Pero no puede reivindicar todo el edificio. Primeramente tendría que ejercer el *actio ad exhibendum*, para que se separen los materiales y se muestren individualizados. Pero esto estaba prohibido por la ley de las XII Tablas (59, Ulp., D.47.3.1 pr.), para evitar la destrucción de las construcciones. En cambio, aun cuando el constructor sea de buena fe, se le otorgaba la *actio de tigno iuncto* (Ulp., D.47.3.6; Gayo D.41.1.7.10; Inst., 2.1.29), por la cual podía demandar el doble del valor de los materiales (*tigna* significa en principio palos, parantes, etc., necesarios en un viñedo; por extensión interpretativa, todos los materiales de construcción).

b) Cuando se edifica en terreno ajeno con materiales propios.

Supongamos ahora que A es un poseedor del fundo cuyo propietario es B, y construye con sus materiales un edificio. Conforme a la regla general de la accesión el edificio es de B por ser el propietario del fundo. ¿Qué pasa con A dueño de los materiales? Acá hay que distinguir si su posesión era de buena o de mala fe:

i) Si ha edificado de buena fe, creyendo que el terreno era suyo, y está en posesión de la construcción, no tiene acción para exigir el precio de los materiales y demás gastos al dueño del fundo, pero frente a la *rei vindictio* de éste, puede por la *exceptio doli* oponerse a la entrega de lo construido hasta tanto se haya realizado dicho pago (Gayo, 2.76; D.41.1.7.12; Inst., 2.1.30). Pero si perdió la posesión, entonces nada puede reclamar (Juliano, D.12.6.33; D.6.1.59; Paulo, D.44.4.14).

ii) Si ha edificado de mala fe, sabiendo que el terreno era ajeno, entonces pierde el dominio de los materiales y nada puede reclamar (Inst., 2.1.30; Gayo, D.41.1.7.12), pues se consideraba que había actuado temerariamente, dado que conocía que no era propietario del suelo.

III. *Accesión de un mueble a otro mueble.* § 246. Pueden suceder los siguientes casos:

a) *adiunctio* (cuando se incorpora una cosa a otra ajena; así, una rueda a un carro):

b) *ferruminatio* (unión de dos metales; p.ej., si agrego un brazo de plata ajeno a mi candelabro; distinta de la *adplumbatio* (unión de trozos metálicos unidos por otro elemento: plomo o estaño);

c) *textura* (si a una tela ajena se le agrega un bordado o un adorno de púrpura);

d) *tinctura* (colorante con que se impregna un vestido ajeno);

e) *scriptura* (si se escribe sobre pergamino, carta u otro material ajeno);

f) *pictura* (cuando se pinta algo sobre una tela ajena).

1. La cuestión principal consiste en averiguar cuál es la cosa principal y cuál la accesoria. Los sabiniños parecen inclinarse por el criterio de la *quantitas* y de la *maior species*, es decir, hay que atender a la cosa prevaleciente por el tamaño o el volumen (así, si agrego una piedra preciosa a un vaso o a un plato, estos últimos serán cosas principales: Sabino-Ulp., D.34.2.19.13; Cassio-Paulo, D.6.1.23.5; Cassio-Pomp., D.41.1.27.2). En cambio, los proculeyanos parecen dar preferencia a la *qualitas* (así, si se agrega una mano un pie a una estatua ajena; acá coinciden con los sabiniños, pero más que el tamaño, los proculeyanos consideran la función del todo; Próculo-Paulo, D.41.1.26.1; Florentino, D.34.2.29.1).

En realidad asistimos a una casuística que puede ser innumerable. En general, en el caso de la *adiunctio*, se atiende en cada caso particular; así el carro es principal respecto de la rueda, la mano respecto de la estatua (Paulo, D.6.1.23.2-5); en la *ferruminatio* y en la *adplumbatio*, se sigue el criterio de que la cosa principal es la de mayor tamaño (Paulo, D.6.1.23.5); en el caso de la *textura*, se entiende que la cosa principal es la tela (Inst., 2.1.26); en la *tinctura*, la principal es el vestido (Paulo, D.41.1.26.3); en la *scriptura*, lo escrito accede al pergamino (Gayo, 2.77; Inst., 2.2.33); en la *pictura*, para Gayo (2.78) y para Paulo (D.6.1.23.3) es la tela; Justiniano, considerando ridículo que se le dé mayor valor a una misera tela, en relación con la obra artística, determinará que la pintura es la cosa principal (Inst., 2.1.34), criterio que no siguió con la *scriptura*.

2. En todos los casos, el dueño de la cosa principal será también el dueño de la accesoria. Si se puede separar la accesoria (caso de la rueda agregada al carro), entonces su propietario tiene la *actio ad exhibendum* (D.10.4) para separar la rueda del carro y luego de individualizada, poder ejercitar la *rei vindictio* (Paulo, 6.1.23.5).

3. Pero si no se puede separar (caso de la *scriptura*, *tinctura*, etc.), si la cosa está en poder de quien realizó la escritura o de quien era dueño de la tin-

tura, podrá oponer la *exceptio doli*, para denegar la restitución, a los efectos de que se le indemnice (Gayo, 2.77; D.41.1.9.1; Inst., 2.1.33).

Si la tiene el dueño de la cosa principal (caso del papiro en la *scriptura*), se concede una *actio in factum* a quien hizo la escritura (Paulo, D.6.1.23.5), pero para tener la cosa, deberá pagar el valor del papiro; de lo contrario el dueño de ésta es quien puede oponer la *exceptio doli* (Gayo, 2.78; D.41.1.9.2; Inst., 2.1.34).

Todo esto ocurre siempre que haya buena fe; caso contrario, corresponden la *condictio furtiva* y la *actio furti* (Gayo, 2.78; Inst., 2.1.26).

III. *Especificación (specificatio).* § 247. Se da este caso cuando alguien utilizando una materia prima ajena hace con ella una especie nueva (*nova species*), como p.ej.: si con mis uvas, tú has hecho vino; o si con mi oro, tú has hecho un anillo (Gayo, 2.79; D. 41.1.7.7; Inst., 2.1.25).

1. Para que se dé la *specificatio* es necesario:

a) que alguien con una materia prima ajena,

b) sin permiso o acuerdo con su dueño (Calístrato, D.41.1.25); en efecto, si ha mediado p.ej., un acuerdo para que con mi tela; tú me hagas un vestido, estaríamos en presencia de una locación de obra, que no se hace adquirir el dominio, que sería mío,

c) hiciera una *nova species* (así, aceite con las olivas, o una estatua con el mármol); siempre debe haber una transformación sustancial de la materia prima, ya que si p.ej., tiño una vestimenta ajena, será un caso de "accesión" (Paulo, D.41.1.26.3),

d) y, por supuesto, con ánimo de apropiarse del producto final.

2. El vocablo *specificatio* no aparece en las fuentes. Los juristas clásicos hablan de *speciem facere*, y en algún caso *novam speciem facere* (Gayo, D.41.1.7.7, in fine). La denominación de *specificatio* procede de los glosadores.

El problema era saber de quién es la cosa especificada. Los sabiniños se inclinaban por el dueño de la materia prima, mientras que los proculeyanos, por quien había realizado la cosa especificada (Gayo, 2.79; Inst., 2.1.25).

1. Sobre esta discusión se ha especulado mucho. Así, resulta inexacto vincularlo con ideologías capitalistas o laboristas, diciendo que los sabiniños eran "materialistas" y los proculeyanos "espiritualistas". Para otros, los primeros siguieron los principios estoicos, dando preferencia a la "materia" y a la "sustancia", mientras que los segundos, siguiendo la filosofía aristotélica, han hecho prevalecer la "forma".

2. Juridicamente, los juristas de las dos escuelas, parecen preocupados por otro aspecto: se trata de saber si ha ocurrido o no la extinción de la materia prima, ya que los sabiniños estiman que el mármol

con qué se ha hecho la estatua continúa siendo el mármol primitivo, el oro con qué se ha hecho el vaso sería el oro primero, etc., mientras que para los proculeyanos, como se ha fabricado una especie nueva, la materia primera se ha extinguido y por ello desaparece el dominio que su dueño tenía sobre ella, por lo que es apropiada por el especificador, ya que es una cosa nueva (*nova species*).

Existió una tercera posición doctrinaria (*media sententia*), que ya existió en la época clásica, y será la que adoptará Justiniano (Inst., 2.1.25). Si la *nova species* permite que se pueda volver a la materia prima anterior (caso del anillo que se puede fundir y recobrar el oro), la cosa pertenece al dueño de la materia prima. Pero si, al contrario, la *nova species* no permite la vuelta al estado anterior (caso del vino, o de la estatua de mármol), entonces la cosa es de quien hubiere hecho la cosa. Si para hacerla se empleó materia prima propia y también ajena (así, si con vino propio se hizo una bebida nueva mezclándola con miel ajena, o con lana propia y lana ajena se hizo un vestido), entonces es de quien hizo la cosa, "puesto que no sólo ha puesto su trabajo, sino además parte de la materia".

1. Lo que no se explica es el procedimiento de las acciones y de las indemnizaciones. Aquí se debían seguir las reglas de la accesión. Así,

a) Si la operación es reversible, el dueño de la materia prima, o poseía la cosa, o la podía reclamar ejerciendo primero la *actio ad exhibendum*, para regresar a la materia prima y luego la *rei vindictio*. Si reivindicó directamente la especie nueva, el especificador podrá interponer la *exceptio doli* para hacer pagar el mayor valor que tendría la cosa.

b) Si la operación es irreversible, el dueño de la materia prima, sólo en el caso de que esté poseyendo la cosa, podrá interponer la *exceptio doli* ante la *rei vindictio* del especificador.

c) Si la materia prima fue hurtada, en ambos casos el dueño tiene siempre la *actio furti*, puesto que la obligación de devolver queda perpetuada por el delito (Gayo, 2.79). E incluso la *condictio furtiva*, ya que dice Gayo (ibid.) "que si bien no se pueden reivindicar las cosas extinguidas, ellas pueden ser objeto de la *condictio* contra los ladrones y poseedores".

IV. *Confusión y commixión.* § 248. Tiene lugar la *confusio* cuando en forma casual o voluntaria se mezclan líquidos (así, vino o aceite) que pertenecen a distintos dueños. La *commixio* ocurre cuando se mezclan en forma casual o voluntaria sólidos (así, si se mezcla tu cobre y mi plata o el trigo tuyo con el mío); Inst., 2.1.27.28; Gayo, D.41.1.7.8.

1. Estos casos no son de accesión o de especificación. Así, si agrego un brazo a mi estatua de bronce

por medio de una soldadura del mismo metal, será un caso de *accessio*, porque hay una cosa principal y una accesoria; y la principal "atrás a sí por su superioridad la cosa ajena y la hace mía" (Paulo, D.6.1.23.4-5). En cambio, si mi lingote de plata y otro tuyo fueran reducidos a una masa, entonces es un caso de *commixtio*. Lo mismo si yo tení miel ajena la mezcló con mi vino, será un caso de *specificatio*, pero si yo aporté vino y otro miel, entonces será un caso de *confusio* (Gayo, 4.1.1.7-8).

2. En principio, las materias confundidas por voluntad de los dos propietarios, en ambos casos conforma un condominio por parte de ambos propietarios (Inst., 2.1.27).

Si la quieren dividir, tendrán que recurrir a la *actio communi dividundo* (Ulp., D.6.1.5 pr., in fine).

3. Si la mezcla ha sido realizada en forma casual o por el hecho de un tercero, es decir, no por voluntad de las partes, hay que distinguir si se puede separar o no las partes.

En caso de que fueran separables —así, p.ej., si se hubiera mezclado tu plomo con mi plata (Pomp., Ulp., D.6.1.5.1), o tu cobre con mi plata (Calístrato, D.4.1.1.12.1), o estuvieran las partes unidas con soldadura (Próculo-Pegaso-Pomp., D.4.1.1.27.2)— no se produce una situación de condominio, puesto que pueden volver a la situación primitiva. Cada propietario conserva su propiedad, pudiendo actuar por la *actio ad exhibendum* y luego por la *rei vindicatio*.

Iguamente, si se hubiera mezclado tu trigo con mi trigo, o mi ganado con el tuyo, también en forma casual, cada uno de los propietarios tiene una *vindicatio pro parte* (Inst., 2.1.28; Pomp.-Ulp., D.6.1.5 pr.).

4. Pero si la separación no es posible (caso de bronce tuyo y oro mío) o los elementos son de la misma naturaleza (p.ej., se hubiera confundido tu lingote de plata con el mío reduciéndolos a una sola masa), cada uno de las partes tiene una *rei vindicatio pro parte*. Si no se puede determinar lo que corresponde a cada uno, se podrá ejercer también la *actio communi dividundo* (Pomp.-Ulp., D.6.1.3.2; D.1.4 y 5.1). Se entiende acá que se ha producido una condominio incidental (*communio incidens*).

5. Como se ve, la *confusio* y la *commixtio* no son modos propios de adquisición del dominio, sino que provocan situaciones especiales entre los propietarios, quienes estarán a veces como condóminos y otras como propietarios que podrán reclamar sus cosas.

Un caso especial ocurre con la mezcla de monedas, que sigue reglas especiales. Así, si alguien hubiese pagado una deuda, p.ej., con monedas hurtadas, y éstas hubieran sido mezcladas con las del acreedor que las recibió, el dueño de ellas no podría, ante la imposibilidad de identificarlas, reclamarlas por la *rei vindicatio*, aunque sí por la *actio furti* (Javol.,

D.46.3.78). Pero quien gasta de buena fe el dinero ajeno, hace, a su adquirente, propietario de él (Pomp., D.46.3.17; Pap., D.23.3.81).

V. Protección de la propiedad.

§ 249. El propietario queda amparado por diversos medios:

a) Así, por un lado tiene la acción petitoria (la *rei vindicatio* y la *actio Publiciana in rem*)—así como medidas procesales preparatorias (el *interdictum quum fundum* y la *actio ad exhibendum*); igualmente, la *actio negatoria*:

b) Para reglar sus relaciones vecinales, goza de ciertas acciones (*actio finium regundorum**, *actio aquae pluviae arcendae**, así como de la *cautio damni infecti* y la *operis novi nuntiatio*); e igualmente una serie de interdictos (así, *interdictum quod vi aut clam*, etc.; ver *supra*, § 234).

c) Igualmente goza de las acciones penales por los delitos que afectan la cosa que se tiene en propiedad (así, la *actio furti**, la *actio vi bonorum raptorum**, la *actio legis Aquiliae**, etc.), así como de la *condictio furtiva* *.

d) Finalmente, como poseedor legítimo está protegido por los interdictos posesorios (v. *supra*, § 215 y ss.).

I. *Rei vindicatio*. § 250 La *rei vindicatio* es una *actio in rem* que protege al propietario civil —dominus ex iure Quiritium— contra el tercero que posee injustamente, con la finalidad de que se lo reconozca como propietario y en consecuencia se le restituya la cosa.

1. La *rei vindicatio* se puede promover respecto de las cosas particulares, sean éstas muebles o inmuebles (Ulp., D.6.1.1); incluso respecto de un rebaño en conjunto (Ulp., D.6.1.3). En cambio, para reclamar un patrimonio, o una cuota parte de él —p.ej., diciendo ser heredero—, se debe ejercer la *petitio hereditatis* *.

2. No se puede reivindicar a las personas libres, p.ej., a los hijos (*filifamiliae*). Para ellos existen acciones prejudiciales e interdictos. Pero si se alega, no la propiedad, sino que exprese la causa de la *patria potestas*, se le permite al *pater* reivindicarlos (*rei vindicatio adientia causa*; Pomp.-Ulp., D.6.1.2).

3. Lo que hay que señalar en la *intentio* es la nitidez de la cosa reclamada: "Si se prueba que el fundo Tusculano o el esclavo Stichos es de Aulo Agerio ex iure Quiritium". Con esta condición, se puede reclamar la cuota parte indivisa de un condominio (Paulo, D.6.1.6; 8).

También, en forma excepcional, se admitió una *rei vindicatio incertae partis*, cuando el actor tenía una justa causa. Así, si se reclama un legado cuyo monto exacto no se conoce por aplicarse en ese caso la *lex Falcidia**, que puede operar una reducción de

los legados para preservar al heredero su *quarta pars* (Gayo, D.6.1. 76.1).

§ 251. *Contra quién se ejerce. La rei vindicatio se ejerce:*

a) contra el poseedor de la cosa que afirma que es suya (Ulp., D. 6.1.9);

b) Si se trataba de un tenedor (así, un arrendatario, un comodatario, etc.), en un principio no se lo consideró pasivamente legitimado; había que demandar a aquel por quien tenía la cosa.

1. Para decidir quién era el poseedor, en caso de duda, se recurría al trámite previo de los interdictos (*uti possidetis; utrubi*; v. *supra* § 214.1).

2. Si el tenedor lo era respecto del actor, así era su inquilino o depositario, sólo podía actuar por la *actio in personam* que correspondiera al contrato que los unía, pero no tenía la *rei vindicatio*.

3. Si estaba poseyendo a nombre de un tercero, por una disposición de Constantino, el tenedor debe denunciar al causante de su tenencia, el cual es requerido de intervenir en él (C.3.19.2.9).

4. En el derecho antiguo (caso del *sacramentum*), el demandado debía llevar la cosa ante el magistrado. En el proceso formulario, la posesión del demandado podía ser precisada ante la pregunta del pretor. Según los proculeyanos, no era necesario que fuera poseedor en el momento de la *litis contestatio*, aunque sí en el momento de la sentencia, para ser condenado. En cambio, los sabínianos exigían una posesión efectiva al tiempo de la *litis contestatio* (Paulo, D.6.1.27.1; Ulp., D.10.4.7.4).

En la época de Justiniano, la *rei vindicatio* se extiende contra cualquier poseedor o tenedor de la cosa (Ulp., D.6.1.9 it., in fine). Incluso también (a) contra los denominados *ficti possessores*, es decir, a aquellos que sin haber sido poseedores, fingen serlo como si poseyeran realmente, p.ej., para encubrir al verdadero poseedor de tal modo que pudiera cumplirse el plazo de la usucapción (Paulo, D.6.1.27.3 it.); y también (b) contra aquellos que desde antes de la *litis contestatio* hubieran dolosamente dejado de poseer, habiendo destruido la cosa, o abandonado la posesión o tenencia (Gayo, D.1.36.1 it.).

§ 252. Desarrollo del juicio.

1. En la época clásica, la *rei vindicatio* se podía llevar a cabo por dos procedimientos:

a) *Rei vindicatio per sponsionem* (Gayo, 4.93-94). Era una supervivencia del régimen arcaico del *sacramentum**. Se acudía primero a una *sponsio*, en la cual el actor preguntaba al demandado: "Si el esclavo por el cual se acciona es mío ex iure Quiritium ¿prometes solemnemente darme 25 sestercios?". Al aceptarla, se permitía la iniciación del juicio. Esta *sponsio*, llamada *sponsio praedictialis*, en caso de ganar el actor era ejecutada, por una *actio in personam*, al

margen de la sentencia que versaba sobre la propiedad del esclavo.

Aparte de ella, las partes efectuaban otra, ya in iure, que era denominada *sponsio pro praede litis et vindictarum*, que obligaba al demandado por una suma si no restituía la cosa en caso de condena.

Esta forma *per sponsionem* desaparece en el proceso posclásico.

b) *Rei vindicatio per formulam petitoriam* (Gayo, 4.92). Es una forma posterior a la anterior. Se siguen acá las reglas del procedimiento formulario. La fórmula era así: "Si aparece probado que la cosa de que se trata es ex iure Quiritium de Aulo Agerio, y que ella, según tu arbitrio, no fuera restituida a Aulo Agerio, entonces por tanto dinero cuanto valga la cosa, condénalo a Numerio Negidio en favor de Aulo Agerio" (EP, § 69). Se podían intercalar las excepciones y repeticiones que fueran alegadas y aceptadas por el pretor. El juez tenía libertad para considerar probada la propiedad, así como las restituciones por frutos o pagos por mejoras.

3. El procedimiento *per formulam petitoriam* prevaleció en la época clásica. Con la introducción del procedimiento cognitorio (*cognitio extra ordinem*) la *rei vindicatio* apareció más simplificada, al desaparecer el procedimiento dividido en dos etapas.

§ 253. *Prueba de la propiedad*. El actor debía probar que era el propietario. Si funda su derecho en una adquisición originaria, su prueba puede verse facilitada. Pero si ha obtenido la propiedad por otro que se la ha transmitido, debía irse remontando a los títulos de los propietarios anteriores. Por eso, los juristas medievales la llamaban *diabolica probatio domini* (prueba diabólica del dominio) en alusión a los "juicios del alma" de las comedias teológicas, en las que el Diablo pretendía, sin conseguirlo, por las dificultades probatorias, el alma del muerto.

Pero en la práctica, los problemas de la prueba son solucionados gracias a la *usucaipio*. Probada ésta, obviamente el actor era el propietario.

§ 254. *Efectos de la sentencia*. En la época clásica, siendo la *rei vindicatio* una fórmula arbitraria, si bien el demandado vencido es invitado a restituir la cosa, podía optar por la condena pecuniaria (*litis aestimatio*) sobre la base de la suma del valor de la cosa y sus accesorios, según el juramento del actor (*iusiurandum in litem*). Sobre esto, v. *supra*, § 137.

En el procedimiento cognitorio, la condena puede ser la entrega directa (*manu militari*) de la cosa, con intervención de la fuerza pública (Ulp., D.6.1.68 it.).

La restitución de la cosa debe serlo con sus accesorios, frutos y productos (*cum sua causa*). En principio, se debe restituir, según el arbitrio

del juez, todo aquello que el actor habría tenido si la cosa le hubiera sido entregada en el momento de la *litis contestatio* (Gayo, D.6.1.20).

1. *Respecto de la cosa*. En la época clásica, si la cosa se deteriora o destruye antes de la *litis contestatio*, ello no se toma en cuenta, a los efectos de la *rei vindicatio*. El perjudicado puede actuar, si cabe, por el delito de daño previsto en la *lex Aquilia*. En la época de Justiniano, el que deja de poseer con dolo o culpa, antes de la *litis contestatio*, responde por ello por la propia *rei vindicatio*.

Si la pérdida o el deterioro ocurre después de la *litis contestatio*, en la época clásica debe responder el poseedor de buena fe sólo si ello ocurrió por dolo o culpa, pero no por caso fortuito, como p.ej., si el esclavo o los animales se mueren (Cassio-Paulo, D.5.3.40 pr.; Ulp., D.6.1.15.3); en cambio, el de mala fe responde aun en este caso (Proculo-Paulo D.12.1. Justiniano entiende que es como si estuviera en mora (Ulp., D.6.1.15.3 itp.).

2. *Respecto de los frutos*. a) Antes de la *litis contestatio*, los frutos conseguidos por el poseedor de buena fe pueden ser retenidos, en la época clásica, por el poseedor de buena fe, no así los frutos pendientes. Pero bajo Justiniano, debe devolver también los percibidos que están en sus manos y no haya consumido (Inst., 2.1.35).

En cuanto al poseedor de mala fe, aun en la época clásica debe devolver todos los frutos percibidos consumidos o no, ampliándolo Justiniano a aquellos que dejó de percibir (Labeón, D.6.1.73, para la época clásica; luego, Inst., 4.17.2).

b) En cambio, después de la *litis contestatio*, tanto el de buena como el de mala fe, deben devolver todos los frutos percibidos y también los dejados de percibir por negligencia (Pap., D.6.1.62.1; Inst., 4.17.2).

c) *Respecto de los gastos realizados en la cosa*. Los gastos (*impensae*) realizados en mejoras necesarias* y útiles* de la cosa deben ser retribuidos por el propietario, en la época clásica, sólo al poseedor de buena fe que los hizo.

Desde el período clásico sólo el poseedor de buena fe tiene un derecho de retención, que se ejerce por la *exceptio doli* opuesta a la *rei vindicatio* (Gayo, 2.76; Pap., D.6.1.48, 65 pr., auténticos). Justiniano le da el derecho de retención, sin necesidad de excepción. Incluso, al poseedor de mala fe, para impedir un enriquecimiento sin causa (D.5.3.38 itp.).

Además, todo poseedor tiene derecho a exigir la separación de las cosas que representen mejoras voluntarias o de placer, siempre y cuando que ello sea posible sin deteriorar la cosa, salvo que el actor prefiera quedarse con ellas indemnizando al poseedor (Celso, D.6.1.38 itp.).

II. *Actio publiciana in rem*. § 255. Es una acción pretoria, creada por un pretor Publicius (quizá, Quinto Publicio, año 67 a. C.), que le

dará su nombre. Se protegía con ella a ciertos poseedores calificados, que por no ser propietarios *ex iure Quiritium* carecían del amparo de la *rei vindicatio*. En estos casos, el pretor empleaba la terminología *in bonis habere* (v. *supra*, § 228).

Veamos los dos casos siguientes:

I. A, dueño quirritario de una *res Mancipi*, la vende a B, transmitiéndole la cosa por una *traditio*. Al no hacerle la *mancipatio* o la *in iure cessio*, B era para el *ius civile* un poseedor de buena fe y con justo título que estaba en vía de usucapir la cosa. Sin embargo, antes de cumplirse el plazo de la *usucapio*, pierde la cosa que es ahora detentada por un tercero C. En este caso B cuenta con la protección de los interdictos, pero carece de la *rei vindicatio*, por no ser propietario quirritario. Pese a ello, el pretor lo ampara considerándolo "propietario bonitario" (*in bonis habere*), y le concederá frente a ese tercero una acción análoga a la *rei vindicatio*, que será precisamente la *actio Publiciana in rem* (Gayo, 4.36; EP, § 60).

1. El pretor valora que mientras B tiene una posición expectante de una usucapción, C, al contrario, carece de fundamento para ser protegido. Por eso otorga a B la *actio Publiciana in rem*, usando de la técnica de la *fictio*. En efecto, le ordena al juez que finja haberse cumplido el plazo de la *usucapio* B actor deberá probar, sin embargo, los otros requisitos de la *usucapio* (posesión, buena fe y justo título). Debido a la *fictio* se trata de uno de los mejores ejemplos de equidad por medio de una *actio ficticia* (Gayo, 4.36).

2. Se da acá el caso especial de que A continúa siendo el propietario quirritario. Por ello, pese a haber vendido y traido la cosa, podría iniciar contra B la *rei vindicatio*. Pero de ocurrir ello, siguiendo el mismo principio de equidad, el pretor le permite a B oponer la *exceptio rei venditae et traditae* (EP, § 276), y si fuera por otra causa que la compraventa, la *exceptio doli*.

Igualmente, si la cosa ha ido a parar a A, es decir, el propietario quirritario, y B inicia contra él la *actio Publiciana in rem*, A podría oponerle la *exceptio iusti dominii*, a lo cual el pretor le concede a B la *replicatio rei venditae et traditae*.

II. Supongamos este otro caso. A, sin ser propietario de una *res Mancipi* o de una *res Mancipi* se la vende a B, dándosele por una *traditio*. La posición de B es endeble, por cuanto se la ha comprado a alguien que no es el dueño. (venta *a non domino*: por un no dueño). Si B pierde la cosa a manos de un tercero C; en este caso B no tiene contra éste la *rei vindicatio*, pero el pretor le otorga también la *actio Publiciana in rem*.

1. En este caso, si A, que no era propietario, llegara a adquirir la cosa (p.ej., por ser el heredero del verdadero dueño quirritario) y pretenda demandarlo por la *rei vindicatio*, el pretor le otorga igualmente a B la *exceptio rei venditae et traditae*.

2. Pero si aparece el verdadero propietario quirritario y ejerce la *rei vindicatio* contra B, éste no le puede oponer la *exceptio rei venditae et traditae*. Lo mismo, si la cosa llega a poder del verdadero propietario y B pretende iniciar la *actio Publiciana in rem*, le podrá oponer con éxito la *exceptio iusti dominii*, ya que B no le podrá oponer ninguna *replicatio*.

3. Como el ejercicio de la *actio Publiciana in rem* depende de la *traditio* de la cosa, puede suceder que alguien haya vendido separadamente a dos personas una cosa.

En principio, tiene la acción el comprador que recibió la cosa por *traditio* (Jul-Ulp., D.6.2.9.4).

Si luego la cosa volviera al vendedor y éste hiciera una nueva venta y *traditio* a un tercero, prevalece la primera *traditio*, considerando que el que la obtuvo por primera vez podría ejercitar la *actio Publiciana in rem* contra dicho vendedor (Neracio, D.19.1.31.2), aun cuando en esa oportunidad no era el dueño y en la segunda se hubiera convertido, p.ej., por herencia, en verdadero propietario (Jul-Pomp., D.21.3.2; Ulp., D.6.1.72).

Si la misma cosa fue comprada a dos vendedores distintos, que no eran dueños, prevalece el poseedor actual (Jul-Ulp., D.6.2.9.4; principio: "por igual causa es mejor la condición de quien posee"; *in pari causa, melior est conditio possidentis*; Paulo, 50.17.128 pr.).

A estos dos casos especiales se les puede agregar otros. Así, si B ha adquirido la posesión de una *res Mancipi* por causa de donación, o por causa de dote, o por causa de pago, el pretor lo protege por medio de la *actio Publiciana*, ya que en todos estos casos B es un *possessor ad usucapionem* (Ulp., D.6.2.1.2 ss.).

1. La *actio Publiciana in rem* es considerada en todos los casos como una *actio utilis* (*ad exemplum vindicationis*; Paulo, D.44.7.35 pr.).

2. Le compete igualmente al propietario quirritario, en tanto que concurren en él los supuestos de la *possessio ad usucapionem*, liberándolo de las dificultades probatorias de la *rei vindicatio* (*supra*, § 253).

3. Con la desaparición de las categorías de *res Mancipi et nec Mancipi*, así como también por la abolición de la propiedad quirritaria (*vacuum et superfluum verbum*; C.7.25.1), la *actio Publiciana in rem* pierde su campo originario de aplicación. Justiniano la mantiene para los supuestos de adquisición por cualquier título por un no dueño (*a non domino*; D.6.2).

III. Interdicto "quem fundum" y "actio ad exhibendum"

§ 256. Estas medidas están vinculadas con la *rei vindicatio*. Conforme a lo ya visto (*supra*, § 91), en la época clásica, cuando se actúa por una *actio in rem* (a diferencia de lo que ocurre en una *actio in personam*), aquel que es demandado no puede ser construido a ser parte en el juicio (Fur-Anth., D.6.1.80; Ulp., D.50.17.156). Le basta con negar ser el poseedor, o directamente no decir nada. Siendo así, el actor se encuentra con una dificultad, ya que para reivindicar (ya *per sponsonem* o *per formulam petitionem*) necesita la cooperación de la contraparte, no se podría formalizar la *litis contestatio*, o dicho de otra manera no habría posibilidad de juicio. Para ello el pretor concede estas dos vías:

A) Si se trataba de la *rei vindicatio* de un inmueble, y el demandado se negaba a defenderlo, el pretor le otorga el interdicto *Quem fundum*, por medio del cual se le daba al actor la posesión del mismo (EP, § 248; Lenel agrega el caso de quien dolosamente dejara de poseer). El demandado poseedor podía exigir una fianza (*satisfactio*; Paulo 1.11.1; Lenel, cit.).

B) Si se trataba de la *rei vindicatio* de una cosa mueble, el pretor otorga con antelación al actor, la *actio ad exhibendum* (EP, § 90). Esta acción podía servir:

a) como preparación para la *rei vindicatio*, ya que le puede interesar al actor identificar la cosa que quiere identificar, para demandarla correctamente (Ulp., D.10.4.3.6; Jul-Ulp. D.12.1.3.11), o si ésta estaba unida por accesión, para pedir la separación (Paulo, D.10.4.6);

b) como recurso para, cuando el actor se encontraba con que el demandado se negaba a defenderse. Siendo así, por estar en situación de *indensus*, el actor podía obtener un decreto del pretor de ser puesto en posesión de la cosa (*iussum de duci vel ferri*; Ulp., D.2.3.1.1);

c) en la época clásica, se concedía la *actio ad exhibendum* contra el que dolosamente dejó de poseer (Labeón, D.12.4.15; Ulp., D.10.4.9.1 ss.). Por ello es que cumplía un papel sustitutivo de la *rei vindicatio*. Y ésta es la razón por la cual no era necesario en esta época incluir este supuesto en la acción petitoria, como luego la hará Justiniano.

1. La *actio ad exhibendum* se concede no sólo al propietario que va a intentar luego la *rei vindicatio*. Así, a quien va a iniciar otras acciones *in rem* (caso del usufructo, del *pignus*; Ulp. D.12.1.3.4-6; y también a quien va a intentar un interdicto (Ulp., D.12.3.5), a quien quiere vindicar la libertad de una persona (Paulo, D.12.12), etc.

2. Se trata de una *actio in personam* (Ulp., D.10.4.3.3), lo que significaba que estaba obligado a trábale el juicio. Para evitar la condena, el demandado debe presentar la cosa. La *condemnatio* era arbitraria, ya que el *iudex* podía obligar a exhibir la cosa (no a restituirla), ya que de lo contrario se producía una condena pecuniaria por el valor de la cosa (Gayo, 4.51); en la época justinianea se dejó librado el monto al arbitrio del juez (Inst., 4.6.31, *in fine*; Ulp., D.10.4.3.2 itp.).

Con Justiniano en caso de que el demandado rehusara la defensa en la *rei vindicatio*, tanto en caso de cosa inmueble como mueble, se le debía poner en posesión de la cosa, posiblemente *manu militari* si seguimos el procedimiento usual de esta época (Ulp., D.6.1.68 itp.). El interdicho *quem fundum* desaparece totalmente. Y en cuanto a la *actio ad exhibendum*, quedó ampliada como una acción general que se concede a todo aquel que demuestre tener interés en la exhibición de la cosa (Ulp., D.10.4.3.9 itp.; Paulo, D.10.4.19 itp.).

IV. *Actio negatoria*, § 257. Esta *actio negatoria* (Ulp., D.8.5.2 pr.) o *negativa* (Gayo, 4.3; Inst., 4.6.2) la tiene el propietario contra aquel que pretenda tener una servidumbre o un usufructo sobre su cosa, para lograr que se declare la inexistencia de estos *tura in re aliena* (Ulp., D.10.4.3.1), debiendo en su caso restituir el fundo libre o ser condenado a una condena pecuniaria (EP, § 72).

Es la réplica de la *vindicatio servitutis* (luego llamada por los bizantinos *actio confessoria*), es decir, aquella que tienen quienes pretenden tener uno de estos *tura in re aliena* y la intentan contra los propietarios que no se los quieren reconocer (Ulp., D. 10.4.3.1).

La *actio negatoria* se caracteriza porque el actor, lo único que debe probar es que es propietario, ya que siendo el dominio, en principio libre de *tura in re aliena*, el demandado es el que tiene la carga de probar la existencia de ellos.

La condena arrastra: a) la cesación de la servidumbre o del usufructo; b) la reparación de los perjuicios ocasionados, y en su caso la devolución de los frutos (Ulp., D.7.6.5.6); c) dar una caución —*cautio de amplius non turbando*— de que el demandado vencido no causará nuevas molestias o perturbaciones (Javol., D.8.5.12).

§ 258. Publicidad de la propiedad.

1. En Roma, a diferencia de lo que ocurría en Grecia, no se contó con un sistema de publicidad inmobiliaria. En general, los romanos son "oralistas", y no "escriturarios". Prueba de ello es que los modos

de adquisición de la propiedad son orales (en la *mancipatio*, basta la presencia de cinco testigos; en la *in iure cessio*, el acto realizado ante el magistrado; en la *traditio*, el hecho público y notorio de la posesión, etc.); por lo común, el empleo de documentos escritos obedece a una influencia greco-oriental.

2. En forma muy tímida, aparecerán en el siglo IV d.C. algunas disposiciones que tenían un trasfondo de neta preocupación tributario-fiscalista (v. *supra*, § 238 d) 3). Así, Constantino, a propósito de las donaciones, considerará bueno consignar el acto en un documento escrito, que debían inscribir los magistrados (FV 249; año 316, sería del 322; C.Th.8.12.1; C.8.53.25). Y este mismo emperador (FV.35; C.Th. 3.1.2; año 313, sería del 337) obliga a vender los inmuebles ante testigos y previo pago del tributo, bajo pena de que si no se pagaba, el vendedor pierde el precio y el comprador el fundo. Zenón, continuando lo dicho por Constantino, obliga a la inscripción (*insinuatio*) de las donaciones (C.8.54(53).31; año 478). Con Justiniano continúa la obligación de la *insinuatio* en las donaciones importantes *inter vivos*, dejándola como facultativa para los otros actos (C.4.21.17). A su vez, en la tardía *Novella Valentiniana* 15, se establece un gravamen sobre las ventas, que debían pagar por mitades, pero sin hablar de inscripción de inmuebles.

3. Lo curioso es que los romanos conocían el sistema de la publicidad inmobiliaria. No sólo el existente en Grecia (Cicero, *pro Flacco*, 30), sino también el de Egipto. En este último país, existía un sistema de publicidad muy completo, que decayó en el siglo I d.C., cuando ya era una provincia romana. Y es el prefecto de Egipto, Marco Metio Rufo, quien en el año 89 publicó un edicto sobre publicidad inmobiliaria recreando el sistema anterior.

Mediante él, no se podía efectuar ninguna venta (lo mismo que gravámenes, así hipotecas, etc.) sin que previamente se pidiera al titular del Registro un "certificado de dominio" (*epistagma*) donde constara la posibilidad de efectuar el negocio. Éste debía tenerlo a la vista el escribano (*agoranome*), debiendo asentar dicha circunstancia, bajo sanción del "castigo mercenario". Luego, el escribano debía redactar una breve minuta sobre el negocio, las partes y las características del inmueble. Ésta servía para su registro en la *Bibliothèque ephthéseon*, donde se producía el asiento definitivo (*paráthesis*). El texto del Edicto (conocido como "petición de Dionisia") se puede encontrar en Bruns, *Fontes*, 73; Girard, *Textes*, 4ª ed., ps. 176 y ss., y en Riccobono, *Fontes*, I, n° 54, ps. 257 y ss.

4. Esta medida, que por un lado significa una muestra del respeto por parte de Roma de las instituciones locales de cada región del Imperio, fue una muestra de su genio jurídico, capaz de solucionar problemas ajenos a su *ius*. Pese a todo ello, el Derecho Romano, que prefiere ser "oralista" y no "escriturario", no adoptará para su uso interno el sistema registral de publicidad inmobiliaria.

VI. El condominio.

§ 259. Por el carácter "exclusivo" del dominio, dos o más personas no pueden denominarse "dueños" (*domini*) de la misma cosa (Celso, D.13.6.5.15). Pero se puede dar la figura —distinta del dominio— del condominio (*condominium*; *communio pro indiviso*).

En este caso, los condóminos mantienen una comunidad, no sobre partes dividas materiales de la cosa (por ello es *pro indiviso*), sino sobre cuotas partes ideales en dicho condominio (Ulp., D.13.6.5.15; D.45.3.5). Así, si A, B y C son condóminos o copropietarios del fundo X —salvo que se haya establecido un régimen distinto de atribución de las partes ideales—, cada uno de ellos tendrá 1/3 del fundo.

1. La primera figura de una *communio* aparece en el antiguo derecho con la comunión de bienes hereditarios que se producía automáticamente (*erctum non cito*) (Gayo, 3.154 a); a la cual hay que agregar la forma ya voluntaria del *consortium inter fratres* (Gayo, 3.154 b). En estos casos la totalidad de los bienes pertenece a todos, y cada uno de los consortes podía manumitir un esclavo, proporcionando a todos un liberto, o vender por *mancipatio* alguna de las res *mancipi* que se tuvieran en común (Gayo, *ibid.*).

2. Ya en la época clásica estas figuras desaparecen. Pero se admite la *communio* en otros casos:

a) Cuando, de manera voluntaria, las propias partes lo constituyen. Así, si A y B compran en común una cosa. También, como consecuencia de una sociedad, en la cual los socios se transfieren recíprocamente sus propios bienes en común; o

b) De manera involuntaria, en cuyo caso se habla de *communio incidens*. Así, en el caso de dos o más herederos, respecto de la herencia, o de dos o más legatarios de una misma cosa (Paulo, D.10.2.25.16; Ulp., D.17.2.31). También en el caso de *commixtio* o de *confusio* cuando se produce la mezcla irreversible de sólidos o de líquidos.

§ 260 La vida jurídica del condominio se rige por estas reglas:

A) *Actos de disposición*. Cada uno de los condóminos puede, por su cuenta y sin consentimiento de los demás, disponer de su cuota parte ideal, ya enajenándola, ya gravándola con un *pignus*. En cambio, para disponer de la totalidad de la cosa común (venderla o gravarla) es necesario el acuerdo de todos los condóminos (Pap., D.10.3.28).

1. Cuando el acto de disposición consiste en la constitución de un derecho indivisible, como p.ej. una servidumbre, se requiere la voluntad de todos los

condóminos (Ulp., D.8.1.2; Celso, D.8.3.11; Paulo, D.8.4.18; Ulp., D.39.3.10). En cambio, se permitió que un condómino pudiera ceder el usufructo de su cuota parte, sin el consentimiento de los demás (Pap., D.7.1.5).

2. En el caso de la manumisión de un esclavo común, si uno de los condóminos le daba la libertad, en la época clásica perdía su derecho, que pasaba a acrecer el de los demás condóminos (Paulo, 4.12.1; Ulp., 1.18). En el derecho antiguo (*erctum non cito* y *consortium inter fratres*) se producía un efecto solidario, por lo que la manumisión de un esclavo común, por parte de uno de los herederos, era plenamente válida respecto de los demás. Esta solución será adoptada por Justiniano, basándola en el *favor libertatis*, de tal modo que el esclavo manumitido *pro parte* se hace libre, pero se debe previamente indemnizar a los que no manumitieron (C.7.7.1; Inst., 2.7.4; Julian, D.40.12.30, *in fine*, itp.).

3. Si uno de los condóminos gravaba su cuota parte indivisa, el *pignus* pesaba sobre la totalidad del bien en condominio, debiendo no sólo responder el que lo contrajo, sino también los demás (Gayo, D.20.6.7.4).

B) *Actos de uso y administración de la cosa común*. Cada condómino puede usar de la cosa actuando independientemente, si bien cualquiera de los otros puede oponer (*ius prohibendi*).

Este derecho de veto no se funda en el ejercicio *pro parte* del dominio, sino en la cotitularidad solidaria patrimonial, que se ejerce en porciones abstractas. Por ello, un condómino no puede realizar actos materiales sin el consentimiento de los demás (Pomp., D.8.2.27.1; Marcelo, D.8.5.11; Pap., D.10.3.28). Esto tenía importancia en lo relativo a construcciones e innovaciones en la cosa común, por lo que era conveniente que el condómino que quisiera hacerlas contara con el consentimiento preventivo de los otros.

Justiniano establece que las relaciones entre los condóminos, sobre la base de que se parece a una sociedad, es un *cuasi-contrato* (Inst., 3.27.3). Por ello, tiende a limitar el *ius prohibendi*, supeditando las consecuencias de un acto ya realizado por uno de los condóminos a la falta de beneficio de la comunión de bienes (Paulo, D.8.2.26 itp.), lo cual se verá cuando se deban decidir las consecuencias de la partición ante el juez.

1. Así, si un condómino ha percibido la totalidad de los frutos que ha dado la cosa común, debe devolver los que correspondan a las cuotas partes de los demás (Ulp., D.10.3.4.3). Igualmente, si ha realizado gastos por mejoras necesarias o útiles, hechas en beneficio común, los demás, en su proporción, lo deberán indemnizar (Ulp., *ibid.*).

2. Todo condómino está obligado a tener que reparar el perjuicio causado a los otros por dolo o culpa, en la administración de la cosa en común (Paulo, D.10.2.25.18).

§ 261. La situación nacida de la *communio* es muy inestable, debido a las dificultades existentes entre los condóminos para usar y administrar económicamente la cosa común, razón por la cual a todos y cada uno de ellos se les otorga la posibilidad de lograr la partición material de la cosa, adjudicándose la parte material que les corresponde. Esto se logra por medio de la *actio communi dividundo* (para el caso de condominio de una cosa concreta) y de la *actio familiae erciscundae** (para el caso de la comunidad hereditaria).

1. Estas dos acciones (juntamente con la *actio finium regundorum**, de regulación de límites confusos) son "acciones divisorias". La fórmula cuenta en todas con la *adjudicatio*. Por ella, el juez puede atribuir a cada uno de los condóminos, la parte que le corresponde. Así, si la cosa puede ser dividida con comodidad, se da a cada uno lo que le corresponde

proporcionalmente. Si la cosa es indivisible, se puede otorgar la cosa a uno de los condóminos, quedando éste obligado a tener que pagar a los demás una suma de dinero equivalente al valor de las cuotas partes. O también se puede vender a un tercero, procediéndose a la partición en cuanto al precio recibido (Inst., 4.6.20; 4.17.4; Ulp., D.10.3.6.8, D.10.3.7 pr y 1).

2. La acción de partición no se limita a solucionar el problema de la división material de la cosa, sino que se aprovecha para regular las relaciones de créditos surgidas durante la vida comunitaria. Así, la atribución de frutos, los pagos por expensas o mejoras. Incluso, en la época de Justiniano, ambas acciones serán consideradas mixtas* (*tam in rem quam in personam*; Inst., 4.6.20), con la particularidad de que es posible ejercerlas (como la *actio pro socio*), al solo efecto del pago de estas compensaciones, pudiendo la cosa quedar indivisa (Paulo, D.10.3.14.1 itp.).

3. Por ser un modo de adquisición, la *adjudicatio* hace que la propiedad sobre las porciones materiales que correspondan a cada uno de los comuneros, se considere adquirida desde el momento en que se verifica la división (es decir, no desde la situación inicial de la *communio*). Se dice, por ello, que la sentencia tiene efectos constitutivos.

CAPÍTULO 4

IURA IN RE ALIENA

§ 262. Aparte de las limitaciones impuestas por la ley o el *ius* al propietario (ver *supra*, § 232-4), éste goza de la plena *in re potestas*, pero podía voluntariamente producir una limitación jurídica respecto de su dominio, permitiendo que de algún modo concurra con él en el ejercicio de su propiedad. Esta concurrencia se da en los siguientes casos: a) en las servidumbres; b) en el usufructo, uso y habitación; c) en ciertas situaciones amparadas por el *ius praetorium* (enfiteusis, superficie); d) en ciertas garantías reales (*pignus*; hipoteca). Podemos hablar en general de *iura in re aliena*, si bien reconocemos que la terminología no es clásica.

I. Las servidumbres.

§ 263. La palabra "servidumbre" (*servitus*) designa una carga o un gravamen que debe soportar un fundo. Esa carga o gravamen es en favor de un predio vecino, de tal modo que quien se halle en él, y haya convenido la servidumbre pueda llevar a cabo una actividad limitada en la cosa ajena, o también obtener el beneficio de una cierta abstención por parte del propietario de la cosa que soporta la servidumbre.

1. Así, p.ej., el fundo A tiene una fuente caudalosa de agua, de la que carecen los fundos vecinos B, C y D. Se puede entonces constituir servidumbres de agua, en virtud de la cual los titulares de los fundos vecinos pueden tomar el agua para sus necesidades agropecuarias.

A) En el derecho antiguo y clásico, la expresión usada era la de *servitutes* o *iura praediorum*. En efecto, sólo se utilizaba para designar las cargas que debía soportar un inmueble en favor de otro. Las fuentes nombran al fundo gravado como *fundus qui servitutem debet* —fundo que debe la servidumbre— o *fundus serviens* (en general, se suele hablar de "fundo sirviente"); y al fundo que goza del beneficio, como *fundus cui servitus debetur* —fundo al cual se le debe la servidumbre— o que *servitutem habet* (se suele hablar de "fundo dominante", aunque

el vocablo no existe propiamente en las fuentes).

1. Esta relación de la *servitus* aparece, pues, en principio, como la existente entre dos fundos (dominante y sirviente). Lo que se quiere significar es más bien la relación entre las personas que tienen la propiedad de ambos fundos, pero sin hacer mención concreta de propietarios determinados. Si éstos cambian, la *servitus*, que tiene carácter permanente, continúa como una carga del fundo sirviente, que deberá soportar su titular, en favor del fundo dominante, que beneficiará a su propietario.

2. Las servidumbres no son propiamente "derechos subjetivos" en el sentido moderno, sino caracterizaciones de la "posición jurídica del fundo sirviente", con sus cargas y gravámenes, en beneficio del fundo dominante. Por eso se habla de *ius fundi* (Próculo, D.50.16.126), de *domus cum iure suo omni* (Mod., D.33.10.8) o de *alienatio rei suae iurisque in ea sui* —venta de la cosa y de los *iura* que tenga ella en sí— (Séneca, de benef., 5.10.1). Se puede ver en estas expresiones una situación más bien objetiva, que tiende a denotar los *iura* como "cualidades" de la cosa misma, si bien están por un lado como cargas y por el otro de beneficios. Celso (D.50.16.86) nos dice: "¿Qué otra cosa son las servidumbres sino las condiciones de bonitas, salubritas y amplitud en que se hallan los fundos?"

3. Precisamente cada uno de los casos de servidumbres demuestra que éstas surgieron por exigencias de la convivencia humana, sea de la vida rústica o urbana. Pero son como "cualidades" o "atributos" que se complementan con las cosas, permaneciendo unidas a ella, pero de tal modo que aun cambiando las personas, esas ventajas continuaban acompañando a los fundos, si bien gozadas por los hombres, que son quienes las ejercitan. Comp. esto con Pomponio (D.8.3.20.3): "El *ius* de sacar agua, no corresponde al hombre, sino al predio".

B) El sentido primero de las servidumbres como prediales, se verá alterado y organizado de un modo más amplio y genérico en el derecho justiniano, clasificándolas en servidumbres reales (las que afectan tanto a fundos rústicos como a fundos urbanos) y en servidumbres personales (las establecidas en favor de una perso-

na determinada, que es la única que puede sacar los beneficios; p.ej., el usufructo (Marciano, D.8.1.1 itp.).

§ 264. *Servidumbres prediales*. Son las establecidas en un fundo rústico o urbano en favor de otro fundo. Hay algunas características generales para todas ellas:

a) Los fundos deben pertenecer a distintos propietarios. No se puede tener servidumbre sobre la cosa propia (regla: *nemini res sua servit*; Paulo, D.8.2.26).

b) Los fundos deben ser vecinos, lo cual no significa necesariamente que sean contiguos. Así, la existencia de una vía pública entre dos fundos no impide la servidumbre de paso, aunque sí la de apoyar vigas (Paulo, D.8.2.1 pr.).

c) La carga que soporta el fundo sirviente consiste siempre en un sufrir (*in patiendo*), o en un no hacer (*in non faciendo*); pero no en un hacer (*in faciendo*); Pomp., D.8.1.15.

1. Una situación especial se plantea con la servidumbre urbana de *oneris ferendi* (apoyo en el muro vecino), en la cual el propietario del muro podía ser demandado a reparar la pared a su propia costa, para que la servidumbre pudiera tener lugar (Ulp., D.8.5.6.2).

d) De la servidumbre debe resultar un beneficio o una utilidad al otro fundo; así, darle la posibilidad de sacar agua o pasar por él, e incluso la vista. Pero si se trata de una simple carga que no reporta un provecho concreto a nadie, no constituye servidumbre (Pomp., D.8.1.15).

1. La *utilitas* no debe consistir en cargas menores, como p.ej., pasear o cenar en el fundo ajeno (Paulo, D.8.1.8 pr.).

2. No se puede constituir una servidumbre predial en favor de una persona (así, p.ej., el permitirle a alguien que no es vecino, sacar agua; Ulp., D.34.1.14.3). Por ello, el titular del fundo dominante puede p.ej., utilizar el agua para riego de su fundo, pero no venderla para regar otras fincas (Afric., D.8.3.33.1; si bien con Justiniano ello puede ser posible por un pacto o *stipulatio*, *ibid.* itp. al final). Tampoco puede dar en arriendo una servidumbre (Ulp., D.19.2.44).

e) La servidumbre predial debe ser establecida a perpetuidad. No podría ser constituida ni a plazo, ni bajo condición (Pap., D.8.1.4 pr.).

1. Justiniano permitirá que se pueda establecer una servidumbre a plazo o hasta que se cumpla una condición, y los beneficiarios serán defendidos por medio de la *exceptio pacti conventi* y la *exceptio*

doli respecto a quien contra lo pactado vindicase la servidumbre (Pap., *ibid.* itp.).

f) Esto está vinculado con el tema de la "causa perpetua", que es una denominación posclásica: "todas las servidumbres de los predios deben tener una causa perpetua" (Paulo, D.8.2.28 itp.). Esto significa que siendo el beneficio una cualidad del fundo sirviente, debe permitir un ejercicio indefinidamente renovable, independiente del hecho del propietario del fundo sirviente.

1. Así, a propósito de la servidumbre de acueducto, encontramos ya en el derecho clásico, que se debe tratar de *agua perennis*: así, la que derive de un manantial (Ulp., D.43.20.1.5-8), donde el agua mana perpetuamente.

2. Los compiladores mantienen un criterio más amplio. Así, si bien se mantiene lo que dice Paulo (D.8.2.28) de que el agua debe provenir de una fuente, no de un lago ni de una cisterna, en otro párrafo de este autor (D. 8.3.9) se interpola: "pero hoy día suele constituirse desde cualquier lugar". De todos modos, no parece admisible que se establezca tomando agua de una cisterna que debe ser llenada y renovada por el propietario del fundo sirviente, puesto que sería una labor *in faciendo*.

g) Las servidumbres son "indivisibles": siendo una cualidad del fundo, subsiste en forma íntegra, aunque se dividan los fundos dominantes o sirvientes. En este caso, la servidumbre corresponde por entero a cada una de las partes, que la pueden reclamar totalmente (Paulo, D.8.3.23.3).

§ 265. *Clasificación*. Se distingue entre "servidumbres rústicas" (*iura praediorum rusticorum*) y "servidumbres urbanas" (*iura praediorum urbanorum*); Gayo, 2.14; Inst., 2.3 pr.; 2). Esta clasificación no coincide necesariamente con la ubicación de los fundos (campo o ciudad), sino más bien con la función que cumplen. Así, las primeras se refieren a dejar pasar, sacar agua u otras ventajas rurales, mientras que las segundas se relacionan con ventajas que el propietario de un edificio puede imponer a su vecino.

A) *Servidumbres rústicas*. Fueron las más antiguas. Pertenecen a ellas las de paso, en sus distintas formas y la de acueducto.

Las variantes que podía tener la servidumbre de paso eran:

- (i) el *iter*, que permite el paso a pie, a caballo, o en litera;
- (ii) el *actus*, por el cual se podía pasar ganado;
- (iii) la *vía* —que es la más amplia— no sólo permite lo que está comprendido en las dos

anteriores, sino además el poder contar con un camino (*vía*) en el fundo sirviente, el cual según la ley de las XII Tablas tenía 8 pies en la parte recta y 16 en las curvas (Ulp., D.8.3.1 pr.; Gayo D.8.3.8).

En cuanto a la *de aquae ductus*, es la que permite el transporte de agua por canales o tubos por el fundo vecino (Ulp., D.11.1 pr.).

1. Estas cuatro servidumbres eran las más antiguas. Son *res incorporales* (Gayo, 2.14) y son consideradas *res mancipi* (Gayo, 2.17).

2. Se agregaron prontamente otras vinculadas al campo: (i) la de sacar agua de una fuente (*aquae haustus*), lo que implicaba el acceso a ella (*iter ad hauriendum*), (ii) la de llevar a abreviar el ganado al campo vecino (*pecoris ad aquam adpulsus*); (iii) la de llevar a pastar el ganado (*ius pascendi*); (iv) la de sacar cal o arena del fundo sirviente; etc.

B) *Servidumbres urbanas*. Podemos citar como las más importantes (D.8.2):

(i) la de empotrar una viga en la pared vecina (*igni immittendi*);

(ii) la de apoyarse la construcción sobre la pared vecina (*oneris ferendi*);

(iii) la de proyectar un voladizo o un balcón (*ius prociendi*);

(iv) la de poder tener luz en el fundo propio, ya sea abriendo ventanas (*ius luminum*), ya impidiendo que el vecino eleve la edificación actual (*ius altius non tollendi*) y también la de poder tener vista impidiendo al vecino construcciones que las impidan (*ius ne prospectui vel luminibus officiatur*);

(v) las vinculadas con el agua, ya sea dejando caer el agua de lluvia por el tejado (*ius stillicidii*) o por una canaleta (*ius fluminis*);

(vi) la de permitir el desagote por cloacas de líquidos servidos o excrementos (*cloaca*).

1. El número de las servidumbres, de las cuales hemos mencionado las principales, no era cerrado, ya que siempre se podía crear figuras nuevas.

2. En el derecho bizantino se establecerán una serie de medidas urbanísticas (v. *supra*, § 234 (B) 3), mal llamadas servidumbres legales, que son restricciones por causa edilicias y de vecindad.

§ 266. *Constitución de las servidumbres*.

I. La forma normal en el derecho antiguo y clásico de constituir una servidumbre era mediante la *in iure cessio**, la cual era válida para todas las servidumbres. Respecto de las más antiguas (*iter, actus, via* y *aquae ductus*), por ser *res mancipi*, se las puede adquirir por *mancipatio**.

También se podía en la misma venta de un inmueble, hacer una "reserva de servidumbre"

en favor del vendedor, utilizando la misma *mancipatio* o *in iure cessio* (Javol., D.8.4.5; Paulo, D.11.7). Igualmente una servidumbre puede ser constituida en un legado *per vindicationem** (Jul., D.33.3.1); o por una *adiudicatio** en el supuesto de una acción divisoria.

II. En un principio, pudieron usucapirse, pero en el siglo I una *lex Scribonia* lo prohibió (Paulo, D.41.3.4.28(29)). El motivo parece haber sido el evitar la constitución más o menos fácil de servidumbres, atentando contra la libertad del dominio.

III. En los fundos provinciales se podían constituir servidumbres por *pactiones* o *stipulationes*, es decir, por medio de pactos o acuerdos no formales y por *stipulationes*, por los cuales el titular del fundo sirviente prometía que ni él ni sus herederos impedirán el ejercicio de la servidumbre (Gayo, 2.31; Paulo, D.45.1.2.5 ss.).

1. En la época clásica se fue permitiendo una *longi temporis praescriptio*. Los textos aparecen manipulados y no parecen fidedignos. Así, se habla de que alguien puede adquirir una servidumbre (p.ej., la de acueducto), si probaba un uso diario (*diuturnus usus*) y una larga *quasi possessio* (no menciona plazos), gozando de una *actio utilis* para probar que habiendo hecho uso por tantos años, no poseyó la servidumbre por violencia, ni clandestinamente, ni en precario (Ulp., D.8.5.10 pr.). Igualmente en Ulp., D.39.3.1.23, se habla de *vetustas, diuturnus usus*, dado que la *vetustas vicem legis tenere* (la antigüedad hace veces de ley). Y también, en las constituciones de Caracalla (C.3.34.1, del 211; y 2, del 215).

2. Justiniano, que había unificado la propiedad en una sola categoría, hará subsistir la forma de la venta de la cosa seguida ahora de *traditio* (o del legado), con la reserva de la servidumbre (*deductio servitutis*) y de la *adiudicatio*, pero además permitirá:

a) la adquisición generalizada de las servidumbres por medio de "pactos y estipulaciones" (Inst., 2.3.4). Estos pactos eran seguidos de una *quasi traditio* (Jav., D.8.1.20 itp.). En la época clásica, por ser una *res incorporalis* no era susceptible de *traditio* (Gayo, 2.35). Pero ahora se entiende que lo que se traspasa es el derecho, lo que da origen a una *quasi possessio** (Javol., *ibid.*). Esta *quasi traditio* se traduce en el compromiso de tolerar el ejercicio de la servidumbre (*patientia*; Ulp., D.6.2.11.1 itp. (Javol., *ibid.*)).

b) También la puede constituir el testador en su testamento, estableciendo que p.ej., tal fundo estará cargado con una servidumbre (Inst., *ibid.*). Incluso, lo que se denomina "destino del padre de familia". Así, si el testador tenía dos fundos, que tenían ciertos servicios comunes, pero luego estos fundos pasan a distintos herederos o legatarios, se interpretaba por una presunción tácita de la voluntad del testador, que dichos servicios debían continuar como servidum-

bres (Marcelo, D.33.2.15 itp.; *secundum voluntatem defuncti*; Scévola, D.8.5.20 itp.; D.8.2.41 pr. itp.).

c) Igualmente Justiniano termina por admitir la aplicación de la *longi temporis praescriptio* (10 años entre presentes y 20 entre ausentes); C. 7.33.12, *in fine*.

§ 267. *Extinción de las servidumbres*. Las servidumbres se extinguen por varios modos:

a) Por confusión, al tornarse alguien propietario tanto del fundo dominante, como del sirviente (regla: no existe servidumbre en la cosa propia; Gayo, D.8.6.1).

1. La adquisición debe ser por entero de ambos fundos. Si el propietario del fundo dominante, pej., adquiere parte del fundo sirviente, la servidumbre no se extingue, sino que permanece en favor del fundo dominante sobre la parte no comprada. Esto obedece a la indivisibilidad de las servidumbres (*supra*, § 264-g; Paulo, D.8.2.30.1).

2. Si más tarde el propietario de ambos fundos vende uno de ellos, no se restablece la antigua servidumbre; hay que constituir una servidumbre nueva (Paulo, D.8.2.30 pr.).

b) Por renuncia de quien goza de la servidumbre. En el derecho clásico se efectuaba una *in iure cessio*, por la cual quien goza de la servidumbre renuncia a ella frente al gravado. En tiempos de Justiniano, basta la renuncia no formal (*concessio*; v. Pomp., D.8.2.21 itp.).

1. Si se hubiera hecho la renuncia por un simple pacto, la servidumbre no se pierde. Pero, ante el reclamo de quien renunció y quiere ejercer la *actio confessoria*, se le concede al titular del fundo sirviente la *exceptio pacti conventi* o la *exceptio doti* (Ulp., D.44.4.4.12).

2. Además, se pierde la servidumbre si su titular permite que el propietario del fundo dominante haga actos que sean contrarios al ejercicio de la servidumbre. Así, tengo la servidumbre de echar el *stillicidium* en tu campo, y te permito que hagas una casa en el mismo (Paulo, D.8.6.8 pr.).

c) Por el "no uso" de la servidumbre por el plazo de dos años, es decir, el plazo requerido para la usucapción. En la época de Justiniano, 10 años entre presentes y 20 entre ausentes (C.3.34.13, año 531). Si la servidumbre era rústica, era suficiente el abandono del uso (*non usus*). Si en cambio era urbana, se exige por parte del titular del fundo sirviente que realice un acto contrario a la existencia de la servidumbre (así, elevando el edificio gravado con una *servitus altius non tollendi*; Gayo, D.8.2.6). Esto se explica, debido a que en la rústica el titular de la servidumbre debe realizar ciertos actos.

pasar, sacar agua, etc. En cambio, en la urbana, se mantiene la servidumbre como un estado permanente de los inmuebles. Si la situación creada es permitida por el titular del fundo dominante durante dos años (o 10 o 20 con Justiniano), ocurrirá la *usucapio libertatis* (Paulo, 1.17.1-2; Gayo, D.8.2.6).

d) También ocurre la extinción de las servidumbres si el fundo sirviente se convierte en *extra commercium*, o si se inunda total y definitivamente o se destruye el edificio, salvo que sea así para volver a reconstruirlo, o en general si desaparecen las condiciones de utilidad del beneficio. Ello da lugar a circunstancias de hecho, de tal modo que si se vuelven a dar las condiciones de utilidad y no se cumplió el plazo de no-uso, se restituye la servidumbre (Ulp., D.8.5.6 pr.; Javol. D.7.4.24 pr.).

§ 268. *Protección de las servidumbres*. El beneficiario de una servidumbre tiene una *vindicatio servitutis* (en el derecho posclásico es llamada *actio confessoria*). Es el reverso de la *actio negatoria* que tiene el dueño del fundo pretendidamente sirviente para negar la servidumbre.

En principio, se ejerce sólo por el titular del fundo sirviente contra el del fundo dominante que desconozca o impida la servidumbre (Ulp., D.8.5.6.3). Pero más tarde se concede también contra el poseedor del fundo dominante y contra cualquiera que impida el ejercicio de la servidumbre (Ulp., D.8.5.10.1 itp.).

1. Esta acción es similar a la *rei vindicatio*. Por ella se busca la declaración de la existencia de la servidumbre, y el restablecimiento de ella. Tiene como la *rei vindicatio* una cláusula arbitraria que permite que el demandado escape a la condena dando una caución de *non amplius turbando* (EP. § 255). Si se da la situación de indefensión, el pretor concede un *interdictum quam servitutem* (similar al *quem fundum*).

2. Ulpiano, en D.6.2.11.1, habla de una *actio Publiciana* para defender la servidumbre, pero el texto ha sido manipulado, y no corresponde al derecho clásico.

3. El titular de una servidumbre no tiene el interdicto propiamente posesorio *Uti possidetis*, que requiere la *possessio*. Pero en cambio, igualmente goza de ciertos interdictos especiales (así, de poder pasar, de *utitine actuque privato*, de sacar agua, de *aqua*, etc.; D.43.19-23); aunque en realidad no se requiere la titularidad de la servidumbre, sino que se haya usado de ella *nec vi nec clam nec precario* durante el último año. Se emplea acá la expresión *quasi possessio*, aún en la época clásica (Gayo, 4.139), terminología que continúa Justiniano (*supra*, § 221). Estos interdictos cumplen el papel preliminar respec-

to de la *vindicatio servitutis*, de modo análogo a los interdictos posesorios en la *rei vindicatio* (*supra*, § 214.1).

II. El usufructo.

§ 269. A) Por el usufructo (*usus fructus*) se confiere a una persona el derecho de usar de manera amplia una cosa ajena, así como también percibir los frutos de ella (*ius utendi fruendi*; Gayo 2.93), sin más limitación que la de no alterar la sustancia de la cosa.

1. La célebre definición de Paulo (D.7.1.1): *Usus fructus est ius alienis rebus utendi fruendi salva rerum substantia* (Usufructo es el derecho de usar y gozar en las cosas de otro, dejando a salvo la sustancia de las cosas) parece de origen clásico. Es la reproducida casi textualmente en el Cód. Civil argentino (art. 2807).

2. En cuanto a la salvedad de la sustancia, puede resultar imprecisa en ciertos casos; así, el usufructuario puede extraer piedras, arenas, minerales, etc. (Ulp., D.7.1.9.2), lo cual no resulta posible sin disminuir la sustancia de la cosa. Pero define bien la característica limitativa del usufructuario.

E! De este modo, el usufructuario, al tener el uso (*usus*) y el goce (*frui*) de la cosa tiene todas las ventajas económicas de ella (el *commodum*; los medievales hablarán de "dominio útil") quedando reservado al propietario solamente el poder enajenar o disponer de la cosa (por eso se lo llama *nudus proprietarius*, por cuanto sólo retiene el título de dominio). Se caracteriza porque es personalísimo, es decir, se lo constituye teniendo en cuenta las condiciones personales del usufructuario. Por ello es intrasmisible *inter vivos* y *mortis causa*.

1. El usufructo aparece tardíamente en la época republicana, posiblemente en el siglo III a.C., y con más seguridad en el siglo II a.C.

Resulta interesante anotar los fines prácticos que aportaba. Un *pater* podía, recurriendo a esta figura, asegurar el futuro económico de ciertas personas, a las que no quiere instituir herederos. Así, con la mujer casada *sine manu* o con hijos a los que se ha desheredado. En el testamento, les deja uno o varios legados de usufructo de determinados bienes.

Ello permitía que se pudiera lograr el mantenimiento de la integridad de la familia, sin perjudicar al hijo o hijos herederos, que quedaban como nudos propietarios, asignando el usufructo a los otros. Estos aprovechan el *uti* (así, el uso de una vivienda, mobiliario, esclavos, etc.), así como el *frui* (el poder gozar de los frutos). Si no se hubiera fijado un plazo de extinción, el usufructo se mantendría por toda la vida

del usufructuario. De este modo, equivalía a una "renta vitalicia". Pero con más fuerza jurídica que ésta —que genera solamente efectos obligacionales—, puesto que se trata de un *ius in re aliena*.

2. Es por estas circunstancias que se explica el carácter netamente *personalísimo* del usufructo (le era concedido a una persona determinada atendiendo a sus circunstancias especiales y no podía cederlo) y *temporario* (podía ser por un plazo determinado; si no había plazo, se entendía que por vida del usufructuario, pero éste no puede transmitirlo a sus herederos). Igualmente, por el origen narrado, aparece netamente vinculado con los legados.

C) El usufructo aparece como una figura jurídica particular. Pero ya en la época bizantina existió el criterio de ver en el usufructo una "parte de la propiedad" (*pars domini*; Paulo, D.7.1.4 itp.), configurándolo como una servidumbre personal (Marciano, D.8.1.1 itp.; Paulo, D.50.16.25 pr. itp.).

§ 270. Cosas susceptibles de usufructo.

A) Se puede constituir usufructo sobre inmuebles; pero también sobre esclavos, ganados, naves, etc. Se requiere que sean cosas no consumibles, puesto que según la definición de Paulo, se debe dejar a salvo la sustancia de la cosa. Y no sobre las consumibles (así, vino, aceite, dinero, etc.), ya que con su primer uso se extinguirían, lo que significaría el *ius abutendi*, es decir, la disposición material de la cosa, y con ello concluiría el usufructo (Inst., 2.4 pr.; 2).

B) Pero en la práctica se daban supuestos que posibilitaron una cierta relatividad de la regla. Así, si se legaba una cuota parte de la herencia (que podía contener cosas consumibles) se planteaba el problema de que no se podía cumplir la voluntad del testador. Un senadoconsulto del siglo I d.C. permitió el usufructo de todas las cosas del patrimonio, incluida las consumibles (Ulp., D.7.5.1). Pero como por ello se alteraba la naturaleza del usufructo, se hablaba de *quasi usufructus* (Gayo, D.7.5.2.1; Inst., 2.4.2). El legatario era propietario de dichas cosas consumibles, pero se obligaba a restituir otras de la misma cantidad y calidad, al final del cuasi usufructo (Gayo, D.7.5.7).

1. El heredero que era el cuasi nudo propietario, le exigía una caución (*cautio ex senatusconsulto*). Mediante ella se aseguraba que el legatario debía devolver a su muerte (sus herederos), o cuando sufriera una *capitis deminutio*, cosas de la misma naturaleza, calidad y cantidad. Si las cosas hubieran sido estimadas en su valor, la caución debía ser por ese monto (Gayo, D. 7.5.7).

Pero si la caución no había tenido lugar, el heredero contaba con una *condictio* para que el legata-

rio la tierra. Cuando concluía el *quasi usufructus*, se podía demandar el reintegro de lo debido por otra *condictio*. (Ulp., D.7.5.5.1; D.7.9.7 pr.).

2. Después de este s.c. se discutió si era posible el usufructo de créditos obligacionales (*usufructus nominum*). Nerva lo admitió únicamente en favor del deudor mismo que se beneficiaba con la condonación de los intereses. Pero Próculo y Cassio llevaron adelante la idea de que el legado de créditos podía ser hecho en favor de otro (Ulp., D.7.5.3). De este modo, los intereses (frutos) que cobraba eran para él, e incluso se admitió que podía disponer del capital cobrado, que luego debía devolver cuando finalizara el *quasi usufructo* (Pap., D.33.2.24, C.3.33).

3. Como se puede apreciar, los casos de *quasi usufructus* se parecen más a un mutuo que a un *ius in re aliena*. La *actio* para el "nudo *quasi propietario*" (en realidad era un acreedor) no es *in rem*, sino *in personam*. Así, para exigir la *cautio* cuando no se devolvían las cosas se utilizaba la *actio ex stipulatu*. Justiniano dará la *condictio certae creditae pecuniae* (si se trataba de dinero), o la *condictio certae rei* (si se trataba de otras cosas consumibles). Estas son las mismas que protegen el mutuo de dinero o de cosas consumibles (Ulp., D.7.9.7 pr.; D.7.5.5.1 itp.).

§ 271. *Ejercicio del usufructo*. El usufructuario tiene el beneficio de usar (*uti*) ampliamente de la cosa, e igualmente de poder aprovecharse de los frutos que la cosa produzca (*frui*). El *uti* y el *frui* no aparecen deslindados, sobre todo si tenemos en cuenta que para poder gozar de los frutos es necesario el uso (*fructus sine usu esse non possunt*; Paulo, 3.6.24).

A) El *uti* permite usar de la cosa, pero de una manera regular (como lo haría un *bonus paterfamilias*; Inst., 2.1.38). La regla general, en el derecho clásico, es que el usufructuario no puede alterar el destino económico de la cosa (el *salva rerum substantia*; Paulo, D.7.1.1; Ulp., 24.26). Así, si se trataba de un fundo de recreo, no podía sacar los canchales y árboles para hacer huertas (Ulp., D.7.1.13.4). En el derecho bizantino, esto se flexibilizará. La regla será que "el usufructuario no debe empeorar la condición (causa) de la propiedad, pero puede mejorarla" (Ulp., *ibid.*, itp.).

B) En cuanto al *frui*, el usufructuario adquiere la propiedad de los frutos naturales por percepción (*per perceptionem*; Ulp., D.7.1.12.5; Inst., 2.1.36) y los civiles, día por día (Ulp., D.7.1.25.2; D.19.2.9.1). En cambio, los productos (beneficios de la cosa que no se renuevan periódicamente), no pueden, en principio, ser gozados por el usufructuario; así cortar los árboles frutales, ni demoler los edificios (Ulp., D.7.1.13.4).

1. Recordemos que la *perceptio* involucra el acto de recoger los frutos (o comenzar a recogerlos); así, cortar el trigo, o sacar las uvas o las aceitunas (Paulo, D.6.1.78); Mientras estén pendientes o unidos a la tierra son del propietario.

2. Por ello, si a la muerte del usufructuario no han sido recogidos, los frutos son del nudo propietario, y no de los herederos del usufructuario (Inst., 2.1.36). Si aún pendientes, son robados, el usufructuario no tiene la *condictio furtiva** para recuperarlos, puesto que ésta le pertenece al propietario; aunque sí, como interesado, tiene la *actio furti* (Ulp., D.7.1.13.5).

C) La casuística de los juristas es muy interesante, puesto que aclara muchas situaciones particulares:

a) si se trata de un fundo, el usufructuario se aprovecha de todo lo que nace en él y que sea percibido, si bien debe recoger los frutos en forma no perjudicial para la explotación, como un *bonus vir* (Ulp., D.7.1.9 pr.);

b) si se trata de una casa, no debe hacer de ella una casa pública, ni dividirla en cuartos más pequeños (Ulp., D.7.1.13.8). Pero sí puede alquilarla —al arrendarla no está cediendo el usufructo, sino conviniendo su ejercicio—, gozando de las rentas del alquiler (Ulp., D.7.1.7.1; D.12.2.2).

1. Sin embargo, pesa sobre el usufructuario el deber de atender las reparaciones (una *modica refectio*); no ha de reconstruirla si se destruye sin culpa suya; debe también pagar los tributos u otras cargas que pesen sobre la casa (Ulp., D.7.1.7.2).

c) Si se trata de un fundo donde hay un sauzal, un cañaveral o un bosque maderable (*silva caedua*) puede aprovecharse de los sauces, cañas o árboles, según lo hacía el propietario, e incluso venderlos (Ulp., D.7.1.9.7). Está obligado a replantar los árboles (Cassio-Ulp., D.7.1.7.3).

1. Aun no tratándose de estos casos, se puede aprovechar de los árboles derribados por la fuerza del viento, para su uso y el de su granja; pero no para hacer leña si tuviera de donde proveerse de ella (Labéon-Ulp., D.7.1.12 pr.).

d) Si se trata del usufructo de un esclavo, es del usufructuario todo aquello que obtenga el esclavo como consecuencia directa de su trabajo o negociando con bienes del usufructuario; también lo puede locar y percibir los réditos producidos (frutos civiles). Pero si se trata de ingresos producidos por otra causa (así, sucesiones, legados) no se entiende que sean frutos, perteneciendo al nudo propietario (Gayo, 2.91 = D.41.1.10.3).

1. Debe usar del esclavo conforme a su condición. Así, si es un copista de libros, no lo puede enviar a

trabajar en el campo; o si fuera un músico, destinarlo a mayordomo (sería ir contra el principio del *salva rerum substantia*; Ulp., D.7.1.15.1).

2. En cuanto a los hijos de la esclava, el punto apareció discutido ya en época de Cicerón (*de fin.* 1.4; Ulp., D.7.1.68 pr.), prevaleciendo la tesis de que no se los considera frutos, por lo que serían del nudo propietario. Se mencionan motivos humanitarios ("parecería absurdo, en efecto, considerar como fruto al hombre, para quien la naturaleza le ha criado todo"; Gayo, D.22.1.28.1; Inst., 2.1.37). Curiosamente se admite que sean del usufructuario, si el usufructo era en forma determinada de parto de la esclava (Ulp., D.7.1.68 pr.).

e) Si se trata de ganados, las crías que nacen son del usufructuario (Ulp., D.7.1.68.1). Está obligado a mantener el número de cabezas, reemplazando los animales que hayan muerto (Ulp., Dig. id., 2).

f) Si en el fundo dado en usufructo hay canteras, el usufructuario puede extraer los minerales, siguiendo la explotación que realizaba el propietario, usando de ellas como *bonus paterfamilias* (Ulp., D.7.1.9.2). Siguiendo el criterio de que puede "mejorar" la causa de la cosa, se le permitirá abrir canteras nuevas "si para esta finalidad no ha de ocupar una parte importante del campo"; e incluso minas de metales, si en nada perjudicare a la agricultura (Ulp., D.7.1.13 5 itp.).

1. Incluso, en la parte final del párrafo, evidentemente manipulado, se dice que si con la apertura de minas o canteras nuevas se obtiene más rédito que con las viñas o los arbustos, o los olivares que hubo "quizá podrá también arrancarlos, puesto que se permite mejorar la propiedad". En la época clásica, esto hubiera significado un cambio en el destino de la cosa, a la que se alteraba, yendo en contra del *salva rerum substantia*.

2. Curiosamente aparece un adelanto de la ecología, por cuanto no podía el usufructuario hacer alteraciones que "vicien la atmósfera del campo" (Ulp., D.7.1.13.6).

§ 272. *Constitución del usufructo*. A) El usufructo se constituye, en principio por los mismos modos que las servidumbres prediales. El modo usual más generalizado, por las razones dadas a propósito de su aparición, fue el legado *per vindicationem*. De esta forma, el testador deja el dominio al heredero, pero reserva su goce (*uti frui*) al legatario usufructuario (Gayo, D.7.1.6 pr.).

1. Puede también darse el caso de legarse el dominio deducido el usufructo, para que éste quede

al heredero, siendo el legatario el nudo propietario (Gayo, D.7.1.6 pr.).

2. Si hablamos del legado *per vindicationem**, es porque por este modo el testador puede transmitir *ipso iure* el usufructo al legatario. Podría ocurrir también en el legado *per damnationem* o por fideicomiso, pero entonces la constitución no es directa; el legatario deberá pedirlo al heredero, quien queda obligado a constituirlo por un acto *inter vivos* (p.ej., una *in iure cessio*); Paulo, 3.6.17. El legatario cuenta con la *actio ex testamento*.

B) Por actos *inter vivos*, el modo usual era la *in iure cessio** (Gayo, 2.30). También por medio de una *adiudicatio** en los juicios divisorios (Gayo, D.7.1.6.1). En cambio, en el derecho clásico no resulta verosímil la adquisición del usufructo por *usucapio*. En los fundos provinciales se utilizan los pactos y estipulaciones (*pactiones et stipulationes*; Gayo 2.31).

1. Al igual que con las servidumbres, si se constituía sobre una *res mancipi*, se podía hacer una *mancipatio* con deducción del usufructo. Gayo (2.33) hace notar que acá no es propiamente el usufructo lo mancipado, sino que como consecuencia del negocio, aparece retenido por el vendedor. La *deductio* también podía efectuarse en la *in iure cessio* (FV. Paulo, 47).

C) En el derecho justiniano, el usufructo puede adquirirse por legado, y también por *adiudicatio* (Gayo, D.7.1.6 pr.; 1). Sin embargo, al igual que para las servidumbres prediales, por actos *inter vivos*, el modo usual son los pactos y estipulaciones (Inst., 2.4.1), seguida de la *traditio usufructus* (o *traditio rei deducto usufructu*); así, Ulp., D.6.2.11.1; D.7.1.25.7; D.7.4.1 pr. itps. (v. *supra*, § 266.2). También se admite, al igual que para las servidumbres prediales por la *longi temporis praescriptio* (C.6.60 y 61; 7.33.12, *in fine*).

§ 273. *Duración del usufructo*. La constitución del usufructo era, por lo general vitalicio, es decir, duraba mientras viviera el usufructuario. Pero también se admitió que se estableciera por un plazo determinado (p.ej., 10 años; FV. Paulo, 48). Si se hubiera constituido en favor de un municipio, se estableció un plazo de 100 años, "porque éste es el término de la vida de un hombre de larga vida" (Gayo, D.7.1.56; D.33.2.8; itps.).

El usufructuario no puede ceder el usufructo a un tercero, pues está concedido a alguien en forma personal e intransferible (Gayo, 2.30). Pero si podría locar o vender las ventajas económicas del usufructo. El tercero sería un simple locatario o comprador de los beneficios, pero el usu-

fructo continúa siempre en cabeza del usufructuario (Ulp., D.7.1.12.2). Sin embargo, se permitía hipotecar el usufructo, aun contra la voluntad del nudo propietario (Pap.-Marciano, D.20.1.11.2).

§ 274. *Extinción del usufructo*. Puede ocurrir de varios modos:

a) Por la muerte del usufructuario, o por haberse producido la *capitis deminutio* de éste (Inst., 2.4.3) o por haberse finalizado el plazo establecido (FV.48).

1. En el caso de la muerte, dado el carácter personal del usufructo, no pasa nunca a los herederos del usufructuario (Ulp., D.7.4.3.3).

2. La incapacidad producida por la *capitis deminutio* (máxima y media) resultaba equiparable a la muerte (FV.61). Para el caso de la "mínima", se consideró que el constituyente del usufructo, para evitar situaciones contrarias a su voluntad, podía establecer una cláusula especial a fin de que no se extinguiera el usufructo (FV.64). Justiniano dispuso directamente que la *c.d. minima* no lo extinguía (C.3.16.2; año 530; Inst., 2.4.3).

b) Por confundirse en una las personas del propietario y del usufructuario. Esto podía ocurrir (i) por renuncia del usufructuario, quien hacía una *in iure cessio* del usufructo al propietario (Gayo, 2.30, quien señala que sería el único caso admitido de cesión del usufructo), y (ii) por la *consolidatio*, cuando el usufructuario adquiría la propiedad de la cosa y reunía la totalidad del dominio de ella (Inst., 2.4.3).

c) Al igual que para las servidumbres prediales: (i) por el *non usus* (época clásica 1 año para los muebles y 2 para los inmuebles; Paulo, 3.6.30; para Justiniano por el plazo de 10 o de 20 años para los inmuebles (C.3.34.13; no se menciona a los muebles, pero cabe suponer 3 años); (ii) por la desaparición total y definitiva de la cosa (v. *supra*, § 267.d).

§ 275. *Protección del usufructo*. A) Para defender su situación el usufructuario cuenta con la *vindicatio usus fructus* (en época de Justiniano llamada *actio confessoria*; D.8.5). En principio, la podía dirigir sólo contra el nudo propietario que le desconociera el usufructo, pero desde Juliano, también contra cualquier poseedor que le impidiera el *uti frui* (Jul.-Ulp., D.7.6.5.1).

1. La *vindicatio usus fructus* es propiamente una *actio in rem* (EP. §72) similar a la *vindicatio servitutis*. Por medio de ella se pide declarar la existencia del usufructo, restableciendo la situación

2. El demandado vencido debe restituir todos los frutos, ya que no es considerado poseedor de buena fe a los efectos de adquirir los frutos anteriores a la *litis contestatio* (Ulp., D.7.6.5.3-4; D. 4.6.23.2). En caso de indefensión del demandado el usufructuario contaba con el *interdictum quem usum fructum* (FV., Ulp., 92), análogo al *quem fundum*. Se debía dar caución de no molestar el ejercicio del usufructuario (Paulo, D.8.5.7).

3. La existencia de una *actio Publiciana* para proteger al usufructuario que hubiese constituido el *uti frui* sin formalidad, resulta dudosa para la época clásica (Ulp., D.6.2.11.1 *jtp?*).

Además, a pesar de no ser poseedor de la cosa, el pretor lo defenderá con interdictos útiles (así, el *uti possidetis* y el *unde vi*; FV.90-91, Ulp.). También la *actio utilis legis Aquiliae* (Ulp., D.7.1.17.3; D.9.2.11.10, opinión de Juliano); incluso contra el nudo propietario que le hubiese ocasionado un daño a la cosa (p.ej., haber matado al esclavo dado en usufructo; Paulo, D.9.2.12). Igualmente si le hubiese corrompido al esclavo, la *actio servi corrupti* (Ulp., D.11.3.9.1).

B) A su vez, el nudo propietario contaba con determinadas acciones penales (así, *actio legis Aquiliae** y *actio furti**), y la *actio servi corrupti* (si quien corrompía al esclavo era el usufructuario (Ulp., D.11.3.9.1) pero carecía de acciones in personam (no penales) para exigir la reparación de daños ocasionados por el usufructuario. Por eso se introdujo la práctica de una fianza (*cautio usufructuaria*).

Esta comenzó solamente para el caso de un legado de usufructo, pero posteriormente se hizo general a los constituidos por otros modos (Ulp., D.7.9.1.2). Mediante esta *cautio* se comprometía por una *stipulatio* a) a usar la cosa a "arbitrio de buen varón" (*boni viri arbitratu*); y b) a restituir la cosa (si o sus herederos) cuando concluyera el usufructo (Ulp., D.7.9.1 pr.).

1. El nudo propietario estaba autorizado a no entregar la cosa antes de que se diera la *cautio* (Ulp., D.7.9.7 pr.). Si inadvertidamente no la hubiera exigido, el pretor le otorgaba la *rei vindicatio* para reclamar la entrega de la cosa. Y ante una eventual excepción de usufructo, le concedía una *replicatio* al propietario (Ulp., D. *ibid.*).

2. Mediante la *cautio* dada por el usufructuario o por fadores, se responde no sólo por los actos positivos de daño (estarían cubiertos por la *actio legis Aquiliae*), sino además por actos de omisión: así, no labrar el campo, no cultivar las viñas, dejar que se deterioren los acueductos. La *actio* sería *ex stipulatu*; la mención de *condictio cautionis* empleada en D.7.9.7 pr., es una interpolación al texto de Ulpiano. No es clásica.

III. El uso, la habitación y las *operae servorum*.

§ 276. *Uso*. En el derecho clásico se admitía junto al usufructo una variedad más limitada: el *usus*. El usuario tiene solamente el "uso" (*uti*), pero no el goce (*frui*) de la cosa (Gayo, D.7.8.11; Ulp., D. *id.* 2 pr.). Ello significaba que podía usar de la cosa, pero no podía percibir ningún fruto (Ulp., D.7.8.12 pr.). No podía ni vender, ni ceder, ni locar (los alquileres son frutos civiles); Inst., 2.5.1.

Pero esta situación fue flexibilizada, aunque los textos han sido interpolados. Así, el usuario de una casa la podía habitar con su familia (Ulp., D.7.8.2.1) y hasta recibir huéspedes y hasta locar una habitación a un tercero viviendo en la casa (opinión de Labeón, D., *ibid.*). En lo que respecta al *frui*, se admitió que el usuario "puede servirse de la leña y del huerto, de las frutas, de las hortalizas y flores y del agua, no para realizar ganancia, sino para el uso, esto es, no para el abuso (*abuti* = poder disponer; Ulp., D.7.8.12.1). Igualmente si tenía el "uso" de un ganado (así, para abono), se interpretó que podía tomar una "módica cantidad" de leche (Ulp., contra Labeón, D.7.8.12.2).

Está protegido por una *vindicatio usus*. Al igual que el usufructo, cuyas reglas en lo pertinente le son aplicables, debía proveer de una fianza (*cautio*).

§ 277. *Habitación*. Esta otra figura, que para los clásicos era una forma de *usus*, nace de la interpretación de legados que consistían en "la habitación de una casa". Se interpretaba que estaba limitada a la vida del habitador; no pasaba a sus herederos, ni se perdía por el no uso ni por la *capitis deminutio* (Pap.-Ulp., D.7.8.10 pr.).

Justiniano, quien la considera como figura separada (*quasi proprium aliquod ius*), permite incluso arrendar la "habitación", sin ceder el *ius* (C.3.33.13; Inst., 2.5.5).

1. Debe ser encarado como un *ius in re aliena* concedido generalmente en un legado, que no debe ser confundido con el mero préstamo, comodato, ni con el contrato de locación, que engendran sólo vínculos obligacionales.

§ 278. *Operae servorum*. Esta figura también debió haber sido considerada por los clásicos como una forma de *usus* (Jul.-Ter.Clem., D.7.7.5), o de usufructo (Pap., D.33.2.24.1). Justiniano le da una singularidad especial al tratarla en forma separada en el Digesto (D.7.7). Tiene aplicación cuando lo que se legaban eran "las obras (trabajos) de los esclavos ajenos". Po-

día el legatario beneficiarse directamente de ellos, o localarlos y ganar las sumas de los arriendos (Gayo, D.7.7.3).

1. No se extinguen ni por el no uso ni por la *capitis deminutio*, pudiéndose transmitir a los herederos (Pap., D.33.2.2 *jtp?*).

2. Ulpiano (D.7.9.5.3: *vel cuius alterius animas...*) parece referirse a una servidumbre análoga de las *operae servorum*, sobre los animales ajenos.

IV. La superficie y la enfiteusis.

§ 279. Tanto la superficie (*superficies*) como la enfiteusis (*emphyteusis*), aparecen en el derecho justinianeo como dos formas especiales de servidumbres, basadas en principios que resultan inconciliables con las reglas del derecho clásico a propósito de la locación y del dominio. Ambas reconocen antecedentes en ciertas prácticas usadas con anterioridad. Sobre esta base los bizantinos terminarán por tipificar estos *iura in re aliena*. Obviamente los textos del Digesto (D.43.18: *superficies*; D.6.3: *emphyteusis*), al igual que otros referidos a estos temas han sido muy manipulados, lo que torna un problema la reconstrucción de las formas anteriores.

A) *Superficie*. § 280 Se origina en la práctica de locar terrenos públicos a particulares, permitiendo que los locatarios pudieran construir un edificio, contra el pago de un canon. Generalmente era un contrato a muy largo plazo o a perpetuidad. Aquellos que construían podían usar y beneficiarse (*uti frui*) del edificio construido (se lo llama *superficies*) siempre y cuando que pague dicho canon (se lo llama *solarium* = de *solum*, suelo). Si bien se lo encuadraba en la locación, tenía todas las características de una concesión pública.

1. Según lo que cuenta Tito Livio (26.27.2), a propósito de un incendio ocurrido en el año 210 a.C., existían en el Foro determinados negocios (*tabernae*), entre ellas las de los banqueros (*argentarii*). Estos negocios debían estar vinculados con este tema de la concesión de la "superficie". También a construcciones de los *argentarii* se refiere Ulpiano (D.18.11.32).

E igualmente, la construcción hecha en el año 193 d.C. por el guardián de la colonia Antonina y el edificio de la ciudad de Puteoli, actual Pozzuoli (siglo II d.C.); Girard, Textes, ps. 832-3.

Así, en el caso de la inscripción de la colonia Antonina, el guardián de ella, un tal Adrastus, obtiene de Septimio Severo que se pueda elevar un edificio junto a las columnas de Marco Aurelio. Y se dice que lo tendrá para sí (*sui iuris*), siempre y cuando pague el *solarium*.

En el otro caso, de mediados del siglo II d.C., el

Decurión de Puteoli pide la aceptación de la proposición de un particular para levantar un edificio sobre la tierra comunal, que gozará el peticionario (*uti frui*) por vida; permitiéndole que mientras viva no pague el *solarium*. A su muerte, quedaba para los *municipes*.

Las construcciones eran del *populus* o del *municipium*, conforme a la regla clásica de que *superficies solo cedit* (lo que está en la superficie accede al suelo; Gayo, 2.73). Pero se le reconoce a quien ha logrado la concesión de edificar en un terreno público, que podía usar de la construcción si pagaba el *solarium*.

En la época clásica, se amplió la posibilidad de tener una *superficies* en terrenos privados.

2. Si alguien hubiera construido en terreno público sin concesión, pero sin que nadie se lo prohibiera, no por ello debía ser demolido "para que no se afea la ciudad con ruinas". Pero si obstara al uso público, el *curator publicorum operum*, lo podía demoler. De todos modos, si no molestara la construcción efectuada, se lo obligaba a pagar el *solarium* (Ulp., D.43.8.2.17).

§ 281. *Situación y protección del superficiario*. Por lo que hemos visto, se trata hasta acá de una locación especial, puesto que se permite que se pueda hacer una construcción, y además fuertemente penetrada por los principios de la concesión pública.

a) Por tratarse de una relación contractual, el superficiario tiene, en caso de ser privado de ella por el locador, la *actio conducti**, y en caso de privación por un tercero, el dueño locador debe cederle sus propias acciones (Ulp., D.43.18.1.1).

1. La *superficies* nace normalmente de una locación. Ulpiano habla de que también se puede comprar, en cuyo caso se darían las acciones de compra.

Pero este pasaje aislado resulta extraño. Se ha planteado una discusión al respecto. Pensamos en que dicha posibilidad iría en contra del principio general de que por la *superficies* había que pagar un *solarium*.

Además: a) En el interdicto que protege al superficiario, del cual hablamos a continuación, se menciona bien claramente que se ampara la *superficies* nacida de la *locatio et conductio*, y no de una *emptio et venditio*; b) Paulo (D.6.1.74) define al superficiario como aquel "que tiene la superficie en suelo ajeno, y que debe prestar cierta pensión (*pensio*); c) Y Gayo (D.43.18.2) dice que "llamamos cosas superficiales a las que se levantaron en solar tomado en arrendamiento".

b) El pretor le concederá además un *interdictum de superficie* (EP, § 249), de carácter

prohibitorio, vetando la violencia respecto de la posesión de la *superficies*. Estaba redactado en términos análogos al interdicto *uti possidetis* (Ulp., D.43.18.1.2).

1. Decía así: "Prohibo que alguien haga violencia respecto de que no disfrutéis de la *lex* de una *locatio* o *conductio* de la *superficies*, de que se trata, que tavieras *nec vi, nec clam, nec precario* del uno respecto del otro" (Ulp., D.43.18.1 pr.).

2. La particularidad de la concesión pública irá permitiendo que el constructor pueda disponer, es decir, vender, el *ius* que tiene sobre lo edificado (Ulp., D.18.1.32). Pero estas cesiones no son de la propiedad, "que es por el *ius civile* y el *ius naturale* de aquel de quien también es el suelo" (Gayo, D.43.18.2), sino de la *superficies*.

Incluso, una vez constituida la *superficies*, se puede donar o legar (Ulp., D.18.1.7). Así, se puede legar la *superficie* a aquel en cuyo suelo estuviere, aunque sea el dueño del suelo, porque conseguirá que quede libre de esta carga (*servitus* itp.), y gane la *superficie* (Jul., D.30.86.4).

También el superficiario puede dar la *superficies* en garantía, es decir, en prenda o hipoteca, concediéndose *acciones utiles* (Ulp., D.18.1.6; 8 y 9; Paulo, D.13.7.16.2). Y si correspondiere a dos personas en común, se concedía una *actio communi dividundo utilis* de división (Ulp., D.18.1.8).

3. De este modo, en desmedro del principio *superficies solo cedit*, se está admitiendo que el superficiario está gozando de un *ius in re aliena*.

Pero se diferencia de los otros *ius in re aliena*. Así, respecto de las *servidumbres*: a) éstas requieren siempre de dos fundos: dominante y sirviente; en cambio, en la *superficie*, el fundo es único; y b) la *servidumbre* no puede ser enajenada aisladamente del fundo al cual es inherente; la *superficie* es enajenable como bien en sí.

También se distingue del usufructo y del uso, que están limitados a la vida del titular, mientras que la *superficie* es enajenable y se transmite a los herederos.

4. Cuando la población de una ciudad se volvió numerosa, y muchas personas deseaban habitar no lejos del centro, las casas comenzaron a ser de más de una planta. Cuando se construía un piso superior, se lo llamaba *coenaculum*, porque allí se acostumbraba cenar, y cuando en un subsuelo, *krypta*. Estos lugares, podían ser locados e incluso conceder al locatario la *superficies*.

Es interesante el párrafo de Ulpiano (D.43.17.3.7). Si en una casa existe la planta baja y el *coenaculum* es habitado por un *quasi dominus* (itp.), según Laboón, el dueño de la casa es el de la planta baja, y tiene el interdicto *uti possidetis*. No así, el que habita el *coenaculo*. Éste tiene solo la acción nacida del arrendamiento. Es una neta aplicación del principio *superficies solo cedit*.

La segunda hipótesis es que la casa esté formada por un *coenaculum* a nivel del suelo con salida a la calle y una *krypta*. En este caso, Laboón sostiene que el interdicto *uti possidetis* le es concedido al poseedor que está en la planta baja y tiene salida a la calle, y no a quien está en la *krypta*.

Sin embargo, los otros superficiarios tendrán el interdicto de *superficie* y las acciones del pretor, pero el dueño del suelo será preferido en el interdicto *uti possidetis*, tanto respecto de otro como contra el superficiario.

De este modo se ve cómo los romanos admitieron la posibilidad de la "superficie" en plantas distintas del mismo edificio. Pero dada la pluralidad de personas, una sola era la que podía tener la propiedad, y los demás, solamente un derecho de superficie. Lo que no es posible es una *communio pro diviso*. Esto está bien afirmado por Pomponio (D.8.28.2.25 pr.): "Nadie puede tener sobre edificio ajeno otro superior".

c) Igualmente el pretor concederá al superficiario una *actio in rem utilis* (*quasi in rem actio*; Ulp., D.43.18.1 pr.; 1 y 3).

1. Schulz (DRC, § 695) establece que este agregado al edicto del pretor ha sido una interpolación, no creyendo que los clásicos hayan conocido una *rei vindicatio utilis*. El pretor no podía haber dicho *si qua alia actio* (si alguna otra acción), por cuanto venía hablando del interdicto, el cual no era una *actio*, como va a ocurrir en el derecho justinianeo. Pero el tema es dudoso, por cuanto Paulo (D.13.7.16.2) dice que "hoy día se le dan al superficiario *acciones utiles*". En el "hoy día", se puede intuir que se trataba de una creación más o menos reciente.

2. Según el párrafo de Ulpiano, la acción era concedida "con conocimiento de causa" (*causa cognita*). Y entiende que por ello el pretor, debía analizar, en cada caso, cuánto era el tiempo de la locación. Si el superficiario lo era a perpetuidad o por largo tiempo, se la concedía. Se le denegaba si, al contrario, era por tiempo corto (*modicum tempus*) (Ulp., D.43.18.1.3).

3. También, a pesar de que como locatario era mero tenedor, considerando que es "cuasi poseedor" del *ius (superficies)*, se le conceden el *interdictum unde vi* (Ulp., D.43.16.1.5 itp.) y el de *precario* (Ulp., D.43.26.2.3 itp.).

§ 282. En el derecho vulgar se llega a admitir que el superficiario pueda ser considerado como tal, sin necesidad de una locación, siempre que cuente con el consentimiento del dueño del suelo.

1. Según el Epítome de Gayo (2.1.4), se realiza un agregado al párrafo de sus Institutas: "Si alguien en nuestro suelo sin nuestro permiso edificara, la casa edificada le pertenece a aquel de quien es la tierra". Conforme a una interpretación a contrario,

pareciera que si se ha edificado con permiso del propietario, lo edificado le pertenece al constructor superficiario.

Justiniano no presta demasiada importancia a la *superficies*. En sus constituciones ni siquiera emplea este nombre. A veces, habla de *ius in re aliena*, alguna vez de "servidumbre" (así, Jul., D.30.86.4 itp.). Finalmente, se manifestará conociendo la superficie como una *enfiteusis* (Nov. 7.3.2, *in fine*, año 535; 120.1.2, año 544).

B) *Enfiteusis*. § 283. a) Desde época antigua, se acostumbraba otorgar el arrendamiento de tierras de cultivo a particulares, por un plazo muy largo o directamente a perpetuidad. Los arrendatarios debían pagar un canon determinado —denominado *vectigal*—. De ahí que el campo dado en concesión era denominado *ager vectigalis* (Paulo, D.6.3.1 pr.), siendo transmisible a sus herederos.

1. El régimen de la concesión era establecido por una *lex censoria*. Mediante ella los censores no sólo establecían el monto, sino que además permitían que los *publicani* cobraran los *vectigalia*, pudiendo acudir a la *pignoris capio** (Gayo, 4.28).

b) En la época clásica, la *conductio vectigalis* (o *conductio agri vectigali*) era un procedimiento usado por los *municipia* para favorecer la agricultura. Se entregaba un campo público en arriendo, pero asegurando que mientras el *vectigal* sea pagado, el predio no le sería quitado ni al arrendatario ni a sus herederos (Gayo, 3.145).

Por las características que tenía, parece ser un arrendamiento (*locatio et conductio*). Pero, dada la entrega a perpetuidad, incluso transmitida al heredero, algunos pensaron que se trataba de una venta. Gayo (3.145) nos trasmite las dudas existentes, si bien indica que "la mayoría se inclina a pensar que se trataba de una locación".

Sin embargo, a diferencia del mero locatario, que sólo cuenta con la protección de la *actio conducti*, que es *in personam*, parece ser que acá en la *conductio vectigalis* gozaba de una *actio in rem* (semejante a la *rei vindicatio*) que podían ejercer contra cualquier poseedor y también contra el mismo *municipium* (Paulo, D.6.3.1.1), siempre y cuando que paguen el *vectigal* (Ulp., D.6.3.2).

1. Se discute sobre la clasividad de esta *actio*, pero la opinión dominante es admitir que figuraba en el Edicto (EP, § 70). En D.39.2.15, Ulpiano la denomina *actio vectigalis*. Igualmente, como *actio utilis*, debió contar con la *vindicatio servitutis* (*actio confessoria utilis*; Jul., D.8.2.16) para reclamar una servi-

dumbre y otras acciones semejantes (Paulo, D.47.7.5.3). Como poseedor (Macar, D.2.8.15.1) debió contar también con los interdictos *unde vi* y *uti possidetis*.

c) A partir del siglo III d.C., comienza a aparecer la figura de la *enfiteusis* (= plantación), que rige los arrendamientos a largo plazo de tierras incultas públicas del Imperio (*fundi patrimoniales*); y también el *ius perpetuum*, sobre terrenos del fisco imperial (*fundi rei privatae*). Ya para el siglo IV, ambas formas son asumidas bajo la figura de la *emphyteusis*.

1. La situación jurídica del *emphyteuticarius* resultó bastante confusa. Así, en algunos textos aparece como *conductor* (arrendatario, CTh.5.15.14, año 364; CTh.10.3.3, año 380 y CTh.10.3.7, año 417). En cambio, en otros se lo llama *dominus* (C.11.62.2, año 321; CTh. 2.25.1, año 325; CTh.13.11.6, año 394) y opuesto al *conductor* en C.11.62.8, año 386, y en el CTh. 16.5.54.5, año 414. Lo que ocurrió es que mientras en la parte occidental del Imperio, prácticamente se la asimilaba a la propiedad del derecho vulgar, los bizantinos tratarán de especificar y mantener las diferencias.

§ 284. *Características jurídicas.* a) El emperador Zenón, mediante una constitución (C.4.66.1, sin fecha; segunda mitad del siglo V) establecerá que el *ius emphyteuticarium* no es ni una venta ni una locación, sino una situación particular (*tertium ius*). El efecto práctico principalísimo de esta determinación era clarificar el *periculum* de la cosa dada en enfiteusis, en relación con la productividad del campo. Zenón determinó al respecto que si la pérdida de las cosechas era total, debía ser soportada por el propietario; en cambio, si era parcial, por el enfiteuta. Esta regla valía como normal y supletoria, para el caso de que no se hubiera establecido una convención distinta entre las partes (C., *ibid.*; Inst., 3.24.3).

1. Ya para esta época, la enfiteusis era practica-da también entre particulares. Podemos señalar el gran interés económico que tenía la institución: por un lado convenía al propietario que tenía terrenos incultos y que recibiría el *canon* (generalmente consistía en una parte de la cosecha); por el otro, al enfiteuta, que encontraba la tierra para vivir de ella, y también sus herederos, practicando las labores agrícolas. En tal sentido era mejor que el expandido régimen del "colonato", que convertía a quienes trabajaban la tierra ajena en *servi terrae*.

2. La decisión de Zenón luce como equitativa. Si, p.ej., por un granizo se perdía toda la cosecha, el enfiteuta no debía pagar el *canon* (Ulp., D.19.2.15.2 *itp.*). En cambio, si la pérdida era parcial, quien la

debía soportar era el enfiteuta, que debía pagar el *canon* (C.4.66.1; Inst., 3.24.3).

El enfiteuta tiene sobre el campo enfiteutico derechos que son mucho más amplios que el usufructuario:

a) No está limitado por el principio del *salva rerum substantia*, de tal modo que podía cambiar el destino económico de la cosa a su entera voluntad; los frutos los adquiere por la *separatio* (desde que se separan de la cosa fructífera) como poseedor de buena fe (Jul., D.22.1.25.1), mientras que el usufructuario los adquiere por la *perceptio* (es decir, el acto personal de recogerlos).

b) Al igual que el usufructuario respecto de su usufructo puede dar el *ius emphyteuticarium* en hipoteca (Paulo, D.13.7.16.2; Marciano, 20.1.11.2) y crear servidumbres sobre el campo (Ulp., D.7.4.1 *pr.*).

c) A diferencia del usufructuario, la enfiteusis es transmisible a los herederos del enfiteuta (Paulo, D.6.8.1 *pr.*), quien también la puede transmitir por legado (Ulp., D.30.39.5-6).

También la puede ceder por actos *inter vivos*. En este caso, debe notificar previamente al propietario, bajo sanción de perder la enfiteusis. El propietario podía, durante el plazo de dos meses, ejercer su derecho de prelación, comprando él por el precio de venta dicha enfiteusis, con lo que recobraba la plenitud de su dominio del campo. Si no hacía uso de esta facultad, debía admitir la enajenación, cobrando el 2% del valor de la venta o de la estimación de la enfiteusis si el negocio era gratuito (C.4.66.3, año 530). Los medievales llamarán a este porcentaje *laudemium* (de *laudare* = aprobar).

d) Es considerado poseedor, y en tal carácter tiene los interdictos posesorios (*unde vi** y *uti possidetis**). Tiene también una *actio in rem*, sobre la base de la *rei vindicatio* (C.4.66.1; Inst., 3.24.3).

Justiniano habla de la constitución de la enfiteusis mediante un *contractus emphyteuticos* (C.4.66.2-3), pese a que no figura en la clasificación de los contratos en sus Institutas. Conserva sus derechos mientras pague el *canon*. Lo pierde si deja de pagarlo durante tres años (C.4.66.2; año 529).

V. Garantías reales: prenda e hipoteca.

§ 285. Cuando se trata de garantizar una obligación, se puede recurrir a conceder en favor del acreedor una "garantía personal" o una "garantía real". En la primera, la responsabilidad del deudor se ve reafirmada por la constitución de fianzas otorgadas por terceros. En el

caso de la segunda, se constituyen prendas o hipotecas en favor del acreedor como seguridad de que se va a cumplir la obligación. En el derecho actual, estas últimas son preferidas en la práctica usual de los negocios a las meras fianzas personales. Pero en Roma ocurría lo contrario.

1. Así, como detalle curioso, Q.M.Scávola (D.20.1.34.1) menciona una carta en la cual un deudor requiere de su acreedor que acepte la garantía real de su "tienda" (*taberna*) y de sus esclavos como prenda, en lugar de la fianza personal que al parecer no podía dar.

Lo que ocurre es que para los acreedores les resultaba más seguro y práctico acudir a las fianzas. Por un lado la amplia vigencia de la *fides*, que aquí valía como respeto a la palabra dada; y además, para el caso de no poderse pagar la ejecución se realizaba en forma directa contra la persona del deudor (en la *manus iniectio** contra su cuerpo; más adelante continuará la coacción corporal privada), pero más usualmente, en la época clásica sobre todo el patrimonio del deudor (*venditio bonorum**).

2. En cambio, las garantías reales, pese a que existieron presentaban varios inconvenientes: a) La prenda suponía el traspaso de la posesión en garantía al acreedor, quien a su vez no podía usarla. A su vez, respecto de la hipoteca, Roma careció de un sistema de publicidad —el cual es esencial para un correcto funcionamiento de la garantía—, de tal modo que el acreedor no podía estar seguro si la cosa ya había sido motivo de una hipoteca anterior; b) la existencia en el derecho posclásico de un gran número de prendas e hipotecas legales que tenían prioridad aun respecto a las constituidas anteriormente.

Estas garantías reales fueron, en el derecho antiguo y clásico (a) la *fiducia* celebrada con el acreedor y (b) el *pignus* o prenda en sentido propio. Más adelante apareció (c) la hipoteca.

I. *Fiducia*. § 286. A) En la *fiducia cum creditore contracta*, el deudor le transmite la propiedad de una cosa al acreedor por medio de una *mancipatio* o de una *in iure cessio*. El negocio iba acompañado de un pacto de *fiducia* (*pactum fiduciae*), por medio del cual el acreedor se obliga a retransmitir la propiedad de dicha cosa por esos mismos modos cuando la deuda sea satisfecha.

1. Se podía darle al acreedor también la posesión de la cosa. Pero lo acostumbrado era que la cosa cuya propiedad se transmitía quedara en poder del deudor. Si éste llegara a poseerla durante un año, aun si se trataba de un inmueble, podía usucapirla, recuperando la propiedad. Esta clase de *usucapio* se llamaba *usureceptio* (Gayo, 2.59).

2. Para evitar que ello ocurriera, el acreedor tomaba la precaución de dejarle la cosa al deudor como arrendatario, o le rogaba que la poseyera a título de precario. En ambos casos, el deudor carecía de *iusta causa* para usucapir (Gayo, 2.60).

B) El acreedor quedaba ampliamente protegido, puesto que como propietario gozaba de *acciones in rem* (así, *rei vindicatio* y *actio negatoria*). Si la deuda no era pagada, en principio, el acreedor se quedaba con la cosa. Pero prontamente se hizo valer un pacto de venta (*pactum distrahendi*), que se entendía sobrentendido aunque no figurara expresamente (Pomp., D.13.7.6 *pr.*; id.5.4; referidos originariamente a la *fiducia*: Paulo, 2.13.5).

1. Si al vender la cosa se excede el monto de la deuda, el exceso (*superfluum*) le deba ser devuelto al deudor (Paulo, 2.13.1 *ss.*). Si no se alcanza a cubrir lo adeudado, subsiste el crédito por el resto.

C) El deudor tiene contra el acreedor una *actio fiduciae*, que en el derecho clásico figura entre las *bonae fidei iudicia* (Gayo, 4.62; EP. § 107), para obligarlo, en caso de haber pagado la obligación (o haber incurrido el acreedor en mora en aceptar el pago), a retransmitir la propiedad de la cosa; y en caso de no haberla pagado, y haberse vendido, para reclamar por el *superfluum*. Tenía carácter infamante en caso de condena (Gayo, 4.182).

1. Igualmente, el acreedor gozaba de una *contractio fiduciae actio*, por los gastos que hubiere realizado en la cosa u otra eventual pretensión que pudiera aducir (EP. § 107, *Fiduciae vel contra*).

D) Si bien la *fiducia* aporta una garantía muy fuerte al acreedor, implica un riesgo considerable al deudor que ha transmitido el dominio y una gran desventaja, puesto que luego de haberla efectuado con un acreedor, no podía volver a garantizar con esa cosa a eventuales acreedores posteriores, hasta tanto que se hubiera concluido con el crédito y sus consecuencias.

1. Gayo la menciona en los párrafos citados, aunque no la recuerda en su clasificación de los contratos. Desaparece en la época posclásica, al mismo tiempo que la *mancipatio* y la *in iure cessio*. Justiniano interpola todos los textos, reemplazando *fiducia cum creditore* por *pignus*.

II. *Pignus*. § 287. La palabra *pignus* designa la garantía real que tendrá el acreedor para asegurar el cumplimiento de la obligación. Abarca tanto el caso de la "prenda" —cuando se ha

trasferido al acreedor la posesión de la cosa (*pignus daturum*), como también el caso de la "hipoteca", cuando se la ha convenido; pero permaneciendo la posesión en manos del deudor (*pignus obligatum*); Ulp., D.13.7.1 pr.

1. En principio, la palabra *pignus* se refiere sólo a la "prenda". Gayo (D.50.16.238.2) establece que "*pignus* es llamado así por *pugno* (= puño), ya que la cosa que es dada en *pignus*, es traida con la mano". Esto denota el sentido primitivo de la palabra vinculada a la "prenda", ya que la cosa es puesta bajo el "puño" del acreedor. No obstante lo sugerente de la expresión, la etimología no es exacta; surge a partir de *pangere* = fortalecer.

2. Pero servirá también para identificar la "hipoteca", que aparece posteriormente. Marciano (D.20.1.5.1) dirá que "entre *pignus* e *hypotheca* sólo difiere el sonido de la palabra", lo cual señala la aproximación de ambas figuras. Pese a ello existen diferencias: "Propiamente llamamos *pignus* (prenda) lo que pasa al acreedor, e hipoteca cuando no pasa, ni aun la posesión, al acreedor" (Ulp., D.13.7.9.2). Por ello las debemos considerar en forma distinta.

§ 288. *Prenda*. En el caso del *pignus* (= prenda), el deudor le entrega al acreedor la posesión (no la propiedad) de una cosa mueble (Gayo, D.50.16.238.2) o inmueble (Ulp., D.13.7.15). Esta posesión la tiene como garantía de la deuda, pero goza de la protección de los interdictos, no sólo respecto de terceros, sino también del propio deudor. Igualmente cuenta con la *actio furti*, incluso si quien le hurta la cosa mueble es el deudor (*furtum possessionis*; Gayo, 3.200; 204). Y con la ampliación de la *actio Serviana**, también tendrá una *actio in rem*. Gracias a esta posesión protegida por el pretor, se lo considera garantizado para no devolver la cosa hasta que le haya sido satisfecha la obligación.

1. El deudor que entrega la cosa en garantía, a la cual se la llama también *pignus*, puede ser propietario quintario de ella. Pero hasta que la tenga *in bonis*, puesto que lo que transmite es la posesión. Incluso se admitirá que pueda darse en prenda una cosa ajena con la voluntad de su dueño (Paulo, D.23.7.20 pr.). El acreedor puede mantener la posesión, dejándola en tenencia al deudor, a título de locatario o de precarista, pero será el acreedor quien tenga el ejercicio de los interdictos (Florent., D.13.7.35 l.).

2. Esta posesión que mantiene el acreedor es a los efectos de la garantía, siendo su efecto principal la protección interdictal. Pero, salvo permiso especial convenido con el deudor, el acreedor pignoraticio no puede usar la cosa dada en prenda. Si lo hiciera sin esta autorización, siendo la cosa mueble, queda obligado por la *actio furti (usus)*; Gayo, D.47.2.54 pr.;

Inst., 4.1.6). Además, si el deudor está usucapiendo la cosa, la podrá continuar (Javoi., D.41.3.16).

3. En cuanto a los frutos de la cosa, el acreedor no se los puede apropiar. Al respecto, las partes podían convenir que el acreedor tenía derecho a quedarse con los frutos en lugar de los intereses, renunciando ambas partes a reclamar, ya los frutos y los intereses. Este pacto recibe el nombre griego de *antichresis* (= "contragoce"; Marciano, D.20.1.11.1). De no ocurrir este pacto, el acreedor debe imputar los frutos a los intereses de la deuda, y si sobrepasan, al capital (Ulp., D.36.4.5.21; C.4.24.1), quedando obligado a rendir cuenta aun de aquellos que ha dejado de percibir (C.1d.3).

§ 289. *Caracteres de la prenda*. Por ser una garantía, supone la existencia de una obligación, de la cual está dependiendo. En efecto, no es concebible un *pignus* sin una deuda a la cual está garantizando. De ahí que la prenda es un accesorio de la obligación, que sigue la suerte de ésta. Así, si el crédito se extingue, la prenda cesa (Ulp., D.46.3.43).

1. Las obligaciones que se pueden garantizar con *pignus* (tanto en el caso de prenda como de hipoteca), prácticamente son todas, ya nacidas de un mutuo, de una compraventa o locación, etc. También las obligaciones naturales*, las condicionales y las a plazo, las presentes o las futuras (Marciano, D.40.1.5 pr.). Incluso puede alguien dar *pignus* por obligación ajena (Marciano, D.1d.2).

2. El *pignus* (tanto prenda como hipoteca) es indivisible. Si la deuda es extinguida parcialmente, el total de la garantía responde por el resto de la obligación; y si hay varios objetos pignorados por un mismo crédito, continúan todos ellos garantizando la deuda residual (Pap., D.21.2.65: *propter indivisam pignoris causam*; Scévola, D.20.5.11).

3. Según un rescripto de Gordiano (C.8.26.1.2; año 239), se permite al acreedor retener la cosa prenda, cuando pese a haberse pagado la obligación garantizada por ésta, el deudor adeudaba otras obligaciones. Pese a llamarse *pignus Gordianum*, esta posibilidad —luego admitida en el derecho actual como "prenda tácita"— es un simple derecho de retención.

§ 290. *Efectos de la prenda*. La garantía que tiene el acreedor consiste en el derecho de retener la cosa dada en prenda hasta que la obligación sea enteramente pagada, ejerciendo con ello coacción al deudor que se ve privado de la posesión del *pignus*. Podía ocurrir que efectivamente el deudor pagara la obligación, o que no sucediera así.

A) Si se paga la obligación, o ésta se extingue por otra causa, el deudor pignoraticio tiene una *actio pignoraticia* contra el acreedor que

retiene indebidamente la cosa prenda (Ulp., D.13.7.11.3; id., 13 pr.) para que la devuelva. Además, queda obligado por los daños causados por dolo o culpa, y en caso de ser una cosa mueble, responde también de la "custodia" (igual que el comodatario; Ulp., D.13.7.13.1).

1. La *actio pignoraticia* (EP, § 99) tenía en principio una fórmula *in factum*. Pero más tarde aparece una redacción *in ius*, como *bonae fidei iudicium* (según rescripto del año 225; C.4.26.6) que no parece clásico.

2. Igualmente existirá la forma de *actio contraria* en favor del acreedor, para el supuesto de haberse dado en prenda una cosa ajena sin autorización del dueño, o una cosa ya pignorada (Ulp., 13.7.9 pr.; Paulo, D.1d.16.1).

B) Para el caso de no haberse satisfecho la obligación, entonces el acreedor podía efectivizar la garantía. Generalmente se realizaba, al constituir la prenda un convenio ("contrato de prenda"), que entrará en la clasificación de los "contratos reales". En dicho convenio solían figurar *pacta conventa* (pactos convenidos), para resolver finalmente la situación:

a) A veces se establecía una *lex commissoria*, mediante la cual el deudor le otorgaba al acreedor la posibilidad de quedarse con la propiedad del *pignus* en caso de no pago de la obligación. La utilización de este pacto permitía prácticas usurarias, al aprovecharse el acreedor de cosas de mayor valor que la deuda, ya que el *pignus* quedaría de su propiedad. Por ello, considerando su inmoralidad, fue prohibido por Constantino (CTh., 3.2.1 = C.8.35(34).8; año 320).

b) Otras veces se autorizaba al acreedor para que pudiera vender el *pignus*, y de este modo, cobrarse con el precio (*pactum de vendendo*). En un principio, este pacto debía figurar expresamente. En la jurisprudencia posclásica se interpretó que aunque no hubiere convenio expreso, la cláusula de vender resultaba sobreentendida o tácita en el *pignus* (se convirtió en un elemento "natural" del negocio; Ulp., D.13.7.4 itp.; Pomp., id.5).

1. Si se hubiera convenido el *pactum de non vendendo*, el acreedor incurría en *furtum* si vendía la cosa pignorada, salvo que previamente no hubiese hecho un triple reclamo (*denuntiatio*) al deudor para que pague y éste no lo hubiere hecho (Ulp., D.13.7.4).

2. En el derecho justinianeo se le permite al deudor convenir que luego de vendida, podría rescatarla pagando el precio de compra. De hacerlo, tenía la *rei vindicatio* o una *actio in factum* (Ulp., D.13.7.13 pr., *in fine*, itp.).

3. La venta se solía convenir entre acreedor y deudor mediante un pacto entre ellos (Pomp.,

D.13.7.5). Ni el dueño deudor ni el acreedor pueden comprar el *pignus* (Pap., D.13.7.40 pr.; Paulo 2.13.3).

Si no resultara ningún comprador, se permitiría por una constitución de Alejandro Severo (C.8.34(33).1) realizar una petición al emperador para que se otorgue el dominio del *pignus* (*impetratio domini*). Justiniano establecerá para este caso un procedimiento especial, según el cual había que intimar, luego de dos años (*post biennium*) al deudor, para que pagara la deuda, tras lo cual se fijaba judicialmente un nuevo plazo, y de no ocurrir el pago o estar ausente el deudor, se concedía la propiedad de la cosa (C.8.34(33).3.2-3).

Si resultare un sobrante (*superfluum*), éste debía ser devuelto al deudor, quien la podía reclamar por medio de una *actio in personam*, que en caso de mora del acreedor incluía también los intereses (Paulo, D.13.7.7).

1. En el caso de la hipoteca, se suele hablar de este *superfluum* denominándolo *hyperocha*. Pero este vocablo griego, empleado por los romanistas, sólo se halla mencionado una sola vez en los textos (Tryfino, D.20.4.20).

II. *Hipoteca*. § 291. El *pignus* bajo la forma de la hipoteca, aparece muy tardíamente en Roma. Hubo un desarrollo preparatorio que llevó finalmente a esta forma de garantía, que a diferencia de la prenda, mantenía la posesión de la cosa pignorada en poder del deudor.

1. La palabra griega *hypotheca* es prácticamente desconocida por los autores clásicos. Fue tomada del uso de la institución griega de la hipoteca, pero no resulta aceptable pensar en un origen extraño al propio Derecho Romano, y menos la asimilación a la institución usada en Grecia.

a) Existió la costumbre, en los arrendamientos de fundos rústicos, de convenir que los instrumentos de labranza (*invecta*) y los semovientes (*illata*: esclavos, ganados), garantizaban el pago de los alquileres. Dadas las características de estos *invecta et illata*, era normal que permanecieran en poder del arrendatario, quien de otro modo no podría trabajar el campo locado. Nos encontramos acá con una garantía muy especial, puesto que salvo lo convenido, el arrendador no tenía una *actio in rem* para ejecutar la garantía.

b) Hacia fines de la República, un pretor Salvius creó un interdicto por medio del cual el arrendador podía entrar en posesión de estos *invecta et illata*. Éste fue el *interdictum Salvianum*, que ya Gayo (4.147) lo da como ejemplo de los interdictos *adipiscendae possessionis*. Sólo se podía ejercer contra el arrendatario (EP, § 266).

c) Más tarde, en época clásica anterior a Hadriano, otro pretor, Servio, creó una *actio Serviana*, que era una *actio in rem*, que podía ser dirigida no sólo contra el arrendatario, sino contra cualquiera que detentara la posesión de los *invecta et illata* (EP, § 267).

d) Finalmente los pretores, pero principalmente Salvio Juliano, fueron perfilando una *actio Serviana utilis*, denominada también *quasi Serviana* (por los bizantinos, *actio hypothecaria* o *pignoratitia in rem*; Inst., 4.6.7; id.31). Mediante esta acción, se extendía el caso de los *invecta et illata*, a toda clase de *pignus* (ya fuera "prenda" o "hipoteca"). De este modo, el acreedor tuvo una *actio in rem* para perseguir al *pignus* (ya con desplazamiento de la posesión o sin ello; Ulp., D.13.7.9.2).

§ 292. *Características*. La hipoteca, al igual que la prenda garantizaba toda clase de obligaciones. Pero a diferencia de ésta, que necesitaba de la entrega de la posesión para que comenzara la garantía, la hipoteca se constituía por simple convenio (Gayo, D.20.1.4; Ulp., D.13.7.1 pr.; C.8.16.2, año 207). También se admitió que pudiera constituirse por disposición testamentaria (Pap. Marciano, D.20.1.11.2).

Al no exigirse el traspaso de la posesión, se puede establecer no sólo sobre las *res corporales* (como sucede con la prenda), sino también sobre las *res incorporales*, y en general sobre todas las cosas que pueden ser compradas y vendidas (Gayo, D.20.1.9.1); incluso sobre todo un patrimonio (Pap., D.20.1.1 pr.).

1. Así, se puede hipotecar un crédito (*pignus nominis*). En este caso se permite que el acreedor tenga acciones útiles para ejecutar al obligado a él, compensando el dinero cobrado o reteniendo en *pignus* la cosa, si no se trataba de obligación dineraria (Paulo, D.13.7.13 pr.).

También se puede hipotecar un *pignus*, es decir, sería el caso de dar como *pignus* a un tercero, el que yo tengo como garantía (*pignus pignoris* o *subpignus*), de tal modo que el acreedor subpignoraticio está facultado para ejecutar por la venta dicho *pignus* (Marciano, D.20.1.13.2).

En realidad, en estos casos del *pignus nominis* y del *pignus pignoris* estamos en presencia de cesiones del crédito o de la prenda.

2. Si se trataba de todo un patrimonio, se excluían cosas esenciales como el ajuar, los vestidos y esclavos domésticos, o cosas de uso cotidiano (Ulp., D.20.1.6; Paulo, D.13.7.13 pr.).

3. Igualmente se puede hipotecar una enfiteusis o un usufructo (Pap. Marciano, D.20.1.11.2). En cuanto a las servidumbres prediales; en el derecho clásico no podían ser hipotecadas. Los bizantinos prohíben la hipoteca sobre servidumbres de fundos urbanos, pero

permiten que pueda ocurrir con las servidumbres rústicas (Marciano, D.20.1.11.3; Pomp. Paulo, D.12.12; ambos itps.); en el último se permite hipotecar las de *iter*, *actus*, *via* y *aquae ductus*, diciendo que el acreedor hipotecario las utilizara si tenía fundo vecino, y posteriormente, si no se pagaba la deuda las vendiera (quizá al dueño del fundo sirviente para recobrar la plenitud de su dominio). Como se ve, las utilidades prácticas eran pocas.

§ 293. *Hipotecas tácitas y legales*. Si bien la forma normal de constitución del *pignus* era por convención, existieron en Roma hipotecas impuestas en forma "tácita" (presumiendo la voluntad de constituirse), o establecidas por una disposición legal ("hipotecas legales").

A) Si bien la aplicación de las hipotecas tácitas será muy notable con Justiniano (D.20.2; C.8.14(15)), existieron algunos precedentes clásicos:

a) Por un s.c. de la época de Marco Aurelio, el acreedor que prestó dinero para refaccionar un edificio, tiene un *ius praefereendi* para cobrarse con dicho inmueble (Pap., D.20.2.1).

b) Así, por una constitución de Severo y Caracalla, en favor del pupilo sobre las cosas compradas por el tutor con dinero del pupilo (Ulp., D.27.9.3 pr.; D.20.4.7 pr.).

c) Desde la época de los Severos, el fisco gozaba de hipoteca legal sobre los bienes de los deudores (Hermog., D.49.14.46.3: *fiscus semper habet ius pignoris*; Caracalla, C.8.15.1.2, años 213 y 215).

B) Luego, en la época posclásica, y acentuado con Justiniano, se establecen otros casos, ya sobre bienes particulares, ya abarcando todo el patrimonio del deudor. Este género de hipotecas tácitas y legales (y sobre todo las generales) ocasionó un grave perjuicio al crédito, debido al estado de inseguridad que tenían los restantes acreedores.

a) *Hipotecas tácitas o legales particulares* (es decir, sobre bienes en particular): (i) el arrendador de un fundo rural tuvo hipoteca legal sobre los frutos del inmueble (Pomp., D.20.2.7 pr., itp.); (ii) se extendió el *pignus* de los *invecta et illata*, considerándolo tácito en todos los casos (Paulo, D.2.14.4 pr., itp.); (iii) Justiniano crea una hipoteca legal en favor del legatario sobre la herencia adquirida por el heredero, para el pago de los legados (C.6.43.1.1, año 529); etc.

b) *Hipotecas tácitas o legales generales* (es decir, sobre todos los bienes del deudor): (i) Constantino constituyó hipoteca en favor de los pupilos y menores de 25 años sobre los bienes de los tutores y curadores, por las obligaciones nacidas de la tutela y de la curatela (C.5.37.20, año 312); Justiniano la concedió también a los dementes (C.5.70.5, año 530); (ii) También pesaba una hipoteca legal sobre el patrimonio del

marido por obligaciones nacidas de la dote (C.5.12.30 pr. y 1, año 529), de la *donatio propter nuptias* (C.8.17.12, año 531) y de los bienes parafernales (C.5.14.11, año 530). (iii) sobre el patrimonio de la mujer viuda para garantizar los derechos hereditarios de la línea paterna en favor de los hijos del primer matrimonio (C.5.9.6.9, año 472); etc.

§ 294. Otros casos especiales de "pignus".

a) En la época clásica, aquel que había obtenido una sentencia favorable cuenta con la *actio iudicati* y el procedimiento concursal de la *venditio bonorum*. En los tiempos posclásicos, con la *cognitio extra ordinem*, la ejecución se realizaba mediante una *pignoris capio* sobre los bienes del deudor, ordenada por el juez. Esto fue llamado *pignus ex causa iudicati capium*, y al beneficiado Justiniano le termina por dar la acción real recuperatoria (C.8.22.1.2).

b) Igualmente, el pretor concedía en ciertos casos una *missio in possessionem*; así, al legatario si el legado no era aún debido y el heredero no daba la *cautio* respectiva. Los bizantinos —no los clásicos— dieron a esta *missio* el nombre de *pignus praetorium*. Igual que el caso anterior, este *pignus* difiere totalmente del *pignus* clásico. Pese a ello Justiniano le otorgó la acción real (C.8.21.2).

c) Un caso especial era la celebración de una contratación pública por parte del *aerarium* o *municipia* con un particular, la cual era garantizada por fiadores (*proedes*) que constituían una garantía real (*praedia*). Se firmaba (*subsignare*) un documento especial (*subsignatio*) que se inscribía en los registros públicos.

Algunos han querido ver en estas *subsignationes* el origen de la hipoteca. Pero si bien es cierto que virtualmente esta garantía real funcionaba como hipoteca, no era del derecho privado, sino que se regía por el *ius publicum*. El pretor no concedía una *actio in rem* en favor del *aerarium* o de los *municipia*; si bien protege a los particulares que compraban a éstos un inmueble (Gayo, 2.61; EP, § 186).

§ 295. Derechos del acreedor hipotecario.

A) El acreedor hipotecario está respaldado con la garantía que tiene sobre el *pignus*. Por ello, si no es satisfecha la obligación, puede vender la cosa hipotecada (rige acá el *pactum de vendendo* como elemento natural, tácito; y la prohibición de la *lex commissoria*; ver *supra*, § 290.B) y cobrarse con preferencia a la masa común de acreedores que cuentan con una *actio in personam* (quirografarios).

B) *Ius praefereendi*. I. En el caso de la hipoteca —a diferencia de lo que ocurre con la prenda, en la cual se transmite la posesión de la cosa— se puede obtener un nuevo crédito cons-

tituyendo una segunda garantía hipotecaria; y también otras posteriores. En estos casos ocurre una concurrencia de garantías (así, en primer grado, segundo grado, etc.). Por ello es importante determinar cómo se regula el conflicto entre estos acreedores.

Por lo tanto, se establecía un orden preferencial, de tal modo que el acreedor hipotecario en primer grado es quien tiene el derecho pleno del *pignus*. Este *ius praefereendi* se determina conforme a la regla *prior tempore, potior iure* (el primero en el tiempo tiene mejor derecho; Caracalla, C.8.17.4; año 213; C. id., 2). Él es quien puede obtener la posesión de la cosa y promover la venta de la cosa hipotecada, triunfando respecto de todos los otros acreedores. Si uno de éstos promoviera la venta, obrando *in rem*, puede ser despojado por el primer acreedor (Marciano, D. 20.4.12 pr. y 7). Esto trae las siguientes consecuencias: a) El acreedor en primer grado puede cobrarse la totalidad de su crédito, tanto por el capital como por los intereses, sin preocuparse por el resto de los otros acreedores. b) Una vez vendida la cosa, el comprador de ella adquiere la propiedad de la misma libre de toda hipoteca. En efecto, no sólo se extingue dicha hipoteca en primer grado, sino también todas las de grado posterior (Alej. Severo, C.8.20.1).

Puede suceder que el acreedor en primer grado no alcance a cobrarse la totalidad de su crédito, por lo que en ese caso el deudor quedará obligado por el resto (Paulo, D.20.5.9 pr.). Pero si en la venta realizada existía un *superfluum*, éste era devuelto al deudor (Paulo, D.13.7.7; Ulp., D. id., 24.2). Los acreedores posteriores no tienen ya *actio in rem* para cobrarse, puesto que las hipotecas han quedado extinguidas (C.8.20.1); pero continúan siendo acreedores que podrán obrar por una *actio in personam* respecto de dicho excedente (*superfluum*), corriendo el eventual peligro de la insolvencia del deudor (Pap., D.46.3.96.3; Paulo, D.22.2.6).

1. Dada la falta de publicidad de la hipoteca, era un problema el establecer la fecha cierta de constitución de la hipoteca. La falsificación de la fecha era penada como *crimen falsi* (Mod., D. 48.10.28). El emperador León dio preferencia a la hipoteca documentada en escritura pública, con intervención del escribano (*tabularia*) (C.8.17.11.1, año 472). Justiniano la equiparará con la celebrada en un documento suscrito al menos por tres testigos (C.4.2.17, año 528).

2. La regla general del *prior tempore, potior iure*, queda alterada en presencia de ciertas hipotecas que se consideran "privilegiadas". Así, en el caso de las "convencionales", el acreedor que dio dinero para comprar la cosa que se hipotecó (Diocl., C.8.17.7). Y en el caso de las "legales", no todas tienen rangos

privilegiados. Si, p. ej., la de la mujer sobre los bienes del marido para la restitución de la dote. Para Justiniano, este privilegio se extiende incluso respecto de otras hipotecas celebradas antes del matrimonio (C.8.18.12, año 531). El fisco tiene también privilegio por los tributos debidos (C.8.15(14).1).

II. Para evitar los problemas derivados de la ignorancia por parte de acreedores hipotecarios que ignoraran la existencia de hipotecas en grado anterior, como un complemento rectificativo del *ius vendendi* que tienen los acreedores anteriores en grado, se les otorga el *ius offerendi et succedendi*. Así, al acreedor en segundo grado (y a los posteriores) se les ofrece la posibilidad de ofrecer al acreedor hipotecario en primer grado el pago de su crédito. Si éste lo acepta, entonces el acreedor en grado posterior pasa a ocupar el lugar del primero (*successio in locum*). Incluso, si no lo acepta, el oferente tiene este *ius offerendi et succedendi* si sella el dinero y lo deposita, no aplicándolo a sus propios usos (Marciano, D.20.5.5 pr.; Severo y Caracalla, C.8.17.1, año 197).

1. El acreedor que ha hecho uso de este *ius offerendi et succedendi*, podrá luego cobrarse no solamente el crédito que ofreció y pagó, sino también el suyo propio (C.8.14.22; C.8.18.5). Así, supongamos: el orden era A, primer acreedor por 50, y B segundo por 100. Este último ofrece y paga el crédito de 50 a A. Al pagar este crédito, B podrá ahora cobrarse el que pagó y además el suyo, es decir, 150 (50 + 100), por estar ahora en primer grado.

2. Veamos ahora este otro caso: Sobre una cosa que vale 150 hay tres acreedores en este orden: A por 50, B por 40 y C por 100. Si C usa de este *ius offerendi* y pagando 50 a A, ahora ocupa el lugar de A. Ahora C figura en primer lugar, pudiendo reclamar por 150 (50 + 100).

Pero en este caso, B, que ve que no cobrará nada por su hipoteca, puede impedir la venta ofreciendo a C pagar los 50 de A. Pero también C puede contraofertar pagar el crédito de B, quedando entonces como único acreedor hipotecario. La conveniencia de C está dada por cuanto si bien tuvo que desinteresarse a A (50) y a B (40), podrá vender la cosa por 150 (si bien corre el peligro de que el precio real de venta sea menor). Con ello podrá obtener 60 (150 - 90), y lo que le queda en descubierto de garantía es sólo 40 (100 era su crédito menos los 60 que obtiene). Si no hace estos ofrecimientos, en cambio, su descubierto en garantía es del total, es decir, de 100. Al vender A o B, el *superfluum* le era restituido al deudor y sólo tendrá acción *in personam* por su crédito.

3. En todos los casos, este *ius offerendi et succedendi*, representaba una ventaja para los acreedores en grado ulterior, que se podía ejercitar siempre que pudieran disponer del dinero necesario.

4. También podía ocurrir una *successio in locum*,

distinta del *ius offerendi et succedendi*, por la cual un tercero pasaba a ocupar el lugar del acreedor. Así:

a) quien presta dinero al deudor para desinteresarse al acreedor hipotecario, puede convenir la hipoteca en el mismo grado que el que tenía el anterior (Aristón-Paulo, D.20.3.3; C.8.19.1);

b) quien compra el fundo hipotecado al deudor para desinteresarse al primer acreedor, lo cual hace efectivamente, pasaría a ocupar su lugar, pero no puede ser acreedor del fundo propio; sin embargo, puede prevalecerse de esa situación respecto de acreedores hipotecarios en grado ulterior, ya que queda en la situación de primer acreedor (Paulo, D.20.3.3; D.20.4.17; C.8.19.3);

c) cuando el acreedor hipotecario accede a novar la obligación, agrega la hipoteca a la nueva obligación, ésta conserva el mismo rango que tenía en la obligación anterior (Pap., D.20.4.3 pr.; Pap.-Marciano, D.20.4.12.5).

C) *Ius persequendi*. Tal como lo hemos visto, el acreedor hipotecario, a pesar de que no tiene la posesión del *pignus*, cuenta con el interdicto *Salvianum*, para obtener la posesión de cualquier poseedor (Jul., D.43.33.1 pr. y 1) y la *actio Serviana* (o *quasi-Serviana* o *actio hypothecaria*) para perseguir la cosa hipotecada en manos de quien esté (*ius persequendi*), para poder entrar en la posesión de ella, y de este modo venderla y cobrarse su crédito.

1. La restitución comprende la cosa con todos sus accesorios, incluido el aumento por aluvión (Marciano, D.20.1.16 pr.). También incluye los frutos, a arbitrio del juez, a partir de que se haya incoado el juicio, y no alcanzarse el valor de la cosa para pagar el total de la obligación (Marciano, D.14.4).

2. Si el tenedor de la cosa es un tercero que no es deudor, puede oponer ciertas defensas:

a) Si es un acreedor hipotecario en grado preferente, puede oponer una excepción a la acción hipotecaria (Marciano, D.20.4.12 pr.).

b) El tercer poseedor, luego de haber pagado la deuda, puede obligar al acreedor hipotecario a cederle sus acciones para ir contra el deudor (beneficio *cedendarum actionum*; Scäv., D.20. 4. 19).

c) Justiniano le acordará el beneficio de excusión (*beneficium excussionis personalis*), gracias al cual puede exigir que el acreedor hipotecario vaya primero con sus acciones personales contra el deudor principal y *fideiussores*, si existieren (Nov 4.2)

§ 296. Extinción del "*pignus*". El *pignus* (tanto la prenda como la hipoteca) se extingue:

a) por la extinción de la obligación que se está garantizando, dado que ésta es lo principal y el *pignus* lo accesorio (Ulp., D.20.6.6 pr.);

b) por la extinción total de la cosa corporal que cumplía el papel de garantía (Marciano,

D.20.6.8 pr.); no basta la destrucción parcial, ni tampoco las alteraciones o transformaciones hechas (Marciano, D.20.1.16.2). Si se trataba de un edificio hipotecado y éste se incendió o destruyó, la hipoteca continúa sobre el suelo (Paulo, D.20.1.29.2).

c) Por la venta que hace el acreedor pignoraticio (C.8.27(28).15; C.8.17(18).6). Si el valor obtenido supera lo satisfecho al acreedor primero, queda para el segundo, y eventualmente para los de ulterior grado. Si no los hubiera, el *superfluum* (*hyperocha*) debe ser devuelto al constituyente del *pignus*, quien tiene para reclamarlo la *actio pignoratitia* (Ulp., D.13.7.24.2). Si no alcanza el valor de lo adeudado, las restantes hipotecas en grado posterior se

extinguen (C.4.10.6-7; C.8.20.1). Los acreedores impagos conservan sus acciones *in personam* contra el deudor (Paulo, D.20.5.9 pr.; C.8.28.3);

d) Por la renuncia expresa o tácita del *pignus* por parte del acreedor. Así, se la presume si devuelve la cosa al deudor, o permita que la venda, sin hacer reserva de su derecho (Ulp., D.20.6.4.1);

e) En el derecho posclásico se extingue también por la *praescriptio longi temporis*, si alguien posee con justo título el *pignus* durante 10 o 20 años. Justiniano la permite hacer valer contra el acreedor pignoraticio y el antiguo propietario (C.7.39.8 pr.). Y aun sin justo título, luego de 30 o 40 años (*longissimi temporis praescriptio*; C.7.39.8 pr. y 1).

PART E CUARTA
LAS OBLIGACIONES Y LOS NEGOCIOS

Todos los derechos reservados

CAPÍTULO 1
EL NEGOCIO JURÍDICO

§ 297. Los romanos acuñaron la expresión *negocio* (*negotium*; formada a partir de la partícula negativa *nec* y la palabra *otium*) con el valor de referirse al actuar puramente utilitario o económico, que era distinto del placer espiritual e incluso material del *otium*.

En el derecho moderno y en el actual, el afán abstracto ha hecho concebir una "teoría general del negocio jurídico". Nada más opuesto a la manera de pensar de los romanos. Los juristas romanos huyeron de las generalizaciones abstractas. En cambio, estuvieron dotados de una especial inclinación para resolver los problemas concretos que se les presentaban tratando de encontrar la "solución justa" para el caso determinado. De la mera lectura del Digesto, lo que surge no es una teoría, sino más bien análisis de casos particulares.

1. Pese a ello, los programas usuales de nuestro país y muchos extranjeros, continúan hablando de la necesidad de presentar al alumno un cuadro general del "negocio jurídico". Esta costumbre, de la cual discrepo, tendría la única ventaja de presentar cierta terminología en forma agrupada, lo cual puede resultar de utilidad para el estudiante que se inicia.

Obligado por esta circunstancia escolástica, desarrollaré los puntos usuales de dichos programas. No obstante que mucho de la terminología es netamente modernista, trataré de destacar las soluciones genuinamente romanas.

§ 298. *Hechos, actos y negocios jurídicos*. Esta terminología es netamente modernista. Sin entrar en la consideración de las discrepancias doctrinarias que pudieran existir, una ubicación que no despertaría mayores problemas nos permite distinguir:

A) Todo *hecho* es un mero acontecimiento, que interesará al derecho siempre y cuando que produzca determinadas implicancias jurídicas (nacimiento, modificación o extinción de situaciones o relaciones jurídicas).

1. Así, un hecho natural es el tiempo, que trae consecuencias jurídicas en determinados casos. De este modo, en una *stipulatio** subordinada a un plazo, habrá que esperar el transcurso de éste para que

la obligación se torne exigible. Igualmente, el tiempo es uno de los requisitos de la *usucapio** para poder adquirir la propiedad civil respecto de una cosa. Y también interviene a propósito de la fijación del legado y del momento en que se pueda realmente reclamarlo (regla del *dies cedens** y *dies veniens**).

Asimismo, *hechos naturales*, como p.ej. una inundación, puede acarrear, en caso de ser permanente, la pérdida del dominio del fundo, lo mismo que el derramamiento de una vasija de aceite o de vino.

2. También es un hecho que acarrea consecuencias jurídicas el "nacimiento": al nacer la persona, se consolida la situación del *nasciturus**, ocasionando con ello consecuencias dentro de la familia, no sólo personales, sino también patrimoniales; así desde el punto de vista del derecho sucesorio.

Igualmente es un hecho la "muerte", ya que cesa la persona y determina si se trata de la muerte de un *paterfamilias* la apertura de su sucesión, o si es un *alieni iuris*, la modificación de las cuotas hereditarias, e incluso, si era el único heredero instituido en un testamento, la ineficacia de éste y la apertura de la herencia *ab intestato**.

B) Cuando se habla de actos, nos estamos refiriendo a acciones voluntarias humanas.

Éstos pueden ser la realización de algo prohibido por el *ius*, y entonces se habla de *actos ilícitos*. Tal sería el caso de la comisión de un delito (p.ej., el *furtum*).

En cambio, cuando el actuar voluntario procura ya el nacimiento (así, una *stipulatio*, por la cual nace una obligación), la modificación (como en el caso de la "transacción"*) o la extinción de una situación o relación jurídica (p.ej. el pago, por el cual se puede extinguir una obligación), estamos en presencia de *actos lícitos*. Éstos son denominados, con más propiedad *actos jurídicos*.

C) Para algunos autores, el *acto jurídico* es sinónimo de *negocio jurídico*. Para otros, habría una diferencia. En ambos interviene la voluntad, pero en el caso del *acto jurídico*, ésta se halla totalmente fijada por el derecho (así, p.ej., el pago de una obligación: el *ius* señala cómo, dónde, cuánto y a quién se debe pagar). En cambio, en el *negocio jurídico*, la voluntad tiene una posibilidad de actuación más amplia (así, p.ej., un testamento, ya que el testador puede

con cierta libertad, teniendo en cuenta las variaciones habidas en cada época del *ius*, elegir quién será su heredero, cargarlo con legados* y fideicomisos*).

§ 299. Clasificaciones de los actos y negocios jurídicos.

A) *Unilaterales y bilaterales*. En los primeros, la existencia del acto o del negocio dependerá de la voluntad de una sola persona: así, un testamento*, una manumisión*, la aceptación de una herencia*. En cambio, en los segundos, la celebración del acto o negocio estará supeditada a un acuerdo (*consensus*) de dos o más personas: así, una *stipulatio**, una compraventa*, una sociedad*, etc.

1. Sin embargo, la clasificación no luce tan clara y sencilla. El testamento es un acto o negocio unilateral, pero si el heredero es "extraño*", se necesitará la aceptación de la herencia por parte de éste. Igualmente, una donación* sólo se perfecciona cuando es aceptada por el donatario. ¿Los convierte por ello en "actos bilaterales"? ¿O continúan considerándose "unilaterales"? Los juristas romanos no prestaron atención a estas divagaciones que preocupan a los modernos.

2. Igualmente, el testamento civil romano-clásico fue el efectuado *per aes et libram**. Si bien la voluntad es expresada en una utilización de la *mancipatio*, se necesita de la presencia de otras personas (los testigos, el *libripens*), pero también el que figura como *familias emptor*, que parece estar aceptando por un gesto de *amicitia* las palabras del testador. Lo mismo ocurre en la mera *mancipatio*, o cuando es utilizada para emancipar a un hijo o a una hija.

B) *Inter vivos o mortis causa*. Los primeros son aquellos que son ya eficaces en vida de las partes, como p.ej. una compraventa, un depósito. Los segundos, en cambio, regulan sus efectos para después de ocurrida la muerte del disponente: así, una *donatio mortis causa**, pero también el testamento, el legado, el fideicomiso.

1. La denominación *inter vivos* no se encuentra escrita en los textos de los juristas romanos.

2. La expresión *mortis causa*, en cambio sí. A veces como causa general de adquisición (*mortis causa capere*). O para determinados actos, como *donationes mortis causa*. Curiosamente no se la emplea para el caso de la *institutio heredis* o el legado.

C) *Solemnes y no solemnes*. En los primeros el *ius* exige la observancia de formas muy precisas. Son tales, en general, los correspondientes al *ius civile*; así, la *mancipatio**, la *in iure cessio**, etc. En los segundos existe carencia de formas o libertad para establecerlos. Son tales,

por lo general, los del *ius gentium** o del *ius naturale**. Así, en principio la compraventa clásica, el mutuo, la locación.

D) *Causales y abstractos*. Se dice que en los primeros la existencia de la *causa* aparece ineludiblemente unida a la existencia del acto o negocio, de tal modo que si ésta es ilícita o va contra las buenas costumbres, el acto es inválido. Así, la compraventa, en la cual el fin tenido en cuenta es inseparable de aquélla.

En cambio, en los segundos, si bien existe la *causa*, ésta se oscurece en un segundo plano de significación, no dependiendo la existencia del acto de su explicitación. Así, en la *mancipatio* o en la *stipulatio*. En principio, lo que interesa es la realización de las solemnidades sin tener en cuenta el fin tenido en vista.

1 Sin embargo, ello no es totalmente cierto. Así, en el caso de la *stipulatio*, la "causa" podía adquirir importancia, ya para invalidar el negocio o poder oponerse con alguna *exceptio* a su cumplimiento (v. *infra*, § 385).

E) *Onerosos o gratuitos*. Los primeros suponen una ventaja económica que se adquiere por una contraprestación consistente en un desprendimiento patrimonial —así, la compraventa, donde se recibe una cosa pagando un precio por ella—. En los segundos, la adquisición de la ventaja se realiza sin contraprestación, como p.ej. en la donación.

I. Elementos de los actos y negocios jurídicos.

§ 300. Se suele hablar de *elementos esenciales, naturales y accidentales*.

A) *Esenciales*. Son aquellos sin los cuales no se puede concebir la existencia misma del acto o negocio. Per ello son denominados también "requisitos". Principalmente (a) la *manifestación de la voluntad* y (b) el *objeto*. Además, para los actos causados, (c) la *causa*, y para los actos solemnes (d) la *forma*.

1. Acá nos referiremos al primero de estos elementos, es decir, a la interpretación de la voluntad.

Respecto del segundo, resulta obvio que es esencial, por cuanto la manifestación de la voluntad se debe referir a un objeto determinado. Lo que ocurre es que resulta imposible referirse a él en forma general; sino que cada acto o negocio tiene posibilidades, más o menos amplias o restringidas, acerca del dicho objeto. Hay, pues, que remitirse a cada negocio en particular para saber si él es factible de inte-

grarlo. Así, sobre qué cosas se puede hacer la *stipulatio**, cuáles pueden ser compradas y vendidas, cuáles pueden ser objeto de un legado* o de un fideicomiso*, cuáles pueden ser objeto de la *usucapio**, y así indefinidamente.

Respecto de la "causa", esta palabra tuvo en Roma ya el significado de "causa fuente" (*iusta causa*), es decir, el negocio que le sirve de antecedente. Así, respecto de la *usucapio**, o respecto de la *traditio**. Otras veces, el de "causa fin", es decir, el fin objetivo atendiendo al cual se realiza el acto o negocio, como ocurre en la compraventa (para adquirir una cosa), o en el mutuo (para conseguir dinero prestado). Debemos remitirnos, por tanto, a lo que se dice a propósito de cada caso en particular. Sin olvidar que aun en los actos o negocios abstractos, la *causa* puede tener significación, como ocurre con la *stipulatio*.

Y lo mismo ocurre respecto de la forma en los negocios solemnes, o cuando se requiere especialmente la forma escrita o la presencia de testigos.

B) *Naturales*. Se denominan así aquellos elementos que no resultan necesarios para concebir el negocio jurídico, pero que están en su naturaleza. Así, p.ej., la garantía que presta el vendedor respecto de la propiedad de la cosa vendida ("garantía de evicción*"), y respecto de los vicios ocultos existentes en dicha cosa ("vicios redhibitorios*").

Como se entiende que hacen a la naturaleza de "buena fe" de la compraventa, aunque las partes no mencionen estas garantías, ellas integran implícitamente el negocio. No obstante esto, por no ser esenciales, las partes podían determinar expresamente su exclusión.

C) *Accidentales*. Son aquellos que se pueden lícitamente incorporar a un negocio jurídico, pero cuya existencia no se presume, sino que depende de la voluntad de la o las partes que los hayan querido o no incorporar. Serían principalmente tales: la *condición*, el *plazo* y el *modo* o *cargo*. Los veremos más adelante, a propósito de las modalidades de los actos y negocios jurídicos.

II. La manifestación de la voluntad.

§ 301. La voluntad puede ser manifestada ya en forma "expresa" o en forma "tácita".

a) Ocurre lo primero cuando se la formula de manera indubitable. En algunos negocios, como la *stipulatio**, en forma oral. Así, el estipulante debía preguntar: "¿Promieter darme 100?", y el promitente respondía: "Prometo". En otros, en forma escrita, como sucede habitualmente en los testamentos.

b) Ocurre en forma "tácita" cuando, sin ha-

ber signos expresos de la actitud asumida por la parte, cabe reconocer con certidumbre la existencia de la voluntad. Así, el heredero "extraño" podía aceptar la herencia expresando que la aceptaba (forma expresa), pero también se entendía que aceptaba ser heredero si entraba a administrar los bienes hereditarios como si fuera el heredero (*pro herede gestio**). Éste sería un ejemplo de aceptación "tácita".

c) En cuanto al silencio, cabe decir que, en principio, no tiene valor. Así, si alguien me propone un contrato y yo nada digo, no se puede entender que lo haya aceptado. Sin embargo, este principio reconoce excepciones, cuando por las circunstancias concretas la parte tiene el deber de expresarse y no lo hace.

1. Así, en la *in iure cessio**, ante la afirmación de una de las partes que vindica la cosa afirmando ante el magistrado que es suya, el silencio de la otra es tomada por el pretor como conformidad con el acto.

2. Como veremos (v. *infra*, § 529, D), cuando una *filia* le hace saber a su *pater* que contraerá esponsales y éste no se opone, sino que guarda silencio, cabe entender que los acepta.

3. También, si una mujer casada que no vive con su marido anuncia a éste su embarazo, el silencio es interpretado como una confesión de su paternidad.

III. Interpretación de la voluntad.

§ 302. El problema que plantea la manifestación de la voluntad es el de su interpretación. Ésta a veces puede resultar difícil, por cuanto nos podemos restringir literalmente a la declaración expresada (para la Pandectística del siglo XIX, la "teoría declaracionista"), o más allá de los términos expresados, adentrarnos en la voluntad verdadera de quien lo manifestó ("teoría de la voluntad").

a) En la primera época de Roma, siendo los actos solemnes, el formalismo implicado provocaba que si se habían cumplido los ritos exigidos (así, para una *mancipatio*, una *stipulatio* o una *in iure cessio*), el acto producía los efectos pertinentes aunque éstos no fueran los queridos.

b) Luego de un lento proceso de maduración, se fue admitiendo mayor importancia a la "voluntad real". Así sucedió con los actos más informales, en especial aquellos que debían ser estimados conforme a la *bona fides* (p.ej., los contratos consensuales, como la compraventa, la locación, el mandato y la sociedad). Éstos generaban los *iudicia bonae fidei**, en los cuales el juez tenía mayor libertad para apreciar la real voluntad, más allá de las formas.

c) Este problema de la interpretación tuvo una importancia especialísima a propósito de

los testamentos. Ya hacia fines de la República, por influjo de la retórica helenística, se comenzó a debatir el dilema entre la interpretación estricta de las palabras empleadas (*verba*) y la investigación más profunda de la voluntad (*voluntas*) del testador. Este dilema entre *verba* y *voluntas* fue desarrollada por una línea de oradores, entre los cuales brillaba Cicerón. Fueron los paladines de la hegemonía que debía tener la verdadera voluntad del testador.

1. Este problema entre *verba-voluntas* tuvo importancia decisiva a propósito de los testamentos. Por un lado, porque se trataba de la interpretación de una voluntad irrepetible, ya que quien la manifestó había fallecido. Así, Celso, D.33.10.7.2, nos dice que "la intención del que testa es anterior y de mayor relevancia que la voz", citando a Tiberón acerca de que "las palabras son sólo un medio de expresión de esa voluntad". E igualmente Ulpiano, hablando de las condiciones incardinadas en el testamento afirma que "tiene preferencia la voluntad del difunto que es la que impera las condiciones" (D.35.1.19 pr.).

Por otra parte, este tópico de la *quaestio voluntatis*, tan del agrado de la retórica, encontró eco ante el Tribunal de los Centunviro, ante quien se llevaban estas causas.

Se trataba de interpretar, y a veces de completar y hasta rectificar las palabras literales, conjeturando cuál había sido la verdadera voluntad del testador (Tryfonino, D.15.1.57.2).

2. *Causa Curiana*. Esta causa resultó célebre, y estaba referida precisamente a esta *quaestio voluntatis*. La conocemos gracias a Cicerón (*de orat.* 1.39.180; 2.32.14-41; *Brutus*, 52.194-198; *de inv.* 2.42.122).

El caso era el siguiente: El testador Marco Coponio, creyendo que su mujer estaba embarazada, instituye como heredero al hijo por nacer. Pero para el caso de que dicho hijo muriera antes de la pubertad, el testador dispone su sustitución con Manio Curio (sustitución pupilar*). Muere el testador, pero el hijo que esperaba no nació, por haber errado respecto del embarazo de su mujer.

Se planteó entonces el juicio entre los herederos *ab intestato* —defendidos por Q. Mucio Scévola— y M. Curio —defendido por Licinio Craso—.

El alegato de los primeros se basaba en la literalidad de las palabras expresadas. No habiendo nacido el heredero instituido, y siendo el único, el testamento caía y había que abrir la herencia *ab intestato*. La sustitución en favor de Curio no valía. Si el testador lo quería, podía haber utilizado una "sustitución vulgar". "Si el hijo no llegase a ser heredero, que lo sea M. Curio". Pero no lo hizo.

En cambio, Licinio Craso sostuvo que había que desentranar la voluntad del testador, sin atenerse estrictamente a las palabras empleadas. Era evidente, para él, que el testador quería que el heredero fuera M. Curio, antes que los agnados *ab intestato*.

Por tanto, había que considerar que la "sustitución pupilar" estaba involucrando también la "sustitución vulgar".

El Tribunal de los Centunviro se decidió en favor de M. Curio, por lo que la indagación de la *voluntas* triunfó sobre la literalidad de los *verba*. Esta importante sentencia fue luego seguida por una decisión de Marco Aurelio y Vero (cit. por Modestino, D.28.6.4 pr.).

3. La interpretación en favor de la voluntad del testador se continuó luego por parte de los juristas clásicos. No debemos por ello creer que se dejó de apreciar la importancia de las *verba*. Si la expresión de la voluntad es clara, no hay motivo para interpretarla de manera distinta: "Cuando no hay ambigüedad en los términos, no se debe admitir la cuestión de interpretar la voluntad" (Paulo, D.32.25.1; D.32.69 pr.). Pero cuando surge alguna duda acerca de dicha manifestación, entonces cabía investigar el verdadero sentido de la *voluntas*.

Así, Ulpiano explica la interesante cuestión surgida acerca de si a propósito del testamento de un liberto de su abuelo, el nieto podía pedir la *bonorum possessio contra tabulas** por haber acusado su padre al liberto de un crimen capital. Basado en la autoridad de Maciano y Juliano, respondió que el nieto tenía derecho a pedirla (D.37.14.17 pr.), interpretando a su favor la voluntad del abuelo testador.

Igualmente, en este otro caso: Un *pater* designó en el testamento a su hija Severiana Prúcula para contraer nupcias con Elio Filipo, dejándole por fideicomiso a dicha hija un predio si realmente se casaba con dicha persona, pero si no se casaba con él, estableció que el predio le fuera dado a Elio Filipo. Ocurrió que la hija se murió siendo impúber, por lo que no se pudo casar, no por su voluntad sino porque no tenía la edad para hacerlo. Papiniano interpretó que en las condiciones de los testamentos se debe considerar más bien la voluntad que las palabras. De este modo, el predio dado por fideicomiso a Elio Filipo debía ser considerado de este modo: Le correspondía a él bajo la condición de que su hija Prúcula hubiera manifestado su voluntad de no casarse con Filipo. Pero dado que dicha hija no manifestó su voluntad de no casarse, sino que murió antes de llegar a ser casadera, se considera que la condición no se cumplió, y por lo tanto Filipo carece de derecho a reclamar el predio (Pap., D. 35.1.101 pr.).

4. Pero también se interpretó la voluntad en negocios formales, como la *stipulatio*. Así, en caso de duda, hay que interpretar la promesa de pago en favor del deudor (Pomp., D.45.1.12: si se prometió pagar 10 o 5, se deben sólo 5; o si se dice: "¿Prometes pagar en las calendas de enero o de febrero?", es lo mismo que si yo hubiera estipulado para las calendas de febrero; Ulp., D.14.41 pr. y 1: la agregación de plazo es a favor del promitente).

Y en general, respecto de los contratos libres de forma (Alfeno, D.19.2.29, sobre una locación; Paulo,

D.18.1.21, y Pomp., D.14.33: si un pacto es oscuro debe perjudicar al vendedor, a quien le correspondía expresarse con mayor claridad; Pap., D.35.1.101: en las convenciones se atiende más a la voluntad que a las palabras).

d) En la época posclásica, sobre todo por la influencia expresada en las corrientes helenísticas y en los principios teológicos cristianos, favorables a la voluntad, los bizantinos se pronunciaron abiertamente en la interpretación de la verdadera voluntad del testador o de las partes de un contrato o convención o pacto. Contribuyó también a esto el decaimiento de las formas solemnes de los negocios.

IV. Vicios de la voluntad.

Por lo general, la voluntad interna coincide con la voluntad manifestada. En caso de no ser así, y existir una discrepancia, se habla de un vicio de la voluntad o de su manifestación. Ello puede ocurrir en forma deliberada o de manera inconsciente.

§ 303. I. *Vicios conscientes*. Esto puede ocurrir en el caso de los negocios simulados, o en los hechos *animo iocandi* (como mera broma).

En la época antigua y clásica, si se trata de negocios formales, el negocio vale por sí, de tal modo que aun cuando las partes acuerden que el negocio no valga, dicho acuerdo no tiene validez.

En cambio, tiene mayor importancia cuando se trata de negocios libres de forma. Los casos de los que se ocuparon los juristas clásicos están dirigidos al caso de la realización de un negocio como la compraventa o la locación, pero sin que exista realmente un precio o un alquiler. En realidad, se trata de un negocio por causa de donación, lo cual puede tener importancia para encubrir casos de donaciones prohibidas.

En la época posclásica, fieles los bizantinos a la expresión real de la voluntad, el negocio simulado es nulo, y si el acto verdadero es lícito valdrá como tal, siempre que reúna los requisitos propios (Mod., D.44.7.54; C.4.3.9).

1. Si alguien fija un precio de venta de una cosa, pero se compromete a no reclamarlo, no se considera que vende, sino que está donando (Ulp., D.18.1.36; D.14.38). Pero si entre marido y mujer, la venta de una cosa hecha por un precio menor por causa de donación, el negocio es nulo (Ulp., D.14.38 it.).

Igualmente, si se arrendara por un solo sestercio, la locación es nula, interpretando que se trata de una donación (Ulp., D.19.2.46 it. al final).

Un matrimonio simulado, p.ej. contraído para escapar a las leyes caducarias, es nulo (Gayo, D.23.2.30).

2. Si el fin de la simulación es lícito (así, p.ej., perdonar como donación el alquiler debido por un colono en un año estéril), se tratará de interpretar la verdadera naturaleza del negocio (así, en este caso, valdrá no como donación, sino como transacción; Pap., Ulp., D.19.2.15.4).

3. Estos casos son conocidos en la doctrina moderna como casos de simulación "relativa" (se simula hacer un negocio, pero se hace otro). Si la simulación es "absoluta" y realizada en perjuicio de los acreedores, ocurre un "fraude" a éstos, lo cual merecerá la protección del pretor en su favor (*in integrum restitutio*, *interdictum fraudatorium* y finalmente, con Justiniano, la *actio Pauliana*; v. *infra*, § 466-467).

4. Un negocio efectuado como broma (*iocandi gratia*) carece de validez, por cuanto no hay una voluntad seria de realizarlo. Así, una *stipulatio* hecha como una broma (Florentino, D.44.7.3.2). Y también, pese a las facilidades concedidas a los militares, si un soldado dijese en una mera conversación "yo te hago heredero o te dejo mis bienes, no conviene que esto se mire como testamento" (rescripto de Trajano; Florent., D.29.1.24).

5. Cuando una de las partes manifiesta su voluntad, pero ésta no responde a su pensamiento interno, se hablará más tarde de "reserva mental", como p.ej. si alguien contrae matrimonio cuando en su fuero interno no se quiere casar. En Roma, no se la tiene en cuenta. Tendrá importancia, sobre todo en el caso del consentimiento matrimonial en el derecho canónico medieval.

II. *Vicios inconscientes*. Éstos ocurren en caso de error, dolo y violencia.

§ 304. A) *Error*. Se entiende por error el falso conocimiento que la o las partes tienen sobre el acto o negocio llevado a cabo o sobre un aspecto esencial de él.

1. El error a que nos referimos es el *error de hecho* (*error facti*). Existe el *error de derecho*, o mejor la *ignorancia de derecho* (*ignorantia iuris*), cuando alguien alega no conocer el *ius* o tener un conocimiento equivocado de él. En principio la ignorancia del *ius* resulta inexcusable (Paulo, D.22.6.9 pr.).

2. Sin embargo, se admitió que pudiera ser invocado por determinadas personas: así, los menores de 25 años (Paulo, D.22.6.9 pr.); en ciertos casos para los militares (Paulo, D.14.1); en otros, las mujeres (Ulp., D.2.13.1.5; Jul., D.25.4.2.1), y también los rústicos (Calístrato, D.49.14.2.7; Ulp., D.2.13.1.5; C.6.9.8).

Pero la ignorancia de derecho no aprovecha si uno tuviera forma de aconsejarse por un jurisconsulto, o estuviera instruido por su propia prudencia. Es decir que si le es fácil conocer lo que corresponde al

ius. "lo cual rara vez se ha de admitir", no se puede alegar su ignorancia (Labeón-Paulo, D. 22.8.9.3).

3. En cambio, el error de hecho se puede alegar, siempre que (a) sea esencial, es decir que la equivocación se produzca respecto de un elemento importante constitutivo del negocio y (b) sea excusable, es decir que quien lo alega no haya incurrido en grave negligencia, que consiste en ignorar lo que todo el mundo sabe (Labeón-Paulo, D. 22.6.9.2) o no entender lo que todos entienden (Ulp., D. 50.16.213.2).

I. *Error in negotio*. Ello ocurre cuando recae sobre la naturaleza misma del negocio. Así, si Ticio da una suma de dinero a Seyo con ánimo de donación, y Seyo la recibe creyendo que es a título de mutuo. Acá el error es esencial, de tal modo que no hay ni donación ni mutuo (Ulp., D. 12.1.18 pr.).

1. Sin embargo, Ulpiano en este mismo texto agrega que si el que creyó recibir en mutuo (la otra parte se lo daba en donación) hubiere consumido el dinero, el que se lo dio tendría en principio la *actio certae creditae pecuniae* para reclamarlo, pero el pretor le otorga en favor de quien lo consumió la *exceptio doli mali* "porque el dinero se consumió conforme a la voluntad del que lo da".

2. Pero si alguien dio una cosa en depósito y la otra la recibió como si fuera un mutuo, no hay ni depósito ni mutuo. Tampoco si hubieras dado dinero en mutuo y yo lo recibí en comodato para mostrarlo. En ambos casos, consumido el dinero, habrá lugar a la acción de recupero, pero sin la *exceptio doli mali*. En el primer caso, no hubo voluntad de que el otro lo consumiera; en el segundo, el que lo recibió tampoco estaba en la inteligencia de que lo podía gastar (Ulp., D. 12.1.18.1).

II. *Error in persona*. Tiene lugar cuando se celebra un negocio respecto de una persona distinta de aquella con la cual se creía negociar. Para ser esencial el error, la identidad de la persona o sus cualidades deben ser determinantes. Ello puede ocurrir en los contratos que en la actualidad se denominan *intuitu personae*, como p.ej. la sociedad, el mandato, la locación de obra, etc. De no ser determinante y esencial tal persona, el error es intrascendente.

1. En los textos romanos encontramos muy pocas referencias a esta clase de error en los negocios bilaterales. Así, el caso planteado por Celso: A mi y a Ticio nos has pedido dinero en mutuo. Yo mandé que te lo entregara un deudor mío, y tú estipulaste con él, pero creyendo que era deudor de Ticio. La cuestión es si pese a ese error, quedas obligado hacia mí. Celso contesta que si bien en principio no hiciste un negocio conmigo, el error no tendría importancia porque de todos modos mi dinero fue a tu poder (D. 12.1.32).

2. En cambio tiene especial importancia en los testamentos. Si el testador yerra en cuanto a la designación del heredero: así, dice "Que sea heredero mi hermano", habiendo querido decir: "Que sea heredero mi patrono", la institución es nula, ya que no es heredero el instituido, demostrándose que no fue esa la voluntad del testador, y tampoco aquel a quien quiso instituir, porque no se escribió así" (Ulp., D. 48.5.9 pr.).

En cambio, cuando la institución se ha hecho con certeza, pero incurriendo en alguna falsedad, la institución es válida (Marciano, D. 48.5.48.3).

Lo mismo respecto de los legados, si hay una equivocación respecto del nombre, pero la persona puede ser perfectamente identificada, él es válido (Inst., 2.20.29). También un error sobre una condición del legatario. "Lego a Stichio a Ticio, porque él ha cuidado mis bienes en mi ausencia", aunque esto último sea erróneo, el legado es válido (Inst., 2.20.31).

Se trató, en la medida de lo posible, de interpretar la voluntad verdadera del testador.

C) *Error respecto de la cosa*. Este error puede versar sobre aspectos distintos referidos a la cosa del negocio:

(i) *Error in corpore*. Es el que recae sobre la identidad de la cosa. Así, p.ej., si yo creyera que compraba el fundo Corneliano, y tú creías que me vendías el fundo Sempsonianio, la venta es nula; igualmente, si yo creí que te vendía a Stichio y tú creíste que te vendí a Pánfilo (Ulp., D. 18.1.9 pr.).

1. Sin embargo, el mero error del nombre de la cosa vendida, no existiendo dudas acerca de qué cosa se trata, no invalida el negocio (Ulp., D. 18.1.9.1).

2. Igualmente, si el testador quería dejar en legado una bandeja y erróneamente dejara un vestido, probado el error, no se deberá ni una cosa ni la otra (Ulp., D. 28.5.9.1).

Pero si la cosa estaba suficientemente designada, es decir, no había duda sobre ella, aunque existiera alguna referencia falsa, el legado no dejaba de ser válido. Así, p.ej.: "Lego a Stichio, nacido de mi esclava", y ocurriera que no nació de mi esclava pero era mío por otra causa, así por haberlo comprado.

(ii) *Error in substantia*. Este caso versa sobre una cualidad esencial de la cosa. Así, p.ej., si se vendiera una cosa de oro y se está vendiendo una de bronce, o se vendió vino y en realidad era vinagre (Ulp., D. 18.1.9.2). O se vendió una esclava y tú creíste haber comprado un esclavo (Ulp., D. 18.1.11.1). En estos casos el negocio es nulo.

1. Todo esto dio lugar a una discusión entre los juristas, a propósito de una casuística muy retórica. Así, ¿qué ocurre si se cree vender una mesa de plata,

y en realidad es enchapada en plata? Nótese que este caso tiene la particularidad de que la mesa tiene algo de plata. Juliano (D. 18.1.41.1) entendió que en este caso no había compraventa por *error in substantia*.

Está parece haber sido desde este autor la opinión predominante (Marciano, D. 18.45; Paulo, D. 19.1.21.2). En cambio, Marcelo estaba por la posición contraria, de tal modo que entendió —aunque sin éxito— que el error para invalidar el negocio debía ser *in corpore*, pero no *in substantia* (Marcelo-Ulp., D. 18.1.9.2: vinagre por vino, plomo por plata, bronce por oro).

Al aceptarse la opinión de Juliano, el criterio debió ser casuístico, puesto que el punto a decidir era la importancia de la cualidad. Por el otro lado, esto afectaba lo relativo a los vicios redhibitorios. Las dificultades que traía este *error in substantia* se ve en la distinción hecha por Ulpiano (D. 18.1.9.2): si se vendió vino y en realidad era vinagre, la venta era nula; en cambio, si se vendió vino y éste luego se agrió, era válida.

2. El mero error en las cualidades de la cosa, sin llegar a afectar la sustancia (*error in qualitate*), no trae la nulidad de la compraventa. Así, si te vendí una cosa de oro, pero que no era de la calidad que esperabas (Paulo, D. 18.1.10). Se entiende que hubo consentimiento, pudiéndose discutir en su caso los vicios o defectos ocultos ignorados por el comprador, por las vías vinculadas a los vicios redhibitorios*.

(iii) *Error in quantitate*. Tiene lugar cuando recae sobre la cuantía de la cosa objeto del negocio.

1. Los textos nos refieren el error en la cantidad de la suma prometida en una *stipulatio*. Tratándose de un negocio formal, la pregunta y la respuesta debían ser congruentes. Así, p.ej., si se preguntaba: "¿Me prometes dar 10 sesteracios?", y el otro contestaba: "Te prometo dar 5".

En la época de Gayo, se interpretaba que cada suma era un objeto distinto, por lo que el interrogado no respondió exactamente a lo preguntado; siendo así, la *stipulatio* era nula (Gayo, 3.102). Sin embargo, más tarde, con Ulpiano y Paulo, las sumas son consideradas puras cantidades, por lo que como la suma menor está siempre comprendida en la mayor (los 5 en los 10), se interpretaba que la *stipulatio* era válida hasta el monto menor; en este caso por los 5 sesteracios (Paulo, D. 45.1.1.4; Paulo, D. 18.1.9.2). Será la solución dada por Justiniano (Inst., 3.19.5).

2. En los contratos del *ius gentium* se sigue un criterio semejante. Así, en una locación, A cree arrendar una cosa por 5 y B entiende haber arrendado por 10, la locación es válida por 5. En cambio, si A le arrienda por 10 y B entiende que lo arrienda por 5, el negocio es inválido (Pomp., D. 19.2.52). En el primer caso, hay consentimiento, por cuanto el locatario acepta el precio del alquiler por una suma mayor (en

los 10 están comprendidos los 5). En cambio, en el segundo, la voluntad de alquilar por 10 del locador, no encuentra consenso en la del locatario.

3. En los testamentos, el *error in quantitate* se puede referir a la cuota asignada a un heredero.

(i) Si el testador dictó a quien escribía el testamento: "Que Ticio sea heredero por la mitad", y se escribió que lo fuera por 1/4, si se probare el error, la cuota de Ticio será por la mitad, dando validez a lo realmente querido sobre lo escrito. Y así, siempre que en el testamento se asignara una cuota menor, pero se prueba que el testador quiso dejar más (Celsus-Ulp., D. 28.5.9.2).

(ii) Si el testador ha escrito una cuota mayor, pero realmente había querido dejarle al heredero una menor, esta última es la válida, ya que está comprendida en la mayor. Así, "Que Ticio sea heredero por 1/4", y su voluntad era dejarle la mitad (Próculo-Ulp., D. 28.5.9.3).

(iii) Si el testador hubiese distribuido la herencia de tal modo que se sobrepasa el total de ella, o dejara instituido un heredero sin parte asignada, se trataba de interpretar la voluntad del testador. La costumbre romana era considerar el todo de la herencia como un *as*, que a su vez se dividía en 12 porciones iguales (*unciae*); Inst., 2.14.5.

Veamos este caso: "Que Ticio, Mevio y Seyo sean herederos. Ticio por 8 *unciae* y Mevio por 4 *unciae*". Como vemos, el testador ha agotado el *as*. ¿Qué le corresponde a Seyo, a quien no se le atribuyó ninguna cuota? Se interpretaba que el testador había querido separar su herencia en dos *ases*, compuesto cada uno por 12 *unciae*, lo que hará un total de 24 *unciae*. De este modo, las primeras 12 partes serán distribuidas 8 a Ticio y 4 a Mevio. Las 12 restantes, o sea, el segundo *as* le corresponderá por entero a Seyo (Ulp., D. 28.5.17.3; Paulo, D. 18.1.18; D. 18.1.20.1).

Consideremos este otro supuesto: "Que Ticio, Mevio y Seyo sean herederos. Ticio por 10 *unciae* y Mevio por 8 *unciae*". Nada se dijo de Seyo. Siguiendo el mismo criterio anterior, la división en dos *ases* con sus 24 *unciae*, permite distribuir la herencia así: Ticio tendrá 10 *unciae*, Mevio 8 *unciae*, y las 6 *unciae* restantes le corresponderán a Seyo (Paulo, D. 18.1.18: "por lo que faltase para el doble *as*").

§ 305. B) *Dolo*. Se trata acá del supuesto que una de las partes realiza alguna maniobra para engañar a la otra haciéndola caer en un error provocado. Si aquí hay conciencia del dolo por parte de quien lo comete, el vicio es inconsistente para la otra que lo sufre.

Servio Sulpicio Rufo definió así al dolo: "Cierta maquinación para engañar a otro, cuando se simula una cosa y se hace otra" (Ulp., D. 4.3.1.2). Esta definición resultaba estrecha, por cuanto se podía cometer dolo aun cuando no hubiera simulación. Por ello se adopta la célebre definición de Labeón: "Dolo malo es toda astucia (ca-

luditas), falacia (*fallacia*), maquinación (*machinatio*) empleada para sorprender, engañar o defraudar a otro" (D.4.3.1.2; Ulpiano dice acá que "la definición de Labeo es verdadera").

En un principio los actos y negocios en que hubiera mediado dolo eran válidos, salvo después aquellos en los cuales intervenían menores de 25 años, quienes eran protegidos por el pretor. Sin embargo, desde que se practicaron los contratos de buena fe, se fue forjando la idea de que el actuar doloso era una figura delictual, y fue así que Aquilio Galo, gran jurista del siglo I a.C., actuando como pretor peregrino en el año 66 a.C. tipificó al "dolo malo", concediendo al perjudicado la *actio de dolo* para obtener una indemnización por el perjuicio sufrido (Cic., *de off.* 3.14.60; Ulp., D.4.3.1.1; EP, § 40).

1. Es interesante el caso que narra Cicerón (*loc.cit.*): Un caballero romano C. Canio quería comprar una casa frente al mar en Siracusa. Un tal Pythio, banquero del lugar, se aprovechó de él, invitándolo a cenar en una casa. Arregló con algunos pescadores que se presentaron ante la vista de los comensales, con grandes cantidades de pescados en sus barcas. Ante el asombro de Canio, su anfitrión le explica que ése es el sitio donde más se pesca, y donde se provee de agua la población. Por ello el infortunado caballero se decide a comprar la casa, enterándose al día siguiente que todo había sido una *mise en scène* que se hizo representar ante él para inducirlo a la realización del negocio. Y frente a ello, Cicerón reconoce que nada se pudo hacer: "Mi colega y amigo C. Aquilio no había producido su definición jurídica del dolo".

2. La definición de C. Aquilio Galo era semejante en lo sustancial a la ya citada de Servio Sulpicio: "Hay dolo cuando se simula hacer una cosa y de hecho, efectivamente, se hace otra". Como ya lo vimos resulta incompleta frente a la de Labeo.

Se habla de *dolus malus*. Ulpiano nos explica que los antiguos decían que había un *dolus bonus*, dando este nombre a meros actos de astucia y picardía, y mayormente si la maquinación se hace contra el enemigo o el ladrón (D.4.3.1.3).

(i) Si bien en el dolo se vicia la voluntad, el pretor lo concibió como un delito pretorio. La *actio de dolo* es una "acción penal" por el *simulacrum* y que debe ejercerse dentro del año (EP, § 40) y tiene carácter infamante (Ulp., D.4.3.1.1 (12).1), y tiene carácter noxal (Paulo, D.4.3.18(19).4).

Dado su carácter infamante, sólo es acordada cuando no exista otra vía de procedimiento (ya sea una acción civil u honoraria o una excepción o un interdicto; Ulp., D.4.3.1.4). Luego del año, el pretor daba una *actio in factum* no sólo contra el autor del dolo, sino también con-

tra sus herederos hasta el monto en que se hubieran enriquecido (Gayo, D.4.3.28).

1. La *actio de dolo* sólo puede ser dirigida contra aquel que cometiese el dolo, pero no contra un tercero. En esto se diferencia de la *actio quod metus causa*, para el caso de violencia, en la cual no interesa de quien provenga ella (Ulp., D.4.3.15.3).

2. En la época posclásica, Constantino amplió la acción al plazo de dos años (C.2.20.8, año 319). Igualmente, extendió los efectos contra los herederos hasta el límite de lo enriquecido (Ulp., D.4.3.17.1; Gayo, D.4.3.28 (19).4). Justiniano la incluye entre las acciones arbitrarias (Inst., 4.6.31).

(ii) Aparte de la *actio de dolo malo*, el pretor otorga una *exceptio doli mali* (Paulo, D.44.4.1). Mediante ella, si alguien había celebrado un acto en el cual la otra parte cometió dolo, en caso de ser demandado el perjudicado, podía oponer esta excepción (Ulp., D.45.1.36). En un principio tuvo importancia a propósito del dolo cometido en una *stipulatio*, es decir, en un negocio bien formal. Si se la había efectuado sin causa mediante una maniobra dolosa, y también cuando el dolo fuera posterior al acto, pero vigente en el momento de la *litis contestatio* (así, p.ej., si se realizó la *stipulatio* en la confianza de que el acreedor entregará luego el dinero que debía prestar y no lo hacía). Entonces el demandado podía oponer la *exceptio doli mali* mediante la cual paralizaba la acción de cobro (Gayo, 4.116a; Ulp., D.44.4.2.8).

En los *iudicia bonae fidei* se considera que lo relativo a la cuestión dolosa está subsumido en la noción de *bona fides*, por lo que dado el arbitrio del *iudex*, es innecesario interponer la *exceptio doli mali* (Jul., D.30.84.5; Ulp., D.24.3.21).

El empleo de la excepción de dolo se fue ampliando. En el derecho justinianeo, al lado de la *exceptio doli specialis* que se debía interponer en los *iudicia stricti iuris*, funciona una *exceptio doli generalis* que abarca una gran cantidad de casos y que puede reemplazar las otras excepciones, en particular la *exceptio pacti conventi* (Ulp., D.44.4.4.33).

1. Ya desde la época clásica se solía usar de manera preventiva el agregar a la *stipulatio* una *clausula doli*, por la cual el prestamista se aseguraba respecto de cualquier conducta dolosa del promitente. Esta costumbre continuó en la época posterior (Jul., D.45.1.53; Pap., D.45.119 y 121).

2. Para el caso ya señalado del estipulante que luego no diera el dinero del préstamo por el cual se hizo la *stipulatio*, Justiniano empleará la forma particularizada de la *exceptio non numeratae pecuniae* (Inst., 4.13.2).

(iii) Resulta probable que aparte de la *actio de dolo* y la *exceptio doli*, el pretor otorgara al perjudicado por el dolo la posibilidad de una restitución total (Paulo, 1.7.2; Ulp., D.4.1.1).

§ 306. C) *Violencia*. La palabra *metus* (miedo) sirve para designar el temor a sufrir un daño, del cual se sirve una de las partes para amenazar a la otra para que se realice un acto que de lo contrario no se habría efectuado. Así, p.ej., te comino, bajo amenaza de muerte, a que realices una *stipulatio*, prometiéndome que me manciparás una cosa (Gayo, 4.117; Inst., 4.13.1; *id.* 4).

1. Según el *ius civile*, al igual que lo ocurrido con el dolo, los actos realizados por causa de *metus* eran válidos. Se consideró que esta circunstancia no impedía la existencia de la voluntad en el acto, de tal modo que éste existía. Así, lo que dice Paulo acerca de una aceptación de la herencia: *coactus voluit, sed tamen voluit* (quiso constreñido, pero quiso; D.4.2.21.5), revelan bien lo que sucedía en el *ius civile* estricto.

2. Pero alrededor del año 80 a.C., el pretor Octavio introdujo una acción penal: la *actio quod metus causa* (Ulp., D.4.2.1; EP, § 39), por la cual consideraba inválido el acto realizado por "causa de miedo".

La fórmula *Octaviana* hablaba de actos cometidos por *vis* (violencia) y *metus* (miedo). Pero, como lo explica Ulpiano, se suprimió luego la primera expresión, por entender que estaba comprendida en la segunda: "lo que se hace por fuerza atroz, parece que se hace también por miedo" (Ulp., D.4.2.1). Los medievales diferenciaron entre la *vis compulsiva* (la intimidación) y la *vis absoluta* (la fuerza directa).

Para poder alegar el *metus*, hay que cumplir estos requisitos:

a) Debe haber una amenaza injusta, es decir, el preanuncio de un mal grave a sufrir. Así, no sería injusto el decirle a mi deudor: "Si no me pagas, te demandaré". En cambio, podrá alegar el *metus* aquel que ha sido sorprendido en adulterio o en *furtum*, y lo amenaza con la muerte o la prisión, para que me venda un bien (Ulp., D.4.2.7.1).

b) El mal con que se amenaza debe ser "grave" (así, la muerte; Paulo, D.4.2.8.2, o la esclavitud; Paulo, D.4.2.4). Se debe tratar de la amenaza de un mal inminente, es decir, el miedo presente, no el eventual (caso de una mera sospecha nacida del temor, como p.ej. si yo hubiera abandonado un fundo mío por haber oído que alguien venía con armas; Ulp., D.4.2.9 pr.).

Para la consideración del *metus* se tiene en cuenta no el miedo de un hombre "apocado", sino el que tiene con motivo suficiente un hombre muy sereno (Gayo, D.4.2.6).

c) Debe estar dirigido a que el afectado ten-

ga que realizar el acto que luego se impugna. Así, p.ej., que por esa amenaza haya tenido que dar por recibido el dinero de una deuda, o entregar una cosa (Ulp., D.4.2.14.3).

Las medidas de protección eran las siguientes:

(i) La *actio quod metus causa*, que era una acción penal por el *quadruplum* del interés económico que ha perdido como consecuencia del *metus*. Al igual que con la *actio de dolo*, se debe ejercer dentro del año. Pasado éste, el pretor concede una *actio in factum* pero sólo por el *simulacrum*, después de examinada la causa (*cognita causa*; Ulp., D.4.2.14.1).

A diferencia de la *actio de dolo*, que sólo se puede incoar contra el autor del dolo, en la *actio quod metus causa* no interesa si el que realizó la intimidación fue la otra parte o un tercero. Basta con demostrar que el acto se realizó por *metus* (Ulp., D.4.2.14.3).

1. Era considerada por ello una *actio in rem scripta*, es decir, escrita a propósito de la cosa (la violencia misma) cualquiera que fuera el actor (Ulp., D.44.4.4.33).

2. La pena del *quadruplum* se veía mitigada por la "cláusula arbitraria" (la menos que la cosa sea restituida según el arbitrio del juez), de tal modo que si era restituida no cabía la pena (Ulp., D.4.2.14.3, *in fine*).

3. No tenía carácter infamante (Ulp., D. *ibid.*). Si se trataba de la *actio in factum* se podía dirigir contra los herederos del demandado hasta el monto del lucro o ganancia obtenido por ellos (Gayo, D.4.2.19).

(ii) El pretor concedía también la *exceptio quod metus causa* para el caso de que el acto realizado por *metus* no hubiera alcanzado su ejecución final. Así, si A obliga por medio de la intimidación a B a que le prometa por una *stipulatio* una suma de dinero. Cuando A demande a B, éste le puede oponer esta excepción (Ulp., D.44.4.4.33).

1. Ulpiano explica en el párrafo citado que Cassio decía que esta excepción estaba comprendida en la *exceptio doli mali*. Pero es necesario separarla, por cuanto se puede ejercer no sólo respecto de la violencia ejercida por la otra parte, sino que siendo *in rem scripta*, también se podía ejercer cuando el *metus* proviniera de un tercero.

(iii) Igualmente existía el remedio pretorio de la *in integrum restitutio*, por la cual se volvían las cosas al estado anterior. Presentaba la ventaja p.ej. respecto de un deudor insolvente; de nada valía amenazarlo con el *quadruplum*. Por otro lado, esta *restitutio in integrum* es dada incluso después del año (Paulo, D.4.2.21.1).

V. Modalidades del negocio jurídico.

En un negocio jurídico se pueden incorporar ciertas cláusulas, cuya inclusión depende de la voluntad de las partes. Pero una vez agregadas tienen validez para el negocio respectivo. En términos modernos, se los denomina "elementos accidentales" del negocio jurídico.

1. En realidad la posibilidad de agregar modalidades en un negocio jurídico es muy amplia. Por lo general se piensa en la "condición", en el "plazo" y en el "modo o cargo". Pero también podemos agregar la "cláusula penal" (*stipulatio poenae*), la elección de un domicilio para el pago de una obligación, y en general los distintos pactos que se pueden agregar a un contrato (*pacta adiuncta*), como p.ej., el pacto comisorio*, de *non petendo**, *in diem additio**, etc. La lista total es indefinida.

2. Estos elementos accidentales agregados al negocio, son conocidos también como *leges*. En efecto, las partes se someten a la modalidad que han optado agregar y la deben cumplir como una "ley privada" (*leges rei suae dictae*).

§ 307. A) Condición. La "condición" (*conditio*) es un acontecimiento futuro e incierto del cual depende la eficacia del negocio. Así, p.ej., si en una *stipulatio* se pregunta así: "¿Prometes darme 5.000 sesteracios si Ticio llega a ser cónsul?", o "¿Prometes darme 5.000 sesteracios si llegara una nave del Asia?" (Inst., 3.15.4), de tal modo que hasta que se cumpla dicho acontecimiento la obligación es una situación de expectativa, que no es aún exigible (Ulp., D.50.16.213).

1. El acontecimiento condicional debe ser "futuro". Si se refiere a un hecho pasado o presente, así "Si Ticio es cónsul" o "Si Mevio está aún vivo", se entiende que la obligación es "pura y simple". En efecto, si estos acontecimientos pasados o presentes no han sucedido, la estipulación es nula. Si, en cambio, han sucedido, es exigible en forma inmediata. Y ello ocurre así aun cuando estos hechos sean simplemente desconocidos por las partes, no obstante la apariencia de incertidumbre, no suspende la obligación, puesto que lo que es desde ya cierto por la naturaleza de las cosas, es prontamente constatado (Inst., 3.15.6; Modest., D.45.1.109; Pap., D.id. 120).

2. A su vez, debe ser "incierto", pues si necesariamente debe ocurrir, estamos en presencia de un plazo, y no de una condición.

3. Los juristas clásicos sostuvieron que la condición debía figurar como un evento del cual depende la obligación. Así, "¿Prometes darme tanto si llegara una nave del Asia?". En cambio, si se dijera: "¿Prometes darme hoy tanto si una nave llegara mañana o pasado del Asia?", se entendería que era una condi-

ción "prepostera" (se pone el término para pagar (*pre*) antes de que se cumpla la condición (*postera*)).

El negocio sería nulo. Pero Justiniano, sobre la base de una constitución del emperador, quien admitió la validez de una condición prepostera en materia de dote, amplió el campo de aplicación a todos los negocios *inter vivos* o *mortis causa*. De este modo el negocio es válido pero nada se puede exigir antes de que se cumpla la condición (Inst., 3.19.14; C.6.23.25, año 528).

4. No se consideran estrictamente condiciones, las llamadas *condiciones iuris* o *tacitae*. Son las referidas como requisitos jurídicos para que el negocio tenga efectos. Así, p.ej., la *stipulatio* por la cual se promete la dote, conlleva tácitamente la condición "si las nupcias se hubieren verificado", por lo que si no se la expresaba se entendía que, por supuesto, estaba comprendida en la *stipulatio* (Ulp., D.23.3.21).

5. Principalmente, los textos romanos se refieren a la condición a propósito de la *stipulatio* y de las cláusulas testamentarias. Puede existir, sin embargo, en otros negocios, con excepción de los llamados "actos legítimos" (*actus legitimi*), que no admiten esta modalidad: así, p.ej., una *mancipatio**, una *in iure cessio**, una *acceptilatio**, la aceptación de una herencia*, el legado de opción (*servi optio*)*, la dación de un tutor. De incorporarla a estos actos, éstos resultan ineficaces (Pap., D.50.17.77).

§ 308. Clasificación de las condiciones.

(i) En el derecho moderno se distingue entre la *condición suspensiva* y la *condición resolutoria*. Según la primera, la eficacia del negocio nace cuando el hecho condicional se cumple (Así, p.ej., Te prometo dar 1.000 si llegara una nave del Asia). En cambio, la segunda hace que el negocio nazca y es eficaz, pero de ocurrir la condición, él se resuelve. Así, p.ej., Te daré 100 todos los días mientras no llegue una nave del Asia. Desde ya te estoy debiendo 100, pero esa obligación se resuelve si sucediera el hecho condicional.

En el Derecho Romano sólo se conoce propiamente lo que hoy día se llama "condición suspensiva", es decir, cuando la eficacia del negocio se subordina al hecho condicional. Estrictamente, los clásicos no consideran la "condición resolutoria" como una clase especial y autónoma; cuando se quiera establecer algún efecto resolutorio, se añade al negocio un pacto suspensivamente condicionado.

1. Así, p.ej., si se agregó a una compraventa un pacto de que si dentro de un determinado plazo el comprador no aprueba la cosa comprada la venta queda resuelta, se entiende que se trata de una compraventa pura, con un pacto de resolución suspensivamente condicionado o aplazado (Ulp., D.18.1.3). Lo mismo ocurre con el pacto comisorio* y el pacto *in diem additio*.*

2. En el caso de una *stipulatio* se podía subordinar la eficacia de ella a una condición suspensiva (así, "Prometes darme 100 si llegara una nave del Asia"), pero realizada empleando en la pregunta una condición o un plazo resolutorio, la modalidad no es válida, quedando la obligación debida en forma pura y simple. Así, p.ej.: "¿Me prometes dar 100 aureos por día, mientras no llegue una nave del Asia?", se entiende que la obligación es pura y simple y se perpetúa, de tal modo que según el *ius civile* estricto, el deudor continúa obligado a dar dicha cantidad diaria.

Esto se debe a que los juristas romanos sólo admiten en principio que una obligación se debe extinguir por alguno de los modos admitidos (así, por el pago). Lo que no se admite es que se pueda deber *ad tempus*; es decir, hasta un tiempo determinado (*ad tempus debere non potest*; Inst., 3.15.3; Paulo, D.44.7.44.1 y 2).

Sin embargo, el pretor corregirá los efectos inequitativos que se producían. Otorgaba al deudor, en caso de haberse producido el hecho condicional, la *exceptio pacti conventi* o la *exceptio doli mali* (Inst. *ibid.*; Paulo, D. *ibid.*).

3. En el derecho hereditario se puede establecer una institución de heredero subordinada a una condición suspensiva, como p.ej.: "Que Ticio sea mi heredero si viene una nave del Asia". El instituido será heredero si se cumple la condición.

Pero no se puede instituir heredero subordinado a una condición resolutoria: así, "Que Ticio sea mi heredero hasta que venga una nave del Asia".

La razón está dada por la regla *semel heres semper heres*, es decir que una vez que alguien es heredero lo será siempre, de tal modo que no se admita tampoco la institución de heredero "hasta un tiempo" (*ad tempus*). En favor de la validez del testamento, se entiende que la institución es pura y simple, es decir, no sometida a condición, entendiéndose que la cláusula resolutoria no estaba escrita (Inst., 2.14.9).

(ii) Las condiciones pueden ser *casuales*, *potestativas* o *mixtas* (Justin., C.6.51.1.7). Las "casuales" son aquellas que dependen de un acontecimiento extraño a la voluntad de las partes (así, p.ej., "¿Prometes darme tanto si viene una nave del Asia?"). Las "potestativas" son aquellas que dependen de un acto voluntario propio (así, p.ej., "¿Prometes darme tanto si asciendes al Capitolio?"). Las "mixtas", cuando dependen, en parte de un acto propio y en parte de un acontecimiento extraño a la parte (así, p.ej., "¿Prometes darme tanto si compraras el fundo Tusculano?", ya que depende por un lado de un acto de mi voluntad: que yo compre, y por el otro de un acontecimiento extraño a mi voluntad: que Ticio quiera vender).

1. La condición potestativa no puede quedar reducida a la mera voluntad del promitente: así, "¿Pro-

metes darme 100 si quisieras darme los?" De ser así, se entiende que la *stipulatio* es inválida (Ulp., D.45.1.17; Javol., D.id.105.1; Paulo, D.46.2-3; Pomp., D.44.7.8).

2. Las condiciones pueden ser *positivas* (cuando el negocio se subordina a que se realice un acontecimiento: "que ocurra tal hecho") o *negativas* (cuando se subordina a que no suceda: "que no ocurra tal hecho").

Un problema especial se presentaba cuando el negocio se subordinaba a una condición "potestativa negativa". Así, "¿Prometes darme tanto si yo no ascendiera al monte Capitolio?". Como no había ningún plazo para determinar cuándo se consideraba cumplida la condición, se interpretó que era como si hubiese estipulado que el estipulante se los daría a su muerte, siempre que para esa época no hubiera subido al monte Capitolio (Inst., 3.15.4).

En cambio, se podía estipular sin mayores problemas, diciendo: "¿Prometes dar 1.000 si en el término de dos años yo no subiera al monte Capitolio?", debiéndose esperar dicho tiempo para saber si la condición se cumplió o no (Celso, D.45.1.99.1).

Para el caso de los legados dejados con condición potestativa negativa: "Dejo tal legado a Ticio si no ascendiera al monte Capitolio", o "si no manumitiera a Stichus", se tendría que aplicar la misma regla que respecto de la *stipulatio*, con lo cual el legatario se beneficiaría del legado. Pero se aplicaba un remedio arbitrado por Q. Mucio Scaevola. Consistía en que el legatario tomara inmediatamente el legado, pero dando previamente una caución al heredero, es decir, una seguridad para la restitución si es que no acababa la prohibición del testador (*cautio Muciana*; Ulp., D.35.1.7 pr.; Javol., D.id.67; Pap., D.id. 72 pr., 1-2; 73; 77.2; Pap., D.id. 101.3; Jul., D.id. 106).

Más tarde, se aplicó también al caso análogo de la institución de heredero (Ulp., D.28.7.4.1 itp.).

(iii) Se habla de condición *imposible* cuando consiste en algo que no puede existir, como p.ej. si se estipula: "¿Me prometes dar 100 si yo tocara el cielo con el dedo" (Gayo, 3.98; Inst., 3.19.11). Acá, nos encontramos con una imposibilidad "fáctica". Pero, también puede consistir en una imposibilidad "jurídica", como p.ej.: "¿Me prometes dar 100 si compraras el templo de Ceres (*res sacra*) o el Foro (*res publica*)?" (Inst., 3.19.2; Venuleyo, D.45.1.137.6).

También se habla de condición *ilícita* o *inmoral*, cuando consiste en realizar algo jurídicamente prohibido o inaceptable por las buenas costumbres, como, por ej., "¿Me prometes dar 10.000 si mato a Ticio" o "si cometo un sacrilegio".

1. Agregada a una *stipulatio* una condición imposible torna a ésta nula (Gayo, 3.98; Inst., 3.19.11; 3.19.24; Gayo, D.44.7.1.11). E igual efecto para los negocios contractuales: compra, locación, etc. (Meciano, D.44.31).

En cambio, si se dice: "¿Prometes darme 100 si yo no tocaré el cielo con el dedo?", la obligación se mantiene considerándola pura y simple (Inst., 3.19.11).

2. Respecto de una condición ilícita o inmoral, el negocio *inter vivos* es nulo (Inst., 3.19.24; Ulp., D.45.1.26; Pomp., D.46.27). Pero a diferencia de lo dicho a propósito de la condición imposible, redactada en forma negativa, el negocio quedaría invalidado. Así: "¿Prometes darme 1.000 si no incendio esta casa?" o "si no injurio a tal persona", por cuanto no se puede estipular un precio para abstenerse de cometer un acto ilícito o inmoral (Ulp., D.2.14.7.3).

Sin embargo, en ciertos casos podía resultar válida. Así, el caso que plantea Papiniano, de una mujer que estipuló 200 respecto de su marido si éste persistía durante el matrimonio en tener una concubina. En este caso, lejos de estar en contra de las buenas costumbres, parece estar hecha en favor de ellas (D.45.1.121.1).

3. Son distintos los efectos respecto de las disposiciones testamentarias. Así, la institución de heredero y los legados.

En la época clásica, las escuelas habían debatido el problema de una condición imposible en los legados. Los proculeyanos entendieron, que al igual que la *stipulatio*, el legado era nulo. En cambio, los sabianos opinaban que el legado era válido como debido sin condición.

Esta última opinión es la que triunfará (Inst., 2.14.10), de tal modo que una condición imposible en las instituciones de herederos, en los legados, en los fideicomisos y en las manumisiones, se tiene por no escrita. Sucede lo mismo con las condiciones ilícitas e inmorales (Paulo, 3.4.2, § 2.2).

§ 309. *Efectos de la condición.* Hay que observar acá dos situaciones distintas: ¿qué es lo que ocurre desde que se ha realizado el negocio condicional y la condición está aún pendiente (*pendente condicione*)? y ¿qué es lo que ocurre cuando la condición se ha cumplido (*existente condicione*) o el hecho condicional no ha ocurrido?

1. *Pendente condicione.* a) Para los autores clásicos hay textos muy precisos acerca de que *pendente condicione*, no existe aún la obligación (Marciano, D.20.1.13.5; Ulp., D.50.16.213; Gayo, 3.124).

1. Precisamente, como nada se debe, si el deudor por error paga antes de cumplirse la condición, puede pedir por la *condictio indebiti* la restitución de lo pagado (Pomp., D.12.6.16).

2. Si la obligación condicional es cumplida antes del cumplimiento de la condición, como p.ej. si se hubiera hecho tradición de la cosa prometida al acreedor, éste no deviene propietario; ni tampoco puede comenzar a usucapirla (Paulo, D.41.4.2.2-3; Paulo, D.18.6.8 pr.). Ni siquiera tendría derecho a los frutos (Pomp.-Ulp., D.13.2.4 pr.).

3. Si se produce *pendente condicione* la pérdida total de la cosa vendida, este acontecimiento conlleva la no formación de la venta, puesto que falta precisamente uno de los elementos esenciales de la compraventa, cual es la cosa vendida (Paulo, D.18.6.8 pr.).

4. Una obligación condicional puede tener por objeto la cosa propia del acreedor eventual, lo cual es posible, con la condición de que cuando acaezca ésta, sea otro el propietario (Marcelo, D.18.1.61; D.45.1.98 pr.).

5. La novación de una obligación condicional no podrá producir efectos sino después que la condición se cumpla. En efecto, consistiendo la novación en la transformación de una obligación en otra nueva, no puede surtir efectos si la primera no existe (Ulp., D.46.2.14.1).

6. Sin embargo, los propios autores clásicos admiten algunos efectos. Así, Paulo admite que es en el momento de la celebración del negocio condicional que se debe apreciar la capacidad de las partes. Así, si el estipulante es un *filius* o un esclavo, que luego es emancipado o manumitido, se considera que es el *pater* el beneficiario, quien podrá accionar en nombre propio una vez cumplida la condición (D.45.1.78; D.50.17.144.1; D.45.3.26; FV.55).

Si el deudor de una obligación condicional impide fraudulentamente que la condición se cumpla, se consideraba a ésta como realizada. Labeón le otorgaba una *actio in factum*, pero luego Juliano y Ulpiano parecen acordarle al acreedor la acción propia del negocio (Lab.-Ulp., D.18.1.50; Jul., D.35.1.24; Ulp., D.50.17.151).

b) Pero en la época posterior se fue forjando la idea de que el acreedor bajo condición tiene "una esperanza de obligación" (*tantum spes debitum iri*; Inst., 3.15.4). Por ello es que se ampliaron los efectos *pendente condicione*:

1. Así, en textos en general interpolados los juristas bizantinos entienden que existe un acreedor. Se lo llama "acreedor condicional" (Ulp., D.50.16.54). De ahí que pueda pedir preventivamente ciertas medidas conservatorias en garantía de su crédito: así, p.ej., si bien no puede pedir la *venditio bonorum* (Ulp., D.42.4.7.14), puede solicitar la posesión de los bienes de un insolvente (Paulo, D.42.4.6 pr.1p; el mismo Paulo daba la solución contraria en D.42.14.2); y también el acreedor del *de cuius* la "separación de patrimonios" (Pap., D.42.6.4 pr.).

2. Si el estipulante a quien se le prometió algo llegara a fallecer antes de cumplirse la condición, el derecho eventual (*spes*) se transmite a sus herederos (Jul., D.45.1.57; Paulo, D.18.6.3 pr.).

Acá hay que diferenciar el caso de la *stipulatio* del caso del legado. En materia de estipulaciones, el efecto señalado se produce directamente desde la muerte del acreedor. En cambio, en materia de lega-

dos, por la aplicación de la regla del *dies cedens*, en caso de legado condicional éste se produce a partir del día en que la condición se cumple. Hasta ese momento, el legatario nada ha adquirido y en consecuencia nada puede transmitir a sus herederos (Ulp., D.44.7.42).

II. *Existente o deficiente condicione.* A diferencia de lo que ocurre con el plazo, el hecho condicional puede ser que éste no ocurra o que se realice.

En el primer caso (*condicio deficiens, extincta*) al no cumplirse la condición, o si se torna cierto que jamás se podrá cumplir (*defecta condicione*), ello ocasiona la extinción de la expectativa, y todo transcurre como si el negocio no hubiese existido.

En el segundo, es decir, si se cumple la condición, el negocio se torna exigible por el beneficiario, quien lo podrá demandar por la vía correspondiente. Es decir, adquiere desde ese momento plena eficacia.

1. Un problema que se presenta es si el cumplimiento de la condición al tornar eficaz el negocio tiene efectos desde el momento en que acaece dicha condición, para el futuro (efecto *ex nunc*: desde ahora en adelante) o si en forma retroactiva los efectos se ocasionan desde que se celebró el negocio condicional (efecto *ex tunc*: desde ese entonces).

La opinión generalizada hoy día, es que para los juristas clásicos, el negocio condicional presenta todas las características de un acto dirigido al futuro, por lo que la regla fue la de no admitir efectos retroactivos.

2. Sin embargo, los bizantinos interpolando ciertos textos parecen validar ciertos efectos retroactivos. A pesar de ello Justiniano nunca admitió efectos *ex tunc* como regla general, sino en ciertas hipótesis, que forman una ardua casuística. Se trató de proteger en cuanto a ciertos efectos, al beneficiario del negocio.

3. Se suele mencionar el texto de Gayo (D.20.4.11.1), acerca de que si un acreedor garantizaba una obligación condicional con una hipoteca, ella mantenía el rango de preferencia en el momento de la constitución, y no a partir del cumplimiento de la condición. Pero se puede advertir que lo mismo ocurre cuando se da la garantía hipotecaria respecto de una deuda futura, hipótesis análoga en la cual no juega el principio de la retroactividad.

Igualmente, si se hubiere vendido una cosa bajo condición, y fallece el comprador antes de cumplida ésta, pero luego se cumple, los herederos quedan obligados, como si la compra se hubiera celebrado anteriormente (Paulo, D.18.6.3 pr.).

Y también, si un acreedor reconociera el pago de la estipulación condicional, por medio de una *acceptilatio*, se entiende que quedó libre a partir de ésta,

sin esperar el cumplimiento de la condición (Pomp., D.46.3.16).

4. Que las soluciones bizantinas se refieren a casos determinados, sin llegar a formular una regla general, lo muestra la permanencia en el Digesto de textos que resultarían contradictorios con ella. Así, el caso de validez en forma condicional de dar una cosa propia del acreedor, de la pérdida total de la cosa vendida, de la no posibilidad de considerar la posesión dada a los efectos de la *usucapio* (v. *supra*, este § 1, (a) 2.3.4).

§ 310. B) *Plazo o término (dies).* El término es el acontecimiento futuro y objetivamente cierto del cual se hace depender la eficacia del negocio. Lo que caracteriza al término, a diferencia de la condición es la certidumbre de que el acontecimiento necesariamente acaecerá. Así, p.ej., "¿Prometes darme tanto en las próximas calendas de Julio?". De este modo, la obligación a plazo existe desde que se celebró el negocio, de tal modo que sólo el pago queda diferido en su exigibilidad (Paulo, D.45.1.46 pr.; Gayo, 3.124).

1. Puede, sin embargo, existir cierta incertidumbre en el término. Así, sobre "cuándo" ocurrirá. Pero no puede haber dudas sobre la necesidad del acontecimiento futuro (*dies*). De este modo, cuando hablamos propiamente de "plazo", se puede decir que estamos en presencia de un *dies certus an certus quando* (sabemos qué ocurrirá y sabemos cuándo), como p.ej.: tal día del calendario.

Pero también se puede dar una especie de "plazo incierto" si lo supeditamos a un hecho necesario, aunque no esté precisado el día de su ocurrencia (*dies certus an incertus quando*; así: "cuando muera Ticio").

2. En cambio, si el *dies* es "incierto", entonces no se trata de término o plazo, sino que estamos en presencia de una condición (*Dies incertus appellatur condicio* (Ulp., D.30.30.4). Esto puede ocurrir bajo la forma de *dies incertus an certus quando* (p.ej., cuando cumplas los 30 años; es decir, no sabemos si ocurrirá, ya que puedes morir antes, pero de ocurrir sabemos cuándo). Y también como *dies incertus an incertus quando* (p.ej., "el día que te cases"; no sabemos si ocurrirá ni sabemos cuándo).

§ 311. *Clases de plazos.* El plazo o término puede ser considerado bajo dos aspectos.

En primer lugar, cuando se lo fija en relación al día en que el derecho comienza a ser exigible (*dies a quo*). Así, p.ej.: "¿Me prometes pagar tal día?".

En segundo lugar, cuando se lo fija para determinar que el derecho o situación jurídica se extingue (*dies ad quem*). Así, p.ej., haber establecido que la locación que celebramos, lo